

**Francisco
Javier
Ansuátegui
Roig**

**Razón y voluntad
en el Estado de Derecho**
Un enfoque filosófico-jurídico



INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Colección
Derechos Humanos

y

Filosofía
del Derecho

dykinson

Razón y voluntad en el Estado de Derecho

Un enfoque filosófico-jurídico

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG

Razón y voluntad en el Estado de Derecho

Un enfoque filosófico-jurídico

Dykinson, S.L.



INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Consejo Asesor de la Colección Derechos Humanos y Filosofía del Derecho:

Fco. Javier Ansuátegui
Universidad Carlos III de Madrid
Rafael de Asís
Universidad Carlos III de Madrid
Elías Díaz
Universidad Autónoma de Madrid
Eusebio Fernández
Universidad Carlos III de Madrid
Juan Antonio García Amado
Universidad de León
José Ignacio Lacasta
Universidad de Zaragoza

Javier de Lucas
Universidad de Valencia
Jesús Ignacio Martínez García
Universidad de Cantabria
Luis Martínez Roldán
Universidad de Oviedo
Gregorio Peces-Barba †
Universidad Carlos III de Madrid
Antonio E. Pérez Luño
Universidad de Sevilla
Virgilio Zapatero
Universidad de Alcalá

Los trabajos publicados en esta colección han sido sometidos a un proceso de evaluación anónima, de acuerdo con los criterios empleados en la comunidad científica. Los originales, en los que no deberá figurar la identidad del autor, deben ser enviados a la siguiente dirección electrónica: info@dykinson.com. Deberá adjuntarse un curriculum vitae del autor. Todos los documentos deberán enviarse en formato Word.

© Copyright by Francisco Javier Ansuátegui Roig

Editorial DYKINSON, S. L. Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Teléfonos (+34) 915 44 28 46 – (+34) 915 44 28 69
E-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>
Consejo editorial: véase www.dykinson.com/quienessomos

ISBN: 978-84-9031-757-0
Depósito Legal: M-34599-2013

Preimpresión e Impresión:
SAFEKAT, S.L.
Laguna del Marquesado, 32 – Naves J, K, y L – 28021 Madrid
www.safekat.com

A Gregorio Peces-Barba

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
I. SOBRE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ESTADO DE DERECHO.	27
1. Una aclaración sobre el uso de los conceptos	27
2. Las ventajas de una definición explicativa del Estado de Derecho.....	32
II. DERECHO, PODER Y MORAL EN EL ESTADO DE DERECHO	43
1. La relación entre el Derecho y el Poder en el Estado de Derecho. El problema de la autorreferencialidad.	44
2. La relacion entre el Derecho y la moral en el Estado de Derecho. La positivación del Derecho natural.	68
2.1. La tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral correcta	72
2.2. Las conexiones entre el Derecho y la moral. Análisis de la propuesta de Habermas	80
2.3. Nino y el teorema fundamental de la Filosofía del Derecho	89
III. UN CONCEPTO MATERIAL DE ESTADO DE DERECHO	99
1. Diferentes tradiciones y un sentido común.....	101
2. Estado de Derecho formal y Estado de Derecho material.....	110
2.1. Una caracterización inicial	110
2.2. Sobre la insuficiencia del concepto formal.....	120
2.2.1. Algo más que un modelo de relación entre el Derecho y el Poder.....	120

2.2.2. El imperio de la ley y el concepto de Derecho	126
a) Sobre el valor de la existencia de las normas	126
b) Una concepción formal del imperio de la ley	137
c) El imperio de la ley y la existencia del Derecho. Derecho y arbitrariedad	148
d) Sobre el valor moral del imperio de la ley	167
e) Imperio de la ley y crisis de la ley	186
2.2.3. El principio de legalidad selectiva: los contenidos del Estado de Derecho y el carácter sustantivo de los derechos fundamentales ..	191
2.2.4. Estado de Derecho y derechos fundamentales: algunas consecuencias	214
2.3. El Estado Constitucional como Estado de Derecho	223
2.3.1. El constitucionalismo y su Constitución.....	224
2.3.2. El Estado constitucional y la materialización del Derecho	242
2.3.3. Estado de Derecho y Estado constitucional	257
IV. LAS RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.....	279
1. Sobre las consecuencias de la rigidez constitucional	279
2. Iusnaturalismo y constitucionalismo.....	293
3. Constitución y autorrestricción.....	306
3.1. Sobre la necesidad de limitar las decisiones mayoritarias en democracia.....	306
3.2. Restricciones individuales y restricciones colectivas.....	308
3.3. Autorrestricciones constitucionales	319
4. La «paradoja de la democracia»: heterorrestricciones constitucionales.....	326
5. ¿Tensión irresoluble?	343
BIBLIOGRAFÍA	351
ÍNDICE DE MATERIAS.....	377
ÍNDICE ONOMÁSTICO.....	383

INTRODUCCIÓN

Creo que no hace falta ser un firme defensor del positivismo jurídico para admitir que la referencia inexcusable del trabajo y de la reflexión del jurista viene constituida por el Derecho positivo y sus problemas. Esto no sólo es aplicable al jurista que pudiéramos denominar *práctico* —el funcionario, el juez, el abogado—, sino también al jurista *teórico* que, entre otras cosas, desarrolla propuestas de conocimiento, comprensión y justificación del Derecho. La ciencia o la reflexión filosófica que desconoce o desprecia el Derecho, o que lo subordina a otros objetos de atención, deja de ser ciencia *jurídica* o filosofía *jurídica*. Lo anterior, que pudiera ser entendido —quizás con razón— como una reivindicación del carácter *jurídico* de la Filosofía del Derecho, también supone el reconocimiento de que el aislamiento e incompreensión que en ocasiones han podido caracterizar la situación de la Filosofía del Derecho en las Facultades de Derecho y en el contexto general de las ciencias jurídicas, ha tenido mucho que ver con el tipo de trabajo llevado a cabo desde las mismas filas iusfilosóficas.

Frente a lo anterior, no parece que sea válida la excusa del filósofo del Derecho, encerrado en sí mismo o centrado en dilucidaciones situadas a considerable distancia del Derecho, consistente en afirmar que, en realidad, las cuestiones que interesan no residen en el Derecho o trascienden en mucho a sus dimensiones. Por el contrario, como se podrá observar a lo lar-

go de la lectura de este libro, aquellas que podríamos entender como cuestiones clásicas, tradicionales o capitales para la Filosofía del Derecho, como pueden ser, por ejemplo, la relación entre el Derecho y el Poder, la relación del Derecho con la moral y otros órdenes normativos, o el análisis de la relación entre razón y voluntad, se constatan en la configuración concreta y específica de los ordenamientos jurídicos. El enraizamiento de estas cuestiones en el Derecho positivo justifica una Filosofía del Derecho muy distinta a aquella otra, criticada por Ihering, y que se atribuía la responsabilidad de construir conceptos generales que, si bien se pretendían de aplicación y operatividad en los sistemas jurídicos, muchas veces no tenían demasiado que ver con sus realidades.

Hoy, como en otros momentos, es necesario reivindicar una Filosofía del Derecho positivo, idea ésta que expresa la exigencia de que los problemas que planteemos (y las propuestas de las que nos responsabilizamos los filósofos del Derecho) sean aquellos que tienen una repercusión práctica en los Ordenamientos y que realmente preocupan e interesan a los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, los que se tienen que enfrentar con el Derecho todos los días. Lo anterior, evidentemente, no es incompatible con seguir manteniendo las diferencias entre el trabajo desarrollado por el filósofo del Derecho, de un lado, y por el dogmático, de otro, aunque, como se verá con posterioridad, posiblemente en la actualidad existan argumentos que llevan a la necesidad de replantear, en ocasiones, la distancia que existe entre ambos o, por lo menos, a subrayar de nuevo su necesaria colaboración.

Todos, y me refiero a los integrantes del gremio filosófico-jurídico, hemos podido caer en alguna ocasión en la tentación de justificar nuestras propuestas con referencia a la imprecisión y vaguedad del término con el que fijamos nuestro objeto de referencia: «Derecho». Esta vaguedad está detrás de la confusión, a la que en muchas ocasiones asistimos, entre lo descriptivo y lo prescriptivo. En este contexto, la distinción entre el Derecho como institución y el Derecho como concepto es útil. Massimo La Torre alude al Derecho como institución en

referencia a la comprensión del Derecho «como sistema jurídico, es decir, como conjunto de reglas válidas y eficaces, y como el conjunto de conductas correspondientes»; el Derecho como concepto es «el conjunto de ideas sobre lo que es o debería ser el Derecho como institución»¹. Es evidente que ambas comprensiones del Derecho no son, ni mucho menos, independientes entre sí. Es cierto que el trabajo del filósofo del Derecho está referido a la construcción de propuestas en el ámbito del Derecho como concepto, pero dichas propuestas, para ser útiles, deben estar condicionadas por la configuración del Derecho como institución. Por otra parte, tampoco está de más recordar que, en la generación del Derecho como institución, en muchas ocasiones la tarea del filósofo del Derecho es la de proveer de buenos argumentos, razones y justificaciones. Sabemos que uno de los ejemplos más claros al respecto es el de la aportación kelseniana a la institución del control de constitucionalidad.

Si en la actualidad tuviéramos que identificar, de acuerdo con la anterior distinción, al Derecho como institución de nuestros días, nos veríamos obligados a referirnos al Derecho del Estado constitucional, al Derecho del Constitucionalismo. Es, en efecto, este modelo de Derecho el que constituye la referencia o, por lo menos, una de las principales referencias para el trabajo de muchos filósofos del Derecho en la actualidad. Obsérvese bien que la anterior referencia es necesariamente contextualizada. Es claro que el Derecho de los sistemas constitucionales y democráticos contemporáneos no es el único modelo posible, ni desde una perspectiva diacrónica ni tampoco sincrónica. Pero, como observaremos, gran parte de las

¹ LA TORRE, M., «Derecho y conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde una perspectiva europea», *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, n.º 16, 1993, p. 69. ID., «Formalism and Anti-Formalism in Modern Law-State Law and Beyond», en KRAWIETZ, W., MACCORMICK, N., VON WRIGHT, G. H., *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems*. Festschrift for Robert Summers, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, p. 649.

cuestiones que centran el debate iusfilosófico de nuestra época se encuentran vinculadas a dimensiones de la vertiente jurídica del Estado constitucional. ¿Quiere decirse con ello que el modelo de Teoría del Derecho, dotado de grandes dosis de abstracción y generalidad, que ha propuesto el positivismo no puede seguir manteniéndose? Luis Prieto ha enfocado este problema en términos de reducción de la distancia entre la Teoría del Derecho y la Dogmática del Derecho constitucional, reconociendo que «la postulada generalidad o universalidad de la teoría del Derecho ha sido siempre más un ideal o programa que una realidad efectiva; por eso resulta inevitable que si la Teoría del Derecho ha de dar cuenta de los rasgos más esenciales de los sistemas jurídicos, hoy requiera conectarse a la Constitución y al Derecho constitucional»². En su original pretensión de ofrecer una explicación del concepto de Derecho con validez universal, la Teoría del Derecho posiblemente pueda identificar cuestiones o problemas respecto a los cuales se pueden construir propuestas no vinculadas directamente al Derecho positivo. Pienso que lo anterior no es posible en el contexto del constitucionalismo contemporáneo, lo cual ciertamente puede ir en demérito de la validez universal de la Teoría del Derecho. Ciertamente, nos vemos obligados a reconocer que nos movemos entre dos extremos. Por una parte, el de la universalidad, facilitada en ocasiones por una distancia considerable respecto al Derecho positivo y a sus problemas, si bien dicha universalidad puede ir en detrimento de la utilidad de la teoría (o de su aplicabilidad a la práctica); por otra, el del particularismo, que si

² PRIETO SANCHÍS, L., *Constitucionalismo y positivismo*, Fontamara, México, 1997, p. 10. En otro momento, señala: «... a diferencia del positivismo jurídico, que es una teoría del Derecho con pretensiones de universalidad, es decir, con pretensiones de ofrecer un concepto válido para todo Derecho posible, el neoconstitucionalismo suele presentarse como una teoría expresamente particular, preocupada sólo por explicar los sistemas jurídicos del constitucionalismo democrático», «Sobre las relaciones entre el Derecho y la moral: una crítica del constitucionalismo ético», en ID., *El constitucionalismo de los derechos*, Trotta, Madrid, 2013, p. 111.

bien está atento a las dimensiones positivas, corre el riesgo de carecer de capacidad y atractivo más allá del contexto en el que se articula la propuesta. Irremediablemente, como se acaba de señalar, el teórico del Derecho se desenvuelve entre ambos extremos, lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que situarse en alguno de ellos. Precisamente el constitucionalismo le permite al teórico del Derecho situarse en un punto cercano a la equidistancia, desde el momento en que la configuración efectiva de los sistemas jurídicos constitucionales provoca la discusión sobre cuestiones sumamente relevantes para la Teoría del Derecho desde una perspectiva generalizadora.

En la actualidad, gran parte de la reflexión iusfilosófica (al menos en nuestro contexto jurídico-cultural) está condicionada por la presencia de Constituciones, con rasgos y contenidos específicos, en los Ordenamientos. Creo que se puede reconocer también que un importante número de las discusiones y debates que han centrado y centran nuestra atención en la actualidad podrían considerarse incluidas en lo que podríamos entender como *Filosofía del Derecho constitucional*. Los ejemplos de Dworkin, Alexy, Nino, Ferrajoli o Peces-Barba (por ofrecer una lista incompleta) valen al respecto.

Se ha afirmado que hoy no es posible escribir de Filosofía del Derecho sin abordar alguna de las temáticas propuestas por el constitucionalismo³ (o, si se prefiere, por el neoconstitucionalismo⁴). Pero, ¿por qué es interesante el constitucionalismo

³ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos» en ID., *El constitucionalismo de los derechos*, cit., p. 32.

⁴ No profundizaré, en este sentido, en las posibles diferencias entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, asumiendo que el neoconstitucionalismo es la forma contemporánea de constitucionalismo. Luis Prieto ha desarrollado una presentación de los planteamientos básicos del neoconstitucionalismo, subrayando los más relevantes para la Filosofía del Derecho en PRIETO SANCHÍS, L., «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos», cit., pp. 23 y ss. No obstante, no desconocemos que en este punto una mayor profundidad en el análisis permite identificar diferen-

para la Filosofía del Derecho? Podemos afirmar, entre otras cosas, que constituye un campo de pruebas en el que se someten a prueba temas o cuestiones que tradicionalmente han centrado la atención de la reflexión iusfilosófica. Existen temas esenciales y clásicos, que precisamente lo son porque la decisión sobre los mismos es indispensable para comprender el sentido del Derecho y su funcionamiento. Entre esos temas, se pueden identificar, me parece que sin temor a equivocarnos, el referido a la interpretación y aplicación del Derecho. También figuran el de la relación entre el Derecho y la moral, de un lado, y el de la conexión entre el Derecho y el Poder, de otro. La calificación de las normas jurídicas, y del Derecho en su conjunto, como válidas/inválidas, eficaces/ineficaces, justas/injustas, depende entre otras cosas de manera principal de la posición desde la cual se enfoquen esos temas y de las respuestas que se les ofrezcan. Pero además, del enfoque de los problemas del Derecho del Estado constitucional en perspectiva filosófico-jurídica, se pueden extraer algunas enseñanzas. En primer lugar, la reflexión sobre los Ordenamientos jurídicos del constitucionalismo nos demuestra la necesidad de superar aquellas propuestas defensoras de una Teoría del Derecho, absoluta y estrictamente formal, aislada de otras dimensiones del saber y de la realidad. Lo que se quiere expresar no es que no sea de ningún modo posible desarrollar una Teoría del Derecho formal, sino que en relación con el constitucionalismo, ésta no es útil: el constitucionalismo evidencia de manera clara las dificultades e insuficiencias de este tipo de teoría. La inclusión de propuestas morales exigentes y de contenidos determinados,

cias entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo por ejemplo, en lo que se refiere a la cuestión de la compatibilidad respectiva con el positivismo jurídico. Es la tesis defendida por S. POZZOLO en *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2001. Por su parte, M. TROPER se ha pronunciado a favor de la incompatibilidad entre el constitucionalismo y el positivismo jurídico en «El concepto de constitucionalismo y la moderna teoría del Derecho», en ID, *Por una teoría jurídica del Estado*, trad. de M. Venegas Grau, Dykinson, Madrid, 2001, p. 185.

y la necesidad de identificar las vinculaciones con argumentaciones construidas en el ámbito de la Filosofía política, nos obligan a ampliar los territorios de la Teoría del Derecho del constitucionalismo. En segundo lugar, ya se señaló con anterioridad, el constitucionalismo contemporáneo constituye un laboratorio con el que nos volvemos a encontrar con los *temas* de la Filosofía del Derecho que, con una u otra apariencia, centran de manera recurrente el interés de la disciplina.

* * *

A la hora de identificar los temas o las cuestiones esenciales de la Filosofía del Derecho, el constituido por la tensión entre razón y voluntad ocupa un lugar principal. No se trata aquí de elaborar una nómina de todos los temas relevantes en este ámbito. Lo que sí parece cierto es que más allá de las diferentes formas de presentación y articulación del Derecho a lo largo de la historia y de las culturas, en tanto que realidad normativa constituye el escenario del encuentro o desencuentro entre la expresión de una voluntad y determinadas exigencias de racionalidad o de corrección. Me refiero, en términos habermasianos, a la tensión entre facticidad y validez, entre la positividad del Derecho y la legitimidad, tensión «*inmanente* al derecho mismo»⁵

La idea que se persigue con esta investigación es la de analizar algunas dimensiones de la articulación de la relación entre razón y voluntad, tal y cómo ésta se presenta en el constitucionalismo y, más en particular, en sus estructuras jurídicas y políticas. Importantes episodios de la historia del pensamiento jurídico, de la que hoy somos herederos, se pueden interpretar a la luz de esa relación. El marco en el que va a desarrollar la reflexión es el constituido por el Estado de Derecho⁶. El gran

⁵ HABERMAS, J., *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*, intr. y trad. de M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, p. 203.

⁶ Es evidente que esta no es la única posibilidad de análisis. Creo que esta tensión subyace en el estudio de la interpretación de los derechos llevado

artificio jurídico-político que representa el Estado de Derecho no es sino un modelo de articulación de la relación entre razón y voluntad. Y es un modelo en el que estos dos elementos se encuentran en tensión. El concepto de Estado de Derecho que se defiende en este trabajo, el sustancial o material, permite observar de manera meridianamente clara esta tensión, desde el momento en que supone la concurrencia, en el interior del Ordenamiento, de dimensiones formales y materiales, todas ellas inspiradas en la idea de racionalización y limitación del Poder. El constitucionalismo constituye un escenario privilegiado en el que identificamos determinadas manifestaciones de esta tensión, debido al carácter normativo jurídico que tienen las exigencias de racionalidad y corrección a partir de la materialización del Derecho.

El concepto de Estado de Derecho ocupa a estas alturas una posición paradigmática en el argumentario del Derecho, de la Política, y también de la discusión moral. Permite ser analizado desde diferentes perspectivas y las conclusiones a las que se puede llegar en función de la vía de acercamiento que se emprenda no tienen por qué ser similares. El primer capítulo se refiere a esta cuestión.

La tensión entre la razón y la voluntad en el Derecho se evidencia de manera clara cuando nos planteamos las dimensiones de las relaciones que el Derecho establece con la moral y con el Poder. La razón es la de los buenos argumentos de las pretensiones morales justificadas, y la voluntad es la que está detrás de las normas y se manifiesta en ellas. Por ello, puede resultar interesante —en el capítulo segundo— constatar que el Estado de Derecho constituye un escenario óptimo en el que se pueden observar y comparar diversos planteamientos de la relación entre el Derecho y el Poder, de un lado, y entre el Derecho y la moral, de otro. Ello es posible desde el momento en que, en resumidas cuentas, el Estado de Derecho constituye

a cabo por M. C. BARRANCO AVILÉS en *Derechos y decisiones interpretativas*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

una propuesta de articulación de ambas relaciones. Por ello, dedico las dos partes del capítulo al análisis de algunas vertientes relevantes de esta propuesta. Es evidente que no se trata de mostrar todas las posiciones desde las cuáles se pueden enfocar esas relaciones. Sólo se trata de mostrar cuál es la propuesta del Estado de Derecho al respecto y de analizarla desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho. En ambos casos, estamos frente a estrategias limitadoras del Poder. En todo caso, como se observará, es posiblemente en esta parte del trabajo en la que se puede observar —de manera más o menos evidente— la concepción del Derecho que se asume en el mismo, y que se puede identificar, en términos generales, con el Hart del *Postscript*, y —entre nosotros— con la propuesta del Peces-Barba crítico de Zagrebelsky, aunque en este caso con más matices.

El Estado de Derecho material o sustancial supone un modelo en el que se profundiza en esas estrategias y a él se dedica la parte tercera del trabajo. Su comprensión implica mostrar las insuficiencias de un modelo formal de Estado de Derecho vinculado de manera prácticamente exclusiva a la idea de imperio de la ley. Y cuando hablamos de insuficiencias estamos haciendo referencia tanto a lo que afecta a su capacidad diferenciadora frente a otros modelos de Estado —que no son Estados de Derecho— como a su comprensión en el discurso jurídico-político, e incluso cotidiano. En este sentido, de un lado, se ha intentado mostrar la indispensabilidad de la concurrencia de los criterios que identificamos con el imperio de la ley (concepto que forma parte de una familia de conceptos que, más allá de las distintas tradiciones a las que pertenecen, comparten sentidos comunes) como rasgo distintivo de lo jurídico y, de otro, se ha caracterizado el carácter selectivo y exigente del principio de legalidad propio del Estado de Derecho.

La defensa del modelo material de Estado de Derecho permite asumir una determinada posición respecto a la relación que se establece entre Estado de Derecho y Estado constitucional, tal y como se muestra en el capítulo cuarto. Y aquí la relación se enfoca en términos de continuidad. El Estado constitucional hereda del Estado de Derecho la necesidad de limitar al

Poder; no se diferencia en lo que se refiere a la inclusión de contenidos sustanciales, y en todo caso, implica una profundización y perfeccionamiento en las dimensiones limitadoras a partir de las consecuencias del imperio de la Constitución, manifestación específica y contemporánea del imperio de la ley en el marco del constitucionalismo. En realidad, esta parte del trabajo pretende ofrecer una justificación del hecho de que nuestro objeto de análisis esté constituido básicamente por el Estado de Derecho.

El último capítulo está dedicado a estudiar un caso concreto de articulación de la tensión entre razón y voluntad: las restricciones constitucionales. Dichas restricciones se comprenden a partir de la rigidez que se presenta como rasgo, graduable, de la norma superior. La articulación y puesta en marcha de vinculaciones y restricciones constitucionales, de presencia imprescindible en todo caso, exige una fundamentación y justificación de especial relieve en el contexto democrático, caracterizado por la amplitud de los ámbitos de la política. En todo caso, la tensión entre Constitución y democracia, que es la manifestación en el Estado de Derecho y en el Estado constitucional de la más amplia tensión entre razón y voluntad, parece de inevitable presencia precisamente en aquellos sistemas, como los democráticos, caracterizados por haber asumido una determinada concepción de los derechos y, a partir de ahí, por verse compelidos a articular una propuesta de organización institucional acorde con el compromiso con los derechos y, al mismo tiempo, respetuosa con los mecanismos de adopción de decisiones colectivas que vienen caracterizando los sistemas democráticos.

* * *

Se puede pensar que la caracterización del Estado de Derecho que se plantea en este trabajo es incompleta. En efecto, si se recuerda el concepto de Estado de Derecho que hace años propusiera Elías Díaz, y que hoy bien puede ser considerado como un canon al respecto, se observa que allí se presentaban

cuatro elementos: imperio de la ley, separación de poderes, control de la legalidad de la actuación administrativa, y sistema de reconocimiento y garantía de derechos fundamentales. Si admitimos como válida la propuesta de Elías Díaz, podríamos tachar la caracterización que aquí se ofrece como claramente insuficiente. En efecto, de la lectura de las páginas sucesivas se desprende que no hemos centrado la atención ni en la separación de poderes ni en el control de la legalidad de la actuación administrativa. Creo, por el contrario, que la caracterización ofrecida es justificada. Es más, si tenemos en cuenta una de las afirmaciones de referencia del constitucionalismo contemporáneo, el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, vemos que allí se identifican dos elementos integrantes del concepto de Constitución: la separación de poderes y los derechos. En este caso, nos hemos centrado en el segundo elemento porque es uno de los integrantes principales del Estado de Derecho y permite observar la diferencia entre el Estado de Derecho formal y el Estado de Derecho material. Esta distinción es la que se emplea luego como base para estudiar la cuestión de la diferencia o no con el Estado constitucional. El recurso a los derechos fundamentales en este punto es un expediente más útil que el constituido por la separación de poderes. Permite, además, apoyar el discurso en la conexión que, en términos de vinculación respectiva, existe entre los conceptos de Estado de Derecho, derechos y democracia.

En este trabajo se trata de analizar diversas articulaciones de la tensión entre razón y voluntad, tal y como ésta se presenta en el escenario del Derecho del constitucionalismo. Ambos elementos se presentan de concurrencia necesaria en el Derecho de nuestro contexto, aunque no sólo en él. Si bien el Derecho es fuerza en última instancia, nos resistimos a entenderlo en términos de mera fuerza bruta. A lo largo de los siglos se han ensayado estrategias de racionalización del Poder, que en nuestros días desembocan en el constitucionalismo. El análisis de la relación entre razón y voluntad desde el punto de vista del Estado de Derecho debe centrarse, por tanto, en las dimensiones limi-

tadoras de éste. Es claro que todos los elementos a los que en su día aludiera Elías Díaz son expresión de esa vertiente limitadora. No obstante, la tensión entre razón y voluntad se puede estudiar bien si nos centramos, en primer lugar, en el imperio de la ley. El análisis de su sentido permite observar que una determinada dosis de racionalización del Poder es imprescindible para la existencia del orden jurídico como tal. Al mismo tiempo, y precisamente por lo anterior, el recurso exclusivo al imperio de la ley se muestra como insuficiente no sólo a la hora de ofrecer una visión completa del Estado de Derecho, sino también a la de mostrar en toda su extensión la tensión entre razón y voluntad. En este caso, y en el contexto democrático en el que se desarrolla el Estado de Derecho, los derechos constitucionales desarrollan sus exigencias en tensión con el imperio de la soberanía popular, origen de la ley. Es evidente que las posibles soluciones a través de las cuales se quiera encarar el conflicto (que incluyen el recurso a mecanismos de control de constitucionalidad) pueden suponer una reformulación y una relectura de la concepción clásica de la separación de poderes. Pero se ha creído que el análisis del significado de la teoría de la separación de poderes no era imprescindible para alcanzar los objetivos de este trabajo, sobre todo en su última parte, referida no tanto a la cuestión del diseño institucional preciso para administrar con éxito la tensión entre razón y voluntad, como a la cuestión de las razones, mejores o peores, de las restricciones constitucionales. Y si se ha conectado la cuestión de las restricciones con la del Estado de Derecho democrático es precisamente porque, constituyendo éste un escenario en el que se desarrollan mecanismos sustantivos de limitación del Poder, posee, debido a ese carácter, dimensiones que pueden llegar a desvirtuar las potencialidades, no siempre negativas, de la voluntad política democrática. Quizás una reflexión como la que se contiene en este trabajo permita llegar a la conclusión de que el potencial carácter suicida de la democracia no viene determinado de manera exclusiva por el potencial agresivo de las decisiones mayoritarias, sino que también puede ser provocado por la progresiva eliminación de las capacidades decisio-

rias de las mayorías. Como se observará, en este trabajo no se aspira a solucionar de manera definitiva la tensión a favor de alguno de sus elementos, sino a plantear alguno de los problemas de fundamentación de las restricciones constitucionales.

* * *

Este libro es el resultado de la reflexión sobre cuestiones que me han ocupado (y preocupado) desde hace años, quizás demasiados. Sus orígenes están en los tiempos de la Universidad de Jaén y, aunque durante este largo periodo de tiempo me he interesado en ocasiones por otros temas, el interés por la relevancia del Estado de Derecho y del constitucionalismo para la Filosofía del Derecho ha sido una constante en mi tarea investigadora. Los avances progresivos (o los que yo he considerado como tales) y los resultados de esta tarea han influido en mi forma de estructurar y abordar las tareas docentes, principalmente en lo que se refiere al postgrado, dentro y fuera de nuestro país. Así, quiero recordar aquí las intervenciones en diversos centros, más allá de las Universidades de Jaén y Carlos III de Madrid: Universidad de Alcalá, Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla, Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia (Catanzaro), Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Externado de Colombia, Universidad Autónoma de Occidente (Cali), Universidad del Rosario (Bogotá), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi dell'Insubria y Università di Bologna. Agradezco desde aquí a los colegas y a los investigadores de estos centros la posibilidad de disfrutar de fructíferos espacios académicos y humanos.

Durante todo este tiempo he adelantado en diferentes ocasiones aproximaciones provisionales a las cuestiones que se abordan en el libro. En algunos casos, me he referido a dimensiones del constitucionalismo que no afectan directamente a lo tratado aquí (como por ejemplo, la vocación expansiva del constitucionalismo). En otros, la proximidad temática es

mayor. Estoy pensando en algunos trabajos en concreto: «Estado de Derecho, crisis de la ley y Estado constitucional», ZAPATERO, V. (ed.), *Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, (2), Universidad de Alcalá de Henares, 2002; «La relación entre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho: dimensiones y consecuencias», *Anuario de Filosofía del Derecho*, tomo XXIII, 2006; «El Estado constitucional: apuntes para una comprensión de su significado histórico», *Revista de Historiografía*, n.º 9, V, 02/2008; «Estado Constitucional y producción normativa», *Derechos y Libertades*, n.º 25, junio 2011; «Los derechos fundamentales en *Principia Iuris* (o los límites de la teoría del Derecho)», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXIX, 2013. El impulso final del trabajo se ha desarrollado en el marco de dos proyectos de investigación: Proyecto Consolider-Ingenio 2010 «El tiempo de los derechos». CSD2008-00007, y Proyecto: «Los Derechos Humanos en el S. XXI. Retos y desafíos del Estado de derecho global» (DER 2011-25114), Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Ciencia e Innovación.

Nuestras investigaciones y sus plasmaciones en libros y en otro tipo de publicaciones son el resultado de determinados contextos y circunstancias; en mi caso, universitarias y extrauniversitarias. Aunque hace ya tiempo que dejé la Universidad de Jaén para trasladarme a la Universidad Carlos III de Madrid, los años de Jaén fueron muy productivos en diversos sentidos. Desde el punto de vista estrictamente universitario, disfruté de una tranquilidad y de unos horizontes temporales propicios para la investigación de los que no he vuelto a disponer con facilidad en ningún momento. Desde el punto de vista humano, me encontré con unos colegas (dentro y fuera del área de Filosofía del Derecho) que hoy cuento entre mis amigos. En la Universidad Carlos III de Madrid y en su Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, el volumen de las actividades y el desempeño de la dirección del mismo condicionan de manera evidente la posibilidad de reservar espacios razonables para la investigación tranquila. Pero, al mismo tiempo, tengo la fortuna de poder trabajar rodeado de un grupo de profesores, investigadores y personal de administración, que ha logra-

do que el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, hoy —tras el impulso de Gregorio Peces Barba y el trabajo cotidiano de muchos—, haya llegado a ser una referencia nacional e internacional en la docencia e investigación en derechos humanos. Aunque no citaré a todos y a cada uno de ellos, si quiero reconocer que, cada uno desde sus responsabilidades, todos están contribuyendo a que (en medio de una crisis que en nuestro caso ha supuesto no poder seguir contando con queridos compañeros), el Instituto siga manteniendo alto el nivel de calidad. En ese marco, Rafael de Asís, María del Carmen Barranco y Patricia Cuenca me han hecho observaciones sobre versiones anteriores del texto que sin duda lo han mejorado y que les agradezco. El trabajo que, desde las áreas de administración y gestión del Instituto, llevan a cabo Ana Belén Juez, María Jesús Sánchez Malnero, Yolanda Cañete y Lara Cuenca, posibilita todos los días la marcha de nuestras actividades y es un auxilio imprescindible, que también agradezco de forma especial, de las tareas de dirección.

Las circunstancias extrauniversitarias también forman parte del camino vital a lo largo del cual investigamos y aprendemos. Mis circunstancias son mis amigos, mi familia, mi mujer Mafer y mis hijos Javier y Álvaro. Tengo la suerte de que todos ellos me hayan acompañado, de una u otra manera, durante estos años. Y a todos ellos les debo el tiempo y la dedicación que en ocasiones sigo robándoles.

Este libro va dedicado a Gregorio Peces-Barba. Después de tantos años trabajando con él, y de lo dicho y escrito desde el 24 de julio de 2012, seguramente no tengo que extenderme demasiado en una justificación al respecto. De la misma manera que siempre le oí hablar del orgullo y satisfacción que le producía ver como los «jóvenes» iban creciendo, me parece también que una forma de ser dignos es que reconozcamos lo que debemos a los otros. Y yo me encuentro en el numeroso grupo de los que le debemos respeto, reconocimiento, cariño y gratitud.

Majadahonda, 14 de octubre de 2013

I. SOBRE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ESTADO DE DERECHO

1. UNA ACLARACIÓN SOBRE EL USO DE LOS CONCEPTOS

Es importante aclarar algunos extremos de los aspectos básicos del mapa conceptual que se asume en este libro. Me parece relevante al menos por dos razones. En primer lugar, porque puede aclarar de manera preliminar en qué sentido se van a entender determinados conceptos, con independencia de que, posteriormente, se abunde en las correspondientes justificaciones. En segundo lugar, porque la comprensión de dichos conceptos condiciona la forma de abordar ciertos problemas y en su caso la solución que se ofrezca.

La propuesta conceptual que voy a asumir en este trabajo es la siguiente: Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia son tres conceptos que se implican mutuamente, entre los cuales se establecen relaciones estrechas, de manera que el significado de algún elemento de esta triada condiciona el de los otros dos. Los tres forman un universo de significado, y si alguno de los tres se excluye, los otros dos varían radicalmente en su sentido. El significado de cada uno de ellos viene determinado por el que se atribuya a los otros dos. Así, conviene adelantar cuáles son las relaciones que se establecen en este trabajo entre los tres términos en cuestión.

En primer lugar, me refiero a la relación entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Como vamos a tener

oportunidad de observar posteriormente, el concepto de Estado de Derecho es discutido y complejo. A la hora de abordarlo, no sólo nos encontramos con la presencia de diferentes tradiciones tras el mismo; también están presentes comprensiones más o menos densas, en función de los elementos que se prediquen del mismo. En este momento interesa aludir exclusivamente a dos formas de entender el Estado de Derecho. En una de ellas, los contenidos de las normas tienen una mayor relevancia. Así, es posible defender un concepto formal de Estado de Derecho, o un concepto material o sustancial del mismo. En el primer caso, el Estado de Derecho se identifica exclusivamente con el imperio de la ley, con la presencia teórica de determinados elementos —que en ocasiones se han relacionado con una cierta comprensión del *rule of law*— y con la plasmación práctica de esas exigencias en la actividad de los poderes públicos y también en la de los ciudadanos. El Estado de Derecho implica actuación de acuerdo con el Derecho y bajo el Derecho (art. 9.1 CE). Se identifica principalmente con el imperio de la ley, pero no sólo. Es posible pensar en una alternativa, de forma que se defienda una comprensión material o sustancial del mismo, en donde el imperio de la ley no sea el único componente —y, en este sentido, podemos considerarlo un elemento necesario aunque no suficiente—. De acuerdo con este punto de vista, la existencia de un Estado de Derecho vendrá determinada, en última instancia por el respeto de determinados contenidos normativos, los derechos fundamentales. El Estado de Derecho es imperio de la ley, imperio del Derecho, pero no de cualquier Derecho, sino del Derecho de los derechos fundamentales. Así las cosas, el Estado de Derecho se asocia a un ordenamiento jurídico caracterizado por el reconocimiento y protección de los derechos. Y, en función de los tipos de derechos y de las estrategias que se empleen en su reconocimiento y protección podremos hablar de diferentes modelos de Estado de Derecho, dotados de una mayor o menor densidad.

En mi opinión, abogar por esta forma de entender el Estado de Derecho tiene dos ventajas. En primer lugar, permite una

correcta identificación del Estado de Derecho, respecto a otros tipos de Estado. Como en su momento se encargó de recordarnos Elías Díaz, no todo Estado es Estado de Derecho. Afirmar que un Estado con Derecho es un Estado de Derecho niega sustantividad al auténtico Estado de Derecho. En segundo lugar, la presencia de contenidos materiales —los derechos (y todo el arsenal axiológico que los acompaña)— en el Ordenamiento jurídico del Estado de Derecho y el reconocimiento de su relevancia permite enfocar de una determinada manera —que en mi opinión es la más adecuada— la cuestión de las relaciones/diferencias entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Así, no estaríamos hablando de modelos radicalmente diferentes, ya que el proceso de materialización del Derecho ya se ha producido en el Estado de Derecho. Lo que añade el Estado constitucional en su caso —que, por cierto, no es poca cosa—, es la localización de esos contenidos en sede constitucional, lo cual implica la puesta en marcha de estrategias de protección e incluso, en ocasiones, de blindaje. Pero en todo caso, lo que vincula al Estado de Derecho y al Estado constitucional es la reivindicación del imperio del Derecho, que en un caso se presenta como imperio de la ley —si es que queremos hablar de la manifestación normativa específica del legislador— y en otro caso en forma de imperio de la Constitución.

En segundo lugar, se afirma una relación conceptual entre los derechos fundamentales y la democracia. En este trabajo se va a asumir un concepto sustantivo de democracia. Propongo una comprensión de la democracia que incluye la presencia de derechos fundamentales como elementos del concepto⁷. De manera que la democracia no implica sólo un mecanismo de adopción de decisiones colectivas de acuerdo con una regla básica, la de las mayorías. Esta sería una definición mínima de democracia, pero insuficiente, ya que la operatividad de la

⁷ En sentido contrario, Anna PINTORE defiende un concepto procedimental de democracia en *I diritti della democrazia*, Laterza, Bari, 2003.

regla de las mayorías debe venir acompañada por una determinada teoría en relación con la mayor o menos extensión del universo de participantes en la decisión. Es decir, se necesita un determinado discurso sobre quién debe concurrir en el proceso de toma de decisiones en el marco del cual se constituye la mayoría. No es complicado recordar situaciones en las que se han tomado decisiones a través de un escrupuloso respeto a la regla de las mayorías pero que difícilmente pueden ser consideradas democráticas desde el momento en que el ámbito personal de aquellos que han participado en la adopción de la decisión ha implicado la exclusión de ciertos grupos o colectivos (mujeres, inmigrantes, minorías étnicas...). Por eso, la democracia implica la adopción de decisiones en contextos lo más participativos posibles. La democracia implica respeto a la regla de las mayorías y la puesta en marcha de mecanismos participativos guiados por el ideal del sufragio universal.

Pero, obsérvese, aún no hemos tenido en cuenta la relevancia del contenido de las decisiones adoptadas respetando los dos elementos que acabamos de señalar. Y es que, en última instancia, el carácter democrático de una decisión colectiva viene determinado por el contenido de la misma, y por su capacidad de respeto y promoción de los derechos. Decisiones democráticas son aquellas respetuosas con los derechos. En este sentido, el respeto puede vincularse al reconocimiento y también a la puesta en marcha de políticas activas de promoción o impulso, dependiendo de las exigencias de los derechos que tengamos enfrente.

Para que en un Ordenamiento jurídico se encuentren protegidos de manera consistente y eficaz los derechos, es necesario un determinado compromiso, sincero, por parte del Poder político, cuya expresión normativa es el propio Ordenamiento. Ese compromiso se materializa en la positivación, en forma de normas jurídicas de derechos, de las exigencias morales que existen tras los mismos; al mismo tiempo, esa positivación es el resultado de la identificación que se produce entre el Poder político y la moralidad de los derechos. Dicho compromiso sólo

se produce allí donde existe un Poder político democrático, entre otras cosas porque la juridificación de esas pretensiones morales supone una limitación hacia el Poder político: desde el momento en que existen normas de derechos fundamentales, el Poder político sabe que hay cosas que no va a poder hacer, y al mismo tiempo sabe también que hay cosas que va a estar obligado a hacer, o que por lo menos se le puede exigir, aunque sólo sea en sentido político, que haga. Así, el Poder político democrático, que es por definición participado, es el único capaz de limitarse a través del reconocimiento de derechos fundamentales a los individuos. Es evidente, en este sentido, que la relación entre derechos fundamentales y Poder político no se articula de la misma manera si estamos pensando en un Poder político democrático o en un Poder de otro tipo.

Como vamos a tener ocasión de ver al final del trabajo, el concepto de democracia que se está asumiendo aquí implica la existencia de tensiones entre sus elementos, determinando así su carácter problemático.

En tercer lugar, me interesa aludir a la relación entre el Estado de Derecho y la democracia. Aquel, es un específico modelo de articulación de las relaciones entre el Derecho y el Poder, que se caracteriza por un esfuerzo de juridificación de las dimensiones del Poder. De manera que éstas se someten a límites. Pero no a cualquier tipo de límites, sino a límites jurídicos que se manifiestan de modo privilegiado en las normas de derechos fundamentales. Vemos, así, que tanto el Estado de Derecho como la democracia incluyen como elemento conceptual la presencia de normas de derechos fundamentales. Pero, en todo caso, cuando hablamos de democracia estamos haciendo referencia a un modelo en relación con el ejercicio del Poder político. De manera en este momento esquemática, —evidentemente necesitada de matices— podemos decir que cuando hablamos de Estado de Derecho nos desenvolvemos en el marco del Derecho mientras que cuando hablamos de democracia lo hacemos en el de la política. Pues bien, ¿a través de qué modelo se juridifica la democracia? ¿Cuál es la forma de la traducción jurídica de la democracia? Elías Díaz tiene razón

cuando señala que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia.

En fin, las relaciones que se establecen entre Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia, de acuerdo con la estipulación aquí propuesta, constituyen el ámbito en el que se desarrolla la presente investigación y en el que las reflexiones que se articulan en lo sucesivo pretenden adquirir sentido.

2. LAS VENTAJAS DE UNA DEFINICIÓN EXPLICATIVA DEL ESTADO DE DERECHO

Hace más de treinta años, en plena transición a la democracia en España, Alessandro Baratta comenzaba un trabajo sobre la historia y el significado del Estado de Derecho llamando la atención sobre la fortuna de dicho concepto en el marco de la reflexión jurídico-política de nuestro tiempo. Y reconocía que esa fortuna corría paralela al carácter controvertido del término, hasta el punto de compararlo con el de 'Derecho natural'. Así, señalaba: «Posiblemente, la concepción del Derecho natural sea la única en este sentido equiparable a la del Estado de Derecho: por la riqueza de sus manifestaciones, la pluralidad de puntos de vista desde los que puede ser estudiada y el diverso contenido que se le ha asignado en el desarrollo histórico de las ideas jurídicas. Concepciones diversas acerca del 'Derecho' y la 'naturaleza' produjeron durante los siglos XVII y XVIII múltiples definiciones del Derecho natural. Y del mismo modo, como consecuencia de la Revolución francesa y de la fundamentación kantiana de la moderna ciencia del Derecho, se ha ido delineando en los dos últimos siglos un modelo multiforme, un concepto rico y complejo en extremo de Estado de Derecho: concepciones diversas (científicas e incluso ideológicas) acerca del 'Derecho' y del 'Estado' han contribuido a determinar sus varios aspectos y significados»⁸. Baratta subrayaba también la

⁸ BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», *Sistema*, n.º 17-18, 1977, p. 11.

doble dimensión que, con el tiempo, ha ido asumiendo el concepto de Estado de Derecho: por una parte una dimensión descriptiva, según la cual las estructuras del Estado de Derecho son predicables de cualquier tipo de organización de la cosa pública y, por otra, una dimensión prescriptiva que vincula el Estado de Derecho al Estado óptimo⁹. Posiblemente, la confusión de estos dos planos de análisis, el descriptivo y el prescriptivo, pueda explicar el hecho, al que también se refería Baratta, de la convergencia de posiciones teóricas e ideológicas no sólo diferentes, sino también contradictorias en el contexto del análisis doctrinal sobre el Estado de Derecho¹⁰. En efecto, la idea del Estado de Derecho —si bien no siempre entendida de la misma manera—, o alguno de sus componentes, ha ocupado un lugar en las aportaciones del pensamiento ilustrado (Montesquieu y Rousseau), del liberalismo clásico (Locke, Kant, Humboldt, Constant), del pensamiento conservador alemán del siglo XIX (Stahl), del constitucionalismo y del liberalismo anglosajón (Hamilton, Madison y Jay, Paine, Dicey, Maitland, MacIlwain), de la dogmática iuspublicista alemana del siglo XIX (Gerber, Jellinek, Laband), del pensamiento autoritario (Panunzio), o del socialista y democrático (E. Díaz). A la vista de lo anterior podemos entender a Baratta cuando reconoce que «una investigación sobre la fórmula ‘Estado de Derecho’ no nos daría hoy un resultado coherente. El cúmulo de definiciones ofrecidas se diferencian y contradicen en tal forma unas de otras, que el observador adquiere la impresión de que no se trata del mismo concepto»¹¹. En realidad, esta impresión no sólo se ve ratificada por el hecho de que la alusión al Estado de Derecho se considera paradigmática desde muy diferentes

⁹ M. TROPER se ha referido a la dimensión emotiva del concepto en «I limiti del *Rule of Law*», en MORESO, J. J., TROPER, M., *Giustizia costituzionale e Stato di diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 33.

¹⁰ Vid. BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», cit., 12.

¹¹ BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», cit., p. 11, n. 1.

perspectivas ideológicas. Concorre también el hecho del estrecho parentesco que existe entre la idea de Estado de Derecho y otras expresiones que en ocasiones son traducidas como 'Estado de Derecho' pero que no se corresponden completamente con ella (*Rule of Law*, *Rechtsstaat*); y también tenemos que ser conscientes, como por otra parte se intentará dejar patente a lo largo del trabajo, que en el interior de un mismo idioma no todos los autores utilizan la expresión con el mismo significado y con las mismas implicaciones. En este sentido, posiblemente, la distinción entre Estado de Derecho formal y Estado de Derecho material, o la diferencia entre Estado de Derecho en sentido amplio y Estado de Derecho en sentido restringido, se encuentra extendida entre nosotros. En Francia, con la contribución de Carré de Malberg, se ha elaborado la distinción entre *État legal* y *État de droit*. En el ámbito anglosajón, la idea de *Rule of law* (que, como veremos, no es exactamente sinónima de Estado de Derecho), en ocasiones se identifica por unos con el principio de legalidad, mientras que en otros casos hay autores que lo vinculan a la satisfacción por parte de la ley de determinadas cualidades¹². En definitiva, podemos darle la razón a J. Chevallier en su afirmación según la cual «lo que el concepto de Estado de Derecho ha ganado en extensión, lo ha perdido en comprensión»¹³.

Si siguiéramos al pie de la letra la conclusión a la que llega Baratta, referida al carácter ineliminable de la incoherencia en el resultado de la investigación, estaríamos obligados a renunciar en el empeño de analizar uno de los términos capitales de nuestra cultura jurídico-política en la actualidad. No obstante, la dificultad de análisis puede ser compartida por otros términos, igualmente relevantes, comenzando por el propio de 'Derecho'. En realidad, estamos frente a problemas que afectan a los

¹² A las incertidumbres, ambigüedades y confusiones causadas por estos problemas vinculados a la idea de Estado de Derecho, se ha referido Michel TROPER en «Le concept d'État de Droit», *Cahiers de Philosophie Politique*, n.º 24, Université de Caen, 1993, pp. 25-30.

¹³ CHEVALLIER, J., *L'État de Droit*, Montchrestien, Paris, 1992, p. 7.

conceptos esencialmente controvertidos, categoría ésta en la que se puede incluir el concepto de Estado de Derecho. Como es sabido, Gallie caracterizó estos conceptos de acuerdo con las siguientes notas¹⁴: 1) son valorativos o evaluativos; tienen una carga valorativa o se refieren a realidades que se valoran, ya sea desde una perspectiva positiva o negativa; 2) están estructurados internamente de manera compleja, ya que están compuestos por distintos elementos a partir de los cuales se configura un conjunto que es precisamente la entidad que recibe una determinada valoración; 3) los elementos componentes del concepto no tienen una ordenación jerárquica predeterminada: pueden ser valorados de manera diferente, y de acuerdo con esas valoraciones son posibles comprensiones distintas del concepto; 4) tienen un carácter abierto: su consideración y su aplicabilidad puede variar en función de circunstancias cambiantes; 5) en el debate que se produce en relación con estos conceptos, cada parte interviniente reconoce que el uso que

¹⁴ Vid. GALLIE, W. B., «Essentially Contested Concepts», *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 56, 1955-56, pp. 167-198. La categoría ha recibido especial atención por parte de la doctrina. Entre otros pueden consultarse los trabajos de VILLA, V., *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giapichelli Editore, Torino, 1993, pp. 25-26; ROSENFELD, M., «The rule of law, and the legitimacy of constitutional democracy», *Cardozo Law School, Public Law Research Paper*, n.º 36, march, 2001. También, LA TORRE, M., «Legitimacy for a Supranational European Political Order-Derivative, Regulatory or Deliberative?», *Ratio Iuris*, 15/1, 2002, p. 74; FALLON, R. H., ««The rule of law» as a concept in constitutional discourse», *Columbia Law Review*, vol. 97, n.º 1, 1997, p. 7; WALDRON, J., «Is the Rule of Law an essentially contested concept (in Florida)?», *Law and Philosophy*, 21, 2002, pp. 137 y ss. Anteriormente me he ocupado de la caracterización del Estado de Derecho como un *concepto esencialmente controvertido*, en ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales», *Sistema*, n.º 158, 2000, pp. 91 y ss. La categoría también es aplicable a otros conceptos: en relación con el concepto de democracia, vid. PECZENIK, A., «Una concepción de la democracia», ID., *Derecho y razón*, trad. de E. Garzón Valdés, Fontamara, México, 2000, p. 123; respecto a la interpretación constitucional, vid. IGLESIAS VILLA, M., «Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional», *Doxa*, n.º 22, 2000, pp. 77 y ss.

hace del concepto es contestado por las otras, y cada parte aprecia de alguna manera los diferentes criterios asumidos por las otras; las partes deben ser conscientes de que el uso que se hace del concepto se enfrenta a otros usos, frente a los cuales debe mantenerse. Hay que señalar también que para diferenciar a los conceptos esencialmente controvertidos de los conceptos considerados *radicalmente confusos*, Gallie añade dos condiciones adicionales: 6) los conceptos esencialmente controvertidos se deben derivar de un ejemplo cuya autoridad y valor es reconocida por todos los sujetos que emplean el concepto; 7) el enfrentamiento entre los diferentes usos debe permitir una óptima realización o materialización del ejemplo que se utiliza como punto de partida.

Pues bien, de la misma manera que la caracterización de los *conceptos esencialmente controvertidos* propuesta en su momento por Gallie puede servir de alguna manera para entender no sólo las distintas formulaciones de la idea de Estado de Derecho, sino también sus dificultades de comprensión, creo que la distinción empleada por John Rawls, y también por Ronald Dworkin, entre concepto y concepción también puede ser de utilidad en este ámbito¹⁵, ya que las dificultades de comprensión de la idea de Estado de Derecho pueden ser analizadas como el resultado de la concurrencia de diversas concepciones sobre el concepto de Estado de Derecho.

Así, de las anteriores reflexiones se pueden derivar algunas conclusiones. La primera de ellas es la que se refiere a la operatividad de una definición explicativa del concepto de Estado de Derecho¹⁶. Como sabemos, las definiciones explicativas son, junto a las lexicas y a las estipulativas, tipos de definiciones nominales, ésto es, definiciones cuyo objeto es determinar las

¹⁵ J. RAWLS recurre a la distinción en *Teoría de la Justicia*, trad. de M. D. González, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, pp. 21-22. Vid. DWORKIN, R., *Law's empire*, Hart Publishing, Oxford, 1998, pp. 70 y ss.

¹⁶ Vid. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales», cit.

reglas de uso de un fragmento del lenguaje¹⁷. Mientras que las definiciones *léxicas* son aquellas que describen los usos y empleos que reciben los términos al ser utilizados en el lenguaje en el marco de determinados contextos, las definiciones *estipulativas* son las que establecen y prescriben nuevos usos atribuibles a los términos, con independencia de las reglas que hasta el momento han venido siendo utilizadas; actúan así como auténticas reglas constitutivas de una determinada práctica. Las definiciones *explicativas* comparten caracteres de las dos anteriores: por una parte, están vinculadas a las reglas de uso y a los significados que son compartidos por los miembros de una determinada comunidad y, por otra, implican una reordenación y simplificación de usos y significados confusos e imprecisos. Scarpelli ofrece una definición de las mismas: «La definición explicativa busca, como la definición léxica, corresponder al uso; pero a diferencia de la definición léxica, no se esfuerza por recopilar todas las variedades y transformaciones del uso; más bien quiere captar los significados usuales y acotarlos y eventualmente reajustar y reelaborar el núcleo de mayor importancia y valor operativo, para llegar a un instrumento semántico eficiente y preciso capaz de ofrecer en la situación cultural en la que será empleado claridad y orientación»¹⁸.

Por tanto, una definición explicativa de ‘Estado de Derecho’ tiene en cuenta el uso que en la comunidad lingüística (tanto la académica como la no académica) se hace del término. Presenta una comprensión del mismo que intentará no estar en con-

¹⁷ Sobre las virtudes de las definiciones explicativas, entre otros, SCARPELLI, U., *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1955; ID., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano, 1985; ROBINSON, R., *Definition*, Clarendon Press, Oxford, 1954; PÉREZ LUÑO, A. E., (y otros), *Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica*, Tecnos, Madrid, 1997.

¹⁸ SCARPELLI, U., *Cos'è il positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965, p. 14. Vid. también PÉREZ LUÑO, A. E., (y otros), *Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica*, cit., p. 35.

tradicción con su empleo más extendido. Al mismo tiempo, asume la tarea de reconstrucción a partir de las diferentes propuestas de comprensión existentes. Todo ello, de manera que el producto resultante sea útil en el marco del contexto en el que pretende ser operativo, vinculado en este caso a los escenarios constituidos por los sistemas democráticos¹⁹. En todo caso, conviene tener bien presente el peligro del que nos previene Jeremy Waldron: el análisis filosófico de un término no debe distanciarse mucho del empleo que la gente hace de él en la calle, ya que en caso contrario corremos el riesgo de que no sea el análisis de algo interesante desde el punto de vista político²⁰.

En realidad, las perspectivas desde las cuales se puede explicar o analizar el concepto de Estado de Derecho son bien plurales. Esta sería una consecuencia más de la consideración de este concepto como esencialmente controvertido. Y también sería el resultado de la complejidad de las influencias recibidas. Es Luigi Ferrajoli el que ha señalado que «'Estado de derecho' es uno de esos conceptos amplios y genéricos que tienen múltiples y variadas ascendencias en la historia del pensamiento político: la idea, que se remonta a Platón y a Aristóteles, del 'gobierno de las leyes' contrapuesto al 'gobierno de los hombres', la doctrina medieval del fundamento jurídico de la soberanía, el pensamiento político liberal sobre los límites de la actividad del Estado y sobre el Estado mínimo, la doctrina iusnaturalista del respeto de las libertades fundamentales por parte del derecho positivo, el constitucionalismo inglés y norteamericano, la tesis de la separación de poderes, la teoría jurídica del Estado elaborada por la ciencia alemana del derecho públi-

¹⁹ Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 2003, pp. 240 y ss.

²⁰ Vid. WALDRON, J., «Is the Rule of Law an essentially contested concept (in Florida)?», cit., p. 138. B. Z. TAMANAHA, ha defendido la conveniencia de atender al sentido común y a la interpretación popular del Estado de Derecho, que en ocasiones puede entrar en contradicción con la comprensión teórica y doctrinal, en *On the Rule of Law. History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, 2004, p. 111.

co el siglo pasado y después por el normativismo kelseniano»²¹. El análisis de todas esas perspectivas no es esencial para los fines de esta investigación. Por el contrario me interesa centrarme en este momento en la posible diferenciación entre las diversas comprensiones del concepto. En este sentido, sabemos que se habla de la posibilidad de defender conceptos más o menos amplios de Estado de Derecho; se habla, por ejemplo, de concepto formal y de concepto material. Lo que me interesa es detenerme —en el capítulo tercero— en esta cuestión: la de la distinción entre el concepto formal y el material de Estado de Derecho, y la de las ventajas que tiene el segundo sobre el primero.

Aunque el análisis de la distinción se deja para más adelante, me gustaría adelantar alguna apreciación. Como consecuencia de la concepción del Estado de Derecho que aquí se va a defender, podría concluirse que, en realidad, ya en la aparición del primer modelo de Estado de Derecho, el liberal, la cuestión de la dicotomía o tensión entre Estado de Derecho formal y material, estaría resuelta. En este sentido, se ha señalado que, con los precedentes de Platón, Pufendorf, Locke, Kant, cuando se comienza a manejar el término (V. Mohl) se hace ya incluyendo dimensiones materiales²². Si desde el principio la idea de Estado de Derecho incluye esas dimensiones, carece de sentido

²¹ L. FERRAJOLI, *Derecho y razón*, trad. de P. Andrés Ibáñez y otros, Trotta, Madrid, 1995, p. 856. Por cierto, creo que la distinción entre gobierno de las leyes y gobierno de los hombres mantiene toda su capacidad explicativa a la hora de mostrar el sentido básico del imperio de la ley en el Estado de Derecho, a pesar de críticas como la de J. AGUILÓ REGLA, según el cual la distinción está mal construida, «porque todo gobierno (en el sentido moderno de la expresión, que excluye la legitimidad meramente tradicional) es siempre «gobierno de los hombres» y, como consecuencia de ello no puede oponerse sin más a «gobierno de las leyes»», «Cuatro pares de concepciones opuestas de la Constitución», en AGUILÓ REGLA, J., ATIENZA, J., RUIZ MANERO, J., *Fragmentos para una teoría de la Constitución*, Iustel, Madrid, 2007, p. 41.

²² Vid. DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 36 y 37; también vid. n. 73, p. 40.

plantearse la posibilidad de hablar de un Estado de Derecho en sentido formal por varias razones: 1) porque no habría existido; 2) porque en nada se distinguiría de un Estado *no* de Derecho. El primer modelo histórico, el Estado de Derecho liberal, vinculado a una determinada concepción de los derechos individuales y de participación, sería la expresión de una determinada conexión entre el Derecho y determinados planteamientos morales (conexión *cierta* utilizando la terminología empleada por R. de Asís. *vid infra*); y esa conexión se mantendría, aunque con otros contenidos añadidos, en otros modelos de Estado de Derecho. El anterior sería un argumento que podría utilizarse, en su caso, para afirmar que no tiene mucho sentido analizar el concepto de Estado de Derecho a partir de la dicotomía formal/material: si el primer modelo de Estado de Derecho que aparece en la historia es el Estado liberal, y éste se caracteriza por tener un contenido sustancial, no se entiende bien qué se gana proponiendo un concepto formal que, como tal Estado de Derecho formal, no habría tenido materialización en ninguna situación histórica concreta. No obstante, la alusión a la distinción señalada tiene el propósito de colaborar en la más nítida identificación de los perfiles del concepto material de Estado de Derecho.

Además, como ya se ha señalado, la defensa de un concepto material y exigente de Estado de Derecho permite matizar los planteamientos que en ocasiones presentan una rígida diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional.

Por otra parte, es cierto que muchos de los trabajos en relación con el concepto, rasgos y características del Estado de Derecho, comienzan asumiendo una perspectiva histórica y analizan, de manera más o menos extensa, los orígenes del concepto y las circunstancias en las que comienza a utilizarse, deteniéndose al mismo tiempo el contexto político jurídico correspondiente. En efecto, una de las estrategias que se utiliza para analizar la idea de Estado de Derecho y sus exigencias conceptuales es la que consiste en estudiar los primeros empleos del término, los contextos en los que estos tuvieron lugar y sus rasgos y, posteriormente, su evolución y transforma-

ción²³. Esta estrategia es especialmente fructífera, dado el carácter histórico del concepto de Estado de Derecho. No obstante, no nos vamos a ocupar en esta ocasión de estas cuestiones optando por la posibilidad que consiste en la remisión a valiosos trabajos sobre la materia²⁴.

²³ Vid. por ejemplo DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., pp. 34 y ss.

²⁴ Entre la bibliografía sobre la cuestión, pueden consultarse al respecto los trabajos de M. FIORAVANTI incluidos en su obra recopilatoria *La Scienza del Diritto Pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra otto e novecento*, Giuffré, Milano, 2001, en concreto «Costituzione e stato di diritto» y «Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni preliminari sulla tradizione europeo-continentale», incluidos ambos en el tomo II de la citada obra. También BÖCKENFORDE, E. W., «Origen y cambio del concepto de estado de Derecho», ID., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, trad. de R. Agapito Serrano, Trotta, Madrid, 2000, pp. 17 y ss; HAYEK, F. A., *Los fundamentos de la libertad*, 3ª edic, trad. de J. V. Torrente, Unión Editorial, Madrid, 1978, pp. 215 y ss.; PÉREZ LUÑO, A. E., *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, cit., pp. 213 y ss.; COSTA, P., «Lo Stato di diritto: un'introduzione storica», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, (P. Costa, D. Zolo, eds.), Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 89 y ss.

II. DERECHO, PODER Y MORAL EN EL ESTADO DE DERECHO

En este capítulo voy a proponer una aproximación al Estado de Derecho a partir de su comprensión como escenario en el que se articulan, en alguna de sus posibles formulaciones, la relación entre el Derecho y el Poder, de un lado, y la relación entre el Derecho y la moral, de otro. Como quedó señalado en la Introducción a este trabajo, un correcto enfoque de estas relaciones permite comprender el sentido del Derecho moderno. Pues bien, el concepto de Estado de Derecho que se defiende en estas líneas supone una determinada opción en ambos casos. Respecto a la relación entre el Derecho y el Poder, el Estado de Derecho constituye un caso del modelo de coordinación, que es compatible con la referencia última al Hecho Fundante Básico y que en ocasiones recurre a la estrategia de la autolimitación. Por otra parte, como tendremos ocasión de observar, el Estado de Derecho también supone un determinado modelo respecto a la relación entre el Derecho y la moral. Afirmo esto teniendo presente el modelo de Estado de Derecho que se defiende en este trabajo, es decir el modelo material o sustancial que, como veremos, se caracteriza por integrar unos y no otros contenidos. El Estado de Derecho material y el proceso de materialización del Derecho o de positivación del Derecho natural que se produce en su seno, se podría entender como un reto para la tesis iuspositivista que propugna la separación conceptual entre el Derecho

y la moral. No obstante, el reto no es tal si se tienen en cuenta dos afirmaciones: 1) un adecuado enfoque de la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral implica entender por moral no cualquier propuesta normativa al respecto, sino sólo la moral «correcta»; 2) por otra parte, no debemos olvidar que las consideraciones que se puedan extraer en su caso de la configuración jurídica del Estado de Derecho no son necesariamente extrapolables a otros sistemas jurídicos.

1. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO Y EL PODER EN EL ESTADO DE DERECHO. EL PROBLEMA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD.

Es necesario subrayar aquí que la caracterización del Estado de Derecho se produce necesariamente en el marco de las relaciones entre el Derecho y el Poder. En este sentido, como se ha adelantado, el Estado de Derecho es en realidad un determinado modelo de articulación de estas relaciones.

La relación entre el Derecho y el Poder es imprescindible no sólo para comprender el sentido del Estado de Derecho, sino también para comprender el sentido y el funcionamiento del Derecho en general y de los Ordenamientos jurídicos en particular. La propuesta de la Modernidad en relación con el Derecho, el abandono de los referentes trascendentes de acuerdo con los cuales se pretendía explicar la validez de las normas jurídicas, sitúa en primer plano esta relación. Así, el Derecho se presenta, en última instancia, como expresión de la voluntad del Poder. La actividad del Poder político, organizado en forma de Estado, se vincula a un determinado programa de organización social. El éxito de ese programa es posible a través de la puesta en marcha de un sistema normativo protagonizado por las normas jurídicas. Habida cuenta de que el concepto de Poder se reconduce a la posibilidad de condicionar o modificar los comportamientos ajenos, existen varias posibilidades a través de las cuales se materializa esa posibilidad. La más extraña

al Derecho es la que consiste en el ejercicio de la fuerza bruta, sin sometimiento alguno a reglas.

Las normas jurídicas pueden ser entendidas como expresión de una voluntad, la del Poder político que en la Modernidad se expresa en forma de Estado²⁵. Esta afirmación vale tanto para sistemas democráticos como para sistemas no democráticos. Además, la relación entre el Derecho y el Poder existe también aunque la relación entre el Derecho y el Estado pudiera, en su caso, ser sometida a revisión. Es cierto que en la actualidad, y desde diversas perspectivas, la relación entre el Derecho y el Estado, vinculada a la consideración de que el origen de las normas es exclusivamente estatal, se pone en entredicho. En la actualidad asistimos a un proceso en el que el Estado se ve superado tanto desde el punto de vista interno como externo en lo que se refiere a su protagonismo en los procesos de producción normativa. Dicha superación, que se materializa tanto a través de la supraestatalidad normativa como a través de la infraestatalidad normativa, forma parte del proceso que Pérez Luño ha identificado como «el desbordamiento de las fuentes del Derecho»²⁶. En todo caso, téngase en cuenta que el Estado, concebido como forma de organización del Poder político típica del mundo moderno, conserva una todavía importante capacidad de decisión en lo que se refiere a la definición y potencialidad de los procesos de infraestatalidad y supraestatalidad normativa. En el primer caso, solemos asistir en muchas ocasiones al desarrollo de mecanismos de descentralización del Poder del Estado, resultando así un Poder

²⁵ Sobre los modelos históricos de aparición del Estado moderno, puede consultarse PECES-BARBA, G., *Tránsito a la Modernidad y derechos fundamentales*, Mezquita, Madrid, 1982, pp. 25 y ss. También, SOLARI, G., *La formazione storica e filosofica dello Stato Moderno*, (rist.), Giappichelli, Torino, 1962 y PASSERIN D'ENTREVES, A., *La noción del Estado*, trad. de A. Fernández Galiano, Centro de Estudios Universitarios, s. f.

²⁶ Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., *El desbordamiento de las fuentes del Derecho*, Real Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación, Sevilla, 1993, pp. 76 y ss.

(autonómico o regional, provincial o local), que se presenta como manifestación concreta del Poder estatal. En el segundo caso, podemos estar en presencia de casos de cesión o de traspaso de soberanía, resultado de una determinada decisión política adoptada en el interior de las instituciones estatales. También es cierto que las dificultades de mantener una tesis sobre la producción normativa exclusivamente estatista son tomadas como argumento a la hora de poner en entredicho al positivismo teórico, de acuerdo con la caracterización del mismo presentada por Norberto Bobbio²⁷. Por otra parte, no es éste el momento de atender al discurso sobre la crisis del concepto de soberanía²⁸ o sobre el desarrollo de las propuestas referidas al pluralismo jurídico²⁹, que coincidirían en la afirmación de la pérdida del monopolio de la producción jurídica por parte del Estado. En todo caso lo que interesa aquí es subrayar la importancia de la relación entre el Poder político, allá donde éste resida, y el Derecho. Lo cual no obsta para seguir manteniendo el valor de la conexión básica entre el Derecho y el Estado a la hora de comprender la conformación del fenómeno jurídico en la Modernidad. De manera que se puede afirmar que la relación que en la práctica se produce entre el Ordenamiento jurídico y el Estado es una manifestación de la relación teórica y práctica entre el Derecho y el Poder.

Se ha señalado que varios son los modelos que pueden utilizarse para explicar cómo se desarrolla esa relación. Entre los diversos modelos a los que alude Gregorio Peces-Barba, es el de

²⁷ Vid. BOBBIO, N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, 1965, pp. 107 y ss.

²⁸ Pueden consultarse, entre la bibliografía existente, los trabajos contenidos en BASCIU, M. (ed.), *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Giuffrè editore, Milano, 1996.

²⁹ Vid., ARNAUD A.-J.-FARIÑAS DULCE, M. J., *Sistemas jurídicos: elementos para un análisis sociológico*, BOE-Universidad Carlos III de Madrid, 1996, pp. 281 y ss. También, MERRY, S. E., GRIFFITHS, J., TAMANAHA, B. Z., *Pluralismo jurídico*, est. prel. de L. Ariza Higuera y D. Bonilla Maldonado, Siglo del Hombre, Bogotá, 2007.

coordinación o integración el que sirve mejor para explicar cómo funciona la relación en el marco del Estado de Derecho³⁰, en el que Derecho y Poder se presentarían, siguiendo a Bobbio, como las dos caras de una misma moneda³¹. En el modelo de coordinación entre el Derecho y el Poder se produce una relación entre ambos elementos, de manera que, por un lado, el Poder político crea Derecho. Las normas jurídicas son, en última instancia, el resultado, y la expresión, de una voluntad, la del Poder político. La propuesta de organización del conjunto social, determinada por ese Poder, se manifiesta a través de normas jurídicas. En realidad esta vertiente de la relación según la cual las normas jurídicas son el vehículo a través del cual se manifiesta la voluntad del Poder, no diferencia el modelo de coordinación de otros modelos de relación entre el Derecho y el Poder; en efecto, a no ser que se asuma una perspectiva iusnaturalista, u otra en la que las pautas de organización social se entiendan completamente autónomas respecto al Poder político, la presencia de lo que Peces-Barba ha denominado el punto de vista externo es de necesario reconocimiento. En resumidas cuentas, aquello que en principio diferenciaría y dotaría de autonomía al Estado de Derecho frente a otros modelos de organización jurídica del Poder político es precisamente el punto de vista interno, es decir, la dimensión de racionalización y limitación del Poder operada a través de las nor-

³⁰ Vid. PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, Universidad Carlos III de Madrid, BOE, Madrid, 1995, pp. 327 y ss. La concepción de la relación entre el Estado y el Derecho propuesta por Hermann Heller, a la que Peces-Barba alude expresamente, es un buen ejemplo de este modelo de coordinación. Vid. HELLER, H., *Teoría del Estado*, trad. de L. Tobío, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, pp. 199 y ss. Una completa síntesis del pensamiento de Heller puede encontrarse en LA TORRE, M., «Un giurista nel crepuscolo di Weimar. Politica e diritto nell'opera di Hermann Heller», *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 29, 2000, pp. 241 y ss.

³¹ Vid. BOBBIO, N., «Dal diritto al potere e viceversa», ID., *Diritto e Potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 141 y ss.

mas jurídicas. En el Estado de Derecho, de acuerdo con la concepción que se defiende en estas líneas, esta dimensión de limitación y racionalización adquiere un significado sustantivo específico y relevante.

Por tanto, en el Estado de Derecho, el Poder político crea Derecho y a su vez este Derecho sirve para estructurar y limitar este Poder; es decir, este Poder está sometido al Derecho creado por él. En este punto surge una cuestión: ¿hasta qué punto este esquema es propio del Estado de Derecho y no se reproduce en cierto sentido en el interior de otros modelos?. La presencia de un determinado grado de vinculación a reglas parece requisito imprescindible para la existencia y el funcionamiento de un sistema jurídico. Con independencia del juicio moral que nos merezcan esas reglas, podemos afirmar que su presencia constituye uno de los requisitos mínimos que permiten diferenciar a un sistema normativo como el Derecho de un conjunto de órdenes arbitrarias. Sobre esta cuestión volveremos posteriormente. Baste por ahora adelantar que un mínimo y suficiente cumplimiento de los requisitos que Fuller identificó con la moral interna del Derecho, y que pueden ser reconducidos a las exigencias del imperio de la ley, se presenta como necesario para la identificación del Derecho como tal.

Pues bien, si la vinculación del Poder a normas, aún siendo un rasgo del Estado de Derecho, no es su criterio identificativo, hay que reconocer que, en última instancia es precisamente el tipo de vinculación lo que identifica al Estado de Derecho. En efecto, las normas jurídicas vinculan al Poder en el Estado de Derecho a través de sus contenidos específicos. Así, como luego veremos, la legalidad en el Estado de Derecho no es cualquier tipo de legalidad, sino una legalidad selectiva³². Es la vinculación del Poder a determinados contenidos juridificados lo que permite caracterizar al Estado de Derecho frente a otros modelos. Pero téngase en cuenta que la vinculación a contenidos,

³² Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho», *Sistema*, n.º 138, 1997, p. 102.

considerada en abstracto, se produce también en cualquier Ordenamiento jurídico, y no sólo en el del Estado de Derecho. Peces-Barba llama la atención sobre este extremo al señalar que el modelo de coordinación permite dos aproximaciones. La primera de ellas es la aproximación descriptiva, que vale para todo tipo de Poder y para todo tipo de Derecho producido por ese Poder: «Este tipo de argumentación de lo que trata es de analizar el hecho de que todo poder político asume unos valores y que los traslada como moralidad jurídica a su sistema de Derecho. Así toda relación poder-Derecho supone un poder institucionalizado que tiene unos fines u objetivos susceptibles de ser analizados desde el punto de vista de la moralidad pública, una determinada moralidad pública, y una vocación de ese poder a organizar la convivencia social a través de normas jurídicas, de un ordenamiento, al que ese poder comunica sus criterios o valores de moralidad pública como fundamentos de esa regulación»³³. Por su parte, la aproximación prescriptiva «supone optar entre todos los modelos posibles por el que se considera más deseable, más justificado o más adecuado para alcanzar determinados objetivos. La reflexión sobre el poder democrático, raíz imprescindible del Derecho válido de los derechos fundamentales, se sitúa en este segundo grupo. Así sólo en un tipo de poder democrático se encuentra un modelo de derechos fundamentales, aunque luego existan matices y ámbitos más o menos extensos según el tipo de poder democrático y la ideología y el grupo social que lo apoya»³⁴.

El recurso al modelo de coordinación para explicar la articulación de la relación entre el Derecho y el Poder en el marco del Estado de Derecho permite apreciar el carácter bidireccional de dicha relación. En efecto —como se ha afirmado— el Poder produce Derecho y a su vez esa producción tiene lugar en el marco y en las condiciones establecidas por normas jurí-

³³ PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, cit., p. 328.

³⁴ *Ibidem*.

dicas, que llevan a cabo una función de limitación y racionalización del ejercicio del Poder. Esta configuración de la relación entre el Derecho y el Poder plantea el problema del carácter autorreferencial del Estado de Derecho³⁵, que se produce cuando se afirma que el Poder político que produce normas es a la vez producido por normas.

Podemos aludir a diversas propuestas que permiten escapar a esta circularidad: la identificación kelseniana entre Derecho y Estado, el recurso a mecanismos de heterolimitación del Poder a partir de la afirmación de la existencia de ámbitos de indisponibilidad para el Poder político, la tesis de la autolimitación propuesta por Jellinek y Carré de Malberg entre otros, y la teoría del Hecho Fundante Básico, propuesta por Peces-Barba. En realidad, como recordó Radbruch, estamos ante la cuestión de la precedencia del Estado frente al Derecho o del Derecho frente al Estado³⁶.

Kelsen se opone, como es sabido, al dualismo entre el Derecho y el Estado; por el contrario, afirma la identidad entre Derecho y Estado³⁷. En *La Teoría Pura del Derecho*, podemos leer: «Un conocimiento del Estado libre de ideología y, por ende, liberado de toda metafísica y mística, no puede hacerse cargo de su esencia si no lo capta conceptualmente como una formación social, como un orden de la conducta humana (...) Es usual caracterizar al Estado como una organización política. Pero así sólo se expresa que el Estado es un orden coactivo»³⁸. Kelsen no defiende una mera identificación entre Estado y Derecho; para el jurista austriaco, el Estado se identi-

³⁵ A esta cuestión se han referido entre otros CHEVALLIER, J., *L'État de droit*, cit., y GARCÍA FIGUEROA, A., *Principios y positivismo jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 66 y ss.

³⁶ Vid. RADBRUCH, G., *Filosofía del Derecho*, est. prel. de J. L. Monereo, Comares, Granada, 1999, p. 235.

³⁷ Vid. KELSEN, H., «L'essence de l'État», trad. de P. H. Tavoillot, *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 17, 1990, pp. 17 y ss.

³⁸ KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, trad. de la segunda edic. en alemán por R. J. Vernengo, UNAM, 1982, p. 291.

fica con un orden jurídico relativamente centralizado. El carácter organizado del orden jurídico, con órganos encargados de producir normas y aplicarlas de acuerdo con un esquema de división del trabajo y con un cierto grado de centralización, permite diferenciarlo tanto de un orden primitivo preestatal como del Derecho internacional.

La identificación entre Estado y Derecho, la concepción jurídica del Estado, determina una interpretación también jurídica de los tres elementos tradicionalmente considerados como componentes de la idea de Estado: pueblo, territorio y poder³⁹. Así, en relación con el pueblo, Kelsen señala: «La pregunta de si un hombre pertenece a un Estado no es una cuestión psicológica, sino una pregunta jurídica. La unidad de los hombres que constituyen la población del Estado no puede reconocerse sino en el hecho de que un mismo orden jurídico vale para esos hombres, en que su conducta se encuentra regulada por un mismo orden jurídico. La población del Estado es el dominio de validez personal del orden jurídico estatal»⁴⁰. En relación con el territorio, escribe: «El territorio del Estado es un determinado espacio delimitado (...). Ningún conocimiento natural, sino sólo un conocimiento jurídico puede dar respuesta a la pregunta referente a cómo se determinen los límites del espacio estatal, a la constitución de su unidad. El llamado territorio sólo puede ser definido como el dominio territorial de validez de un orden jurídico estatal»⁴¹. Y respecto al Poder, para Kelsen, en definitiva, «lo que diferencia a la relación denominada poder del Estado, de otras relaciones de poder, es la circunstancia de encontrarse jurídicamente regulada, es decir, que los hombres que, como gobierno del Estado, ejercen el poder, están facultados por un orden jurídico a ejercer el poder mediante la producción y aplicación de normas jurídicas; que el poder del Estado tiene carác-

³⁹ Vid. GOYARD-FABRE, S., «L'État du droit et la démocratie selon Kelsen», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 17, 1990, pp. 161-166.

⁴⁰ KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., p. 293.

⁴¹ *Ibidem*.

ter normativo. El llamado poder del Estado es la validez de un orden jurídico (...). La potencia del Estado no es ninguna fuerza o recurso místico, oculto detrás del Estado o de su Derecho. No es otra cosa que la eficacia del orden jurídico estatal»⁴².

Pero, además, la identificación entre Derecho y Estado está detrás del vaciado de contenido al que Kelsen somete al Estado de Derecho, en relación con la idea de Estado. Para Kelsen, la diferencia entre Estado de Derecho y Estado, desaparece: «Si se reconoce en el Estado un orden jurídico, todo Estado es un Estado de Derecho, dado que esta expresión es pleonástica»⁴³.

El segundo modo de escapar a la circularidad que parece reproducirse en el esquema de la relación entre el Derecho y el Poder en el modelo de integración es el que consiste en recurrir a mecanismos de heterolimitación del Poder político. Existen, de acuerdo con esta vía, determinados contenidos que se encuentran más allá del ámbito de disposición del Poder político y que por tanto limitan (o deben limitar) su capacidad de actuación. La circularidad o carácter autorreferente del Estado de Derecho quiebra desde el momento en que el Poder está vinculado a ciertas instancias normativas (que se identifican con la idea de corrección moral) cuya existencia, a su vez, no está determinada por la voluntad política y por tanto, escapan

⁴² KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., p. 294; Vid. también ID., *Teoría General del Estado*, trad. de L. Legaz Lacambra, Editora Nacional, México 1972 (reimpr.), pp. 21-22. En su discusión con Rudolf Smend, Kelsen afirma: «La Teoría del Estado de la Escuela de Viena afirma que la unidad del Estado sólo puede fundarse en la esfera normativa, que dicha unidad no es más que la unidad de un ordenamiento normativo, que la existencia y realidad del Estado consiste únicamente en la validez de un ordenamiento jurídico que opera como esquema interpretativo para una pluralidad de actos humanos, actos que encuentran su unidad solamente en la unidad del sistema normativo que les presta su específico sentido como actos del Estado», *El Estado como integración. Una controversia de principio*, estudio preliminar y traducción de J. A. García Amado, Tecnos, Madrid, 1997, p. 56.

⁴³ KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., p. 315. También, ID., *¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?*, trad. de E. Garzón Valdés, Fontamara, México, 1992, p. 38.

a su control. Este es un esquema que se puede identificar con lo que tradicionalmente ha supuesto el iusnaturalismo, que encontramos en Radbruch⁴⁴, pero que también reaparece en las posiciones —que han sido caracterizadas genéricamente como no positivistas⁴⁵— de Ronald Dworkin y de Robert Alexy⁴⁶ y, en general, aquellas propuestas que, en el marco del neoconstitucionalismo (constitucionalismo contemporáneo), señalan la indisponibilidad de determinados contenidos en relación con la acción normativa del Poder político. Ronald Dworkin, al afirmar la *rights thesis*, sitúa más allá del ámbito afectado por las decisiones mayoritarias a los derechos, identificando así el núcleo del constitucionalismo como «la teoría de que a la mayoría hay que restringirla para proteger los derechos individuales»⁴⁷. Por su parte, Robert Alexy define el Derecho a partir, entre otros elementos, de la existencia de una pretensión de corrección, a la que otorga relevancia clasificatoria, presentándola por tanto como «un elemento necesario del concepto de Derecho»⁴⁸. Además, para Alexy, «en la medida en que esta

⁴⁴ «Nos vemos, pues, impulsados a marchar por encima, tanto del Derecho positivo como del Estado, y hacia un mundo, no de hechos, sino de normas, que no son ya estatales y positivas, sino que sólo pueden ser de Derecho natural (...); «El Estado está, pues, sujeto a su Derecho positivo, por un Derecho suprapositivo, natural, por el mismo precepto del Derecho natural, con el que únicamente puede fundamentarse la vigencia del Derecho positivo», RADBRUCH, G., *Filosofía del Derecho*, cit., pp. 240 y 241 respectivamente.

⁴⁵ Vid. GARCÍA FIGUEROA, A., *Principios y positivismo jurídico*, cit..

⁴⁶ Vid al respecto, BONGIOVANNI, G., *Teorie «costituzionalistiche» del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin*, Clueb, Bologna, 2000, además de la obra de García Figueroa citada anteriormente.

⁴⁷ Vid. DWORKIN, R., *Los derechos en serio*, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona, 1984. p. 223. ID., «Rights as trumps», en WALDRON, J. (ed.), *Theories of Rights*, Oxford University Press, 1984, pp. 153 y ss.

⁴⁸ ALEXY, R., *El concepto y la validez del Derecho*, trad. de J. M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 40. También, ALEXY, R., «Los principales elementos de mi Filosofía del Derecho», *Doxa*, n.º 32, 2009, pp. 67 y ss. Sobre la cuestión de la pretensión de corrección, vid. ALEXY, R., BULYGIN, E., *La pretensión de corrección del derecho. La polémica sobre la relación entre derecho y moral*, trad. e introd. de P. Gaido, Universidad Externado de Colombia, 2001.

pretensión tiene implicaciones morales, se pone de manifiesto una conexión conceptualmente necesaria entre Derecho y moral»⁴⁹. Junto a esto, el manejo del argumento de la extrema injusticia, vinculado a la propuesta de Radbruch, tanto en lo que afecta a las normas jurídicas aisladas («... cuando traspasan un determinado umbral de injusticia, las normas aisladas de un sistema jurídico pierden el carácter jurídico»)⁵⁰, como en lo que se refiere a los sistemas jurídicos («... un sistema normativo pierde su carácter jurídico si, en general, es extremadamente injusto»)⁵¹, contribuye a establecer límites a la capacidad de disposición normativa del Poder político.

La tercera estrategia es la que afirma la autolimitación del Poder político que, dentro del positivismo jurídico, convive con aquellas posiciones que aseguran la ilimitabilidad jurídica del Poder. Aunque George Jellinek es posiblemente uno de los más reconocidos postuladores de la idea de autolimitación del Estado, desarrollada entre otros lugares en su *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, es cierto que dicha idea ya se encuentra apuntada por Ihering en *El fin en el Derecho*⁵². Es de Gregorio Peces-Barba la afirmación según la cual Ihering es el autor de la formulación más correcta de la relación entre el Derecho y el Poder en el siglo XIX⁵³. En todo caso, lo que sí es cierto es que el Ihering de *El fin en el Derecho* puede ser justamente considerado como digno representante del positivismo imperativista. Ihering define el Derecho como «el conjunto de normas según las cuales se ejerce en un Estado la coacción»⁵⁴. A partir de ahí,

⁴⁹ ALEXY, R., *El concepto y la validez del Derecho*, cit., p. 45.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ ALEXY, R., *El concepto y la validez del Derecho*, cit., p. 69.

⁵² Así lo hace notar M. LA TORRE en *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Bari, 1999, p. 16.

⁵³ Vid. PECES-BARBA, G., *Introducción a la Filosofía del Derecho*, Debate, Madrid, 1983, p. 38.

⁵⁴ IHERING, R. V., *El fin en el Derecho*, s. trad., ed. Heliasta, Buenos Aires, 1978, p. 158. Vid al respecto, SQUELLA NARDUCCI, A., «Derecho y Estado de Derecho en la obra de Rudolph von Ihering», *Revista de Ciencias Sociales*, Valparaíso, 1976-77, pp. 555 y ss. Y LLOREDO ALIX, L. M., *Rudolf*

identifica dos elementos de la idea de Derecho: la norma y la coacción. Ambos confluyen en el Estado, ya que el Estado es el origen único del Derecho, siendo así que la coactividad es la nota que lo caracteriza: «La coacción ejercida por el Estado constituye el criterio absoluto del derecho; una regla de derecho desprovista de coacción jurídica es un contrasentido; es un fuego que no quema, una antorcha que no alumbra»⁵⁵. Para Ihering, las normas jurídicas ejercen su autoridad en dos ámbitos, uno interno y otro externo. El interno es el constituido por los diferentes mecanismos del Estado, mientras que el externo se refiere al pueblo, siendo más importante el primero que el segundo a la hora de definir el Derecho: son los órganos públicos los encargados de aplicar la coacción, estando obligados por el Derecho a ello. En realidad, el carácter jurídico de una disposición —señala Ihering— no depende del hecho de que haya sido dictada por el Poder público, como «de que el poder público obligue a sus órganos a ejecutarla y les arme de coacción externa. (...) el carácter distintivo de una norma de derecho no consiste en la acción *externa* que ejerce sobre el pueblo, sino en su autoridad *interna* sobre los poderes públicos, mucho más importante. De expresar en términos jurídicos la noción de la norma del derecho, lo haremos con exactitud definiéndola, respecto a la forma, en estos términos: contiene un imperativo abstracto dirigido a los órganos del poder público, y el efecto externo, es decir, su observación por el pueblo, debe, bajo este aspecto *puramente formal* (no *teleológico*), ser considerado como un elemento secundario»⁵⁶.

Si bien Kelsen se muestra contrario a la teoría de la autolimitación, es de notar en este punto que en la afirmación de la

Ihering y el paradigma positivista. Fundamentos ideológicos y filosóficos de su pensamiento, Dykinson, Madrid, 2012.

⁵⁵ IHERING, R. v., *El fin en el Derecho*, cit., p. 159. En un momento anterior, afirma: «La fuerza puede, en caso de necesidad, vivir sin el derecho; ya lo ha demostrado. El derecho, sin la fuerza, es una palabra falta de sentido: sólo la fuerza realiza las reglas del derecho y hace de éste lo que debe ser» (p. 127).

⁵⁶ IHERING, R. v., *El fin en el Derecho*, cit., p. 167, cursivas en el texto.

vinculación del Poder al Derecho, Ihering y Kelsen llegan a conclusiones próximas. Ihering, y después Kelsen, subrayan el elemento coactivo del Derecho. Para ambos la naturaleza del Derecho es sancionadora; las normas jurídicas son normas sancionadoras. Recordemos que para Kelsen el Derecho es un orden coactivo de la conducta humana y que las normas genuinas son aquellas según las cuales un cierto órgano debe ejecutar una sanción⁵⁷. Pues bien, su concepción del Derecho tiene como consecuencia la vinculación del órgano jurídico, del sujeto que ejerce autoridad en el marco de un Ordenamiento, al Derecho. Para Ihering el sujeto u órgano que ejerce la autoridad es el destinatario primero del Derecho («...el Código civil, el Código penal, todas las leyes y ordenanzas militares, fiscales, de policía, etcétera, no hacen más que regular el ejercicio del poder público de coacción»⁵⁸), que adquiere perfección en el caso de los imperativos abstractos⁵⁹ y bilaterales⁶⁰. Para Kelsen las normas primarias son aquellas dirigidas al órgano encargado de imponer la sanción al sujeto (súbdito) que ha actuado

⁵⁷ Vid. KELSEN, H., *Teoría General del Derecho y del Estado*, trad. de E. García Maynez, UNAM, 1983, pp. 68 y ss. A partir de esta concepción de las normas jurídicas, Kelsen ha sido destacado como el principal exponente de una teoría «homogénea» de las normas jurídicas, que es superada por una concepción «heterogénea» en la que se subraya la aportación de Hart. Vid. ROBLES MORCHÓN, G., *Teoría del Derecho (Fundamentos de Teoría comunicacional del Derecho)*, vol. I, Cívitas, Madrid, 1998, pp. 145 y ss.

⁵⁸ IHERING, R. v., *El fin en el Derecho*, cit., p. 167.

⁵⁹ «El imperativo puede señalar un modo de obrar en un caso determinado o prescribir un tipo de acción para todos los casos de cierta especie. Esto es lo que nos hace distinguir los imperativos *concretos* y *abstractos*. Estos últimos son idénticos a la norma. La norma es, pues, el *imperativo abstracto de las acciones humanas*», *El fin en el Derecho*, cit., p. 164.

⁶⁰ «La intención del poder público, al formular la norma, puede ser sólo ligar, no a sí mismo, sino únicamente a aquel a quien se dirige. El poder se reserva entonces completa libertad de acción. Puede también dictar su disposición con la intención de ajustarse él mismo a ella. Bajo esta forma, y nada más que ésta, adquiere el derecho toda su perfección; una vez establecida la norma, tiene asegurada su inevitable realización», IHERING, R. v., *El fin en el Derecho*, cit., p. 167.

antijurídicamente siendo su acto «el supuesto al cual la norma jurídica enlaza la sanción»⁶¹, de manera que «únicamente el órgano puede proceder contrariamente al derecho, es decir, a la norma primaria, al no ejecutar la sanción cuando las condiciones de la misma han quedado cumplidas»⁶². Por tanto, el deber ser jurídico, según Kelsen, va dirigido directamente al órgano que tiene que aplicar la sanción: «Sólo el órgano puede, hablando estrictamente, «obedecer» o «desobedecer» la norma jurídica, al ejecutar o dejar de ejecutar la sanción prescrita»⁶³. La concepción del Poder político, del Estado, como detentador del uso de la fuerza en sociedad y monopolizador de la capacidad de aplicar sanciones de forma institucionalizada, en conjugación con una concepción del Derecho que subraya la dimensión sancionadora y coactiva, tiene como consecuencia en ambos casos la afirmación de que son los órganos del Poder los destinatarios directos y principales, y la consiguiente conclusión de que el cumplimiento del Derecho se identifica básicamente con el cumplimiento de las normas sancionadoras por parte de estos órganos.

Pero, como se ha señalado antes, la teoría de la autolimitación del Estado se vincula a Jellinek que, en su *System der subjektiven öffentlichen Rechte*⁶⁴, construye una teoría del Estado en la que éste se presenta como Estado jurídico mediante el mecanismo de la autoobligación. El de autolimitación es el concepto al que recurre Jellinek a la hora de conciliar la idea de límite jurídico, de un lado, y la noción de soberanía del Estado, de otro⁶⁵.

Para Jellinek, el Estado no puede prescindir del Derecho. La soberanía, entendida como categoría histórica, se refiere a

⁶¹ KELSEN, H., *Teoría General del Derecho y del Estado*, cit., p. 60.

⁶² KELSEN, H., *Teoría General del Derecho y del Estado*, cit., p. 72.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Existe traducción italiana, que es la que se sigue aquí, de G. Vitagliano, con prefacio de V. E. Orlando: *Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912.

⁶⁵ Vid. DONNARUMMA, R. M., «Una tematica sempre attuale: lo 'Stato di diritto'», *Diritto e Società*, 1994/1, pp. 90-95.

la existencia de un Poder independiente y supremo, pero no implica, señala Jellinek, que el Estado no pueda estar sometido a vínculos jurídicos. Esos vínculos jurídicos, de alguna manera, garantizan la pervivencia del Estado. Si no existieran, el Estado podría incluso decidir la misma desaparición del Ordenamiento jurídico: «Si el Estado jurídicamente lo puede todo, podrá también suprimir el orden jurídico mismo, introduciendo la anarquía y hacerse a sí mismo imposible, y si un pensamiento de esta naturaleza ha de desecharse, se sigue de aquí que el Estado encuentra una limitación jurídica en la existencia de un orden determinado. Puede, ciertamente, elegir el Estado la Constitución que ha de tener, pero habrá de tener necesariamente alguna. La anarquía es una posibilidad en el terreno de los hechos, pero no una posibilidad en el reino del derecho»⁶⁶. Así, la mera existencia de un orden jurídico niega la idea de un poder absoluto e ilimitado por parte del Estado.

En la explicación de la idea de autoobligación del Estado respecto a su propio Derecho, Jellinek utiliza un paralelismo con la teoría ética de Kant. En este sentido, la concepción ética kantiana supone la superación de aquellas concepciones tradicionales que vinculaban la idea de moralidad y de deber a la idea de heteronomía. Por el contrario, como es bien sabido, Kant subraya la autonomía de la moral: el carácter auténticamente moral de una decisión o de un deber, radica en su naturaleza autónoma. Pues bien, se ha afirmado que la propuesta de Jellinek consiste en la traslación de las consecuencias que la moral kantiana tiene para la idea de deber moral, al concepto de deber jurídico⁶⁷. Así, escribe: «El concepto de deber es un concepto de unidad; el deber de derecho y el deber moral, aunque se diferencian grandemente uno de otro, concuerdan en ser

⁶⁶ JELLINEK, G., *Teoría General del Estado*, prólogo y traducción de Fernando de los Ríos, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 434.

⁶⁷ Vid. BONGIOVANNI, G., «Stato di diritto e giustizia costituzionale. Hans Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, cit., p. 312. También TUORI, K., *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, Ashgate, Surrey, 2010, p. 225.

ambos deberes. Las modificaciones en las teorías éticas de los deberes han de conducir, por consiguiente, de un modo necesario, a la modificación de los deberes jurídicos. En el concepto de autoobligación del Estado no existe contradicción, como no existe en el de la autonomía moral. La autoobligatoriedad es exigida por las convicciones jurídicas dominantes, con lo cual, junto al carácter subjetivo de todo criterio acerca del derecho, existe también el carácter jurídico de la obligación que el Estado se impone a sí mismo»⁶⁸. De la misma manera que el individuo que actúa moralmente es aquel que se mueve de acuerdo con sus deberes impuestos autónomamente, «la soberanía es la capacidad para determinarse de un modo autónomo jurídicamente. De aquí que el Estado soberano es el único que puede, dentro de las limitaciones jurídicas que a sí mismo se haya impuesto, ordenar, de una manera plenamente libre, el campo de su actividad»⁶⁹.

En definitiva, para Jellinek, el Ordenamiento jurídico es en realidad el resultado de la autoimposición de límites de Derecho por parte del Estado. A través de la autolimitación, el poder de hecho se convierte en poder jurídico, siendo también la autolimitación la que permite predicar del Estado derechos y deberes: «Allí donde naturalmente, el Estado puede todo aquello que es accesible a su poder de hecho, en consideración al derecho, puede sólo aquello a lo que está autorizado por el Ordenamiento jurídico; sólo le es lícito aquello que le permite su voluntad vinculada a la ley. Como consecuencia de las limitaciones que le son impuestas por su Ordenamiento jurídico, se transforma en sujeto, en sentido jurídico, de derechos y de deberes hacia sus súbditos»⁷⁰.

⁶⁸ JELLINEK, G., *Teoría General del Estado*, cit., p. 437.

⁶⁹ JELLINEK, G., *Teoría General del Estado*, cit., p. 449.

⁷⁰ JELLINEK, G., *Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi*, cit., p. 214. Vid. también JELLINEK, G., *Teoría General del Estado*, cit., p. 195. Vid. sobre el tema: LA TORRE, M., «Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso del diritti di libertà», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XII, n.º1, junio, 1982; GOZZI, G., «Stato di diritto e diritti soggettivi nella

Tras Jellinek, Raymond Carré de Malberg plantea, en su *Contribution à la Théorie Générale de l'État*,⁷¹ en el marco del análisis de las limitaciones que afectan a los órganos soberanos del Estado, la teoría de la autolimitación: «El Estado no puede estar limitado más que en virtud de su propia voluntad»⁷². El Estado, en ejercicio de su soberanía, dicta normas a las que se somete y que por tanto lo limitan. Pero el origen de estas limitaciones se encuentra precisamente en la voluntad del Estado y no radica en otra sede: «...tanto la Constitución que organiza su potestad y rige su funcionamiento como las leyes que establecen en todos los aspectos su orden jurídico, son obra de su voluntad y tienen su origen exclusivamente en el poder que tiene de determinarse a sí mismo»⁷³.

La teoría de la autolimitación propuesta por Carré de Malberg se refiere a las limitaciones jurídicas y formales, diferenciándose así de las teorías que vinculan al Estado a límites políticos y morales. Carré de Malberg no niega que el Estado pueda estar sometido a vínculos morales o políticos, afirmando solamente que en todo caso los límites jurídicos proceden exclusivamente de su voluntad. Otros límites son evidentemente posi-

storia costituzionale tedesca», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, cit., pp. 272 y ss. He tratado anteriormente la cuestión de la autolimitación del Estado mediante la atribución de derechos públicos subjetivos en la teoría de Jellinek en ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., *Poder, Ordenamiento jurídico, derechos*, Dykinson, Madrid, 1997, pp. 56 y ss.

⁷¹ CARRÉ DE MALBERG, R., *Contribution à la Théorie Générale de l'État, spécialement d'après les données fournies par le Droit Constitutionnel Français* (1922). Se sigue la traducción castellana, *Teoría General del Estado*, estudio preliminar de H. Fix Zamudio, trad. de J. Lión Depetre, UNAM-Fondo de Cultura Económica, México, 1998. Un cuadro de conjunto de las posiciones teóricas asumidas por Carré de Malberg, puede encontrarse en GALIZIA, M., «Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg», *Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno*, 2, 1973, pp. 335 y ss.

⁷² CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 222. Puede consultarse CASTILLO, M., «La question de l'autolimitation de l'État», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 13, 1988, pp. 87 y ss.

⁷³ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 224.

bles, pero su conversión en límites jurídicos sólo es posible a través de la mediación de la voluntad del Estado: «siempre resulta que la intervención del Estado es indispensable para trasladar la regla ideal de Derecho al campo de las realidades jurídicas positivas, y así forzosamente hay que volver a la conclusión de que sólo puede formarse el Derecho propiamente dicho por la potestad y la voluntad del Estado»⁷⁴. La consideración de la autolimitación como formal y exclusivamente jurídica le permite a Carré de Malberg enfrentarse con las críticas dirigidas a la idea de autolimitación centradas, en su caso, en la afirmación de los derechos individuales innatos, en la defensa del vínculo social basado en la idea de solidaridad (Duguit), o en la referencia al Derecho natural. Tanto en el caso de los derechos innatos como en el Derecho natural, Carré de Malberg se presenta como un férreo defensor de la distinción entre el Derecho positivo y otro orden normativo superior, carente *per se* de eficacia. En el caso de los derechos del individuo, «sólo adquieren valor jurídico propiamente dicho con la condición de haber sido declarados, es decir, reconocidos y consagrados, por ley, y en todo caso es la ley la que debe fijar sus condiciones de ejercicio y reglamentar su ejecución y asegurar su sanción positiva»⁷⁵. Por eso, para Carré de Malberg, disposiciones como aquella contenida en la Constitución francesa de 1791 referida a que «el poder legislativo no podrá dictar leyes que lesionen el ejercicio de los derechos naturales y civiles» no son sino fórmulas retóricas y sin eficacia. Respecto a la propuesta que predica la innecesariedad de los límites autoimpuestos por el Estado, desde el momento en que la existencia de vínculos basados en la solidaridad social funciona como un mecanismo de reacción y resistencia frente a los excesos del estado, Carre de Malberg señala que esos mecanismos no constituyen objeto de atención por parte de la ciencia jurídica, son conceptos extrajurídicos, y el recurso a ellos «supone substituir

⁷⁴ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 231.

⁷⁵ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 227.

a los medios sacados de un orden jurídico preestablecido, (por) otros medios sin más fundamento que la indeterminación desordenada de las reacciones que puedan producirse en la masa de los individuos»⁷⁶. Por otra parte, la autolimitación (y, por tanto, la limitación jurídica) del Estado tampoco puede provenir de lo establecido por un Derecho natural, ya que sus criterios constituyen un límite «de orden moral o político, que no es susceptible de reducirse a fórmula jurídica o de expresarse en regla de Derecho»⁷⁷.

Pues bien, posiblemente la correcta interpretación de la propuesta de Carré de Malberg en este punto —por otra parte, exponente típico del positivismo continental de la primera mitad del siglo xx— exige alguna observación. En primer lugar, procede señalar que la afirmación de que los únicos límites jurídicos son los que el Estado se autoimpone no entra en contradicción con aquella otra según la cual existen otros límites que pueden ser predicados de la acción del Estado. En este caso estamos ante límites morales y políticos que pueden fundamentar juicios negativos respecto a la acción estatal. Y muchas veces pueden existir mejores razones morales y políticas a favor de estos límites que respecto a los jurídicos, que por su parte pueden, además, mostrar su ineficacia. En segundo lugar, y directamente conectado con lo anterior, Carré de Malberg es consciente de la posibilidad de que los límites autoimpuestos por el Estado estén afectados por un elevado nivel de precariedad: «el hecho de que la organización estatal entraña necesariamente ciertas limitaciones a la potestad del Estado no puede interpretarse en el sentido de que esas limitaciones, tomadas en su consistencia actual, son superiores a su voluntad y no pueden ser modificadas por él. Si el Estado se hallara así encade-

⁷⁶ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 228.

⁷⁷ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 229. Y añade: «Ahí está el error capital de los juristas que persisten en sostener la doctrina del 'derecho natural', error del que sería de desear se viera liberada de una vez por todas la ciencia del Derecho» (ibidem).

nado de una manera absoluta o inmutable por las limitaciones que rodean actualmente su potestad, ya no podría decirse que es soberano»⁷⁸. Es a esta precariedad a la que Rafael de Asís se ha referido cuando ha analizado las paradojas derivadas de la interpretación actual de la idea clásica según la cual los derechos fundamentales son un límite al Poder⁷⁹. Parece evidente que el hecho de que los límites de los que se predica eficacia jurídica sean el resultado, en cuanto a su existencia y en cuanto a su intensidad, de decisiones del Poder político, puede ser considerado como un aspecto en el que el modelo de autolimitación muestra, en su caso, una cierta debilidad. Estamos frente a la «paradoja de los derechos constitucionales» a la que se refiere Tuori: si las normas de derechos fundamentales son normas constitucionales, ellas también pueden ser modificadas o anuladas. Con lo cual cabe preguntarse cómo pueden llevar a cabo la función de limitación⁸⁰.

No obstante, el correcto funcionamiento del modelo de autolimitación, que se produce en aquellas ocasiones en las que el Estado se somete efectivamente a sus límites, permite observar que la eficacia de la subordinación del Estado a ciertos parámetros es posible en el marco del modelo. Esa eficacia, en su caso, no va a depender exclusivamente de las limitaciones impuestas por la Constitución formal, sino por la existencia de una «cultura constitucional» que constituya el contexto en el que se justifica y respalda la función limitadora de las normas de derechos fundamentales⁸¹. Por el contrario, el modelo de

⁷⁸ CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., p. 225.

⁷⁹ Vid. DE ASÍS ROIG, R. *Las paradojas de los derechos fundamentales como límites frente al Poder*, Dykinson, Madrid, 2000.

⁸⁰ Vid. TUORI, K., *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, cit., p. 252.

⁸¹ Vid. TUORI, K., *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, cit., p. 238. Creo que el planteamiento es coincidente con el de F. LAPORTA cuando subraya la importancia de la existencia de una «exigencia ética viva en la sociedad» como condición imprescindible de la limitación jurídica del Poder: «Lo que hace imposible el imperio de la ley y la consiguien-

heterolimitación es incapaz de asegurar la eficacia de los límites propuestos en su caso, desde el momento en que las propuestas normativas de referencia se caracterizan por su falta de eficacia jurídica⁸². Conviene recordar que los límites de los que se está hablando en el modelo de autolimitación son los normativo-jurídicos. Por otra parte, la aparente precariedad del modelo de autolimitación nos reconduce a otra cuestión, en la que nos detendremos a lo largo de estas líneas. Me refiero a la vinculación entre el Estado de Derecho y la democracia: el Poder democrático es el único en el que concurren las dimensiones morales y políticas que posibilitan el compromiso con las normas por él creadas. No obstante, es también en el marco de los sistemas normativos en donde el modelo de autolimitación plantea problemas evidentes como el referido a la justificación de las imposiciones a las que están sometidos los individuos y que han sido decididas por instancias anteriores a su voluntad. Michel Troper ha planteado el problema en términos claros al plantearse la cuestión de la autolimitación estatal: «La justificación de esta limitación dista por otra parte de ser clara, pues si estas reglas, las de una Declaración de derechos humanos por ejemplo, han sido dictadas por una voluntad humana, se comprende mal por qué, en una democracia, la voluntad de los hombres de hoy debería estar subordinada a la de los hombres de ayer»⁸³.

te limitación jurídica del soberano es la incorporación en la ética individual y social de las exigencias morales que ese ideal lleva consigo. (...) el problema del imperio de la ley es el de la existencia de una práctica social colectiva basada en una determinada educación ciudadana respecto a las exigencias éticas del ejercicio del poder», *El imperio de la ley. Una visión actual*, Trotta, Madrid, 2007, p. 81.

⁸² Se reproduce en este punto uno de los argumentos críticos que Bobbio, entre otros, dirigió al Derecho natural. Vid. BOBBIO, N., «Algunos argumentos contra el Derecho Natural», en VVAA., *Crítica del Derecho natural*, introducción y traducción de Elías Díaz, Taurus, Madrid, 1966, pp. 219 y ss.

⁸³ TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., p. 32. No profundizaré en esta cuestión ahora ya que sobre ella versará la última parte del trabajo.

Otra manera de afrontar la cuestión del carácter autorreferente del modelo de relación entre el Derecho y el Poder constituido por el Estado de Derecho es la que consiste en recurrir a un elemento no jurídico, situado extramuros del Ordenamiento, al que éste le debe su existencia. Pienso que es a dicho elemento al que alude Peces-Barba al hablar de un Hecho Fundante Básico que se encuentra tras el Ordenamiento, al que le presta su apoyo. Utilizando una terminología escogida para marcar claramente la diferencia con la norma fundante básica kelseniana y con el carácter normativo de la referencia última del Ordenamiento, Peces-Barba piensa en una realidad social y política compleja, reconducible al ejercicio del Poder, entendido éste en su sentido más amplio. Es este Poder el que constituye «el fundamento último de la validez de un sistema jurídico»⁸⁴.

Creo que el recurso a esa instancia —que bien puede ser identificada con el Hecho Fundante Básico en la terminología de Peces-Barba— tiene un valor explicativo y representativo de la realidad, que va más allá de su capacidad para romper la circularidad que parece representar el esquema de la relación entre el Derecho y el Poder en el Estado de Derecho. En efecto, la existencia y el funcionamiento —posible a partir de unas mínimas y necesarias dosis de eficacia— de un sistema jurídico, y no sólo de un sistema jurídico de un Estado de Derecho, se explica a partir de la existencia de una realidad social (en la que confluyen vertientes económicas, políticas, ideológicas...), que garantiza el mantenimiento del sistema jurídico. Esa realidad social, reconducible a la idea de Poder en sentido amplio⁸⁵,

⁸⁴ PECES-BARBA, G., «Reflexiones sobre Derecho y Poder», ID., *Libertad, Poder, Socialismo*, Cívitas, Madrid, 1978, p. 231. Estamos en presencia de un criterio empírico de validez vinculado a la capacidad última de coacción y que en mi opinión no se distanciaría mucho de la propuesta de M. D. FARRELL, con la salvedad de la perspectiva neopositivista lógica en la que éste se sitúa. Vid. *Hacia un criterio empírico de validez*, Astrea, Buenos Aires, 1972.

⁸⁵ Vid. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., *Poder, Ordenamiento jurídico, derechos*, cit., p. 44.

constituye el ámbito en que, como ha señalado Elías Díaz, radica la fuerza de la que el Derecho es expresión última: «La sociedad, el grupo, es quien (...) a través del denominado poder constituyente y luego a través fundamentalmente del Estado (...) crea el Derecho, las normas jurídicas». Y continúa: «La fuerza, pues, radica en última instancia en el grupo social (...). Aquel, el grupo, es quien atribuye y traspasa esa fuerza al Derecho, quien así lo define, con objeto de organizar de un modo u otro tal grupo y de resolver los conflictos que en él puedan surgir, regulando comportamientos individuales y relaciones sociales siempre con esa posibilidad de la fuerza, de la coacción-sanción, operando detrás. La fuerza está también, pues, en el origen del Derecho, en la misma sociedad»⁸⁶.

Esa realidad, ese Hecho Fundante Básico, se caracteriza porque su actuación no puede ser explicada en clave de resultado de la aplicación de una norma superior y anterior. Ese Hecho no forma parte de lo que podríamos considerar «el mundo del Derecho» ya que, como señala Jellinek, el acto del nacimiento del Estado «queda completamente fuera del Derecho»⁸⁷, si bien su presencia es imprescindible para el mantenimiento del sistema jurídico. Es este Hecho el auténtico y último Poder constituyente en sentido originario, que se distingue así del Poder constituyente derivado o regulado por normas jurídicas, que es el que se ejerce en el interior del Ordenamiento. De nuevo, en palabras de Elías Díaz, «el grupo originario, el poder social, actúa a estos efectos de manera originaria, aunque en

⁸⁶ DÍAZ, E., *Curso de Filosofía del Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 70.

⁸⁷ JELLINEK, G., *Teoría General del Estado*, cit., p. 270. En otro momento afirma: «en los más de los casos, la formación de los nuevos poderes del Estado descansa en hechos que excluyen toda posibilidad de una cualificación jurídica previa; (...) aún allí donde el origen de un Estado está preparado por un orden jurídico, ocurre (...) que el hecho mismo del nacimiento queda fuera del orden del derecho», *op. cit.*, p. 327. Vid. también, CARPIZO, J., «El Poder: su naturaleza y su tipología», *VVAA, Constitución y constitucionalismo hoy*, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2000, p. 837.

mayor o menor medida representado, condicionado e incluso transformado, a través hoy de las vías preferentes del que cabría calificar en sentido amplio como poder constituyente. Se trata, pues, de una producción social originaria del Derecho que, por lo demás y como influencia directa, siempre permanece después operante y latente impulsando cambios a través (aunque no sólo) de los procedimientos establecidos por el propio grupo, con posibilidad incluso de cambios en los propios procedimientos. Así, en ese poder social originario (hoy relativamente originario) es dónde y cómo con rupturas o reformas del pasado, se crea el Estado, sus leyes básicas, la constitución en su caso, el poder constituido, y con todo ello, el comienzo del ordenamiento jurídico»⁸⁸.

Peces-Barba señala que el Hecho Fundante Básico se mezcla con el Derecho a través de la relación que se establece entre aquel y la norma fundante básica⁸⁹. Estaríamos ante una expresión de la idea, expresada por Bobbio y a la que ya hemos aludido, según la cual el Derecho y el Poder son las dos caras de una misma moneda. Es precisamente en este punto en donde se presenta de forma más evidente la cuestión de la circularidad o de la autorreferencialidad. Pienso en este sentido que esa relación entre el Derecho y el Poder, que se presenta en términos de indispensabilidad respectiva, sólo se produce en el interior del sistema jurídico, es decir en el transcurso de la cadena de desarrollos normativos y habilitaciones que tiene lugar a partir de la norma superior del sistema. Pero, en realidad, la relación que se establece entre el Hecho Fundante Básico y la norma superior no se puede presentar como si estuviéramos ante las dos caras de la misma moneda, ya que es precisamente ese Hecho Fundante Básico el que está tras las normas últimas y detrás de ese Hecho Fundante no hay normas jurídicas: por

⁸⁸ DÍAZ, E., *Curso de Filosofía del Derecho*, cit., p. 86.

⁸⁹ Vid. PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, cit., p. 344.

eso se puede afirmar que no es el resultado de la aplicación de normas anteriores. Es decir, en el ámbito del Hecho Fundante Básico no estamos en presencia de un marco institucionalizado en el que se desarrollan las relaciones entre el Derecho y el Poder, marco que es el constituido precisamente por el Ordenamiento jurídico. Es a partir de la norma superior del Ordenamiento, de la Constitución, cuando se produce esa relación entre el Derecho y el Poder propia del modelo de coordinación, esa mezcla a la que alude Peces-Barba, pero no antes. En este sentido, es cierto que el Hecho Fundante Básico tiene dimensiones normativas o, más bien, puede asumir una determinada concepción normativa, pero, al constituir una realidad *exterior* al Ordenamiento, no se encuentra en una posición que pudiéramos considerar simétrica a la norma superior del Ordenamiento⁹⁰.

2. LA RELACION ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL EN EL ESTADO DE DERECHO. LA POSITIVACION DEL DERECHO NATURAL.

Como se ha indicado en los momentos iniciales de este trabajo, la cuestión de las relaciones entre el Derecho y la moral

⁹⁰ Al mismo tiempo, esa existencia exterior al Ordenamiento obliga a ser cuidadoso a la hora de marcar los paralelismos entre el Hecho Fundante Básico y la regla de reconocimiento hartiana que, en este caso sí, pertenece al Ordenamiento y forma parte del mismo. La regla de reconocimiento lleva a cabo funciones de identificación de los elementos del sistema jurídico, mientras que la función del Hecho Fundante Básico va más allá, desde el momento en que también llega a asegurar la eficacia del sistema en su conjunto. Sobre la relación entre el Hecho Fundante Básico y la regla de reconocimiento, vid. PECES-BARBA, G., «Prólogo», en PÁRAMO ARGÜELLES, J. R. de, *H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. XV-XXV; PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, cit., pp. 344 y ss; PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R., (eds.), *Curso de Teoría del Derecho*, (2ª edic.), Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 105.

es uno de los grandes problemas de la Filosofía del Derecho. Pero no sólo de la Filosofía del Derecho en sentido amplio, sino también de la Teoría del Derecho, ya que la conclusión a la que se llegue a la hora de enfocar y resolver la cuestión de la relación entre el Derecho y la moral va a condicionar necesariamente el concepto de Derecho que se defienda en su caso⁹¹. El concepto de Estado de Derecho con el que se trabaja en esta investigación está vinculado a una determinada manera de entender la cuestión de la relación entre el Derecho y la moral. Incluso se podría afirmar que el concepto material de Estado de Derecho no es sino expresión de un determinado modelo de relación entre el Derecho y la moral.

A continuación se mostrará la comprensión de la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral que se comparte en el trabajo, y se analizarán algunas de las posiciones que Habermas y Nino tienen en relación con esta cuestión. Si se ha elegido a estos autores es por dos razones básicas: en primer lugar, han dedicado reflexiones al sentido del Estado de Derecho y del Estado constitucional; en segundo lugar, asumen la importancia de la presencia de contenidos morales en el Derecho, lo cual les sitúa en una relación de familiaridad con las notas distintivas del Estado de Derecho. A través del repaso de las aportaciones de ambos autores podremos observar la existencia de relaciones funcionales y prácticas entre el Derecho y la moral.

Pero, antes, me parece interesante mostrar las grandes líneas de la recepción de los planteamientos morales en el Estado de Derecho. La tesis según la cual en el Estado de Derecho asistimos a una constitucionalización del Derecho natural puede sernos de utilidad al respecto.

Conocida es, en este sentido, la caracterización del Estado de Derecho propuesta por Luigi Ferrajoli. No es mi intención

⁹¹ Tema «transversal», de acuerdo con la expresión utilizada por L. PRIETO SANCHÍS en «Sobre las relaciones entre el Derecho y la moral: una crítica del constitucionalismo ético», en ID., *El constitucionalismo de los derechos*, cit., p. 103.

en este momento exponerla en su conjunto —ya que volveré sobre ella en un momento posterior—, sino subrayar aquellos aspectos de la misma que están más vinculados al modelo de relación entre el Derecho y la moral que estamos comentando.

Precisamente Ferrajoli sitúa la distinción ilustrada entre el Derecho y la moral en el origen de la moderna idea de Estado de Derecho. Para él, la tesis según la cual no existe una conexión necesaria entre ambos órdenes normativos se puede descomponer en dos afirmaciones: por una parte, aquella según la cual el Derecho «no reproduce ni tiene la misión de reproducir los dictámenes de la moral o de cualquier otro sistema metajurídico —divino, natural o racional— de valores ético-políticos, sino que es sólo el producto de convenciones legales no predeterminadas ontológica ni tampoco axiológicamente»; por otra, la que afirma «la autonomía de la moral respecto al derecho positivo o a cualquier otro tipo de prescripciones heterónomas y su consiguiente concepción individualista y relativista: los preceptos y los juicios morales, con arreglo a esta concepción, no se basan en el derecho ni en otros sistemas de normas positivas —religiosas, sociales o de cualquier otro modo objetivas—, sino sólo en la autonomía de la conciencia individual»⁹². A partir de ahí, asistimos a una historia en la que los referentes morales, muchas veces en forma de derechos naturales, han desempeñado una función de legitimación externa del material jurídico. Así, esos referentes morales se diferenciaban netamente de los criterios de legitimación interna, que tomaban como referencia parámetros de valoración intrasistemáticos. Precisamente la *novedad histórica* del Estado de Derecho consiste precisamente, tal y como la presenta Ferrajoli, en la incorporación jurídica de gran parte de las que hasta un determinado momento fueron exclusivamente las fuentes de legitimación externa, compartiendo, a partir de ahí, carácter intrasistemático⁹³. Entre las múltiples

⁹² FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 218.

⁹³ Vid. FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 354.

consecuencias que se derivan de la conversión de los criterios de legitimación externa en criterios de legitimación interna se encuentra una determinada concepción de la validez, no exclusivamente formal. Una concepción formal «resulta totalmente insuficiente en los modernos Estados constitucionales de derecho en los que la validez de las normas (...) reside en su conformidad no sólo formal sino también sustancial con normas de rango superior, que no sólo regulan las formas, sino que también dictan limitaciones de contenido al ejercicio del poder normativo. En estos ordenamientos la validez no depende sólo de los aspectos formales de la producción normativa que permiten afirmar el «ser» o la existencia de las normas; depende igualmente del significado de los enunciados normativos producidos, y más exactamente de la conformidad de su contenido con el «deber ser» jurídico establecido por normas superiores»⁹⁴.

Así caracterizado, el Estado de Derecho constituye un escenario en el que se reproduce un modelo de relación entre el Derecho y la moral compatible con la tesis de la separación conceptual entre Derecho y moral correcta, entre otras cosas porque estamos frente a un contexto contingente, relativo a la situación específica de determinados ordenamientos, que por tanto es diferente al plano conceptual en el que se pretende operativa la tesis⁹⁵.

La opción a favor de un determinado concepto de Estado de Derecho, el material, supone reconocer que no todo Estado es un Estado de Derecho. Por tanto, supone reconocer la contingencia de la relación entre el Derecho y una determinada propuesta moral. Es cierto que el Ordenamiento de un Estado de Derecho positiviza determinados contenidos morales y no

⁹⁴ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 355.

⁹⁵ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Presupuestos ideológicos y doctrinales de la justicia constitucional» en ID., *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Trotta, Madrid, 2003, pp. 97-98. ID., «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos», cit., p. 55.

otros; pero la ausencia de dicha positivación o incluso el rechazo explícito de esos contenidos no implica la negación del carácter jurídico de tal sistema normativo.

La propuesta moral asumida por el Estado de Derecho se diferencia de otras propuestas, ya que está basada en los derechos fundamentales y en los valores de la democracia. Estos contenidos, insertados en el mundo del Derecho mediante su positivación, tienen una importante relevancia moral, y demuestran que en el caso del Estado de Derecho no es posible hablar de neutralidad moral. Por otra parte, el Estado de Derecho, a partir de la inclusión de determinados contenidos morales, constituye un buen ejemplo de transformación de moral crítica en moral legalizada.

2.1. La tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral correcta

El punto de partida y, al mismo tiempo, la posición que aquí se entiende como aceptable en relación con el problema de la relación entre el Derecho y la moral se identifica con la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral, tal y como ha sido defendida por Hart. Esta tesis, identificada como uno de los postulados básicos del positivismo jurídico en su versión metodológica, afirma que «en ningún sentido es necesariamente verdad que las normas jurídicas reproducen o satisfacen ciertas exigencias de la moral, aunque de hecho suele ocurrir así»⁹⁶; «...aunque existen numerosas e importantes conexiones entre el Derecho y la moralidad, de modo que frecuentemente hay una coincidencia o solapamiento «de facto» entre el Derecho de algún sistema y las exigencias de la Mora-

⁹⁶ HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, trad. de G. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 230. Vid también ID., «Positivism and the Separation of Law and Morals», ID., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1983, pp. 49 y ss.

lidad, tales conexiones son contingentes, no necesarias lógicamente conceptualmente»⁹⁷.

El Derecho y la moral son posiblemente los dos sistemas normativos que regulan de manera más eficiente las conductas humanas. Sabido es que en esta regulación concurren con otros sistemas normativos como las reglas del trato social, y también con otros sistemas, que sin ser estrictamente normativos (al menos en el sentido en el que lo son el Derecho y la moral), también ejercen una notable presión e influencia sobre nuestras conductas: la cultura, la política, la economía, por citar algunos. Estos sistemas no son normativos en la medida en la que lo es el Derecho, pues en términos generales no están constituidos por enunciados de deber ser. Tampoco es claro que su intención sea la de ordenar de acuerdo con determinados criterios o pautas las conductas humanas, al menos en el sentido en el que el Derecho y la moral lo hacen.

Tanto el Derecho como la moral coinciden en gran medida en el ámbito de regulación al que están referidas sus normas. Este ámbito está constituido en términos generales por las conductas humanas en sociedad, o con trascendencia social. En la regulación de dichas conductas concurren el Derecho y la moral. En este sentido, podemos decir que es difícil identificar ámbitos de conducta, bien diferenciados, de exclusiva regulación, sea por las normas jurídicas, sea por las normas morales. En relación con las conductas reguladas, encontramos un gran número de ellas que lo son tanto jurídica como moralmente, y en los extremos del escenario encontramos conductas, o dimensiones de la existencia humana, reguladas solamente por normas morales (posiblemente aquellas más intimamente vinculadas a la individualidad) y otras reguladas exclusivamen-

⁹⁷ HART, H. L. A., «El nuevo desafío al positivismo jurídico» (trad. de L. Hierro. F. Laporta y J. R. de Páramo), *Sistema*, 36, 1980, p. 4. J. Una defensa de esta tesis es la de J. DORADO PORRAS, *Iusnaturalismo y positivismo jurídico: una revisión de los argumentos en defensa del iuspositivismo*, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 77 y ss.

te por normas jurídicas (aquellas que no son susceptibles de ser valoradas de acuerdo con criterios de bondad o maldad moral).

El Derecho y la moral constituyen sistemas normativos, pertenecen a la esfera del deber ser. Quiere decirse con ello, entre otras cosas, que tanto uno como otra constituyen atalayas de valoración de las conductas humanas respectivamente reguladas. En este sentido, no existe un Ordenamiento jurídico, precisamente debido a su naturaleza normativa, neutro desde el punto de vista axiológico. Imaginar un sistema normativo de este tenor supondría hacer referencia a un sistema que intenta regular conductas sin referencia alguna a criterios de valoración. La mera regulación de las conductas por parte de un sistema jurídico implica la distinta valoración de unas u otras conductas a la luz de determinados criterios de corrección, que son los asumidos por el Ordenamiento jurídico. La imprescindible existencia de esos criterios —tengan el contenido que tengan— supone que el Ordenamiento valora conductas de acuerdo con criterios de corrección o maldad. Hay, para el Ordenamiento jurídico, conductas correctas (queridas o permitidas por el sistema) y conductas incorrectas (no queridas o prohibidas por el sistema). Por tanto, todo sistema jurídico supone una toma de posición sobre lo bueno y lo malo, asume una perspectiva moral o, dicho desde otro punto de vista, es expresión de una opción moral. En palabras de Legaz, el Derecho definido descriptivamente supone la realización de «un punto de vista sobre la justicia»⁹⁸. Afirmar la existencia de

⁹⁸ LEGAZ LACAMBRA, L., *Filosofía del Derecho*, cuarta edición, Bosch, Barcelona, 1975, p. 295. Creo que se puede asumir la prevención expresada por Legaz en relación con el subjetivismo implícito en la idea de «punto de vista». Es evidente que el punto de vista al que se alude aquí no es el del individuo particular, sino el del Poder que crea Derecho. Por el contrario, no creo que de lo anterior se pueda derivar la afirmación de que «... en todo caso, el Derecho no es Derecho por *expresar* una opinión subjetiva o intersubjetiva sobre lo que es justo, sino por *ser* una realización de la justicia, por tener sentido de justicia» (*ibidem*). El hecho de ser vehículo de una determinada idea de justicia puede ser un rasgo definitorio del Derecho, aunque no definitivo.

un sistema jurídico neutro desde el punto de vista moral supondría afirmar que puede existir un sistema jurídico (una de cuyas funciones básicas es precisamente la de regular conductas) que pretendería regular conductas careciendo precisamente de criterios de acuerdo con los cuales algunas de estas son preferibles a otras. Y esto, parece evidente, supondría un sinsentido en relación con la idea misma de Derecho, pero no en tanto que sistema jurídico, sino en tanto que sistema normativo, ya que «la delimitación misma de lo prohibido, ordenado o permitido revela siempre la adopción de un cierto punto de vista sobre la moralidad»⁹⁹. Por tanto, el Derecho, como sistema normativo llamado a regular conductas, asume, es expresión de, planteamientos morales, con independencia del juicio de corrección/incorrección moral que podamos emitir respecto a estos.

Si todo Ordenamiento jurídico es expresión de planteamientos morales, se podría pensar que entonces no es válida la tesis de la separación conceptual. Parecería —alguien podría concluir— que la afirmación según la cual todo Ordenamiento jurídico expresa un punto de vista moral entra en directa contradicción con el desarrollo de la tesis de la separación conceptual entre Derecho y moral, según la cual la identificación de los materiales jurídicos no depende de la concurrencia de contenidos morales. Se diría: si se ha señalado que esa concurrencia es necesaria, entonces no es cierto que Derecho y moral sean completamente diferentes o independientes. Por el contrario, una determinada, y asimismo adecuada, interpretación de la tesis de la separación conceptual (por otra parte adecuada al sentido de lo expuesto por un positivismo que bien pudiéramos considerar como inteligente y no ciego

Lo cual supone una contradicción con la tesis mantenida en la anterior cita, a no ser que la noción de justicia a la que alude Legaz carezca de contenido determinado alguno.

⁹⁹ PRIETO SANCHÍS, L., «Sobre las relaciones entre el Derecho y la moral: una crítica del constitucionalismo ético», cit., p. 107.

ante la realidad del Derecho) es aquella que afirma la no necesaria conexión conceptual entre el Derecho y la moral *considerada correcta*. Robert Alexy ha diferenciado dos versiones de la tesis de la conexión necesaria entre el Derecho y la moral¹⁰⁰. Así, la versión *débil*, señala que existe una relación necesaria entre el Derecho y *alguna* moral. Por su parte, la versión *fuerte* afirma la relación necesaria entre el Derecho y la moral *correcta*. Alexy denomina a la versión débil, la ‘tesis moral’. No parece que la tesis débil suponga la negación de la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral, siempre y cuando estemos hablando de moral correcta. De la misma manera, no creo que, al contrario de lo que afirma Alexy, la tesis débil sirva para demostrar la conexión necesaria entre el Derecho y la moral, por lo menos en el sentido que a dicha propuesta ha querido darle el iusnaturalismo, y que ha estado vinculada a la afirmación de la necesaria evaluación moral positiva que merece el Ordenamiento a partir de su concurrencia con la moral, identificada con el Derecho natural. En definitiva, no parece existir contradicción entre la concepción de la conexión entre el Derecho y la moral que se mantiene en estas líneas, y que reconoce su ascendencia positivista, y la tesis débil, tal y como es presentada por Robert Alexy. Afirmar que en un Ordenamiento siempre vamos a encontrar planteamientos morales (es decir, planteamientos sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto o lo incorrecto moral, sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer) no implica afirmar: 1) que esos planteamientos morales deben ser necesariamente unos concretos y no otros; y 2) que esos planteamientos morales son correctos desde el punto de vista de una moral crítica o esclarecida. Aquí se observa claramente que la existencia de dimensiones morales en el Derecho no implica necesariamente corrección moral.

La distinción entre moral como estructura y moral como contenido desarrollada en su momento por José Luis López

¹⁰⁰ Vid. ALEXY, R., *El concepto y la validez del Derecho*, cit., p. 79.

Aranguren¹⁰¹, puede servir de manera adecuada para explicar la tesis asumida aquí y referida al carácter moral del Derecho y a la no necesaria identificación del Derecho con la moral considerada correcta. La siguiente cita, si bien es extensa, resume en mi opinión la posición de Aranguren: «En el hombre no se da la ajustada adecuación animal entre los estímulos y las respuestas. El hombre, antes de ejecutar un acto cualquiera, tiene que considerar sus posibilidades, esto es, tiene que moverse en la irrealidad. El ajustamiento o adecuación no se hace, como en el animal, directamente de realidad a realidad, sino a través de la *posibilidad* y la *libertad*. En una palabra, al animal le está dado, con sus estructuras biológicas, el ajustamiento; el hombre, por el contrario, tiene que hacer ese ajustamiento, tiene que *iustum facere* o *justificar* sus actos, y por eso, quiera o no, es siempre moral. Sobre las estructuras biológicas lleva montada una indeclinable estructura moral, el *genus moris* comprende lo mismo los comportamientos honestos que los impropriamente llamados «inmorales», porque es previo a esta especificación. La moral es así, por de pronto, una estructura o conjunto de estructuras que pueden y deben ser analizadas de modo puramente teórico. No se trata simplemente de que sea posible una psicología de la moralidad y ni siquiera de una fenomenología de la conciencia moral. No. Es que la segunda dimensión, moral como contenido, moral normativa, tiene que montarse necesariamente sobre la primera. Precisamente porque al hombre no le es dado por naturaleza el ajustamiento a la realidad, sino que tiene que hacerlo por sí mismo («justificación»), cobra sentido demandarle que lo haga conforme a determinadas normas, conforme a determinado sistema de preferencias. Precisamente, porque puede preferir, porque tiene necesidades que preferir, cabe señalarle una jerarquía de bienes; y se le imponen

¹⁰¹ Distinción sobre la que puede consultarse el libro de C. HERMIDA DEL LLANO, J. L. L. Aranguren. *Estudios sobre su vida, obra y pensamiento*, Dykinson-Universidad Carlos III de Madrid, 1997, pp. 189 y ss.

deberes porque es —para usar la expresión de Zubiri— una realidad ‘debitoria’»¹⁰².

En efecto, Aranguren, siguiendo en este punto a Zubiri, identifica la moral como estructura vinculándola a «una estructura radical del comportamiento humano, que es la del ajustamiento del acto a la situación»¹⁰³. En realidad, en eso consiste la justificación del acto, que es lo que hace que las acciones humanas sean verdaderamente humanas. En este sentido, justificado es aquel acto que está ajustado a la realidad. Aquí Aranguren emplea el concepto de justificación como ajustamiento. Junto a esto, la justificación tiene otro sentido, justificación como justicia, que implica que el acto humano debe ajustarse, ya no a la realidad, sino a la norma ética (sea ésta cual sea: fin último, ley natural, conciencia moral...). Esta justificación se identifica con la moral como contenido. Ambas dimensiones, la moral como estructura y la moral como contenido, están vinculadas entre sí: «...la moral como contenido se monta necesariamente sobre la moral como estructura y no puede darse sin ella. Precisamente porque al hombre no le es dado por naturaleza el ajustamiento a la realidad, sino que tiene que hacerlo por sí mismo, cobra sentido demandarle que lo haga, no arbitraria o subjetivamente, sino conforme a determinadas normas, conforme a determinados sistemas de preferencias»¹⁰⁴. La moral como estructura constituye la «forma moral» que ha de ser llenada con la materia moral (moral como contenido)¹⁰⁵.

La distinción entre moral como estructura y moral como contenido —que Aranguren completa con la alusión a la moral como actitud— se nos muestra, por tanto, como extraordinariamente útil para explicar la posición que aquí se defiende respecto a la cuestión de la relación entre el Derecho y la moral.

¹⁰² LÓPEZ ARANGUREN, J. L., «La enseñanza de la ética», ID., *Ética de la felicidad y otros lenguajes*, Tecnos, Madrid, 1989, p. 20.

¹⁰³ LÓPEZ ARANGUREN, J. L., *Ética*, Alianza Universidad, 1994, p. 49.

¹⁰⁴ LÓPEZ ARANGUREN, J. L., *Ética*, cit., p. 50.

¹⁰⁵ Vid. LÓPEZ ARANGUREN, J. L., *Ética*, cit., p. 54.

En este sentido, de acuerdo con Eusebio Fernández¹⁰⁶, se pueden defender las siguientes tesis: 1) el hombre es estructuralmente moral; 2) el Derecho, obra humana, es estructuralmente moral; 3) en relación con su contenido, el Derecho puede ser moral o inmoral.

En efecto, el punto de partida es el de la conexión entre lo humano y lo moral. Aranguren señalaba, de un lado, que «el hombre es constitutivamente moral»¹⁰⁷ y, de otro, que «la realidad moral es constitutivamente humana»¹⁰⁸. Ese carácter moral necesariamente se traslada al Derecho que se convierte así en un vehículo de opciones morales. Por eso, el Derecho se nos presenta como estructuralmente moral. Eusebio Fernández se plantea la cuestión: ¿Por qué todo Derecho es estructuralmente moral?. Y responde: «Porque todo ordenamiento jurídico representa un punto de vista sobre la justicia, es decir, sobre lo moralmente justo, y al mismo tiempo está traduciendo o expresando, a través de normas jurídicas, una cierta legitimidad que le sirve de justificación»¹⁰⁹. De la misma manera que, de acuerdo con Aranguren, la forma moral se debe rellenar con la materia moral, en el Derecho, la estructura moral que significa éste, se llena con contenidos morales: «... respecto a su contenido, el Derecho puede ser moral o inmoral ya que toda legalidad, es decir, toda legitimidad legalizada, puede ser evaluada como moral o inmoral desde un punto de vista sobre la justicia que exprese la idea de una legitimidad justa. Si esta legitimidad justa está recogida en la legitimidad legalizada, podremos hablar de Derecho justo o moral; si ocurre el caso contrario nos referi-

¹⁰⁶ Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Ética, Derecho y política ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?, ID., *Filosofía Política y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 23-25; ID., «El Derecho y otros órdenes normativos», en PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R., (eds.), *Curso de Teoría del Derecho*, cit., pp. 67 y ss.

¹⁰⁷ LÓPEZ ARANGUREN, J. L., *Ética*, cit., p. 50.

¹⁰⁸ LÓPEZ ARANGUREN, J. L., *Ética*, cit., p. 47.

¹⁰⁹ FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Ética, Derecho y política ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?, cit., 23.

remos a ese Derecho como injusto o inmoral»¹¹⁰. Lo anterior supone adoptar una perspectiva descriptiva que debe ser en este punto claramente diferenciada de planteamientos prescriptivos o normativos. Parafraseando a Eusebio Fernández, el Derecho siempre se basa en una ética, aunque esa ética no siempre sea la correcta, no siempre sea aquella en la que, desde un punto de vista normativo, el Derecho se debe basar.

2.2. Las conexiones entre el Derecho y la moral. Análisis de la propuesta de Habermas

El carácter normativo compartido y la concurrencia en los ámbitos regulados explican la existencia de conexiones entre las normas morales y las normas jurídicas. La afirmación de dichas conexiones no entra en colisión con la tesis de la separación conceptual. La conexión entre el Derecho y la moral se puede enfocar, al menos, desde tres puntos de vista: a) la afirmación de la relevancia moral de lo establecido en las normas jurídicas; b) la coincidencia de planteamientos entre las normas jurídicas y las normas morales; c) la influencia de planteamientos morales en los procesos de producción, interpretación y aplicación del Derecho. La situación que se presenta ante nuestros ojos es, en palabras de Habermas, la de un «simultáneo entrelazamiento de Derecho y moral»¹¹¹. Detengámonos en estos tres puntos.

a) Cuando se alude a la cuestión de la relevancia moral de lo establecido por el Derecho, se quiere decir, como ya se señaló anteriormente, que los contenidos de las normas jurídicas son evaluables desde el punto de vista moral. En efecto, lo mandado, prohibido o permitido por las normas jurídicas no es inmune al análisis moral, siendo además expresión —ya se ha

¹¹⁰ FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Ética, Derecho y política ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?, cit., p. 24.

¹¹¹ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 559.

dicho— de una opción moral. Las normas jurídicas, por sus contenidos en sí, o por los fines que se proponen alcanzar a través de esos contenidos, pueden ser evaluadas moralmente, esto es, de acuerdo con criterios de bondad o maldad. Las normas jurídicas tienen relevancia moral, especialmente importante y evidente en ciertas esferas del Derecho. En este sentido se ha afirmado la existencia de una conexión *práctica* necesaria entre el Derecho y la moral, «en el sentido de que toda norma y toda decisión judicial son moralmente relevantes en tanto en cuanto tienen efectos sobre la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas»¹¹². No obstante, estos efectos no son de la misma intensidad en función de las normas o de la zona del Ordenamiento jurídico a que nos refiramos. En concreto, el efecto irradiación de las normas de derechos fundamentales al que ha aludido Robert Alexy es, desde este punto de vista, también efecto irradiación de los contenidos morales básicos —asumidos por un determinado sistema jurídico— a lo largo y ancho del Ordenamiento¹¹³.

b) Por otra parte, la cuestión de la coincidencia o no de los planteamientos de las normas jurídicas y de los de las normas morales puede ser analizada a partir de la distinción entre moral crítica y moral legalizada (positivizada). En efecto, las normas morales, ya pertenezcan a la moral personal o individual, ya pertenezcan a la moral colectiva o social, pueden estar en relación con el Derecho en alguna de las dos siguientes situaciones. Podemos aludir, en primer lugar, a la moral crítica, que es aquella que no ha sido recibida por el Derecho. Son variadas las circunstancias que pueden explicar esa no recepción. En todo caso, lo que importa en este caso es que el Derecho no asume determinados planteamientos morales que, por tanto, carecen de fuerza jurídica. Es evidente que, en

¹¹² Vid. LA TORRE, M., *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, cit., p. 325.

¹¹³ Vid. ALEXY, R., *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 507 y ss.

una situación en la que existe un Ordenamiento jurídico válido y eficaz, esta situación no es *cómoda* para ese planteamiento moral, ya que podríamos decir que está en una situación de desventaja respecto a los contenidos morales incluidos en las normas jurídicas, por lo que se refiere al apoyo de la fuerza del Estado. Así, toda propuesta o conjunto de propuestas de moral crítica, pugnan por ser positivizadas, reconocidas y asumidas por el Ordenamiento jurídico. Es a partir de ese momento, del momento de la juridificación, cuando a la fuerza moral se le añade la fuerza jurídica. Podemos afirmar, así, que «lo mejor» que le puede pasar a una propuesta de moral crítica, en lo que se refiere a su efectividad social, es convertirse en moral legalizada¹¹⁴. Sólo a partir de ese momento, las normas morales se convierten, además, en normas jurídicas, recibiendo la fuerza y el apoyo del Estado en orden a su cumplimiento. A nadie se le sanciona jurídicamente por incumplir una norma meramente moral, a no ser que esa norma sea a la vez, jurídica. En los sistemas de moral crítica observamos, así, una vocación de convertirse en moral legalizada, en orden a extender y a dotar de eficacia social, su proyecto normativo. En mi opinión, un buen ejemplo al respecto es el constituido por la actitud de la jerarquía de determinadas confesiones religiosas allí donde —por razones históricas, culturales— alcanzan un determinado grado de implantación social: muy a menudo pugnan y presionan para que el Ordenamiento jurídico, mediante la decisión del Poder político, positivice sus planteamientos, dotándolos así de vinculatoriedad jurídica extendida en el grupo social en el que ese Ordenamiento es imperativo. La moral crítica se convierte, por tanto, en moral legalizada, cuyas normas comparten carácter moral y jurídico.

¹¹⁴ En sentido contrario, para una reivindicación de la infelicidad como posibilidad moral de no integración en el sistema jurídico y político, vid. ZANETTI, G., *Political Friendship and the Good Life. Two Liberal Arguments against Perfectionism*, Kluwer Law International, 2002.

Por otra parte, hay que reconocer también que lo que podríamos considerar «la suerte del Derecho» (en términos de eficacia), el éxito del proyecto de organización social contenido en un Ordenamiento jurídico, no es absolutamente independiente de las relaciones que dicho Ordenamiento establece con la moral social. En efecto, el éxito del control social ejercido por el Derecho tiene muchas más posibilidades de producirse si el sistema jurídico no está en abierta contradicción con las pautas culturales básicas (de las que formaría parte la moral) del grupo regulado. Va a ser esa no contradicción la que, entre otros factores, permita generar un cierto consenso alrededor del sistema jurídico. Ese consenso — del que deriva un reconocimiento del carácter vinculante del Derecho — es necesario en principio para el funcionamiento del sistema jurídico; pero sólo en principio, ya que como nos ha recordado Bobbio, el déficit de consenso (y los problemas de aplicación y de eficacia subsiguientes) se puede superar a través a través de la ejecución de grandes dosis de fuerza¹¹⁵. La necesaria adecuación entre los contenidos de las pautas morales básicas del grupo y la propuesta moral asumida por el sistema jurídico serían expresión, en el sentido señalado, de la conexión *funcional* entre el Derecho y la moral¹¹⁶.

c) Tanto en los procesos de creación, como en los de interpretación y aplicación de normas jurídicas, se refleja la presencia de planteamientos morales. Ello no es sino consecuencia del hecho de que la regulación de los comportamientos humanos responde siempre a la presencia de valoraciones, deliberaciones y decisiones morales. En realidad, la misma decisión de regular determinados comportamientos puede ser ya una decisión expresión evidente de un planteamiento moral, moralista, perfeccionista o paternalista en su caso. Por ejemplo la opción

¹¹⁵ Vid. BOBBIO, N., *Teoría General del Derecho*, trad. de E. Rozo Acuña, Debate, Madrid, 1991, p. 137.

¹¹⁶ Vid. LA TORRE, M., *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, cit., p. 325.

a favor de la regulación jurídica —sea en el sentido que sea—, de determinadas dimensiones de la existencia humana tiene tras de sí no sólo una determinada concepción del individuo, sino también una concreta visión del modo más adecuado de regular las relaciones entre lo público y lo privado, y una propuesta acerca de la delimitación de los ámbitos de lo privado que pueden ser afectados por decisiones públicas.

La presencia, e influencia, de planteamientos morales en los procesos de producción normativa es evidente, siendo en ocasiones más fácilmente identificable en función no sólo de la materia regulada, sino también dependiendo del escalón en la jerarquía de las normas en el que nos encontremos. Así, en un texto constitucional existen partes como las referidas a la regulación de los derechos y libertades, o como las que reflejan los contenidos axiológicos máximos asumidos por el sistema (piénsese en los arts. 1.1 y 10.1 de la Constitución Española) que son directo reflejo de los valores morales asumidos y compartidos por el constituyente en un determinado contexto histórico. Es más, la opción del constituyente a favor de la regulación de ciertas materias a través de normas que permiten más posibilidades interpretativas que otras (como pueden ser los principios en relación con las reglas), puede ser entendida como una señal de que el legislador es consciente de que determinadas regulaciones pueden ser interpretadas de distintas maneras como expresión de diferentes planteamientos morales. Una vez superada la concepción exegética de la función del intérprete y del aplicador del Derecho, producido el reconocimiento del espacio de discrecionalidad en el que se mueve el operador jurídico en estos casos, podemos admitir la presencia y la operatividad de valoraciones morales en estos ámbitos.

Cabe recordar que Habermas ha señalado que la cuestión de las relaciones entre el Derecho y la moral debe analizarse en términos de *complementariedad*¹¹⁷ entre ambos. Derecho y moral no constituyen órdenes normativos extraños respectiva-

¹¹⁷ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 171.

mente, sin ámbitos de confluencia. El desarrollo de los procesos de diferenciación, iniciados cuando quiebra el modelo tradicional que confundía ambos órdenes normativos, no implica el desconocimiento de la coincidencia del Derecho y la moral por lo que se refiere al ámbito de cuestiones sobre las que se ejerce su normatividad; en efecto, ambos se refieren a problemas tales como «el de cómo ordenar legítimamente las relaciones interpersonales y cómo coordinar entre sí las acciones a través de normas justificadas, el de cómo solucionar consensualmente los conflictos de acción sobre el trasfondo de principios normativos y reglas intersubjetivamente reconocidos»¹¹⁸.

Para Habermas, la inclusión de contenidos morales en el Ordenamiento jurídico produce un efecto de *exoneración moral* de los individuos, desde el momento en que las exigencias que anteriormente se dirigían a los individuos ahora se dirigen a las leyes: «Si se introduce el derecho como la complementación que en orden a estabilizar expectativas de comportamiento necesita la moral, la facticidad de la producción del derecho (así como la autoaplicación constructiva del derecho) son elemento esencial de una determinada clase de interacciones que sirven a exonerar a la moral»¹¹⁹.

Pese a que el Derecho y la moral se refieren en ocasiones a las mismas cuestiones, las aproximaciones que se producen desde estas dos perspectivas son diferentes. Las cuestiones morales tienen como referencia la humanidad, lo cual implica que las razones decisorias adoptadas de acuerdo con criterios morales deben poder ser aceptadas por cualquiera; por su parte, las cuestiones ético-políticas a las que intentan ofrecer criterios de solución las normas jurídicas, se refieren a determinadas comunidades. Junto a esto, señala Habermas, mientras que la moral post-tradicional es una «forma de saber cultural», el Derecho tiene obligatoriedad en ámbitos institucionales, funcionando no sólo como un sistema de símbolos, sino también

¹¹⁸ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 171.

¹¹⁹ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 184.

como un «sistema de acción». Esta doble cualidad del Derecho —sistema de símbolos y sistema de acción— es importante para explicar esa exoneración moral de los individuos a la que alude Habermas.

Una moral racional no positivizada somete al individuo a tres tipos de exigencias: cognitivas, motivacionales y organizativas. Cuando Habermas se refiere a las exigencias cognitivas piensa en los problemas que se derivan de las dificultades de fijación de los materiales normativos en el ámbito de la moral racional. En el caso de cuestiones complejas, «los problemas de fundamentación y aplicación desbordan a menudo la capacidad analítica del individuo»¹²⁰. La «indeterminidad cognitiva» que caracteriza a la moral racional se ve contrastada y superada por la determinación de la respuesta jurídica derivada de la positivación, de la facticidad que significan los procesos de creación y fijación del Derecho, de manera que «desde el punto de vista de la complementariedad de derecho y moral, el procedimiento parlamentario de producción legislativa, la praxis institucionalizada de las decisiones judiciales y el trabajo profesional de una dogmática jurídica que precisa las reglas y sistematiza las decisiones, significan para el individuo un alivio y descarga frente a las cargas cognitivas que representa para él tener que formarse sus propios juicios morales»¹²¹. La moral racional, per se, es incapaz de superar la «incertidumbre motivacional» que puede afectar al individuo que se propone actuar de acuerdo con normas morales, cuyos contenidos pueden entrar en conflicto con sus intereses o inclinaciones. También aquí la facticidad de la producción jurídica contribuye a superar esa incertidumbre: «una moral racional en la medida en que no esté suficientemente anclada en los motivos y actitudes de sus destinatarios, depende de un derecho que imponga coercitivamente el comportamiento conforme con la norma, dejando al arbitrio del agente motivos y actitudes. El derecho

¹²⁰ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 181.

¹²¹ *Ibidem*.

coercitivo dota a las expectativas normativas de amenazas de sanción, de suerte que los destinatarios pueden restringirse a consideraciones de prudencia acerca de las consecuencias que para sus intereses van a tener sus acciones»¹²². En fin, en relación con las exigencias organizativas, el Derecho presenta capacidades para superar las carencias organizativas y administrativas que pueden dificultar de manera importante la materialización de los contenidos y de las exigencias de la moral racional. Para Habermas, el Derecho, a diferencia de la moral racional, y precisamente como consecuencia de la presencia de normas secundarias atributivas de roles y competencias, «puede establecer competencias y fundar organizaciones, puede establecer un sistema de asignación de obligaciones que no sólo se refiera a personas jurídicas naturales o físicas, sino también a sujetos jurídicos ficticios, como son organismos e institutos»¹²³. De lo que se trata, en definitiva, según Habermas, es de que el Derecho constituye un complemento funcional de la moral, ya que «puede compensar las debilidades de una moral exigente que, sin embargo, cuando se consideran las consecuencias empíricas, solo proporciona resultados cognitivos indeterminados y motivacionalmente inciertos»¹²⁴. Pero, además, la complementariedad del Derecho respecto a la moral, importante a partir de las carencias e incertidumbres de la moral, puede ser justificada moralmente. La exigibilidad

¹²² *Ibidem*.

¹²³ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 182.

¹²⁴ HABERMAS, J., «El vínculo interno entre Estado de Derecho y Democracia», ID., *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*, trad. de J. C. Velasco Arroyo y G. Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999, p. 251. En palabras de J. A. GARCÍA AMADO, «el derecho satisface una función de garantía última para los casos en que el vínculo racional que dimana de las normas válidas no sea bastante para mover las conductas de todos y, con ello, para asegurar la generalidad de las expectativas de comportamiento en la sociedad», «Habermas y el Derecho», en GARCÍA AMADO, J. A., (coord.). *El Derecho en la teoría social. Diálogo con catorce propuestas actuales*, Dykinson, Madrid, 2001, p. 381.

de una norma está en función del hecho de que los otros individuos se comporten cumpliendo también la norma. Sólo a partir de ahí es posible comenzar la tarea de justificación de la norma. Y esta es una condición, la de la consecución de la eficacia generalizada, respecto a la cual la moral se muestra impotente en relación con el Derecho. Por eso, «como de las convicciones morales no cabe esperar que cobren para todos los sujetos una obligatoriedad que en todos los casos, es decir, con carácter general, las haga efectivas en la práctica, la observancia de tales normas sólo es exigible (si nos situamos en la perspectiva de lo que Weber llamaba una ética de la responsabilidad) si cobran obligatoriedad jurídica»¹²⁵.

De todas maneras, aquí se puede analizar en qué sentido debe comprenderse la *exoneración* a la que Habermas se refiere. La exoneración puede ser interpretada como traslado de la carga de la decisión, traslado de la responsabilidad de la decisión. Me parece que este traslado en el ámbito de la moral plantea dimensiones problemáticas. La responsabilidad en este campo es responsabilidad moral, y el protagonismo de esta responsabilidad corresponde en última instancia al sujeto. Si bien el sujeto que actúa de acuerdo con normas jurídicas no siempre tiene que actuar moralmente —esto es, en el sentido kantiano de la actuación por la misma idea del deber—, el cumplimiento de las normas morales siempre implica la moralidad de la acción. De la misma manera, el incumplimiento de las normas morales es voluntario¹²⁶. La decisión sobre dicha actuación es por definición autónoma. La noción de autonomía implica la titularidad de la decisión y al mismo tiempo también responsabilidad sobre la decisión. La decisión autónoma, y por tanto responsable, está vinculada al contenido de la norma moral. Se establece así un nexo entre autonomía, responsabilidad y moralidad, de manera que el sujeto que

¹²⁵ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 558.

¹²⁶ Sobre el carácter voluntario de las transgresiones morales, vid. HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, cit., pp. 220 y ss.

actúa moralmente, y por tanto autónomamente, es responsable de su decisión y de su actuación. Creo que a estos efectos no es relevante que la norma moral de acuerdo con la cual se actúa y se toma una decisión forme parte del Ordenamiento jurídico —y sea por tanto moral positivizada o legalizada— o se inserte en un sistema de moral crítica. A efectos de la exoneración de la que habla Habermas, sí parecería relevante la situación de la norma moral, ya que dicha exoneración parece presentarse como consecuencia de la inclusión de contenidos morales en los ordenamientos jurídicos. De acuerdo con lo anterior, surge la cuestión de si la exoneración puede interpretarse en el sentido de la reducción de la responsabilidad moral del sujeto; y también el problema de saber si las exigencias cognitivas, motivacionales y organizativas de la moral racional suponen un reclamo de mayor responsabilidad moral al sujeto —de manera que una vez superadas las carencias vinculadas a esas exigencias el individuo se ve sometido a una disminución del grado de exigencia moral— o por el contrario se limitan a suponer la necesidad de mayores destrezas técnicas o instrumentales por parte del sujeto que quiere actuar moralmente.

2.3. Nino y el teorema fundamental de la Filosofía del Derecho

La última cuestión que quedaría por señalar en este capítulo es la referida al teorema fundamental de la Filosofía del Derecho, tal y como es planteado por Nino. Creo que pueden existir razones para argumentar a favor de la tesis según la cual el teorema, se matiza o relativiza en un sistema en el que se produce una positivación de contenidos morales en sentido democrático. Se podría decir, con razón, que en cualquier sistema se produce esa positivación, aunque no necesariamente en sentido democrático. Pero hay que tener en cuenta que nos referimos a sistemas democráticos, por tanto consensuados, y en cuya formación se ha participado. Si esto es así, posiblemente ya no se puede mantener con tanta rotundidad y exclu-

sividad la idea según la cual, en relación con el Derecho, solamente son las normas morales las que en última instancia dan fuerza obligatoria a las prescripciones jurídicas.

Carlos Nino ha enunciado el teorema fundamental de la teoría jurídica (o, en sentido amplio, de la Filosofía del Derecho) en varios de sus escritos. Así, en *La validez del Derecho* señala: «Creo que la pregunta central de la filosofía del derecho, de la que depende una multitud de otros interrogantes, es la que se refiere a si las normas jurídicas expresan o no razones operativas autónomas para justificar acciones o decisiones, como las judiciales»¹²⁷. En su artículo «A Philosophical Reconstruction of Judicial Review», escribe: «... a legal norm or law only justifies the practical reasoning of judges and other social actors insofar as it is accepted by virtue of a moral judgement that grants legitimacy to certain authority and a descriptive judgement of the prescriptions of that authority»¹²⁸. En su libro *La Constitución de la democracia deliberativa*, enuncia así dicho teorema: «...las acciones y decisiones, como aquellas que se toman respecto de problemas constitucionales, no pueden justificarse sobre la base de normas positivas tales como la constitución histórica, sino sólo sobre la base de razones autónomas, que son, a fin de cuentas, principios morales. Presumiblemente aquellos principios morales establecen un grupo de derechos fundamentales»¹²⁹. Es evidente que nos encontramos frente a una crítica de la pretensión iuspositivista de dotar de autonomía al deber jurídico respecto al deber moral, a las razo-

¹²⁷ NINO, C., *La validez del Derecho*, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 125. Para Massimo La Torre, la cuestión de si el Derecho es una razón normativa fuerte para la acción constituye el problema que está en el corazón de las interminables discusiones sobre la relación entre el Derecho y la moral (vid. LA TORRE, M., *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, cit., pp. 327 y ss.).

¹²⁸ NINO, C., «A philosophical reconstruction of judicial review», *Cardozo Law Review*, 1993, p. 814.

¹²⁹ NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, trad. de R. P. Saba, Gedisa, Barcelona, 1997, p. 70.

nes para la acción derivadas de normas jurídicas respecto a las razones para la acción derivadas de normas morales¹³⁰.

En el marco del análisis de diferentes dimensiones del constitucionalismo¹³¹, Nino plantea determinados problemas que surgen en el razonamiento práctico tendente a justificar decisiones. Así, por una parte, la indeterminación radical que presenta la Constitución (histórica, no ideal) a la hora de ser interpretada, y por otra parte el carácter aparentemente superfluo de esa Constitución para la justificación de decisiones en relación con asuntos o materias reguladas por ella¹³². En el primer caso, la indeterminación del significado del texto constitucional plantea, para Nino, el necesario recurso a valoraciones normativas (morales) en la tarea de traducir el texto en determinaciones prácticas. Es en este escenario en el que se presentan los problemas de elección entre diversos métodos interpretativos (originalismo v. constructivismo), y las indeterminaciones sintácticas y semánticas provocadas por la vaguedad de los lenguajes naturales, o por su ambigüedad. Nino aduce que estos rasgos del texto constitucional exigen la utilización de otros elementos normativos-valorativos, más allá de la norma constitucional; utilización que también se plantea como necesaria cuando se trata de solventar contradicciones lógicas entre normas. Los problemas de interpretación, indeterminación, contradicción, vaguedad, ambigüedad demuestran, para Nino, la existencia de una conexión interpretativa entre el Derecho y la moral, basada en la idea de que «el derecho no puede ser interpretado si no se recurre, en

¹³⁰ Massimo LA TORRE ha analizado las consecuencias que se derivan del teorema fundamental de la filosofía del Derecho para el mantenimiento de un concepto neutral de Derecho por parte del positivismo, en «Positivismo giuridico», *Enciclopedia del Diritto*, Giuffré, annali VI, 2013, pp. 710 y ss.

¹³¹ Vid. también NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 130 y ss.

¹³² Vid. NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., pp. 30 y ss.

momentos cruciales de esa tarea interpretativa, a consideraciones de índole moral»¹³³.

De la misma manera que afirma la existencia de esta conexión intepretativa, Nino también defiende la existencia de una conexión justificatoria. Dicha conexión adquiere sentido como consecuencia del imperialismo del discurso moral que imposibilita, a su vez, la insularidad del discurso jurídico: «...no existen razones jurídicas que puedan justificar acciones y decisiones con independencia de su derivación de razones morales»¹³⁴. La Constitución histórica se muestra superflua e irrelevante en el razonamiento práctico. Nino constata la superfluidad de la Constitución a través del análisis de dos hipótesis. La primera de ellas, parte de la afirmación de que la Constitución no puede constituir la base de su propia validez. La validez de la Constitución va a estar apoyada, en este sentido, en elementos normativos superiores a la misma: «Dado que la Constitución no puede adscribir validez a otras reglas si ella misma no es válida y toda vez que ésta no puede adscribirse validez a sí misma, la Constitución no puede otorgar validez a otras reglas»¹³⁵. Por ello la validez de la Constitución deberá basarse en elementos valorativos externos al mismo sistema constitucional. De estos elementos dependerá en última instancia el carácter obligatorio de las prescripciones constitucionales y, en definitiva, del resto de las normas jurídicas. Además, estos elementos valorativos van a ser de naturaleza moral. En este sentido, Nino acepta explícitamente la tesis del caso especial, propuesta por

¹³³ NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., p. 128.

¹³⁴ NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., p. 82. Para Nino, este imperialismo no se ejerce exclusivamente en relación con el discurso jurídico; por el contrario, se extiende también a otros ámbitos, como el de la religión o la economía. Un análisis crítico de las consecuencias de la posición de Nino puede encontrarse en BARBERIS, M., «Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, Trotta, Madrid, 2003, pp. 259 y ss.

¹³⁵ NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., p. 44.

Robert Alexy, que permite identificar el discurso jurídico como un caso especial del discurso moral y que permite llegar a la conclusión, también, de que cuando los jueces recurren a la norma constitucional para justificar la aplicación de una norma concreta perteneciente al sistema, en realidad hacen referencia a la Constitución identificándola no como un mero hecho social, sino como una proposición moral: «... una constitución como texto o como práctica social de reconocimiento no es suficiente en sí misma para proveer fuerza obligatoria o validez a las restantes reglas del sistema jurídico. Consecuentemente, no puede por sí misma justificar decisiones basadas en esas reglas»¹³⁶. Para ello, señala Nino, debemos recurrir a «un principio extrajurídico, cuya adopción tiene las propiedades pragmáticas de la moral»¹³⁷.

La segunda hipótesis, entendida por el propio Nino como más fuerte, se centra en la consideración de los principios morales que permiten legitimar una Constitución, y afirma que si esos principios colman las exigencias morales a satisfacer por la Constitución, entonces ésta misma no añade nada al contenido de esos principios morales y, es más, al razonamiento práctico. El argumento propuesto por Nino es el siguiente: la legitimidad de una Constitución depende de que reconozca e incluya —positivice— determinados contenidos que no son sino exigencias de ciertos principios morales. Esos contenidos, en nuestros sistemas democráticos, se identifican basicamente con derechos fundamentales. Sólo desde el momento en que se produce esa inclusión, podemos considerar que la Constitución contiene razones justificatorias de las decisiones. Pero, en realidad, a partir de ese momento, el recurso a la Constitución pierde valor (la Constitución muestra su irrelevancia), ya que esas razones justificatorias pueden encontrarse directamente acudiendo a esas valoraciones y a esos principios. De manera

¹³⁶ NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., p. 45.

¹³⁷ NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., p. 75.

que «una constitución no es legítima y no puede ser empleada para justificar acciones y decisiones si ella carece de cierto contenido necesario o básico. Si incluye tal contenido, es superflua, porque las justificaciones pueden ser inferidas directamente de los principios morales que prescriben su contenido»¹³⁸. En definitiva, y en otros términos, si la Constitución no es legítima (no incluye determinados contenidos) no vale para justificar decisiones; y si es legítima (incluye esos contenidos) no es necesaria.

Nino es consciente del problema que se plantea como consecuencia de la existencia de conexiones interpretativas y justificativas entre el Derecho y la moral: se corre el riesgo «de que el derecho positivo se vea absorbido totalmente por la moral»¹³⁹. Para evitar esta conclusión inicia una estrategia dirigida a demostrar que tanto la paradoja de la indeterminación radical como la de la superfluidad no son genuinas; en realidad, el Derecho es una práctica social, un proceso de interacción colectiva, que debe ser analizado por tanto de acuerdo con los criterios de racionalidad específica que rigen la participación en obras colectivas¹⁴⁰. No me interesa detenerme en este momento en esta cuestión —tampoco pienso que ello sea necesario para el correcto desarrollo de esta investigación—. Por el contrario, quiero detenerme brevemente en una posible reformulación de la indeterminación y de la superfluidad aludidas por Nino desde la perspectiva de un concepto material de Estado de Derecho¹⁴¹.

¹³⁸ NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., p. 46.

¹³⁹ NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., p. 134.

¹⁴⁰ Vid. NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., pp. 47 y ss; ID., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., pp. 134 y ss.

¹⁴¹ Esta es sólo una posibilidad de análisis crítico de la posición de Nino. Es evidente que caben otras. Así, por ejemplo, Cristina REDONDO ha analizado la capacidad de respuesta del positivismo jurídico frente a los problemas derivados del «principio de unidad del razonamiento práctico» (con el que se refie-

La denuncia de la indeterminación del Derecho y de su superfluidad en el razonamiento práctico constituyen pilares sobre los cuales Nino apoya el contenido del teorema fundamental de la teoría jurídica. No obstante, una concepción del Estado de Derecho como la mantenida en esta investigación, puede, de alguna manera, contribuir a superar las carencias del Derecho denunciadas implícitamente a través de dicho teorema.

Un Derecho como el del Estado de Derecho, que se caracteriza por recibir los contenidos de moralidad que Nino identifica con la Constitución ideal (que «contiene la protección de los derechos y el establecimiento de la democracia»¹⁴²), no es superfluo a la hora de aportar argumentos valiosos para el razonamiento moral. La virtud derivada de la presencia de determinados contenidos en el Ordenamiento jurídico del Estado de Derecho consiste precisamente en que atribuye relevancia jurídica a argumentos que, per se, disfrutaban exclusivamente de relevancia moral. En efecto, las dimensiones normativas de esa Constitución ideal a la que alude Nino, en principio, no constituyen argumentos relevantes desde el punto de vista jurídico, pues fuera del Ordenamiento jurídico del Estado de Dere-

re al imperialismo de la moral) y a la denunciada incapacidad del positivismo a la hora de justificar la normatividad del Derecho sin recurrir a la moral. Vid. «El carácter práctico de los deberes jurídicos», *Doxa*, n.º 21/II, 1998, pp. 355 y ss. Para Redondo, las consecuencias del imperialismo de la moral, esto es, del carácter derivado de la normatividad jurídica respecto a la normatividad moral, se pueden evitar si el positivismo admite la ambigüedad de la noción de deber, la existencia de diversos tipos de deberes, y la existencia de un principio de unidad del razonamiento práctico, pero no necesariamente funciona a partir del reconocimiento de la superioridad de las razones o deberes morales respecto a los deberes jurídicos, siendo por tanto neutral en relación con los distintos sistemas normativos. Por su parte, Marisa Iglesias ha analizado las posibilidades del concepto dworkiniano de integridad a la hora de generar argumentos que superen la superfluidad del Derecho en IGLESIAS VILLA, M., «Es realmente superfluo el Derecho? Justicia política e insularidad del razonamiento jurídico», en ALEGREM, M., GARGARELLA, R., ROSENKRATZ, C. F., *Homenaje a Carlos S. Nino*, La Ley-Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 120 y ss.

¹⁴² NINO, C., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., p. 47.

cho son operativos exclusivamente en el marco de la moralidad crítica. Es la conversión de la Constitución ideal en Constitución histórica la que permite otorgar relevancia jurídica a esas dimensiones de la moralidad. Las normas jurídicas no siempre contienen los mejores argumentos desde el punto de vista del razonamiento práctico considerado correcto pero, en todo caso, contienen los argumentos operativos en el razonamiento jurídico. Las razones jurídicas no tienen por qué ser por definición las razones correctas. De lo contrario, nos veríamos obligados a negar la posibilidad de un razonamiento jurídico a partir del material normativo suministrado por un Ordenamiento jurídico injusto o incorrecto desde el punto de vista de la moral. O —cabe otra posibilidad—, nos veríamos obligados a exigir que el razonamiento jurídico —que pretende ser correcto— no tuviera en cuenta el sentido de las normas jurídicas, que han sido consideradas injustas. Nino tiene razón a la hora de afirmar que la Constitución ilegítima (aquella que no incluye los contenidos de la Constitución ideal) no vale para justificar —correctamente— decisiones. Pero, en todo caso, esa Constitución, aún siendo ilegítima, vale en principio para ordenar la sociedad —podría por tanto cumplir sus funciones—, aunque sus criterios no sean del todo aceptables desde el punto de vista de una moral correcta o esclarecida. Además, Nino afirma la irrelevancia de aquella Constitución que es legítima, desde el momento en que esos criterios de legitimación tienen valor y relevancia per se. Pero lo importante, me parece, es subrayar que esos criterios de legitimación son relevantes jurídicamente precisamente por su juridificación a través de la Constitución.

Recordemos que para Nino «las razones inherentes al razonamiento jurídico que aluden al hecho de que ciertas normas son parte de un sistema jurídico, no son, ellas mismas, razones jurídicas, sino que pertenecen a un sistema justificatorio más amplio»¹⁴³. Es decir, se está afirmando que, en última instancia,

¹⁴³ NINO, C., *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, cit., p. 83.

las razones jurídicas válidas son razones morales y, como consecuencia de ello, se produce una absorción del Derecho por parte de la moral. Según Nino, en definitiva, el valor de lo jurídico depende en última instancia de argumentos morales. Pero existe una dimensión de lo jurídico que conviene no olvidar, sobre todo para no caer en la tentación de construir una idea de Derecho en ocasiones no reconocible en la práctica. Me refiero a la dimensión del Derecho como criterio de ordenación social y como mecanismo de prevención/resolución de conflictos sociales. Ciertamente es que no son éstas las únicas funciones del Derecho, pero en todo caso son dos a las que se les debe —considero— imprescindible atención en el análisis de lo jurídico. Pues bien, la vocación de eficacia social que acompaña al Derecho determina la insuficiencia de las razones morales para la ordenación social. El primer paso de esa pretendida eficacia implica la conversión de las razones morales en razones jurídicas. Posiblemente, que en este punto sea pertinente recordar el paralelismo que se produce entre el argumento que estoy intentado desarrollar y la postura de Robert Alexy, cuando defiende la necesidad del discurso jurídico a partir de la debilidad e insuficiencia del discurso práctico general, ya que éste, a través de sus reglas y formas, define «un procedimiento de decisión que en numerosos casos no lleva a ningún resultado y que, si lleva a un resultado, no garantiza ninguna seguridad definitiva»¹⁴⁴. Alexy constata, de manera no del todo diferente a Nino, determinados aspectos del Derecho que están detrás de la indeterminación de la decisión jurídica, como por ejemplo la vaguedad del lenguaje jurídico, la posibilidad de conflictos normativos, el problema de la ausencia de respuesta normativa jurídica para algunos casos. La argumentación práctica general, el discurso moral, no es capaz de colmar esas insuficiencias, y por ello es necesaria la introducción de las formas y reglas de la argumentación jurídica. Ello, nos lo recuerda Alexy,

¹⁴⁴ ALEXY, R., *Teoría de la argumentación jurídica*, trad. de M. Atienza e I. Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 273.

no supone expulsión de la argumentación práctica del ámbito de la argumentación jurídica, sino un aumento considerable de la operatividad de la argumentación práctica, paralelo al aumento de operatividad de la moral que se produce mediante su positivación: «la argumentación jurídica sigue dependiendo normalmente de argumentos prácticos de tipo general (...). La incerteza debida a la naturaleza del discurso práctico general no puede por ello nunca ser eliminada por completo. Como elemento de la argumentación jurídica, la argumentación práctica general, sin embargo, tiene lugar, no en último término, bajo condiciones que elevan considerablemente su rendimiento, en base a la institucionalización del discurso jurídico como ciencia jurídica»¹⁴⁵.

El modelo material de Estado de Derecho, por tanto, permite fusionar de alguna manera la justificación moral (correcta, la que se reconduce a la Constitución ideal) y la justificación jurídica; permite que lo relevante moral sea también relevante jurídico; en definitiva, permite considerar una vía de superación del teorema fundamental de la teoría jurídica presentado por Nino, rompiendo —en el marco de sus estructuras— la distancia entre razones meramente jurídicas y razones morales que se encuentra tras dicho teorema. No se produce, por tanto, el peligro al que alude Nino de absorción del Derecho por parte de la moral. Al contrario, en el Estado de Derecho, se produce una absorción de determinadas dimensiones morales por parte del Derecho, absorción que de ninguna manera elimina la autonomía de la moral, al contrario de lo que parece ocurrir con el Derecho en el esquema presentado por Nino, que desaparece bajo el imperio de la moral.

¹⁴⁵ ALEXY, R., *Teoría de la argumentación jurídica*, cit., p. 274.

III. UN CONCEPTO MATERIAL DE ESTADO DE DERECHO

Hasta el momento se ha hecho alusión a la relación entre el Derecho y el Poder y a la relación entre el Derecho y la moral. Se ha considerado que la referencia a estas relaciones es importante desde el momento en que, en realidad, el Estado de Derecho supone la manifestación de un modelo concreto de articulación de las mismas.

Es el momento de profundizar en el análisis del concepto de Estado de Derecho. En esta ocasión nos encontramos con, por lo menos, dos problemas. En primer lugar, el de la existencia de diversas tradiciones en relación con el concepto; en segundo lugar, el de la existencia de diferentes conceptos de Estado de Derecho.

El primer problema al que nos referimos es el constituido por la existencia de diferentes tradiciones que se encuentran detrás de lo que hoy podemos conocer como Estado de Derecho. En efecto, este concepto debe ser entendido a la luz del sentido y de la evolución que en sus contextos respectivos han sufrido las ideas de *Rule of law*, *Rechtstaat*, *État de droit*. La pluralidad de tradiciones, no siempre coincidentes en sus contenidos y significados, pero tampoco —ciertamente— absolutamente extrañas entre sí, condiciona necesariamente la metodología de una investigación como ésta. En efecto, se presentan ante nosotros al menos dos posibilidades. Se puede optar, en primer lugar, por iniciar un análisis de los elementos compo-

nentes y de los rasgos característicos de cada una de esas tradiciones. Esta es una posibilidad absolutamente viable, de la cual tenemos diversos ejemplos. La segunda opción, es aquella que parte de la existencia de elementos comunes en las diferentes tradiciones, que formarían parte, a su vez, de una cultura común. De manera que es posible distanciarse de alguna manera de las particularidades de esas tradiciones, asumiendo una cierta perspectiva desde la que analizar rasgos y problemas de lo que, con todas las cautelas necesarias, podríamos proponer como un concepto válido de Estado de Derecho. Pienso que esta opción es la más acorde con el sentido y perspectiva de la Filosofía del Derecho. Como se podrá observar en lo sucesivo, en este trabajo nos decantamos por esta segunda posibilidad, desde el momento en que favorece uno de los objetivos del mismo, que no es sino el del análisis de algunos de los problemas que se plantean en el Estado de Derecho en su configuración contemporánea como Estado constitucional.

En relación con el segundo problema, sabemos que el repaso de la bibliografía básica al respecto nos muestra la circunstancia del empleo de varios conceptos de Estado de Derecho. Así, y siendo esquemáticos, observamos dos distinciones comunes, como aquella entre Estado de Derecho en sentido amplio y restringido, de un lado, y aquella otra entre Estado de Derecho formal y material, de otro. En el análisis de las distintas posibilidades de comprensión del término está en juego la operatividad y sustantividad del mismo. Creo, también, que es posible llevar a cabo un análisis conjunto de ambas parejas de acepciones. En este sentido, y como detallaremos posteriormente, tanto en el concepto amplio como en el concepto formal asistimos a una rebaja o disminución de las exigencias que deben concurrir para su correcta identificación. Así, si manejáramos tanto un concepto amplio como uno formal de Estado de Derecho, estaríamos obligados, si quisiéramos ser coherentes, a identificar como tales a Estados que de otra forma no serían comprendidos como Estados de Derecho. Por el contrario, la opción por un concepto restringido o material/sustancial de Estado de Derecho, limita en gran medida la extensión del

concepto, disminuyendo las posibilidades de identificar como tal a determinadas organizaciones políticas modernas que se articulan en forma de Estados. Estamos en este caso en presencia de una comprensión del Estado de Derecho mucho más exigente que la anterior.

De manera que se pueden extraer dos conclusiones preliminares: a) la primera es la referida a la vinculación respectiva entre el concepto amplio y el formal, de un lado, y el concepto restringido y el sustancial o material, de otro; b) la segunda es la que se refiere a la disminución en la extensión del concepto de Estado de Derecho, cuando se mantiene una comprensión material o sustancial del mismo, y que es consecuencia de una mayor exigencia en la identificación de sus rasgos o elementos constitutivos, configuradores de su intensidad.

1. DIFERENTES TRADICIONES Y UN SENTIDO COMÚN

Como acabamos de señalar, el análisis conceptual de la idea de Estado de Derecho se encuentra de manera inevitable con el problema originado por la existencia de distintas tradiciones intelectuales que se encuentran en la base de las ideas de *Rule of law*, *Rechtsstaat*, o *État de droit*¹⁴⁶.

Por de pronto, nos encontramos con la circunstancia de la ausencia de una correspondencia exacta entre los diferentes términos utilizados. Así, se ha puesto de relieve que el término *rule of law* no tiene una exacta traducción en otros idiomas¹⁴⁷. A partir de la propuesta de comprensión presentada por Dicey, a la que posteriormente nos referiremos, su significado se aso-

¹⁴⁶ Las diferencias entre las tradiciones simbolizadas por las ideas de *Rule of law*, *Rechtsstaat*, o *État de droit* han sido estudiadas en profundidad por la doctrina. Por todos, puede consultarse ROSENFELD, M., «The rule of law, and the legitimacy of constitutional democracy», cit.

¹⁴⁷ Vid. MARSH, N. S., «The Rule of Law as a Supra-National Concept», en GUEST, A. G., (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, 1961, pp. 229-230.

cia a nociones como las de «*le principe de la légalité*», «*la suprématie de la règle de droit*», «*le règne souverain de la loi*», en francés; «*Rechtsstaat*» en alemán; en los Estados Unidos de América está asociado a las nociones de «*government under the law*», «*government of laws and not of men*», y también al «*due process of law*». Por otra parte, podemos observar que el término *rule of law* no siempre es traducido de la misma manera. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se traduce como «régimen de Derecho»¹⁴⁸; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales de 1950, se traduce como «preeminencia del Derecho»¹⁴⁹. Y también hay que tener en cuenta las diferentes traducciones llevadas a cabo por la doctrina¹⁵⁰.

Danilo Zolo ha apuntado que la cuestión de la posible coincidencia conceptual de las distintas tradiciones no es pacífica¹⁵¹. En efecto, por una parte, nos encontramos con una tradición con origen en la cultura liberal alemana de la segunda mitad del siglo XIX, que influye de manera importante en la doctrina iuspublicista de la Tercera República francesa y en Italia. Por otra,

¹⁴⁸ En el Preámbulo podemos leer: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un *régimen de Derecho*, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». El texto de la Declaración se puede consultar en PECES-BARBA G., (y otros), *Textos básicos de derechos humanos*, Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 283 y ss.

¹⁴⁹ En el Preámbulo se alude a la resolución de los gobiernos signatarios «en cuanto gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de *preeminencia del Derecho*, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal». El texto del Convenio se puede consultar en PECES-BARBA G., (y otros), *Textos básicos de derechos humanos*, cit., pp. 570 y ss.

¹⁵⁰ Vid. RAZ, J. «El Estado de Derecho y su virtud», ID., *La autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y moral*, trad. y notas de R. Tamayo Salmorán, UNAM, México, 1982.

¹⁵¹ Vid. ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, cit., p. 17.

nos encontramos con la idea de *rule of law* que, aunque con raíces más lejanas, es teorizada por Dicey y que posteriormente condiciona el Derecho constitucional norteamericano.

No podemos detenernos en el análisis pormenorizado de los rasgos y particularidades de las distintas tradiciones que se encuentran tras la idea de Estado de Derecho¹⁵². Entre otras cosas, no es el objetivo del presente trabajo. Por lo tanto, no pretendo desarrollar en este momento un análisis de los orígenes intelectuales y de las implicaciones de los distintos términos con los que en ocasiones se ha identificado la idea de Estado de Derecho. De lo que se trata, por el contrario, es de analizar el sentido del concepto que se esconde tras los términos y que es compartidos por éstos. Así, no me detendré en la cuestión de la definición de los términos, desde el momento en que, como ha recordado entre otros Oppenheim, no siempre existe una correspondencia entre palabras y conceptos¹⁵³. No creo que esta estrategia metodológica dificulte la investigación, ya que tras la diversidad de tradiciones es posible identificar rasgos comunes o ideas-guía que nos permiten comprender tanto el significado como las exigencias del Estado de Derecho en la actualidad. Así, por ejemplo, Richard Fallon ha señalado

¹⁵² Por ello remito a la lectura de los siguientes trabajos incluidos en el volumen, ya citado, editado por P. COSTA y D. ZOLO, *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*: COSTA, P., «Lo Stato di diritto: un'introduzione storica», pp. 89 y ss.; SANTORO, E., «Rule of law e 'libertà degli inglesi'. L'interpretazione di Albert Venn Dicey», pp. 173 y ss.; CASALINI, B., «Sovranità popolare, governo della legge e governo dei giudici negli Stati Uniti d'America», pp. 224 y ss.; GOZZI, G., «Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca», pp. 260 y ss.; LAQUIÈZE, A., «État de droit e sovranità nazionale in Francia», pp. 284 y ss.; BONGIOVANNI, G., «Stato di diritto e giustizia costituzionale. Hans Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920», pp. 317 y ss. También, MONHAUPT, H., «L'État de Droit en Allemagne. Histoire, notion, fonction», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 24, 1993, pp. 71 y ss.; y BINGHAM, T., *The Rule of Law*, Penguin Books, London, 2011, pp. 10-33.

¹⁵³ Vid. OPPENHEIM, F. E., *Conceptos políticos. Una reconstrucción*, trad. de M. D. González Soler, Tecnos, Madrid, 1987, p. 13.

tres objetivos básicos del *rule of law*¹⁵⁴: proteger contra la anarquía, permitir a la gente planear sus asuntos con una razonable confianza en la posibilidad de conocer con anticipación las consecuencias jurídicas de sus comportamientos, y proteger contra la arbitrariedad de la autoridad. En diferentes términos, pero compartiendo la idea de fondo, Pier Paolo Portinaro ha aludido a las tres ideas-guía del Estado de Derecho: aquella según la cual el Derecho regula y limita el ejercicio de los poderes públicos; la exigencia de que el ejercicio del Poder se someta al gobierno de las leyes; y la afirmación de la tutela jurisdiccional del derecho a defenderse frente a actuaciones arbitrarias del Poder¹⁵⁵. Posiblemente estos objetivos e ideas-guía forman el ámbito de concurrencia de las distintas tradiciones y el dato que permite calificar al imperio de la ley y al Estado de Derecho como un concepto supranacional¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Vid. FALLON, R. H., ««The rule of law» as a concept in constitutional discourse», cit., pp. 7-8.

¹⁵⁵ Vid. PORTINARO, P. P., «Oltre lo Stato di diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, cit., p. 389. En sentido similar, BINGHAM, T., *The Rule of Law*, cit., p. 8.

¹⁵⁶ Vid. MARSH, N. S., «The Rule of Law as a Supra-National Concept», cit.. Entre nosotros, E. GARCÍA DE ENTERRÍA asume explícitamente la tesis de Marsh en *La lengua de los derechos. La formación del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa*, Alianza, Madrid, 1994, pp. 147 y 151.

De esta forma, aunque las tradiciones originarias toman cuerpo en Europa, el significado contemporáneo de la idea de Estado de Derecho trascendería los confines del Continente. En el libro editado por P. Costa y D. Zolo, *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, cit., se pueden encontrar interesantes trabajos al respecto: DUPRET, B., «Il 'governo della legge' nei limiti dell'etica islamica. Il caso egiziano», pp. 646 y ss.; TAY, A. E.-S., «I valori asiatici e il *rule of law*», pp. 683 y ss.; GIRI, A. K., «I 'governo della legge' e la società indiana. Dal colonialismo al post-colonialismo», pp. 708 y ss.; PEI, C., «La dottrina confuciana e il 'governo dell'uomo': l'umanesimo cinese originario», pp. 739 y ss. No obstante, existen comprensiones del Estado de Derecho que subrayan la dimensión europea y occidental del mismo. Pueden consultarse al respecto GOZZI, G., «Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca», cit., p. 260; BARTOLOMEI, F., «Lo 'Stato di diritto' nel rapporto di tensione esistente tra legge e diritto», *Diritto e Società* 1997/4, p. 463. Por ejemplo,

Esas ideas-guía actúan mucho antes de que se manejan los diferentes términos a los que hemos aludido¹⁵⁷. Así, por ejemplo, se ha señalado que aunque la expresión *rule of law* fue popularizada por Dicey, en realidad, los conceptos a los que se hace referencia venían desarrollando una función muy importante, desde hace ya siglos, a la hora de conformar las relaciones entre los individuos, las normas y el gobierno¹⁵⁸.

En este sentido, la interpretación constructiva (o, más bien, podríamos decir, reconstructiva), propuesta recientemente por

D. ZOLO nos ofrece la siguiente: el Estado de Derecho es «... la versión del Estado de Derecho europeo que, sobre la base de una filosofía individualista (...) y a través de procesos de difusión y diferenciación del Poder, atribuye al Ordenamiento jurídico la función primaria de tutelar los derechos civiles y políticos, contrarrestando a este fin la inclinación del Poder al arbitrio y a la prevaricación», «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., p. 45. El hecho de que la concepción antropológica sobre la que descansa el Estado de Derecho (individualismo, racionalismo, secularización) sea típicamente occidental, conduce a Zolo a afirmar que aquel es «el patrimonio más relevante que hoy, a los inicios del tercer milenio, la tradición política europea deja en herencia a la cultura política mundial» (op. cit., p. 46). Aunque no es el momento de profundizar en la cuestión de la compatibilidad entre el Estado de Derecho y las diversas concepciones culturales diferentes a la europeo-occidental, sí podemos afirmar que, dada la imprescindibilidad de la satisfacción mínima de las exigencias del imperio de la ley para la eficacia y la existencia de un Ordenamiento jurídico, la citada compatibilidad dependerá en última instancia de la capacidad de las respectivas culturas de asumir las exigencias morales básicas vinculadas a los derechos fundamentales. A este respecto, Mauro BARBERIS ha defendido que los derechos y el constitucionalismo forman parte de la identidad política y jurídica europea en *Europa del diritto*, il Mulino, Bologna, 2008.

¹⁵⁷ Se afirma, desde esta perspectiva, que las ideas que dotan de sentido al término 'Estado de Derecho' son más antiguas que el propio término. Vid. MONHAUPT, H., «L'État de Droit en Allemagne. Histoire, notion, fonction», cit., p. 75; REDOR, M.-J., *De l'Etat legal a l'Etat de droit. L'Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française 1879-1914*, Economica-Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1992, p. 9.

¹⁵⁸ Vid. REYNOLDS, N. B., «Grounding the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 2, n.º 1, 1989, p. 1.

Danilo Zolo merece ser tenida en cuenta¹⁵⁹. Siguiendo a Alessandro Baratta¹⁶⁰, Zolo ha distinguido entre la historia interna y la historia externa del concepto de Estado de Derecho. La historia interna es la configurada por las diversas tradiciones. Se señala, a este respecto, la relevancia de la tradición alemana¹⁶¹. Y es en este contexto, el constituido por las diversas tradiciones, señala Zolo, donde se observan las diferencias en lo que se refiere a la soberanía de las fuentes normativas, las técnicas constitucionales de limitación y diferenciación de los poderes estatales, en el fundamento de los derechos individuales y en sus diversos mecanismos de garantía y protección. Pero cuando analizamos lo que podríamos considerar la historia externa del concepto, es posible reconducir la pluralidad de elementos a criterios y esquemas comunes. En este sentido, es posible encontrar referentes filosófico-políticos y valorativos comunes y compartidos. Así, para Zolo, el Estado de Derecho es «una versión del Estado moderno europeo en la cual, sobre la base de específicos presupuestos filosófico-jurídicos, se atribuye al Ordenamiento jurídico la función de tutelar los derechos subjetivos, contrastando la tendencia del poder político a dilatarse, a actuar de manera arbitraria y a prevaricar»¹⁶². Esta comprensión del Estado de Derecho es el resultado del juego interrelacionado de dos principios: el principio de la difusión del Poder y el principio de la diferenciación del Poder. Detengámonos en el análisis de estos dos principios.

Según Zolo, el principio de difusión del Poder, «tiende a limitar con vínculos explícitos los poderes del Estado para dilatar el ámbito de las libertades individuales. Implica por ello una definición jurídica de los poderes públicos y de su relación con los

¹⁵⁹ Vid. ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., pp. 18 y ss.

¹⁶⁰ Vid. BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», cit., p. 15.

¹⁶¹ Vid. BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», p. 15; MONHAUPT, H., «L'État de Droit en Allemagne. Histoire, notion, fonction», cit., p. 74.

¹⁶² Vid. ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., p. 34.

poderes de los sujetos individuales, que también están jurídicamente definidos»¹⁶³. Este principio supone la atribución, con reconocimiento y efectos jurídicos, de derechos y de poderes a los sujetos, que pueden ejercerlos frente a los poderes públicos, suponiendo por tanto una limitación frente a estos. Para que el contenido del principio de difusión del Poder se materialice, es imprescindible la afirmación del carácter único e individual del sujeto jurídico. Quiere decirse con ello que, al menos desde un punto de vista teórico, todos los individuos gozan de la misma capacidad jurídica a la hora de ser titulares de derechos y a la hora de ejercerlos, lo cual supone una negación de la idea premoderna de privilegio como opuesta a las exigencias de igualdad y de generalidad implícitas en la noción de derecho. La idea de Estado de Derecho está asociada, por tanto a la igualdad jurídica entre los sujetos. El principio de difusión del Poder exige también certeza del Derecho, entendida como medio para garantizar la capacidad de prever consecuencias normativas y de reforzar expectativas individuales. Y por último, añade Zolo, dicho principio exige el reconocimiento constitucional de los derechos subjetivos.

El principio de diferenciación del Poder se expresa «ya sea como diferenciación del sistema político-jurídico respecto a los otros subsistemas sociales, en particular el ético-religioso y el económico, ya sea como criterio de delimitación, coordinación y regulación jurídica de distintas funciones estatales, básicamente correspondientes al establecimiento de normas (*legislatio*), y a la aplicación de normas (*legis executio*)»¹⁶⁴. Es decir, implica una doble diferenciación. Por una parte, una diferenciación externa del Poder político en relación con otros centros de Poder y, por otra, una diferenciación interna al Poder político, entre diferentes instituciones u órganos caracterizados fundamentalmente por las funciones que desarrollan. En el caso de la primera diferenciación, la externa, el Estado de Derecho no es sino el resultado de la concepción del Poder político que

¹⁶³ ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., p. 34.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

triunfa en la modernidad y que lo entiende como separado, tanto en su origen y en sus funciones, de otros núcleos de Poder, principalmente los ético-religiosos. Respecto a la diferenciación interna que, ciertamente, adquiere sentido a partir de la consecución de la diferenciación externa, Zolo recuerda que su materialización, también en este caso, exige la puesta en marcha de diferentes mecanismos o instituciones, constatables a lo largo de la evolución histórica del Estado de Derecho. Así, en primer lugar, la delimitación del ámbito de ejercicio del Poder político y de aplicación del Derecho, que implica la distinción entre la esfera pública y la esfera privada y la exclusión de componentes nucleares de ésta del ejercicio del dominio público. En segundo lugar, la separación entre instituciones legislativas y administrativas, basada en la distinción entre la producción de normas generales y abstractas, que corresponde al Parlamento y la aplicación de las mismas, que es una función del ejecutivo y del aparato burocrático que depende de él. En tercer lugar, la primacía del Poder legislativo, el principio de legalidad y la reserva de ley. En cuarto lugar, la subordinación del Poder legislativo al respeto de los derechos subjetivos constitucionalmente definidos. Y, por último, la autonomía del Poder judicial.

Más allá de los aspectos particulares de las diferentes tradiciones y de las concretas experiencias históricas, se puede afirmar que, desde distintas perspectivas, todas ellas están vinculadas de manera directa o tendencial a la operatividad del principio de difusión del Poder y del principio de diferenciación del Poder. Sin embargo, ambos principios son expresión, a su vez, de determinados presupuestos filosófico-políticos, sin los cuales toda la maquinaria institucional del Estado de Derecho pierde sentido. A partir de la afirmación de la primacía del valor del individuo, y de las exigencias subsiguientes de libertad y autonomía, Zolo resume el argumentario político y axiológico a través de la afirmación de dos tesis básicas: el pesimismo potestativo (*sic*) y el optimismo normativo¹⁶⁵. El pesimismo

¹⁶⁵ Vid. ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., pp. 35-37.

potestativo es el resultado de la influencia del liberalismo clásico y de la desconfianza que éste predica respecto al Poder político que, por definición, es entendido como peligroso respecto a las libertades individuales, pero que tiene que conjugar esta desconfianza con el convencimiento de la necesidad de su existencia y del ejercicio a la hora de procurar el orden y la estabilidad social. Como ha recordado Garzón Valdés, «el gran desafío teórico con el que se encuentra la teoría moral y política del liberalismo es cómo armonizar su suposición básica según la cual los individuos, en tanto seres autónomos, procuran formular sus planes de vida privilegiando la realización de sus propios intereses, con el establecimiento necesario de un orden social heterónomo que preserve esta autonomía»¹⁶⁶. El optimismo normativo, por su parte, es expresión de la creencia en la capacidad del Derecho de controlar, racionalizar y limitar el ejercicio del Poder político.

Pues bien, a partir de las anteriores reflexiones se puede llegar a determinadas conclusiones en relación con los elementos centrales de la idea de Estado de Derecho, que constituyen el mínimo común denominador de las diferentes tradiciones. Si bien es cierto que es una noción en ocasiones difícilmente reconducible, en sentido exclusivo y excluyente, al ámbito jurídico¹⁶⁷, es posible identificarlo, en lo que aquí nos interesa, como un mecanismo jurídico de limitación del Poder. Como veremos posteriormente, esta caracterización vale con independencia del concepto, formal o material, de Estado de Derecho que se mantenga, si bien es cierto que la opción por una u otra posibilidad repercute en la configuración e intensidad de los límites a los que se somete, en su caso el Poder político. La dimensión limitativa es imprescindible para comprender el

¹⁶⁶ GARZÓN VALDÉS, E., «Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho», *Claves de razón práctica*, n.º 101, abril 2000, p. 10.

¹⁶⁷ Vid. BARTOLOMEI, F., «Lo 'Stato di diritto' nel rapporto di tensione esistente tra legge e diritto», cit., p. 461, en donde se ha destacado la naturaleza plurianfibológica del término.

sentido del Estado de Derecho y es uno de los elementos que vincula este modelo con el Estado constitucional. En este sentido, un repaso a los temas recurrentes que aparecen y reaparecen a lo largo del desarrollo intelectual y jurídico del concepto, muestra la conexión del mismo con dicha dimensión limitadora¹⁶⁸.

2. ESTADO DE DERECHO FORMAL Y ESTADO DE DERECHO MATERIAL

2.1. Una caracterización inicial

Partiré de definiciones básicas y orientativas. El Estado de Derecho formal es aquel modelo de estructuración de las relaciones entre el Derecho y el Poder político, que afirma que éste se debe ejercer en el marco de las limitaciones formales establecidas por las normas jurídicas. El Estado de Derecho material o sustancial es aquel modelo de estructuración de las relaciones entre el Derecho y el Poder político, que afirma que éste se debe ejercer en el marco de las limitaciones formales y materiales establecidas por las normas jurídicas. Es evidente que estas definiciones exigen una ulterior profundización, que será desarrollada a lo largo de las páginas que siguen. En todo caso podemos utilizarlas desde este momento como criterios básicos de referencia. A partir de ellas, la tesis que me propongo desarrollar en lo sucesivo es la que afirma la mayor utilidad del concepto material de Estado de Derecho, determinada de modo principal por su sustantividad, que permite diferenciarlo de otras estructuras político jurídicas.

Antes de continuar, es necesario efectuar una aclaración sobre el sentido en el que se va a manejar la idea de *rule of law* en lo sucesivo. Anteriormente aludí a las dificultades de traduc-

¹⁶⁸ Vid. al respecto, COSTA, P., «Lo Stato di diritto: un'introduzione storica», cit., pp. 155 y ss.

ción de los términos que se manejan en este contexto. En efecto, *rule of law* en ocasiones es traducido como *Estado de Derecho*, mientras que en otras ocasiones lo es como *imperio de la ley*. En el marco de la tradición anglosajona, en la que se desarrolla la idea de *rule of law*, la misma se vincula, en términos generales, a la de imperio de la ley, es decir, al elemento suficiente de la comprensión formal del Estado de Derecho. Sin embargo, las concepciones substantivas o materiales del *rule of law* se pueden identificar con lo que aquí se comprende como Estado material de Derecho. Por ello, a lo largo del trabajo, las reflexiones doctrinales del *rule of law* que se tomen como referencia, podrán referirse, en función de su sentido, al Estado de Derecho formal —vinculado exclusivamente a las exigencias del imperio de la ley— o, en su caso, al Estado de Derecho material o sustancial.

Volviendo a la distinción entre Estado de Derecho formal y material, en realidad, la diferencia entre ambas concepciones del Estado de Derecho constituye un tópico al que la doctrina se refiere en múltiples ocasiones, con independencia de la opción por alguna de las dos alternativas¹⁶⁹. Así, por ejemplo, Paul P. Craig¹⁷⁰ caracteriza las concepciones formales como aquellas que centran su atención en los procedimientos a través de los cuales se han producido las normas, en la claridad del resultado normativo, y en la dimensión temporal (la ocasión

¹⁶⁹ G. MARSHALL se muestra contrario a la distinción entre conceptos formales y materiales del Estado de Derecho, prefiriendo hablar de comprensiones de su significado y ámbito de aplicación más amplias o restrictivas en «The Rule of Law. Its Meaning, Scope and Problems», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 24, 1993, pp. 43-44. No obstante, creo que ambos criterios son perfectamente compatibles entre sí y con la perspectiva defendida en este trabajo. F. VIOLA, por su parte, ha señalado que la distinción entre concepciones formales y materiales en este punto no es tajante desde el momento en que el principio de legalidad presenta un valor moral. Vid. *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 25-26.

¹⁷⁰ Vid. GRAIG, P. P., «Formal and substantive conceptions of the rule of law», *Diritto Pubblico*, vol. 1, 1995, pp. 35 y ss. También, SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 6, n.º 2, 1993, p. 135.

temporal, en términos de Von Wright) del mismo. Estas concepciones formales se caracterizan por no incidir, a la hora de examinar la satisfacción de las exigencias del Estado de Derecho, en los contenidos de las normas. Es decir, prestan atención a las cuestiones de quién manda y cómo se manda, pero no a la de qué se manda. Por el contrario, las concepciones sustanciales o materiales son más exigentes desde el momento en que van más allá que las anteriores, ya que para considerar satisfechas las condiciones del Estado de Derecho exigen la presencia de determinados contenidos en el Ordenamiento jurídico, básicamente en forma de derechos fundamentales. Prestan atención a la cuestión de qué se manda. Anteriormente, Ronald Dworkin había aludido a esta distinción aunque con una terminología diferente. En efecto, en el marco de la reflexión sobre el carácter político de las decisiones judiciales, distingue entre la *Rule-book conception* del *rule of law* y la *Rights conception* del mismo¹⁷¹. En el primer caso, se exige que los poderes públicos actúen en relación con los individuos de acuerdo con reglas explícitamente establecidas en textos accesibles a todos, y que dichas reglas sean transformadas de acuerdo con los criterios establecidos en esos textos. Pero lo que interesa subrayar en este momento es que estamos ante una concepción que no establece criterios en relación con el contenido de las normas que se incluyen en los textos. El de los criterios es un problema de justicia substantiva que, como tal, excede el ámbito de la *Rule-book conception*. Por eso, la *Rights conception* es más compleja y exigente, ya que implica una determinada concepción de los derechos y una propuesta normativa al respecto. La materialización y satisfacción de las exigencias de esta propuesta constituye un requisito indispensable, en este caso, del *rule of law*.

También es útil hacer referencia a la propuesta de Peces-Barba, en la que se señalan distintas comprensiones del con-

¹⁷¹ Vid. DWORKIN, R., *A Matter of Principle*, Harvard University Press, 1985, pp. 11 y ss. Vid sobre la cuestión, entre otros, ARCOS RAMÍREZ, F., *La seguridad jurídica. Una teoría formal*, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 373-376.

cepto de Estado de Derecho. Así, y reconociendo que nos movemos en el marco de las relaciones entre el Derecho y el Poder, el Estado de Derecho «puede ser entendido como la relación necesaria que en la cultura política y jurídica moderna tienen Derecho y Poder. Eso significa afirmar que todo Estado es un Estado de Derecho, porque en todo Estado se da el apoyo a la eficacia de su sistema jurídico, todo Derecho supone siempre regulación del uso de la fuerza del Poder»¹⁷². Como el mismo autor reconoce, esta concepción del Estado de Derecho es axiológicamente neutra y conceptualmente compatible de la misma manera con un régimen democrático o dictatorial, y además, «es poco relevante, no añade nada para la valoración de los tipos de poder ni suministra elementos adicionales a la legitimidad de ejercicio, que es, sin embargo, lo que interesa»¹⁷³. De otra parte, existe una segunda noción del concepto, que incluye determinados elementos normativos. A su vez, y en función de esos elementos, podemos identificar dos versiones: la versión normativa amplia y la versión normativa restringida. En la primera, «los rasgos identificadores son formales y se refieren a la acción limitadora que el Derecho ejerce sobre el Poder, racionalizando las expresiones de su voluntad, sometiénola al Derecho y separando las funciones del Poder para contrapesarlos entre sí. Así, se puede decir que el Estado de Derecho se caracteriza por el gobierno de las leyes y por la separación de poderes»¹⁷⁴; la segunda, «incluye dimensiones materiales, como el reconocimiento y la garantía de los derechos y, a su vez, según el tipo de derechos que se reconozcan, el Estado será liberal de Derecho, democrático de Derecho o social de Derecho...»¹⁷⁵.

¹⁷² PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R., (eds.), *Curso de Teoría del Derecho*, cit., p. 108. Vid también ID., *Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de siglo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995.

¹⁷³ *Ibidem*.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

En mi opinión, el concepto de Estado de Derecho debe ser entendido de acuerdo con el modelo normativo restringido de Peces-Barba. Varias razones se encuentran tras la anterior afirmación e irán apareciendo a lo largo de esta investigación. No obstante, en este momento nos podemos limitar algunas. Parece evidente que, a no ser que nos desenvolvamos en el marco de una comprensión aséptica, estructural y, por otra parte, aferrada a una comprensión estrictamente formalizada de los términos del lenguaje, carece de sentido en la actualidad hablar de Estado de Derecho en un sentido formal, similar al señalado en primer lugar por Peces-Barba, ya que, como reiteraré, dicho sentido formal elimina la sustantividad del concepto mismo y nos deja desarmados a la hora de diferenciar un Estado de Derecho de un Estado no de Derecho. Por otra parte, si bien la versión normativa amplia incluye exigencias que la diferencian de la anterior, tampoco sirven, en mi opinión, para individualizar y dotar de autonomía al concepto de Estado de Derecho, entre otras cosas, porque el imperio de la ley y la separación de poderes pueden ser comprendidos desde un punto de vista formal. Y, aunque, en efecto, el imperio de la ley y la separación de poderes están vinculados a determinados valores, no señalan necesariamente criterios en torno a la corrección de los contenidos jurídicos. Este modelo se identifica con una concepción estándar del *rule of law* como la defendida por Summers o Raz, como tendremos ocasión de observar con posterioridad. En definitiva, el Estado de Derecho en su versión normativa restringida incluye esos criterios de corrección, materializados en las normas de Derechos fundamentales. Va a ser esa inclusión la que contribuya a dotar de sustantividad al concepto y la que, además, nos permita por una parte, entender la vinculación que se establece entre Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia, y por otra, defender la tesis según la cual el Estado constitucional es una manifestación concreta del Estado de Derecho.

La distinción entre diversos sentidos del principio de legalidad desarrollada por Luigi Ferrajoli puede ser puesta en relación con la anterior reflexión. Ferrajoli, en el marco del análisis

del concepto de Estado de Derecho subraya, con acierto, la relación que se establece entre el citado concepto, y otra distinción, aquella entre gobierno *sub lege* y gobierno *per leges*¹⁷⁶. En el Estado de Derecho, la idea de imperio de la ley aúna los dos extremos de esta distinción. El imperio de la ley, en su dimensión de poder *sub lege* puede entenderse a su vez de dos maneras. Así, en un sentido débil («cualquier poder debe ser *conferido* por la ley y ejercido en las formas y procedimientos por ella establecidos») y en un sentido fuerte («cualquier poder debe ser *limitado* por la ley, que condiciona no sólo sus formas sino también sus contenidos»)¹⁷⁷. Pues bien, si el Estado de Derecho se vincula a la idea del poder *sub lege* en sentido débil, «son Estados de derecho todos los ordenamientos, incluso los autoritarios o, peor aún, los totalitarios, en los que en todo caso *lex facit legem* y el poder tiene una fuente y una forma legal»¹⁷⁸; por el contrario, el sentido fuerte permite considerar como Estado de Derecho a aquellos Estados, que Ferrajoli identifica con los Estados constitucionales, en cuyos escalones normativos superiores se incluyen contenidos materiales. En el primer caso, se maneja una idea del principio de legalidad entendida en sentido amplio o lato (la ley es condicionante), mientras que en el segundo, la referencia se hace al principio de legalidad en sentido estricto (en el que la ley se encuentra condicionada). Así, estableciendo una vinculación entre mera legalidad y legitimación formal, de un lado, y estricta legalidad y legitimación sustancial, de otro, afirma Ferrajoli que «el principio de mera legalidad se limita en realidad a exigir que el ejercicio de cualquier poder tenga por fuente la ley como condición *formal* de legitimidad; el principio de estricta legalidad exige por el contrario a la propia ley que condicione a determinados contenidos sus-

¹⁷⁶ Sobre la distinción, vid. BOBBIO, N., «Governo degli uomini o governo della legge», en ID., *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991, pp. 169 y ss.

¹⁷⁷ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 856.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

tanciales la legitimidad del ejercicio de cualquier poder por ella instituido»¹⁷⁹.

Por tanto, la concepción del principio de legalidad —expresión del imperio de la ley— que sirve para caracterizar el Estado de Derecho es la estricta, ya que la exigencia de mera legalidad es algo predicable del Derecho moderno considerado genéricamente: «La novedad del derecho moderno no radica tanto en los contenidos (extraordinariamente parecidos, en particular en el derecho privado, a los romanos), como sobre todo en la forma «legal», «convencional», o «artificial», es decir «positiva» del derecho vigente consiguiente a la nueva fuente de legitimación no ya la *veritas* sino la *auctoritas*. (...) *el principio de legalidad* viene a configurarse como el principio constitutivo de la experiencia jurídica moderna; (...) es efectivamente constitutivo del *moderno derecho* positivo y al mismo tiempo del moderno Estado de derecho»¹⁸⁰. La presencia de elementos sustanciales a los que está vinculado el legislador, y no la operatividad del mero principio de legalidad, es el criterio que permitiría distinguir al Estado «de Derecho» del Estado «legal». Esta diferencia, que en resumidas cuentas es la que en ocasiones se establece entre Estado de Derecho formal y Estado de Derecho material, justifica, la consideración exclusiva del segundo como auténtico Estado de Derecho.

Creo que una caracterización coincidente con la de Ferrajoli es la desarrollada por Riccardo Guastini. Afirma el profesor de la Universidad de Génova que el Estado de Derecho puede entenderse de varias maneras¹⁸¹. En primer lugar, el Estado de

¹⁷⁹ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 857. En un momento anterior de la obra (pp. 374 y ss.), Ferrajoli utiliza la distinción entre ambos criterios, amplio o restrictivo, de legalidad en aplicación al principio de legalidad penal; pero, como él mismo reconoce (p. 380) sirve para definir «la compleja estructura de la legalidad en el Estado de derecho».

¹⁸⁰ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 869.

¹⁸¹ Vid. GUASTINI, R., «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», en MONTANARI, B., (ed.), *Stato di diritto e trasformazione della politica*, Giappichelli Ed., Torino, 1992, p. 170.

Derecho es aquel en el que se garantizan los derechos de libertad de los ciudadanos; en segundo lugar, el Estado de Derecho se correspondería con aquel Estado en el que el Poder político está limitado por el Derecho; y en tercer lugar, se identificaría con aquel Estado en el que el ejercicio del Poder político está sometido al principio de legalidad. En realidad, así lo reconoce el propio Guastini, la segunda y la tercera versión son reconducibles a la unidad, desde el momento en que consideramos que el principio de legalidad es, en resumidas cuentas, una técnica de limitación del Poder. Por tanto, la tercera versión sería una manifestación específica de la segunda, pero no la única, ya que el Poder político también se puede limitar a través de técnicas de división, fragmentación o descentralización, o a través de la creación de contrapoderes¹⁸². En todo caso, nos interesa centrarnos aquí en el principio de legalidad entendido como el sometimiento del Poder a reglas y a controles (básicamente de tipo jurisdiccional) llevados a asegurar el cumplimiento de esas reglas y a suministrar reparaciones en caso de violación de esas reglas¹⁸³.

Señala Guastini que el principio de legalidad permite ser analizado desde dos perspectivas: desde la de su contenido y desde la de su extensión¹⁸⁴. A través de dichas perspectivas podemos acceder a diferentes consideraciones del Estado de Derecho. Desde la perspectiva del contenido, Guastini entiende

¹⁸² Vid. GUASTINI, R., «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», cit., p. 173.

¹⁸³ Así lo entiende R. GUASTINI en «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», cit., p. 173.

¹⁸⁴ No nos detendremos en este momento en el análisis de la extensión del principio de legalidad. Nos limitamos a señalar que Guastini identifica dos tipos de Estado de Derecho: un primer tipo («Estado de Derecho sin ulteriores especificaciones») es aquel en el que el principio de legalidad material es vigente sólo respecto al Poder ejecutivo; un segundo tipo («Estado constitucional de Derecho») es aquel en el que el principio de legalidad, vinculado a los contenidos de la Constitución) es operativo también frente al poder legislativo.

que el principio de legalidad es «aquel principio en virtud del cual la validez de un cierto acto jurídico está condicionada por normas jurídicas que disciplinan su ejercicio»¹⁸⁵. Esa disciplina, que se materializa mediante diferentes normas jurídicas, puede consistir en una autorización a través de normas de competencia que conceden a un sujeto el poder de llevar a cabo determinados actos (disciplina en sentido débil) o puede consistir también en la limitación, predeterminando, por ejemplo a través de obligaciones o prohibiciones, el contenido de ese acto (disciplina en sentido fuerte). En el primer caso se puede hablar de legalidad formal ya que se exige que todo acto del Poder político esté basado en el Derecho, desde el momento en que supone ejercicio de un poder derivado de una norma de competencia; en el segundo caso, se hace referencia a la legalidad material en la que, además de la exigencia anterior, se presuponen normas que disciplinan desde el punto de vista sustancial o material, el ejercicio de ese poder¹⁸⁶. Guastini afirma que ambas comprensiones del principio de legalidad se pueden identificar respectivamente con dos versiones del Estado de Derecho, una débil, que se refiere a un Estado en el que está vigente el principio de legalidad (sólo) formal, y una fuerte, en la que está vigente (además) el principio de legalidad material¹⁸⁷.

Pues bien, en esta investigación vamos a asumir la versión fuerte del Estado de Derecho, de acuerdo con la terminología y caracterización propuesta por Guastini. La versión débil, aquella en la que el poder normativo se ejerce en el marco de la competencia formal atribuida por normas habilitadoras superiores, sirve en realidad para describir lo que ocurre en cualquier Ordenamiento jurídico, con independencia de que se confirme como Estado de Derecho o no.

¹⁸⁵ GUASTINI, R., «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», cit., p. 174.

¹⁸⁶ Vid. GUASTINI, R., «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», cit., p. 175.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

A partir de la anterior reflexión se desprende que en este trabajo no se considera como auténtico Estado de Derecho el identificado con una concepción meramente formal del mismo, ni con una teoría estándar del *rule of law*. En este sentido, se va a defender una concepción sustancial del Estado de Derecho, construida a partir de dos elementos principales: el imperio de la ley (entendido en sentido amplio), y el reconocimiento, protección y garantía de los derechos fundamentales. Es decir, para poder identificar un modelo de estructuración jurídica del Poder político con el Estado de Derecho, los dos anteriores elementos son de necesaria concurrencia. Por tanto, con la diferenciación entre Estado de Derecho formal y Estado de Derecho material o sustancial, no se pretende aludir a la distinción entre un Estado que actúa a través del Derecho, de una parte, y un Estado que actúa a través de un Derecho superior, de otra¹⁸⁸, sino más bien a la distinción entre un Estado que meramente actúa a través del Derecho y un Estado que actúa mediante un Derecho caracterizado por la inclusión de contenidos específicos. La mera actuación a través del Derecho no es algo que sirva para caracterizar a un Estado frente a otros¹⁸⁹. En todo caso, sirve para distinguir a un Estado de otras instancias de toma de decisiones. La distinción, así entendida, entre el Estado de Derecho formal y el material permite comprender la afirmación de Michel Troper según la cual el Estado de Derecho es inevitable¹⁹⁰, que sólo tiene sentido si se está pensando en una concepción formal, de tipo kelseniano: afirmada la necesaria relación entre el Estado y el Derecho, el Estado de Derecho formal es inevitable, pero no lo es el Estado de Derecho material.

¹⁸⁸ Vid. TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., p. 29.

¹⁸⁹ B. Z. TAMANAHA se ha referido al carácter vacío de la legalidad formal en *On the Rule of Law. History, Politics, Theory*, cit., pp. 93 y ss.

¹⁹⁰ Vid. TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., pp. 33 y ss.

2.2. Sobre la insuficiencia del concepto formal

2.2.1. *Algo más que un modelo de relación entre el Derecho y el Poder*

A lo largo de este trabajo se defiende la conveniencia de tener en cuenta la importancia de la relación entre el Derecho y el Poder para analizar correctamente el sentido de la idea de Estado de Derecho. Esa ha sido la razón por la que en un momento anterior se ha elaborado una propuesta respecto a dicha relación. Pero centrar el análisis sobre el significado de la idea de Estado de Derecho exclusivamente en esa relación se muestra como una estrategia insuficiente. Ello porque, en primer lugar, la relación es imprescindible para captar el significado tanto del Estado como del Derecho en la modernidad. Y, en segundo lugar, porque aquí se defiende la tesis, que será desarrollada con posterioridad, según la cual la mera existencia del Derecho y un mínimo funcionamiento del mismo en términos de corrección funcional exige la satisfacción de las exigencias básicas del imperio de la ley, vinculadas a la positividad del Derecho. Es a esta idea a la que se refiere Ferrajoli cuando afirma que el principio de legalidad se presenta como «el principio constitutivo de la experiencia jurídica moderna». Si esto es así, se puede comprender que la mera existencia del Derecho, entendido como sistema de control social, implica unas determinadas dosis de limitación del Poder por parte del Derecho, por lo menos en la medida necesaria para que el sistema jurídico pueda actuar como criterio efectivo de guía de las conductas de los individuos. Por ello, hay que ir más allá de las exigencias establecidas por los instrumentos de limitación formal del Poder.

Ciertamente, la que podemos considerar como concepción canónica del *rule of law*, se nos presenta en realidad como una propuesta en torno a la relación entre el Derecho y el Poder. Me estoy refiriendo a la construcción elaborada por Albert Venn Dicey en 1885 en su libro *Introduction to the study of the Law of*

*the Constitution*¹⁹¹. El intento de Dicey es el de compatibilizar los dos principios que caracterizan la tradición constitucional inglesa, el de la supremacía del parlamento, de un lado y el del *rule of law*, entendido como «*rule or supremacy of law*», como «*the predominance of the legal spirit*»¹⁹², de otro. En efecto, cada uno de los tres sentidos que, según Dicey, pueden ser atribuidos al *rule of law*, puede ser considerado como una manifestación de la relación entre el Derecho y el Poder. En primer lugar, el *rule of law* es «la absoluta supremacía del Derecho como opuesta a la influencia del Poder arbitrario, y excluye la existencia de arbitrariedad o prerrogativa, o incluso amplia autoridad discrecional por parte del gobierno. Los ingleses son gobernados por el Derecho, y sólo por el Derecho: entre nosotros un hombre puede ser sancionado por infringir el Derecho, pero por nada más»¹⁹³. En segundo lugar, implica «la igualdad ante el Derecho, o la igual sujeción de todas las clases al Derecho ordinario del país, administrado por los tribunales ordinarios de justicia; en este sentido el *rule of law* excluye la idea de cualquier exención de los funcionarios u otras personas respecto al deber de obediencia al Derecho que obliga a otros ciudadanos o respecto a la jurisdicción de los tribunales ordinarios»¹⁹⁴. Por último, expresa el hecho de que en Inglaterra, «el Derecho de la Constitución, las reglas que en países extranjeros usualmente forman parte de un código constitucional, no es la fuente, sino la

¹⁹¹ Liberty Fund, Indianapolis, 1982. Vid sobre el tema, SANTORO, E., «*Rule of law e 'libertà degli inglesi'*. L'interpretazione di Albert Venn Dicey», cit., pp. 173 y ss. Y TUORI, K., *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, cit., pp. 212 y ss.

¹⁹² DICEY, A. V., *Introduction to the study of the Law of the Constitution*, cit., pp. 107 y 115, respectivamente. Sobre el desarrollo de estos dos principios, véase DORADO PORRAS, J., *La lucha por la Constitución. Las teorías del 'Fundamental Law' en la Inglaterra del siglo XVII*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

¹⁹³ DICEY, A. V., *Introduction to the study of the Law of the Constitution*, cit., p. 120.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

consecuencia de derechos de los individuos, tales y como éstos son definidos y aplicados por los tribunales». En los tres casos estamos ante manifestaciones de la relación entre el Derecho y el Poder, en su dimensión de limitación del Poder por parte del Derecho.

El análisis de las relaciones entre el Poder y el Derecho nos puede servir de marco en el cual identificar los tipos de Estado de Derecho entendidos como distintos modelos de estructuración de esas relaciones. Sabemos que el Estado moderno no se puede entender básicamente sino en conexión con el Derecho. Esa conexión se presenta como una concreta manifestación de la relación entre el Derecho y el Poder, considerada como imprescindible desde diversos planteamientos (entre los que destaca el positivista) para entender no sólo la existencia, sino también el funcionamiento del sistema jurídico. Esta dimensión se observa claramente en diversos autores como Norberto Bobbio, Elías Díaz o Gregorio Peces-Barba. Y es perfectamente compatible con la tesis del origen social de las fuentes del Derecho que Hart señala como una de las afirmaciones básicas del positivismo, junto con la de la separación conceptual entre el Derecho y la moral y la de la discrecionalidad judicial. En todo caso, si se utilizase de manera indiscriminada el escenario de las relaciones entre el Derecho y el Poder para identificar los modelos de Estado de Derecho, un positivista coherente estaría obligado a señalar como Estado de Derecho cualquier Estado, ya que en la modernidad la aludida relación es consustancial al Estado y al Derecho. De ser así las cosas, el Estado de Derecho perdería sustantividad, como hemos señalado líneas atrás. Este es el problema que se puede derivar de hacer depender el análisis descriptivo de las versiones del Estado de Derecho de «cómo se concibe la relación entre Poder y Derecho bien en la doctrina bien en un determinado Ordenamiento jurídico»¹⁹⁵. Es, en definitiva, el problema que se puede observar en aque-

¹⁹⁵ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 32.

llas propuestas de tipología del Estado de Derecho que se construyen a partir de la identificación de distintos modelos de articulación de la relación entre el Derecho y el Poder.

Entre nosotros, Rafael de Asís ha defendido la posibilidad de manejar un concepto formal del Estado de Derecho. En su libro *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, defiende la posibilidad de desarrollar, en relación con el concepto de Estado de Derecho, dos tipos de aproximaciones, la analítica y la histórica, y asimismo, dos perspectivas, la descriptiva y la prescriptiva. También se desarrolla la distinción entre dos tipos de concepciones del Estado de Derecho, las funcionalistas y las finalistas. Las primeras «se centran únicamente en el estudio de la función del Derecho como técnica normativa de control social, extrayendo de aquí una serie de características que lo definirían y que se trasladan por lo tanto a la relación entre Estado y Derecho»¹⁹⁶; las segundas, junto a lo anterior, «subrayan la necesidad de la consecución de determinados fines por el Derecho, con lo que aumentan las exigencias de su definición y, por ende, de las de la relación entre Poder y Derecho»¹⁹⁷. Por otra parte, las concepciones funcionalistas construyen un concepto de Estado de Derecho en el que la conexión con la moral es aleatoria («puede existir una conexión entre estado de Derecho y Moral pero sin que sea posible especificar los contenidos de moralidad»), mientras que las finalistas se refieren a modelos de Estado de Derecho en las que la conexión es cierta («la conexión cierta supone defender esa conexión identificando los contenidos de moralidad»)¹⁹⁸.

Rafael de Asís identifica determinados modelos de Estado de Derecho. Así, el modelo restringido es el del Estado «que actúa mediante una separación funcional de poderes, a través de normas, principalmente generales, y que lo limitan tanto por ser

¹⁹⁶ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 20.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 27.

emitidas y conocidas como por formar un conjunto unitario y coherente»¹⁹⁹; el modelo estricto se identifica con el Estado que «actúa mediante una separación funcional de poderes, a través de normas, principalmente generales, que protegen la autonomía individual, y que lo limitan tanto por ser emitidas y conocidas como por formar un conjunto unitario y coherente»²⁰⁰. Como se observa, este modelo se construye sobre la base del anterior, pero sus requisitos se justificarían en referencia a la defensa de la autonomía individual, lo cual supondría una conexión cierta entre el Estado de Derecho y determinados contenidos morales. Otros modelos forman parte a su vez del modelo amplio de Estado de Derecho. Así, por su parte, el modelo democrático es el del Estado «que actúa mediante la separación funcional de poderes, a través de normas, principalmente generales, fruto de la participación de los ciudadanos, y que lo limitan tanto por ser emitidas y conocidas como por formar un conjunto unitario y coherente»²⁰¹. El modelo liberal²⁰² considera que los derechos individuales van a ser objeto de protección, mientras que el modelo exigente²⁰³ estaría referido a los derechos individuales y a los sociales; el modelo garantista²⁰⁴ sería una versión del modelo exigente construido en torno a la figura del Estado constitucional.

El acierto o desacierto de esta clasificación puede observarse a la luz de la idea de legalidad selectiva —a la que ya se ha aludido—, como la legalidad propia del Estado de Derecho. La legalidad selectiva se asocia a unos determinados contenidos

¹⁹⁹ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 44.

²⁰⁰ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 54.

²⁰¹ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 64.

²⁰² Vid. DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 79.

²⁰³ Vid. DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 83.

²⁰⁴ Vid. DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 89.

materiales, de moralidad en definitiva, de manera que la presencia de dichos contenidos es la que permite identificar como tal a un Estado de Derecho. Esos contenidos de moralidad se juridifican en forma de derechos fundamentales. Si asumimos como cierta la necesidad de una legalidad selectiva en el Estado de Derecho, y en consecuencia reconocemos que sin dicha legalidad no hay Estado de Derecho, estamos obligados a admitir también que el Estado de Derecho implica una conexión cierta entre Derecho y moral —con independencia de que, en el interior de un marco moral general (la moralidad de los derechos), se proceda posteriormente a una concreción de esa moralidad en forma de diversas categorías o clases de derechos-. Por eso, no me parece que se pueda hablar de modelos de Estado de Derecho en los que exista una relación no cierta, sino aleatoria, entre Derecho y moral. El «modelo restringido de Estado de Derecho», tiene una legalidad —eso es evidente— pero esa legalidad no es necesariamente selectiva. Y pienso que esta puede ser una buena razón para no considerarlo como un auténtico Estado de Derecho. Dicho modelo, cuyas exigencias recuerdan a la moral interna del Derecho en la propuesta de Fuller, se refiere a condiciones que hacen posible la existencia, y el funcionamiento del Derecho. Esto vendría a reforzar la idea según la cual si son condiciones de existencia del Derecho (y no del Derecho correcto) entonces, si queremos dotar de autonomía y sustantividad a la idea de Estado de Derecho respecto a la de 'Estado' y a la de 'Derecho', no es correcto identificar un modelo de Estado de Derecho con aquellos rasgos que son imprescindibles para la existencia del Derecho. Son rasgos (la idea de sistema, la separación de poderes, el principio de legalidad en sentido amplio), que «se justifican por hacer posible su constitución [la del Derecho] como técnica normativa de control social, es decir, por permitir que la técnica previsiblemente sea eficaz»²⁰⁵. Si una técnica no es eficaz, entonces no sirve para

²⁰⁵ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 48.

nada y necesita ser abandonada. La consideración del Derecho como una técnica (y no como un arte) explica por qué es importante la vinculación entre validez y eficacia. Por otra parte, en relación con este modelo restringido, se contempla la posibilidad de la presencia de contenidos morales²⁰⁶, pero no se identifican, como en los otros modelos. Esta es una razón más que muestra que este modelo puede servir para explicar lo que es el Derecho, pero no para explicar lo que es el Estado de Derecho. La alusión a la conexión aleatoria entre el Derecho y la moral es realidad es aplicable al concepto de Derecho, pero no al del Estado de Derecho. En éste, la conexión es cierta. En realidad la idea de legalidad selectiva se explica a partir de esa conexión cierta, en la que las exigencias de los derechos fundamentales constituyen un componente importante y, es más, imprescindible.

Por lo anterior, sólo el modelo estricto y los modelos amplios, tal y como son presentados por Rafael de Asís, se podrían considerar como manifestaciones del Estado de Derecho. Las diferencias respectivas vienen determinadas por el concreto peso que se da a las dimensiones materiales, a partir del referente último de las mismas, constituido por la idea de autonomía (entendida como requisito de la dignidad), criterio último de fundamentación de los derechos.

2.2.2. *El imperio de la ley y el concepto de Derecho*

a) Sobre el valor de la existencia de las normas

Sabemos que son múltiples los mecanismos mediante los cuales pueden controlarse las conductas humanas. Es posible, por ejemplo, remitirse a la expresión de voluntad de aquel que tiene la suficiente capacidad para imponerla. Dicha expresión de voluntad no tiene por qué someterse necesariamente a algún

²⁰⁶ DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 50.

tipo de criterio, sino que puede vincularse al capricho o incluso al azar. Estaríamos frente al caso de un sujeto que controla y somete la actuación de los demás sin referencia a un determinado plan o esquema, remitiendo a lo que es la manifestación de su voluntad en el caso concreto y aislado, y no siendo posible identificar tipo alguno de relación entre las diversas órdenes o mandatos. Estamos frente a una decisión particular. Un mecanismo diametralmente opuesto al anterior, en su funcionamiento y en su sentido, es el que consiste en la ordenación de los comportamientos mediante la configuración de un sistema de reglas. Es en este sentido en el que podemos asociar la idea de Derecho a la existencia de un conjunto de reglas o normas²⁰⁷. Como Hart recuerda, «en cualquier grupo grande el principal instrumento de control social tiene que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales, y no en directivas particulares impartidas separadamente a cada individuo. Si no fuera posible comunicar pautas generales de conducta, que sin necesidad de nuevas instrucciones puedan ser comprendidas por multitudes de individuos como exigiéndoles cierto comportamiento en ocasiones determinadas, no podría existir nada de lo que hoy conocemos como Derecho»²⁰⁸.

Se podría señalar, con razón, que la exclusiva identificación del Derecho como un conjunto de reglas simplifica en exceso la configuración interna del mismo. Es cierto que la Teoría del Derecho contemporánea ha dedicado parte de sus más relevantes esfuerzos a demostrar que el Derecho tiene un mayor nivel de complejidad, lo cual no se ignora en absoluto en este trabajo. Si en esta ocasión se ha optado por la vinculación entre el Derecho y las reglas (o las normas) es porque se ha querido explicitar, aún corriendo el riesgo de incurrir en un posible reduccionismo, en la necesaria conexión entre la idea de Derecho y la existencia de patrones o modelos de comportamiento.

²⁰⁷ Parece innecesario apuntar aquí que, más allá de otras posibilidades de comprensión, la noción de regla se considera en este punto sinónima de la de norma.

²⁰⁸ HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, cit., p., 155.

En este sentido, la idea de regla se puede entender, dentro del género de lo normativo, como un tipo al respecto.

La noción de regla implica la existencia de un criterio de regulación del comportamiento, asociado a la idea de regularidad. La regla ordena comportamientos mediante criterios de regularidad. La existencia de una regla supone la existencia de criterios de comportamientos que afectan de manera igual a todos los sujetos que se encuentran en una misma situación. Ello implica que cada uno de estos sujetos va a poder tener conocimiento del comportamiento que se le va a exigir en caso de que se encuentre en una cierta situación, y además va a poder saber también que esa circunstancia es predicable de la misma manera de todos los sujetos que se encuentran en casos similares. Por eso, si la finalidad de la regla es la de regular el comportamiento, mediante el establecimiento de modelos o patrones de actuación perceptibles por los sujetos, una regla secreta incumple de manera evidente esta finalidad.

En principio, nada impide que el mecanismo de la decisión particular pueda tener una cierta efectividad a la hora de controlar las conductas. Ello, siempre y cuando pudiera existir un sujeto lo suficientemente capaz de tomar decisiones necesariamente diferentes en un contexto plural. No obstante los argumentos a favor de un mecanismo de toma de decisiones basado en reglas parecen más relevantes. Y ello no sólo por lo que se refiere a las mayores posibilidades de los sujetos de ajustar sus comportamientos al patrón establecido en la regla, sino también por lo que afecta a la capacidad normativa de la autoridad. Parece que el establecimiento de un sistema de reglas exige a la autoridad que se encuentra tras él de la labor de determinación particularizada de los rasgos concretos de todas aquellas situaciones concretas que se pretenden ordenar.

F. Schauer ha señalado determinadas razones a favor de un sistema regulador de las conductas humanas basado en reglas²⁰⁹.

²⁰⁹ Vid. SCHAUER, F., *Playing by the rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 135 y ss.

Así, en primer lugar, alude a la imparcialidad (*fairness*). La existencia de reglas generales está vinculada al carácter impersonal de las mismas. Las reglas regulan situaciones, abstracción hecha de los elementos particulares que concurren. La generalidad de las reglas permite despersonalizar las situaciones que las reglas están llamadas a regular. En ese sentido, Schauer señala que un sistema de toma de decisiones basado en reglas, permite adoptar decisiones tomando en consideración lo que un individuo es o lo que un individuo hizo, pero no quién es ese individuo. En definitiva, las reglas constituyen obstáculos frente a la particularización.

La regulación de conductas y casos de acuerdo con reglas tiene como efecto la no consideración de las diferencias entre las situaciones. En ocasiones se pueden tratar de manera semejante situaciones que no lo son del todo. Las reglas generales pueden tener como efecto marcar diferencias entre los casos que no son relevantes y, de la misma manera, considerar de manera similar circunstancias que en lo esencial justificarían diferencias de trato. La segunda de las razones a favor de los sistemas de adopción de decisiones basados en reglas, es el referido a la confianza que éstas generan. En efecto, un sistema de ordenación de las conductas mediante reglas, permite que los sujetos conozcan los criterios de comportamiento, de un lado, y conozcan las consecuencias que se van a derivar de la observancia o inobservancia de esos criterios. En este sentido, la confianza es el resultado de la certeza y de la predictibilidad.

La confianza generada por la existencia de reglas implica la presencia de una comunidad de comprensión entre el sujeto encargado de dictar la regla y el sujeto que va a seguirla. Se quiere decir con ello que ambos sujetos deben compartir la capacidad para identificar casos concretos como integrantes de una categoría. Para que la regla que prohíbe fumar tenga la capacidad de generar confianza en el sentido indicado, es necesario que el destinatario de la misma esté en condiciones de identificar una determinada actuación como un caso de la categoría «fumar». Pero es necesario al mismo tiempo que ambos sujetos, autoridad y destinatario, perciban las mismas actua-

ciones como casos de la categoría ‘fumar’. Esa comunidad de comprensión es exigida por la confianza, con independencia las opiniones personales o de los juicios que merezcan las acciones a las que se refiere la regla, en este caso, el consumo de tabaco. Por eso, el proceso de simplificación implícito en esa comunidad de comprensión, es especialmente relevante en aquellos casos en los que autoridad y destinatario tienen distintas percepciones, no necesariamente resultado de una valoración, del caso al que se refiere la regla en cuestión.

El argumento basado en la eficiencia también merece ser tenido en cuenta. La existencia de un sistema de toma de decisiones basado en reglas libera a los individuos de considerar todas y cada una de las circunstancias que debe tener en cuenta para actuar en cada caso. Así, por ejemplo, la existencia de una regla sobre el tipo de traje que se debe vestir en una determinada ocasión, exime al sujeto afectado de considerar un conjunto de circunstancias o factores concurrentes antes de tomar la decisión sobre cómo ir vestido. En cierto sentido, se produce una transferencia de responsabilidad hacia el sujeto productor de la regla, aligerando el caudal de cálculos y consideraciones que debe llevar a cabo el sujeto que se propone actuar, lo cual es relevante desde el momento en que normalmente es difícil que tengamos la capacidad, o estemos en disposición, de tomar decisiones «all things considered». La restricción, no por imposible sino por innecesaria, de esas consideraciones tiene como consecuencia la disminución de las posibilidades de error. La capacidad de cometer errores puede obedecer a déficits de conocimiento o a la existencia de predisposiciones, imparcialidades o tendencias. Por eso, el argumento referido a la aversión al riesgo, al que también alude Schauer, debe ser puesto en relación con el argumento referido a la eficiencia.

Junto a lo anterior, también hay que recordar que la existencia de un sistema de decisiones basado en reglas produce estabilidad. Cuando en este momento hablamos de estabilidad, debemos ser conscientes de que podemos hacer referencia tanto a los sujetos que producen las reglas, como aquellos llamados a seguirlas. En el primer caso, la producción de una regla

en el marco de un sistema basado en reglas va a constituir una actividad guiada a su vez por reglas. En este sentido, la capacidad de sorpresas en relación con el contenido de la regla disminuye, desde el momento en que se produce un estrechamiento, recuerda Schauer, del potencial ámbito de decisiones y las alternativas al status quo decrecen en relación con aquella situación en la que el sujeto llamado a decidir no se encuentra vinculado a reglas. En relación con el destinatario de las reglas, éstas materializan un ámbito en el que es posible actuar y programar comportamientos.

Pero el seguimiento de reglas tiene efectos que van más allá de aquellos que pudieran afectar al sujeto particular. Si trasladamos la reflexión al punto de vista colectivo, podemos llegar a la conclusión de que, en efecto, las normas —o mejor dicho, el seguimiento de las normas— son relevantes a la hora de conseguir determinados resultados en el ámbito de las acciones colectivas²¹⁰. Tanto Jon Elster como Carlos Nino, entre otros, ofrecen útiles consideraciones al respecto.

Jon Elster ha señalado que, a partir de la comprensión de dos diferentes nociones del orden social, la idea de desorden social se puede entender también de dos maneras diferentes²¹¹. En primer lugar, si el orden social se entiende de acuerdo con la configuración de conductas estables, regulares y predecibles, el desorden tiene como una de sus causas la imposibilidad de predecir comportamientos. En segundo lugar, entendido el orden social como la existencia de conductas cooperativas, el desorden estaría asociado a la falta de cooperación. Según Elster, las dificultades de predicción de los comportamientos pue-

²¹⁰ Es en este ámbito en el que cabe plantearse la cuestión —que supera las pretensiones de este trabajo— de la necesidad del sistema jurídico, y en el que la razón práctica individual puede mostrar sus insuficiencias a la hora de guiar las conductas de los sujetos. Vid. SUMMERS, R. S., «The practical and theoretical importance of the formal character of law», *Rechtstheorie*, 30, 1999, p. 305.

²¹¹ Vid. ELSTER, J., *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, trad. de A. L. Bixio, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 13 y ss.

den depender tanto de un defecto como de un exceso en la información de la que disponen los sujetos. En efecto, en ocasiones los individuos carecen de la información necesaria sobre las acciones que los demás llevarán a cabo y por tanto están imposibilitados para predecir comportamientos de éstos. Y de la misma manera, también carecen de guías de conducta en relación con sus propios comportamientos. En otras ocasiones, el exceso de información, puede dificultar la adopción de decisiones. Ello es debido a que, en algunos casos, la capacidad de procesamiento de la información por parte del sujeto es insuficiente respecto al caudal de la misma. En todo caso, tanto si existe falta de información como si se produce exceso, se genera desestabilización.

En lo que hace referencia a las conductas cooperativas, Elster hace referencia a cinco tipos: las circunstancias exteriores, las conductas de asistencia y ayuda, los equilibrios de convención, las empresas colectivas y las acciones privadas. En el caso de las *circunstancias exteriores*, hablamos de actos individuales de cooperación que aportan beneficios a todos. Pensemos, por ejemplo en la acción consistente en limpiar los jardines públicos o en donar sangre. Como señala Elster, «aunque los beneficios directos para el que coopera sean demasiado pequeños para motivarlo a actuar, puesto que la cooperación tiene sus costos, es mejor para todos si todos (o por lo menos algunos) cooperan que el hecho que nadie coopere»²¹², habida cuenta, entre otras cosas, de que los beneficios derivados de la participación superan en mucho a su coste. Respecto a las *conductas de asistencia o ayuda*, como decir la verdad, cumplir una promesa, o ayudar al vecino a recoger una cosecha, señala Elster, es posible que no supongan un beneficio directo y evidente para aquel que coopera, pero, en todo caso, «si todos ayudan a los demás, en el caso de que puedan hacerlo a ligero costo, todos se beneficiarán más que cuando nadie presta ayuda a los

²¹² ELSTER, J., *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, cit., p. 24.

demás»²¹³. Los *equilibrios de convención* se producen allí donde ninguno de los participantes que en una convención puede salir beneficiado se aparta, de manera unilateral, del acuerdo; al mismo tiempo, se acepta que nadie desea que los otros se excluyan del acuerdo. Pensemos por ejemplo en la regla de tráfico que señala que hay que conducir por la derecha. Las *empresas colectivas* son aquellas en las que la colaboración física de los sujetos se muestra como imprescindible para generar un resultado cooperativo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una cadena de producción organizada de acuerdo con el principio de división del trabajo. Por último, las *acciones privadas*, facilitan «acuerdos recíprocamente beneficiosos que dependen no de la colaboración física sino de la voluntaria transferencia de derechos con el fin de llegar a un excedente»²¹⁴. En efecto, no implican a diferencia de las empresas colectivas, una colaboración física, si bien, recuerda Elster, suelen ser el preludio de aquellas. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso en el que un obrero transfiere al empresario su fuerza de trabajo como paso previo a la prestación laboral.

Pues bien, aunque puede que la nómina de comportamientos cooperativos a los que alude Elster pueda ser complementada con otros, pienso que es posible llegar a la conclusión de que la intervención de normas en todos ellos facilita la cooperación y el logro de las finalidades (particulares o compartidas) de los sujetos que participan en los mismos.

Por su parte, Carlos Nino demostró hasta qué punto un fenómeno de ilegalidad masiva, como el que ha podido caracterizar prolongados períodos de la historia política, social y jurídica de su país natal, Argentina, tiene como resultado situaciones de ineficiencia, subrayando de esta manera la importancia que tiene el seguimiento de normas en las acciones colecti-

²¹³ ELSTER, J., *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, cit., p. 25.

²¹⁴ ELSTER, J., *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, cit., p. 28.

vas. En efecto, para Nino existe una clara relación entre la observancia de las normas jurídicas y sociales y el desarrollo de una sociedad, de manera que un fenómeno de ilegalidad masiva, donde concurren conductas contrarias a las normas y una determinada actitud hacia ellas, consistente en la ignorancia, o el desprecio, de los fines perseguidos por ellas, produce situaciones de ineficiencia y subdesarrollo. Así, defiende la tesis según la cual «la existencia de *determinadas* normas es, en general, condición *necesaria* para desarrollar acciones colectivas eficientes»²¹⁵.

Nino explicó las causas del subdesarrollo argentino en términos de anomia en general y de ilegalidad en particular, esto es, en referencia al incumplimiento de normas morales, jurídicas y sociales. La ilegalidad puede ser de varios tipos. En primer lugar, podemos hacer referencia a la desviación individual; en segundo lugar, al conflicto social cuando un determinado sector desconoce la legitimidad de la autoridad que dicta las normas; en tercer lugar, a lo que Nino considera la ilegalidad o anomia «boba», referida a situaciones sociales en las que todos los sujetos resultan perjudicados por la ilegalidad. En este caso, no se está aludiendo al incumplimiento de normas originado en la persecución de intereses no satisfechos por las normas. Se hace referencia a «la inobservancia de las normas que producen una cierta disfuncionalidad en la sociedad, de acuerdo con ciertos objetivos, intereses o preferencias»²¹⁶.

Pues bien, en opinión de Carlos Nino, este tipo de anomia boba produce ineficiencia. La relación entre la anomia y la ineficiencia se produce allí donde se incumplen normas que se

²¹⁵ NINO, C. S., *Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino*, Emecé, Buenos Aires, 1992, p. 176.

²¹⁶ NINO, C. S., *Un país al margen de la ley*, p. 31. Sobre el papel que juegan las reglas como instrumentos de coordinación en un contexto comunitario en el que los individuos interactúan, vid. SCHAUER, F., *Playing by the rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, cit., pp. 162-166. Y LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, Trotta, Madrid, 2007, pp. 39 y ss.

necesitan para conseguir determinados objetivos que pueden ser individuales y/o sociales. Parece evidente que no en todos aquellos casos en los que se incumplen normas necesarias para satisfacer fines individuales se puede hablar de anomia. En este caso se podría hablar de irracionalidad por parte de un agente que, sabiendo que una actuación en determinado sentido le asegura alcanzar un fin u objetivo pretendido— de acuerdo con lo establecido en la norma— procede de manera diferente a lo establecido en ella. Por eso, Nino amplía el ámbito del concepto y lo extiende al conjunto social: «Podríamos decir que hay situación anómica cuando un grupo de individuos tienen intereses tales que sólo pueden satisfacerse si todos ellos cumplen con una cierta norma, y un grupo significativo de tales individuos no cumplen con esa norma»²¹⁷. Es decir, Nino considera que una acción colectiva²¹⁸ está afectada por anomia boba cuando es menos eficiente que cualquier otra acción colectiva que, en la misma situación, observara una determinada norma. En este sentido, cabe subrayar que la anomia no se produce siempre allí donde se incumplen normas, sino sólo donde se incumplen normas existiendo por lo menos una que permitiría lograr una mayor eficiencia de la acción colectiva: «una acción colectiva en que se observara alguna norma puede ser ineficiente pero no anómica. Y una acción en que no se observara ninguna norma pero no hay una norma asequible que condujera a una acción colectiva más eficiente para satisfacer los intereses de los participante tampoco es anómica»²¹⁹.

No obstante, y esto es algo que también recuerda Nino, la eficiencia no es el único criterio de evaluación aplicable a las normas. Las consideraciones de justicia son conceptualmente

²¹⁷ NINO, C. S., *Un país al margen de la ley*, p. 34.

²¹⁸ Entendida como «un conjunto de determinadas acciones de diversos individuos que tienen fines que no son lógicamente incompatibles y que requieren de la acción o de la omisión de los demás individuos» *op. cit.*, p. 35. NINO considera al Derecho como una acción colectiva en *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., pp. 51 y ss.

²¹⁹ NINO, C. S., *Un país al margen de la ley*, p. 37.

independientes e incluso superiores desde un punto de vista moral respecto a los criterios de eficiencia. Lo anterior es cierto aunque de hecho, en muchas ocasiones, ambos criterios pueden estar vinculados. Así, si un Ordenamiento impone prescripciones justas, la eficiencia derivada del cumplimiento de las normas redunda en la justicia²²⁰.

En definitiva, las normas son instrumentos útiles a la hora de solventar problemas de cooperación social, en situaciones de interacción en las que el logro de objetivos y fines no dependen exclusivamente de actuaciones particulares, y en donde son imprescindibles esquemas de cooperación. Las normas que regulan el tráfico constituyen al respecto un ejemplo sencillo y claro. Las normas, en este sentido, desarrollan su capacidad de facilitar la eficiencia en el contexto de acciones sociales desde el momento en que, de un lado, aseguran expectativas y, de otro, modifican las preferencias de los sujetos²²¹. En efecto, el hecho de que una norma esté respaldada por la amenaza de una sanción, positiva o negativa, puede provocar en el individuo una reconsideración de las alternativas de acción y de las preferencias. Por otra parte, como ya hemos señalado en un momento anterior, la mera existencia de las normas implica la existencia de un esquema de regularidad y de previsibilidad de comportamientos, que el individuo puede considerar a la hora de programar sus actuaciones y de prever respuestas a las mismas.

Pero las consecuencias de la anomia no se reducen sólo a la dificultad de la cooperación social o a la ineficiencia en el ámbito de las acciones colectivas. Además, como ha recordado Dahrendorf, la anomia entendida como aquella situación en la

²²⁰ Vid. al respecto, CALSAMIGLIA, A., «Justicia, eficiencia y optimización de la legislación», en *Racionalidad y eficiencia del Derecho*, Fontamara, México, 1993; HIERRO, L., «Justicia, igualdad y eficiencia», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 2, 1998, pp. 145 y ss.

²²¹ Vid. NINO, C. S., *Un país al margen de la ley*, pp. 176 y 177.

que las violaciones de las normas quedan impunes, genera incertidumbre e inseguridad: «La gente ya no puede prever si su vecino les va a matar o a darles su caballo. Las normas parecen haber dejado de existir o, si son invocadas, resultan ser inofensivas. Todas las sanciones parecen haberse marchitado. Ello, a su vez, hace referencia a la desaparición del poder o, más técnicamente, a la transformación de la autoridad legítima de nuevo en poder desnudo y arbitrario. Difícilmente es este un estado en el que alguien desearía vivir. Es probable que los hombres no pudieran sobrevivir en él mucho tiempo»²²².

b) Una concepción formal del imperio de la ley

La noción de imperio de la ley, al igual que la de *rule of law*, es confusa y permite diferentes comprensiones. Marina Gascón ha identificado diferentes significados de la expresión²²³. Para ello, parte de la distinción de dos acepciones de «ley». En el primer caso, cuando se habla de ley en sentido amplio se hace referencia a todo el Derecho producido por el Estado y formulado en términos lingüísticos, con independencia de las instituciones concretas y determinadas que los produzcan. En segundo lugar, en sentido estricto, la ley es una determinada fuente que ocupa una concreta posición en la jerarquía de las mismas y que ha sido producida por el Parlamento en un sistema democrático. Y de la misma manera, se puede aludir a tres significados de ‘imperio de la ley’. En el primer caso, el imperio de la ley se vincula al efectivo cumplimiento del Derecho, a la eficacia de la ley, a partir de los comportamientos de sus destinatarios, entendidos en sentido amplio, es decir, funcionarios y ciudadanos. En el segundo caso, se hace referencia al principio de legalidad, es decir, a la actuación de los poderes públicos de acuerdo con patrones jurídicos establecidos. El principio de

²²² DAHRENDORF, R., *Ley y orden*, trad. de L. M. Díez-Picazo, Cívitas, Madrid, 1994, p. 44.

²²³ Vid. GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», *Jueces para la democracia*, n.º 32, 1998, pp. 26-27.

legalidad afecta, así, al Gobierno y a la administración, al legislativo y al judicial; e implica un uso de la idea de ley en sentido amplio. Y en el tercer caso, el imperio de la ley se define a partir de la posición privilegiada que ocupa la ley, como fuente específica, en la jerarquía de las fuentes y es una manifestación de la carga de legitimidad del Parlamento, órgano productor de la ley.

Liborio Hierro también se ha referido a la cuestión de la conceptualización del imperio de la ley²²⁴. Parte de la consideración, de acuerdo con Laporta (vid infra) del sentido ético del imperio de la ley, como mecanismo jurídico que tiende a asegurar las exigencias del principio de autonomía. Así, la idea según la cual el imperio de la ley es una exigencia ética puede ser interpretada de dos maneras. Cabe, en primer lugar, una interpretación débil que no toma en cuenta el origen de la ley y que se centra en la estructura de la misma y en su aplicación. Frente a ésta, una interpretación fuerte es aquella, como la de Elías Díaz²²⁵, que vincula el imperio de la ley al origen democrático de la misma. Es claro que de esta interpretación fuerte se derivan determinadas consecuencias morales, en lo que se refiere a la justificación de la obediencia a la ley. Pero ello no quiere decir, añade Liborio Hierro, que la interpretación débil carezca en absoluto de repercusiones morales. Por el contrario, reconoce que «la tesis débil parece seguir defendiendo la superioridad moral de la legalidad frente a la arbitrariedad, lo cual no parece estar hoy en cuestión; la tesis fuerte parece seguir defendiendo la superioridad moral de la voluntad general (democracia) frente a cualquier forma de autoritarismo (tiranía u oligarquía), lo que todavía está, desgraciadamente, en cuestión»²²⁶.

Pues bien, las anteriores caracterizaciones del imperio de la ley pueden sernos de utilidad a la hora de identificar la idea del

²²⁴ Vid. HIERRO, L., «El imperio de la ley y la crisis de la ley», ID., *Estado de Derecho. Problemas actuales*, Fontamara, México, 1998, pp. 17 y ss.

²²⁵ Vid. DÍAZ, E., *Estado de Democrático y Sociedad democrática*, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1973.

²²⁶ HIERRO, L., «El imperio de la ley y la crisis de la ley», cit., p. 21.

mismo que se asume en este trabajo. En este sentido, se defiende una concepción formal del imperio de la ley. Imperio de la ley es imperio del Derecho²²⁷. Es decir, no focalizamos nuestra atención en una norma concreta y determinada, caracterizada y diferenciada tanto en lo que se refiere a su origen como en lo que se refiere a su contenido. Por lo tanto se comparte el primer sentido de 'ley' al que alude Marina Gascón. Por otra parte, el imperio de la ley, así entendido, no extiende su ámbito de operatividad exclusivamente en relación con los funcionarios o, más en general, con los poderes del Estado. Al contrario, todos, ciudadanos y poderes, se encuentran vinculados a la ley en el sentido en que aquí se entiende²²⁸. Sólo así se puede pensar en la eficacia del Derecho, incomprensible, al mismo tiempo, sin la efectividad del principio de legalidad, cuyo ámbito de operatividad es más reducido que el del imperio de la ley, ya que aquel afecta sólo a la acción de los poderes públicos.

No se defiende por tanto, una concepción del imperio de la ley que pudiéramos considerar material, y que subrayara el carácter privilegiado de una fuente específica como es la ley. No quiere decirse con ello que se desconozca lo que bien podríamos considerar un plus de legitimidad de la ley respecto a otras fuentes del Derecho como resultado de su origen (todo ello, claro está, en un contexto democrático, caracterizado por la participación). Pero el imperio de la ley tiene un significado más amplio. Pretende ser operativo en cualquier sistema jurídico con independencia del contenido de las normas que forman parte de éste. Se podría afirmar que el imperio de la ley —entendido repito, como imperio del Derecho— pretende ser

²²⁷ Conviene aclarar que no estoy refiriéndome al imperio de la ley como elemento del Estado de Derecho —en donde se justifica la interpretación fuerte defendida por Elías Díaz— sino a una consideración del mismo que trasciende al Estado de Derecho como modelo específico de la relación entre el Derecho y el Poder.

²²⁸ Una concepción restrictiva el imperio de la ley en el sentido de que se refiere sólo a los actos del Estado es la de R. GUASTINI, «Implementing the Rule of Law», *Analisi e diritto*, 2001, p. 95.

un rasgo del Derecho, y no sólo de los sistemas jurídicos democráticos en donde se pueden identificar con claridad dimensiones de legitimidad que refuerzan la obligatoriedad moral del sistema.

Por otra parte, como veremos, y como también recuerda Liborio Hierro, la defensa de una concepción formal o estructural del imperio de la ley, como la que aquí se asume, no clausura el problema del valor moral. Summers ha señalado que una cosa es la institucionalización formal de las exigencias del imperio de la ley y otra diferente los valores a que éste sirve²²⁹. La estructuración de un sistema jurídico, y de sus componentes, de acuerdo con las exigencias y principios del imperio de la ley, contribuye a configurar contextos, caracterizados por la predecibilidad, en los que tanto poderes como individuos están llamados a desarrollar sus conductas. Pero sobre esta cuestión regresaré posteriormente.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, el punto de partida de la comprensión del imperio de la ley puede estar constituido por la idea según la cual los poderes públicos y los individuos deben estar sometidos a las normas jurídicas. Dicho sometimiento es imprescindible para que el Derecho cumpla su función básica que es la de constituir una guía de los comportamientos de los sujetos. Y para que esto sea así, el Derecho debe estar constituido de una determinada manera, debe tener una determinada forma. En este sentido, es provechoso un análisis formal del imperio de la ley y de sus requisitos o principios. Un análisis formal del imperio de la ley tiene determinadas ventajas: en primer lugar, permite observar la conexión entre la satisfacción de sus exigencias y la existencia de un sistema jurídico; en segundo lugar, y en directa vinculación con lo anterior, permite constatar la insuficiencia de un concepto formal de Estado de Derecho basado exclusivamente en el imperio de la ley y en sus exigencias; en tercer lugar, una teoría formal

²²⁹ Vid. SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», *Ratio Juris*, vol. 6, n.º 2, 1993, p. 131.

del imperio de la ley es políticamente neutral, es «de-sustantivizada» y es aplicable por tanto a cualquier sistema jurídico²³⁰.

Es cierto que la aportación de Fuller y el debate intelectual que protagonizó con Hart constituye posiblemente la referencia a la hora de analizar la cuestión de la forma en la que debe estar constituido el Derecho y de las consecuencias que se derivan de la satisfacción de determinados requisitos formales tanto en lo que se refiere a la constatación de la existencia misma del Derecho como a la evaluación moral que se deriva de su satisfacción. No obstante, no me voy a centrar en esta ocasión en una relectura de la propuesta de Fuller en relación con la moral interna del Derecho, que, por otra parte, ha sido convenientemente estudiada entre nosotros²³¹. Me interesa por el contrario subrayar algunas dimensiones vinculadas a la naturaleza formal del Derecho, que considero básicas a la hora de comprender su sentido y su funcionamiento. Dichas dimensiones afectan de lleno a la idea de imperio de la ley que se mantiene en estas líneas.

En varios de sus escritos, Robert S. Summers ha defendido la naturaleza formal del Derecho y más en particular del imperio de la ley²³². La importancia del análisis formal del Derecho

²³⁰ Vid. SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», cit., pp. 136-137.

²³¹ Vid. ESCUDERO ALDAY, R., *Positivismo y moral interna del Derecho*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, y el debate que el autor mantiene con los profs. Rodríguez Toubes y García Manrique en *Derechos y Libertades*, n.º 10, 2001 (GARCÍA MANRIQUE, R., «Acerca de la moralidad intrínseca del Derecho», pp. 199 y ss.; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J., «La relevancia conceptual y valorativa de la moral interna del Derecho», pp. 215 y ss.; ESCUDERO ALDAY, R., «La moral interna del Derecho como objeto de debate (Respuesta a J. Rodríguez-Toubes y R. García Manrique)», pp. 233 y ss.). También ESCUDERO ALDAY, R., «Argumentos para la recuperación de la teoría de Lon L. Fuller», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIX, 2002, pp. 309 y ss.; ARCOS RAMÍREZ, F., *La seguridad jurídica. Una teoría formal*, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 122 y ss.; ID., «Una defensa de la moral interna del Derecho», *Derechos y libertades*, n.º 9, 2000, pp. 35 y ss.

²³² Vid. SUMMERS, R. S., «The Ideal Socio-Legal Order. Its «Rule of Law» Dimension», *Ratio Iuris*, vol. 1, n.º 2, 1988, pp. 154 y ss. (un comentario

viene determinada, entre otras circunstancias, por el hecho de que el Derecho es un sistema de normas o reglas. En este sentido, Summers denuncia el hecho de que, así como la doctrina se ha ocupado de analizar las funciones o la naturaleza de las reglas, no ha mostrado demasiada atención a la cuestión de la forma de las mismas. Una consideración completa del significado de una regla depende del análisis tanto de su forma como de su contenido. La forma, así, constituye el substrato básico que permite identificar y reflexionar posteriormente en relación con el contenido. Para Summers, «la forma general de una regla es un tipo particular de arreglo organizacional prescriptivo que incorpora contenidos relativos a una materia (*subject-matter contents*)»²³³. Es posible diferenciar dos dimensiones de una regla: una regla-forma y una regla-contenido. En el segundo caso, hacemos referencia a los valores o a las políticas que se pretenden implementar a través de la regla-forma.

La forma básica de una regla depende de unas características mínimas que, según Summers, son las siguientes²³⁴: 1) una regla se expresa o se puede expresar a través de alguna formulación lingüística; 2) la expresión de la regla, de manera directa o indirecta, permite, exige, prohíbe, o guía de alguna manera una acción; 3) la regla es general en alguna de sus dimensiones; 4) la regla está definida de alguna manera; 5) la regla es, al

a este artículo puede encontrarse en REYNOLDS, N. B., «Comment on Robert Summers on the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 1, n.º 3, 1988, pp. 263 y ss); «On analyzing and characterizing the General Style of a legal system as a formal or as substantive», *Rechtstheorie*, 23, 1992; «A formal Theory of the Rule of Law», cit.; «The Juristic Study of Law's Formal Character», *Ratio Iuris*, vol. 8, n.º 3, 1995, pp. 237 y ss.; «The practical and theoretical importance of the formal character of law», cit.; «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2, 1998, pp. 183 y ss. Alguno de estos trabajos pueden encontrarse recopilados en ID., *Essays in Legal Theory*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, e ID., *La naturaleza formal del Derecho*, trad. de P. Larrañaga, Fontamara, México, 2001.

²³³ SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., p. 60.

²³⁴ *Ibidem*.

menos mínimamente, completa en sus elementos; 6) la regla estructura las relaciones entre estos elementos, y 7) la regla está diseñada y encaminada, de manera explícita o implícita, para servir a una política determinada o a algún fin del Derecho.

La forma básica de las reglas, constituida a partir de las anteriores características, permite, aunque no asegura necesariamente, la eficacia de las mismas. En este sentido, lo que pudiéramos considerar el test de la eficacia, viene determinado por el cumplimiento por parte de los destinatarios de los criterios normativos establecidos en la norma. No es sino este cumplimiento el objetivo de la norma. Y dicho cumplimiento depende —más allá de las consideraciones individuales (morales en última instancia) que nunca conviene perder de vista— en primer lugar, de que los individuos puedan conocer con antelación la existencia y el contenido de la regla; en segundo lugar, de que la regla sea comprensible para los destinatarios; en tercer lugar, de que éstos puedan identificar los casos o situaciones a los que la regla se debe aplicar; en cuarto lugar, de que sea posible y no excesivamente gravoso llevar a cabo el cumplimiento del contenido de la regla. Parece evidente la importancia de la satisfacción de estos criterios formales a la hora de asegurar el cumplimiento de las normas. Como señala Summers, contribuyen a establecer «las condiciones necesarias para que los destinatarios guíen su conducta en virtud de las reglas y, en esa medida, contribuyen a la eficacia de las políticas expresadas en las reglas (dando por sentado que las hipótesis medios-fines han sido correctamente concebidas)»²³⁵.

Pues bien, los principios del imperio de la ley (del *rule of law*) tienen mucho que ver con los rasgos básicos de la dimensión formal de las reglas a los que se acaba de aludir. Estas dimensiones formales constituyen la base a partir de la cual es posible exigir el cumplimiento del Derecho. En relación con los principios del imperio de la ley, se pueden ofrecer listas más o

²³⁵ SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., p. 68.

menos exhaustivas²³⁶. La caracterización ofrecida por Fuller en relación con la moral interna del Derecho es una de las posibilidades²³⁷. Recordemos que para Fuller ocho son los requisitos de la moral interna del Derecho: 1) generalidad de las normas; 2) promulgación; 3) irretroactividad; 4) claridad; 5) coherencia normativa; 6) posibilidad de cumplimiento; 7) estabilidad; y 8) congruencia entre lo establecido en la ley y su aplicación. Por su parte, A.-E. Pérez Luño, cuando se plantea la cuestión de las condiciones de la seguridad jurídica propone incluirlas en el seno de dos condiciones básicas: la corrección estructural y la corrección funcional²³⁸. La corrección estructural implica que las normas que forman parte del sistema deben ser formuladas y configuradas de acuerdo con ciertas condiciones: 1) *lege promulgata*: la ley debe haber sido promulgada ya que la posibilidad de conocimiento es un requisito de su exigibilidad; 2) *lege manifesta*: la ley debe ser clara y comprensible; 3) *lege plena*: la plenitud del Ordenamiento jurídico garantiza que todo comportamiento o problema merecedor de ser regulado jurídicamente, recibe respuesta por parte del sistema; 4) *lege stricta*: la ley, entendida como norma general y abstracta, lleva a cabo la regulación de las materias fundamentales en la sociedad que, a partir de ese momento, encuentran acomodo en un lugar cualificado dentro de la jerarquías de las fuentes; 5) *lege perpetua*: la estabilidad de las normas y su tendencia a la permanencia de su contenido son condiciones de la confianza en los patrones de conducta establecidos por las propias normas. La corrección funcional supone, por su parte, el cumplimiento del Derecho por parte de los destinatarios y la actuación de los poderes

²³⁶ Una nómina mucho más exhaustiva que las que aquí comentamos es la propuesta por R. S. SUMMERS en «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», cit., pp. 184 y ss. ID *La naturaleza formal del Derecho*, cit., pp. 81 y ss.

²³⁷ Vid. FULLER, L. L., *La moral del Derecho*, trad. de F. Navarro, Trillas, México, 1967, pp. 43 y ss.

²³⁸ Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., *La seguridad jurídica*, Ariel, Barcelona, 1991, pp. 23 y ss.

públicos en el marco de lo establecido por él. Waldron ha señalado que los elementos componentes del imperio de la ley, a los que en diferentes versiones hemos aludido, son lógicamente independientes entre sí, aunque están vinculados por el hecho de que tienen una naturaleza instrumental respecto al valor de la certeza y de la predictibilidad del Derecho, imprescindibles para la materialización del desarrollo de la autonomía individual²³⁹.

En relación con los principios del imperio de la ley cabe efectuar algunas consideraciones. En primer lugar, son considerados como principios de segundo orden²⁴⁰. Aquí es conveniente aludir a la diferencia entre principios de primer orden o del sistema primario, y principios de segundo orden o del sistema secundario. En el primer caso, estamos ante principios cuya función es la de determinar las relaciones entre los destinatarios de la normas. Un ejemplo al respecto es aquel principio según el cual nadie puede beneficiarse de las consecuencias de sus propios actos ilícitos. Los principios de segundo orden están referidos a lo que Summers considera el sistema primario (o de primer orden) y a cualquiera de las normas que lo integra y su función es la de establecer criterios que deben ser seguidos a la hora de producir y aplicar esas normas.

Además, en segundo lugar, los principios del imperio de la ley son formales en dos sentidos básicos: afirmativamente formales y formales «por contraste»²⁴¹. En relación con el carácter afirmativamente formal de los principios del imperio de la ley (los principios son «afirmativamente» formales en la medida en la que cada uno supone un rasgo o varios rasgos efectivamente presentes, en contraposición con una mera ausencia o carencia del atributo»²⁴²), Summers destaca cuatro tipos de formalidad:

²³⁹ Vid. WALDRON, J., «The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory», *Ratio Juris*, vol. 2, n.º 1, 1989, pp. 84-85.

²⁴⁰ Vid. SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., p. 80.

²⁴¹ Vid. SUMMERS, R. S., «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», cit., p. 190; ID *La naturaleza formal del Derecho*, cit., pp. 90 y ss.

²⁴² SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., p. 92.

metodológica, procedimental, acomodativa y autorizacional. Cabe señalar que estos cuatro tipos no afectan por igual a todos y cada uno de los principios, y que cada uno de los cuatro tipos dependen en su significado de una determinada comprensión del concepto de «formal». Si se maneja el concepto de formal en el sentido de ‘perteneciente al método’, los principios son formales en sentido metodológico ya que muchos de ellos están relacionados con los modos y maneras en que se adquiere su propia forma. Así, por ejemplo, los requisitos de claridad y carácter prospectivo, señala Summers, son formales desde esta perspectiva. El carácter formal en sentido procedimental —entendiendo formal en el sentido de ‘perteneciente al procedimiento’— se refiere a que los principios sirven para configurar los procedimientos y mecanismos de creación y aplicación del Derecho. Pensemos por ejemplo en el principio referido a la existencia de un proceso con garantías. Por otro lado, se puede hablar de un carácter acomodativamente formal, en el sentido en que su operatividad no depende de los contenidos concretos de las normas. Están referidos a normas cuyos contenidos pueden ser muy variados. Por último, es posible hablar de un carácter formal autorizacional, desde el momento en que sirven para conferir y/o limitar la autoridad creadora de normas. Por ello se señala que estos principios están relacionados con los criterios de validez operativos en un determinado sistema.

Los principios del imperio de la ley también son formales «por contraste». Y lo son en dos sentidos. En el primer sentido, lo son a partir del contraste entre sus contenidos y los de las reglas o normas de primer orden. Frente a éstas, carecen del contenido sustantivo que las caracteriza, si bien lo presuponen. Así, a diferencia de las primeras, no tienen contenido, moral, o económico, por ejemplo. En el segundo sentido, son formales a partir del contraste que se presenta entre el sujeto que actúa de acuerdo con sus propios criterios, necesariamente sustantivos, y el que actúa de acuerdo con las exigencias del imperio de la ley.

Pues bien, a partir de la exposición de los puntos importantes de una concepción formal de los principios del imperio de

la ley como la de Robert Summers, podemos plantearnos dos cuestiones. En primer lugar, la de la indispensabilidad de los mismos para la mera existencia de un sistema jurídico. En segundo lugar, el problema derivado de lo que podríamos considerar el valor moral del imperio de la ley.

Pero antes de pasar a estas cuestiones, parece necesario efectuar una breve referencia a lo que podríamos considerar el contexto no institucionalizado del imperio de la ley. La alusión a la concepción formal del imperio de la ley necesariamente debe ser completada con una referencia a las condiciones del contexto en el que aquel va a desarrollar su virtualidad. En efecto, el imperio de la ley, al igual de lo que ocurre con otros conceptos como el de democracia, o el de derechos fundamentales, no es exclusivamente un problema de mayor o menor perfección en las estructuras jurídicas. Por el contrario, hace falta la concurrencia de ciertos rasgos que en ocasiones trascienden en su sentido al propio Ordenamiento y que de alguna manera constituyen lo que sería su sustrato político y cultural en sentido amplio. En este sentido, Robert Summers ha vinculado el éxito del imperio de la ley a la existencia de una educación cívica adecuada²⁴³. Por su parte, Raz ha aludido a la necesidad de una «cultura de la legalidad», como base a partir de la cual el imperio de la ley puede desarrollar sus potencialidades²⁴⁴. En efecto, la conciencia de la importancia del imperio de la ley constituye el punto de partida de la operatividad del mismo. Pero, en realidad, este convencimiento no es suficiente. A partir de ahí, se puede comenzar a pensar en otras condiciones²⁴⁵. En primer lugar, el compromiso de las propias autoridades

²⁴³ Vid. SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», cit., p. 130.

²⁴⁴ Vid RAZ, J., «The Politics of the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 3, n.º 3, 1990, pp. 331 y ss. Vid. también REYNOLDS, N. B., «Grounding the Rule of Law», cit., pp. 7-8.

²⁴⁵ Sigo en este punto a SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., pp. 102-103; ID., «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», cit., pp. 197-198.

des, sólo eficaz a partir de una correcta preparación técnica de los sujetos (legisladores, jueces, funcionarios) responsables de la producción normativa. En segundo lugar, es importante aludir también a la existencia de una opinión pública y de unos medios de comunicación también comprometidos con el imperio de la ley y críticos con las violaciones del mismo. A lo anterior, hay que añadir la existencia de una profesión jurídica bien organizada, libre e independiente, capaz de exigir el correcto funcionamiento del imperio de la ley. Y, por último (volvemos a la importancia de la educación y de la formación), el papel de las Facultades de Derecho es importante, desde el momento en que constituyen el ámbito en el que se estudian de manera ordenada las distintas dimensiones del imperio de la ley, constituyéndose también en instancia crítica al respecto.

c) El imperio de la ley y la existencia del Derecho. Derecho y arbitrariedad

Como acabo de señalar, la cuestión del tipo de relación que se establece entre la satisfacción de los principios del imperio de la ley y la existencia de un Ordenamiento jurídico es importante. Podemos plantear, en primer lugar, la posibilidad de hablar de una relación contingente entre la satisfacción del imperio de la ley y la existencia de un Ordenamiento. O bien podemos entender que la relación es necesaria. Es evidente que las consecuencias de una u otra postura son bien diferentes. Sobre todo, lo son si, además, se considera que la satisfacción de las exigencias del imperio de la ley tiene un insuprimible sentido moral. Pero dejo esta cuestión para más adelante.

En el caso de que se mantenga el carácter contingente de la relación, se está afirmando que es posible identificar como tal a un sistema jurídico que no satisficiera los principios del imperio de la ley, es decir, un sistema (o, más bien, un pretendido sistema) que, por ejemplo, no contuviera normas públicas y claras, cuyas autoridades normativas no fueran conocidas, o que incluyera, como criterio general, normas retroactivas. Para

alguien que afirmara el carácter contingente de la relación estaríamos ante un sistema jurídico, pero en el que no se materializarían ni siquiera de forma mínima, las exigencias del imperio de la ley. No obstante, la posición se podría matizar en el sentido de reconocer que un sistema que incumple esas exigencias es un sistema jurídico imperfecto.

Pero esta posibilidad se presenta como problemática. En realidad, no creo que la cuestión se tenga que plantear en términos de perfección jurídica o no, sino en términos de auténtica juridicidad o no. Identificar unos supuestos criterios de perfección jurídica es una tarea ciertamente complicada a no ser que se adopte una perspectiva sustantiva, es decir, que la perfección se identifique con determinados contenidos, y no otros, de las normas. Considerando que el Derecho es a fin de cuentas una técnica de control social, la perfección debe venir determinada, en todo caso, por la capacidad estructural y técnica del Derecho a la hora de llevar a cabo ese control social. Es esa capacidad la que le va a permitir presentarse como un sistema de control social. Es aquí donde se presenta como imprescindible un cierto grado de satisfacción de las exigencias del imperio de la ley. Sabemos que esas exigencias permiten que los individuos y los funcionarios, los destinatarios o sujetos normativos en general, actúen de acuerdo con el Derecho y en el marco del Derecho. De manera que si no se produce ese grado de satisfacción, en realidad estamos ante un sistema (o algo parecido —una especie de agregado normativo— ya que los criterios del imperio de la ley también son expresión de la naturaleza sistemática del Derecho), incapaz de cumplir su función básica: la de articular criterios de conducta que puedan ser obedecidos. Ciertamente, es posible distinguir entre una violación particular y localizada de los principios del imperio de la ley y una violación generalizada de los mismos. En el primer caso, las consecuencias van más allá de la mera falta de eficacia: «Una ley secreta, por ejemplo, no es realmente «jurídica» (*law-like*), y por tanto no es realmente derecho o no es tan verdaderamente derecho. Aquí no es sacrificada la eficacia del derecho sino que se pierde la pretensión conceptual misma al *status* de

derecho»²⁴⁶. En relación con la violación generalizada de los principios del imperio de la ley, los efectos son similares, ya que «es justamente una característica de un sistema de derecho que opere sustancialmente de acuerdo con los principios del imperio de la ley»²⁴⁷. En ambos casos, la consecuencia es la desaparición como tal de un sistema que no es capaz de guiar de manera efectiva los comportamientos humanos.

De lo anterior se puede deducir que las consecuencias de la falta de efectividad de un sistema que no satisface los criterios del imperio de la ley son similares a las de la falta de efectividad de un sistema que, por otras razones, es desobedecido en su conjunto. En ambos casos estamos obligados a dejar de reconocer el carácter jurídico de ese conjunto normativo. En el primer caso, el motivo es de naturaleza formal o estructural. En el segundo caso, posiblemente podamos encontrarnos con razones de naturaleza moral o política.

En definitiva, los requisitos del imperio de la ley se nos presentan como una condición de la eficacia del sistema jurídico. Permiten que el sistema sea obedecido. Si no concurren dichos requisitos, el sistema no puede ser obedecido en ningún caso desde el momento en que carece de las dimensiones formales y estructurales mínimas necesarias. Además, la presencia de esos elementos crea condiciones de certeza y seguridad²⁴⁸. En este sentido, y siendo la presencia de estos elemen-

²⁴⁶ SUMMERS, R. S., «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», cit., p. 189.

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ No es mi intención detenerme en el análisis de las diferencias entre ambos conceptos. A.-E. PÉREZ LUÑO distingue entre dos facetas del concepto de seguridad (vid. *La seguridad jurídica*, cit., pp. 21-22). Entendida strictu sensu, la seguridad implica una exigencia objetiva de regularidad, estructural y funcional, del sistema jurídico. La faceta subjetiva supone la repercusión de la seguridad objetiva en las situaciones personales, y se vincula a la certeza. Qué duda cabe que, así entendidos, la seguridad strictu sensu y la certeza no son independientes entre sí; bien al contrario, para que exista certeza (seguridad subjetiva) es imprescindible la satisfacción de las exigencias de la seguridad objetiva. Por su parte, R. ESCUDERO ALDAY parece otorgar un sentido

tos necesaria para la existencia como tal del sistema, todo Ordenamiento, más allá de su carácter justo o injusto, moral o inmoral, genera seguridad²⁴⁹. Al respecto, Scalia ha reconocido que, en ocasiones, incluso una mala norma (desde el punto de vista moral) es mejor que la ausencia de regla²⁵⁰. Por eso tiene razón Peces-Barba cuando, en referencia al ‘Derecho’ premoderno, señala que «no genera seguridad. El pluralismo de fuentes, el entrecruzamiento de competencias, una creatividad judicial sin norma previa, buscando el ‘*id quod iustum est*’, en el caso concreto, y sobre todo la falta de un poder capaz de imponer sus normas jurídicas, no permite hablar de certeza ni de ausencia de temor»²⁵¹. El Derecho, en tanto que sistema de información sobre los modelos de conducta juridificados, produce seguridad: «Sistema y seguridad jurídica son inseparables. No hay sistema que no produzca, por su sola existencia, una cierta seguridad jurídica, ni seguridad jurídica

contrario a estos términos (vid. *Positivismo y moral interna del Derecho*, cit., pp. 501 y ss). Distingue dos niveles en la consideración de la seguridad jurídica que produce un Ordenamiento jurídico. En el primer nivel, cualquier Ordenamiento, a partir del cumplimiento de las exigencias del imperio de la ley, produce certeza. La certeza es así un dato que ofrece el sistema jurídico. Pero en el segundo nivel, la seguridad jurídica depende de los contenidos concretos del Ordenamiento a través de los cuales se traducen las dimensiones de moralidad asumidas por el sistema y en las que los derechos fundamentales ocupan un papel paradigmático. De manera que, de acuerdo con esta propuesta, todo Ordenamiento ofrecería certeza, pero no seguridad jurídica. R. GARCÍA MANRIQUE defiende la equivalencia entre la certeza y la seguridad jurídica entendida en sentido formal en *El valor de la seguridad jurídica*, Fontamara, México, 2007, pp. 164 y ss.

²⁴⁹ De manera que aquí se defiende una concepción formal de la seguridad jurídica, que «no determina el contenido material del Derecho» y que «puede predicarse de un sistema jurídico con cualquier contenido material» (GARCÍA MANRIQUE, R., *El valor de la seguridad jurídica*, cit., p. 157).

²⁵⁰ Vid., SCALIA, A., «The Rule of Law as a Law of Rules», *The University of Chicago Law Review*, vol. 56, n.º 4, 1989, p. 1179.

²⁵¹ PECES-BARBA, G., «La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho», ID., *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 265.

que se pueda concebir al margen del sistema»²⁵². Así, la seguridad, entendida desde esta perspectiva vinculada a una comprensión formal del imperio de la ley, no es una cuestión exclusiva del Estado de Derecho o de un Ordenamiento jurídico justo²⁵³. Como señala Legaz, la seguridad, «no es tanto el resultado de un querer conscientemente realizado, como un

²⁵² PECES-BARBA, G., «La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho», cit., p. 268. En este sentido, la seguridad se presenta como un dato derivado de la misma existencia del Ordenamiento. Si esta afirmación es cierta, parecería entrar en contradicción con la consideración de la seguridad como un valor superior del Ordenamiento (vid. PECES-BARBA, G., «Seguridad jurídica y solidaridad como valores de la Constitución española», ID., *Derecho y derechos fundamentales*, cit., pp. 283 y ss.). En tanto que valor, la seguridad se configuraría como una meta, como un objetivo a alcanzar, que puede materializarse o no, en mayor o menor medida. Por otra parte, creo que en este punto se mezclan dos discursos diferentes: al afirmar que la seguridad es un dato del sistema, nos situamos en un discurso descriptivo, mientras que la consideración de la seguridad como valor procede de un discurso normativo.

²⁵³ En la contraposición entre Estado de Derecho y dictadura, HELLER vincula la idea de seguridad jurídica al Estado de Derecho: «Seguridad del tráfico o seguridad jurídica se hacen posibles merced a una intensificación en la calculabilidad y en la acomodación a planes conseguida en las relaciones sociales. Porque esta calculabilidad puede alcanzarse solamente si las relaciones sociales y ante todo las económicas se someten en medida creciente a un orden unitario, esto es, a una normación desde un punto central del territorio. El resultado provisional de este proceso de racionalización social es el moderno Estado de Derecho, surgido en lo esencial de una voluminosa legislación, vale decir, del establecimiento consciente de reglas para la acción social, reglass que en relación con un ámbito de personas y de cosas han ido progresivamente excluyendo, en beneficio de la creación y la ejecución de normas desde un modelo institucional central, la defensa propia», «¿Estado de Derecho o dictadura?», ID., *Escritos políticos*, trad. de S. Gómez de Arteche, prólogo y selección de A. López Pina, Alianza, Madrid, 1985, p. 284. Heller considera que el rasgo común de las dictaduras europeas de los años 20 y 30 es precisamente su negación del Estado de Derecho. En este punto, Heller está manejando un concepto formal de Estado de Derecho y, al mismo tiempo, está asumiendo que un sistema dictatorial, por muy despótico y arbitrario que sea, puede seguir siendo considerado como un sistema normativo jurídico. Por el contrario, en este trabajo, se defiende un concepto material de Estado de Derecho y se entiende que la arbitrariedad, en tanto que negación absoluta de la seguridad, es la antítesis de la idea de Derecho.

fruto espontáneo del mismo Derecho en tanto que Derecho; y precisamente por eso es absurdo querer prescindir de la seguridad en un sistema jurídico cualquiera, pues existiendo un sistema jurídico ya existe seguridad. No es la seguridad la que constituye un principio de valoración, sino la justicia. El hombre está siempre seguro con el Derecho, siempre sabe a qué atenerse sobre su situación, pero no siempre se siente a su gusto con esta seguridad; preferiría, a veces, poner su situación más cerca del peligro, a cambio de una más amplia y cómoda libertad de movimientos; otras veces, clamará contra la seguridad de una situación injusta y exigirá la seguridad de una mejor justicia; pero el orden jurídico es, por esencia, la estabilización de las sociedades y, por lo tanto, implica una situación general de seguridad...»²⁵⁴. Claro está, si se mantiene un concepto material de seguridad jurídica, como el que en mi opinión mantiene Pérez Luño, es posible afirmar que la tesis según la cual el Derecho es un sistema de seguridad es expresión de una acepción sociológica y empirista de la seguridad que no se corresponde con el Estado de Derecho²⁵⁵. Estamos entonces frente a una concepción de la seguridad jurídica mucho más restrictiva que la mantenida aquí, y que le permite afirmar al prof. de la Universidad de Sevilla que más allá del Estado de Derecho, la única seguridad de la que se puede hablar es la seguridad de una iniquidad, «la seguridad fáctica de una inseguridad jurídica»²⁵⁶.

La relación entre los requisitos del *rule of law* y la existencia de un sistema jurídico se presenta como necesaria. Pero esta

²⁵⁴ LEGAZ LACAMBRA, L., *Filosofía del Derecho*, cit., p. 632. Vid. también ARCOS RAMÍREZ, F., *La seguridad jurídica. Una teoría formal*, cit., pp. 18 y ss.

²⁵⁵ Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., *La seguridad jurídica*, cit., p. 19.

²⁵⁶ PÉREZ LUÑO, A. E., *La seguridad jurídica*, cit., p. 58. Esta concepción le permite considerar por separado la positividad del Derecho de la seguridad jurídica (pp. 22-23), contrariamente a la posición de LEGAZ LACAMBRA, que afirma que el Derecho desarrolla una función de seguridad, «porque y en cuanto que cristaliza en un sistema de legalidad», *Filosofía del Derecho*, cit., p. 624.

necesidad se manifiesta claramente también si elevamos un poco la perspectiva de nuestra reflexión y ya no nos planteamos la relación entre el imperio de la ley y la existencia de un Ordenamiento jurídico determinado, sino la relación entre el imperio de la ley y la idea misma de Derecho.

Es aquí donde nos encontramos con la noción de arbitrariedad, que constituye la negación de la idea de Derecho²⁵⁷. El Derecho se presenta como un sistema normativo de ordenación de las conductas humanas. Dicha ordenación, como hemos señalado en momentos anteriores de este trabajo, es de un tipo muy específico, es decir se lleva a cabo a través de mecanismos determinados, como son las reglas. Las reglas constituyen criterios de regulación regular de las conductas. Es decir, precisamente el significado contrario al expresado a través de la noción de arbitrariedad. El Derecho, más allá de su carácter justo o injusto, moral o inmoral, no puede ser arbitrario. En este sentido, la noción de «Derecho arbitrario», carece de sentido, pero no como consecuencia de la adulación y santificación de la ley, sino por la imposibilidad de concebir como jurídico un sistema arbitrario²⁵⁸. Puede señalarse, de acuerdo con F. Viola, que la contradicción en los términos se produce cuando hablamos de un Derecho arbitrario y no de un Derecho injusto²⁵⁹. En realidad, los mandatos de una banda de ladrones no son las normas jurídicas injustas, sino más bien las órdenes

²⁵⁷ En este sentido se refieren a ella, G. RADBRUCH, *Filosofía del Derecho*, cit., p. 242, y LEGAZ LACAMBRA, L., *Filosofía del Derecho*, cit., p. 651. Sobre la cuestión, puede consultarse, ARCOS RAMÍREZ, F., *La seguridad jurídica. Una teoría formal*, cit., pp. 53 y ss.

²⁵⁸ Vid. RADBRUCH, G., *Arbitrariedad legal y Derecho supralegal*, trad. de M. I. Azareto de Vásquez, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 21. Como señala LEGAZ LACAMBRA, «decir Derecho arbitrario sería, sencillamente, expresar una imposibilidad lógica: una *contradictio in adjecto*, pues sería decir de una cosa que era y no era Derecho: pues arbitrariedad es no-Derecho, lo contrario que Derecho, la negación del Derecho en su forma», *Filosofía del Derecho*, cit., p. 653.

²⁵⁹ Vid. VIOLA, F., *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi*, cit., p. 84.

arbitrarias. Como veremos posteriormente, un sistema de normas injustas no tiene por qué ser arbitrario.

La caracterización de los que Raz ha denominado «sistemas de discreción absoluta» sirve para ejemplificar la situación a la que se está haciendo referencia aquí al hablar de arbitrariedad²⁶⁰. Frente a los sistemas institucionalizados —de los que los sistemas jurídicos se nos presentan como una manifestación— los sistemas de discreción absoluta se caracterizan porque en ellos los tribunales no se encuentran vinculados a estándares normativos preestablecidos. En estos sistemas, cuyos tribunales dictan decisiones concluyentes en aquellos asuntos en los que intervienen, aquellos están obligados a dictar la decisión que, a partir de todas las razones concurrentes y válidas, es la mejor. Esa decisión no está apoyada en normas precedentes, Derecho consuetudinario o precedentes. No obstante, Raz afirma que «los tribunales de este peculiar sistema no están habilitados para decidir de una manera arbitraria. Han de actuar sobre la base de razones, pero la selección de las razones que determinan los casos está dentro del marco de la propia discreción absoluta»²⁶¹. En la formulación de ese juicio sincero, la opinión del juez sobre el mérito o el demérito de la norma juega un papel importante, papel que tiende a desaparecer en los sistemas institucionalizados en los que se excluye el juicio del juez sobre la deseabilidad o no de la norma. Estamos ante un claro ejemplo de situación de arbitrariedad, más allá de la terminología adoptada por Raz. A efectos prácticos, y en lo que se refiere a la guía efectiva de las conductas, la situación a la que alude Raz no se distingue de la de arbitrariedad, tal y como es entendida en este trabajo. Lo que caracteriza a una situación arbitraria es precisamente la ausencia de criterios normativos estables y cognoscibles. Es evidente que tras cualquier tipo de decisión existe algún criterio determinante, reconducible inclu-

²⁶⁰ Vid. RAZ, J., *Razón práctica y normas*, trad. de J. Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 158 y ss.

²⁶¹ RAZ, J., *Razón práctica y normas*, cit., p. 159.

so al capricho o al mero gusto del sujeto. Pero lo que evita la arbitrariedad no será tanto la existencia del criterio determinante, que puede tener en su caso carácter normativo, cuanto la estabilidad del mismo, a partir de la cual es posible la construcción de guías de conducta. Ciertamente, Raz así lo reconoce cuando señala que «los sistemas de discreción absoluta difieren de los sistemas jurídicos y sistemas semejantes principalmente en un aspecto. Dado que sus tribunales no están obligados a seguir ningún estándar común y pueden decidir lo que ellos piensen que es lo mejor, un sistema tal no proporciona ninguna guía a los ciudadanos sobre la conducta que les daría derecho a una decisión a su favor si surgiera una conducta»²⁶².

Una caracterización clásica de la arbitrariedad es la ofrecida por Ihering. Según Ihering, la actuación arbitraria presupone una posición de superioridad. Sólo aquel que está, en el marco de una determinada relación, en dicha posición, puede actuar de manera arbitraria frente a los otros. Por eso, señala Ihering, «la arbitrariedad es la injusticia del superior»²⁶³. Además, la arbitrariedad supone también la existencia de una ley, de una norma respecto de la cual se aparta el individuo. En ese sentido, la arbitrariedad se distingue de la acción que ejerce una potestad (en el sentido de un poder)²⁶⁴, simplemente: «La potestad de la voluntad que no se halla regida por una ley, no es la arbitrariedad, es la simple potestad»²⁶⁵. Es en este sentido en el que se afirma que la noción de arbitrariedad es la antítesis del Derecho: «Noción puramente negativa, la arbitrariedad supone como antítesis, el derecho, del cual es negación»²⁶⁶. La arbitrariedad es negación del Derecho, pero no desde el punto

²⁶² RAZ, J., *Razón práctica y normas*, cit., p. 159.

²⁶³ IHERING, R. v. *El fin en el Derecho*, cit., p. 176.

²⁶⁴ Se efectúa aquí esta matización, ya que en principio el ejercicio de una potestad sólo es tras la existencia de una norma habilitadora. El concepto de potestad que maneja Ihering implica la no existencia de dicha norma de habilitación, atribuidora de competencia.

²⁶⁵ IHERING, R. v. *El fin en el Derecho*, p. 176.

²⁶⁶ IBIDEM.

de vista meramente teórico, sino desde el punto de vista de la contradicción con lo que podríamos considerar el sentimiento jurídico, con la percepción del significado del Derecho. Por eso es necesaria —señala Ihering— la previa existencia del sentimiento jurídico: «Sólo siente la arbitrariedad aquel que tiene vivo el sentimiento del Derecho, y únicamente en proporción a la energía de ese sentimiento. El peso de la arbitrariedad se deja sentir en razón directa al desarrollo de la fuerza moral del sentimiento jurídico»²⁶⁷.

Por su parte, Recasens ofrece una comprensión de la idea de arbitrariedad coincidente en muchos puntos con la de Ihering²⁶⁸. Así, los actos arbitrarios deben proceder de alguien que se encuentra en una posición determinada. Esta posición es la que ocupa aquel que puede ejercer el Poder social efectivo; por ello, Recasens piensa en los Poderes públicos. Además, se dice, los actos arbitrarios son aquellos caracterizados por su inapelabilidad. Si se tratara de actos apelables, sigue Recasens, serían ilegales o erróneos, pero no arbitrarios.

Recasens propone la distinción entre arbitrariedad e injusticia. Mientras que ésta se refiere a los contenidos de un precepto, aquella implica «que un mandato sea formalmente negador de lo jurídico. Un mandato arbitrario es algo que no sólo no constituye Derecho, sino que, además, representa su radical negación —la negación de la esencia de lo jurídico, pura y simplemente»²⁶⁹. Por lo tanto, el Derecho es compatible con la

²⁶⁷ IHERING, R. v., *El fin en el Derecho*, cit., p. 177. En el mismo sentido, KELSEN afirma que «la seguridad jurídica, más que la justicia absoluta, ocupa el primer plano de la conciencia jurídica», «Los fundamentos de la democracia», ID., *Escritos sobre la democracia y el socialismo*, selección y presentación de J. Ruiz Manero, Debate, Madrid, 1988, p. 245.

²⁶⁸ Aunque el autor al que Recasens parece tomar como referencia sea R. STAMMLER, *Tratado de Filosofía del Derecho*, trad. de W. Roces, Editora Nacional, México, 1980, pp. 112 y ss. (Vid. RECASENS SICHES, L., *Tratado General de Filosofía del Derecho*, Porrúa, México, 1986, p. 215).

²⁶⁹ RECASENS SICHES, L., *Tratado General de Filosofía del Derecho*, cit., p. 214.

injusticia, pero no con la arbitrariedad, desde el momento en que ésta supone la negación de las características formales básicas y esenciales de lo jurídico. La arbitrariedad, desde este punto de vista, supondría la negación de la regla y de la regularidad a la que esta reconduce. Así, el mandato arbitrario es aquel que no se funda en un principio general —aplicable a todos los casos análogos— sino que responde a un simple *porque sí*, porque me da la gana; en suma, a un capricho o antojo que no dimana de un criterio general»²⁷⁰. La imposibilidad de reconducir la decisión arbitraria a un criterio general determina su falta de justificación²⁷¹.

La correcta comprensión de lo que significa la arbitrariedad implica, por tanto, una correcta interpretación de sus relaciones con la justicia/injusticia. Se ha señalado antes que la arbitrariedad implica injusticia; es más, se ha dicho que es una condición suficiente de la injusticia. Si esto es cierto en todo caso, no serían en absoluto válidos los argumentos tendentes a demostrar la compatibilidad entre una medida arbitraria y su carácter justo. No obstante, podemos plantearnos la posibilidad de que existan matizaciones al respecto. Podemos recordar el ejemplo que propone Recasens, al que también alude Legaz, a partir de un caso extraído de la Prusia de Federico II. Un molinero, Arnoldo, era el titular de un predio en la parte baja de una ladera. A ese predio llegaba una corriente de agua que

²⁷⁰ RECASENS SICHES, L., *Tratado General de Filosofía del Derecho*, cit., p. 216.

²⁷¹ Vid. PERELMAN, Ch. *De la justicia*, trad. de R. Guerra, UNAM, México, 1964, p. 66, en donde también se afirma: «Justificar es siempre mostrar cómo una categoría determinada se integra en una categoría más vasta, cómo una regla particular se deduce de una regla más general». Para Perelman, los sistemas normativos descansan en última instancia en una decisión o en un valor arbitrario en el sentido de no justificable ulteriormente: «En cuanto al valor que funda al sistema normativo, no se le puede someter a ningún criterio racional; es perfectamente arbitrario y lógicamente indeterminado (op. cit., p. 73). En el mismo sentido, PECZENIK, A., «Dimensiones morales del Derecho», *Doxa*, n.º 8, 1990, pp. 95-96.

previamente pasaba por el terreno de un vecino. Dicho vecino, movido exclusivamente por razones de enemistad y sin perseguir ningún beneficio al respecto, tomó la decisión de desviar la corriente de agua, de manera que el predio del molinero quedaba desabastecido. Este demandó al dueño del predio vecino pero, como el abuso de derecho no estaba previsto por el Ordenamiento, se desestimó su demanda. El molinero apeló al Tribunal superior, que procedió a confirmar la sentencia recurrida. Angustiado por la situación, el molinero se dirigió personalmente al monarca que, considerando injusta la sentencia, la revocó por mandato personal, y castigó a los jueces que la habían dictado. Pues bien, Recasens llega, con razón, a la conclusión de que la actuación del monarca es arbitraria. La razón es la siguiente: «...si bien Federico II, a fuer de monarca absoluto, tenía facultades para abrogar una ley y dictar otra en su lugar, en cambio lo que no podía hacer jurídicamente era violar una ley vigente —que no derogó— y aplicar a un caso particular su antojo —por muy justo que fuese en dicho caso concreto—, y todavía menos sancionar a los magistrados que habían cumplido fielmente con lo que era el Derecho vigente»²⁷².

Este ejemplo nos enfrenta con la cuestión de la relación entre la arbitrariedad y la injusticia. En principio parecería que toda decisión arbitraria es injusta. Pero el ejemplo propuesto por Recasens parece indicar lo contrario. Es cierto que la decisión del monarca es arbitraria, pero al mismo tiempo supone el reconocimiento de una pretensión justa del molinero. Parece por tanto que sería conveniente distinguir dos puntos de vista en el análisis de la relación entre ambas nociones. Desde el primer punto de vista, exclusivamente teórico o formal, la arbitrariedad es siempre injusta desde el momento en que niega las exigencias, entre otras, de certeza y seguridad. El segundo punto de vista está referido al contenido concreto de los sistemas

²⁷² RECASENS SICHES, L., *Tratado General de Filosofía del Derecho*, cit., p. 215.

normativos y de las reglas que los componen. Desde esta perspectiva, conviene tener en cuenta que siendo la arbitrariedad la actuación con desatención a la regla, dicha actuación puede ser justa (desde el punto de vista sustancial, referido al contenido), en aquel caso en que la regla o la ausencia de la misma supongan una injusticia. En este sentido se ha afirmado que no hay nada en un sistema de toma de decisiones basado en reglas que lo haga intrínsecamente más justo que un sistema de toma de decisiones no condicionado por reglas. Frederick Schauer nos recuerda que identificamos la sabiduría del Rey Salomón con la justicia, no porque en el caso del niño que se disputaban las dos madres tomara una decisión basada en reglas, sino porque tomó la decisión justa en el caso concreto²⁷³.

Para terminar este apartado, conviene recordar que la arbitrariedad no debe confundirse con la discrecionalidad que ejercen los operadores jurídicos (los jueces) en su tarea de interpretación y aplicación del Derecho. El contexto normativo dentro del cual se ejerce la discrecionalidad es inexistente en el caso de la arbitrariedad, que se caracteriza precisamente por la negación del mismo. Como señala Dworkin, «el concepto de discreción sólo es adecuado en un único tipo de contexto; cuando alguien está en general encargado de tomar decisiones sujetas a las normas establecidas por una autoridad determinada»²⁷⁴.

Como sabemos, los operadores jurídicos actúan discrecionalmente como consecuencia de la vaguedad congénita al Ordenamiento jurídico, y de su textura abierta. El lenguaje a través del cual se expresa el sistema jurídico está afectado por problemas de vaguedad, como ocurre también con las expresiones lingüísticas que utilizamos en muchas facetas de

²⁷³ Vid. SCHAUER, F., *Playing by the rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, cit., p. 137.

²⁷⁴ DWORKIN, R., *Los derechos en serio*, cit., p. 84. Sobre el tema puede consultarse IGLESIAS VILLA, M., *El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.

nuestra existencia. Los problemas de vaguedad se muestran de manera más evidente en determinadas parcelas del sistema jurídico. En todo caso, la cuestión que nos ocupa aquí es la de la influencia de la vaguedad del lenguaje del Derecho en las exigencias del imperio de la ley. Kelsen ya se planteó en su momento este tema aludiendo a dos aspectos que podrían debilitar la eficacia del imperio de la ley: el hecho de que las normas individuales no se puedan determinar completamente a partir de una norma general, con la consiguiente existencia de un margen de discrecionalidad, y la circunstancia de que, a partir del hecho de que la aplicación siempre implica interpretación, las normas generales admiten siempre diversas posibilidades de interpretación²⁷⁵.

Otros autores como Troper o Endicott se han planteado, ciertamente, hasta qué punto la vaguedad, que afecta a cualquier sistema jurídico, supone un peligro para el Estado de Derecho y para el imperio de la ley. En este sentido, el planteamiento de Troper es mucho más tajante, desde el momento en que afirma explícitamente la imposibilidad del Estado de Derecho, con independencia de la concepción que se mantenga del mismo.

En efecto, según Troper, cabe identificar dos variantes del Estado de Derecho, a partir de la idea básica del sometimiento del Poder al Derecho²⁷⁶. En un primer caso —comprensión ius-naturalista del Estado de Derecho— se afirma que el Estado está sometido a un Derecho exterior preexistente al mismo, y que puede tener su origen en la voluntad divina, en la naturaleza humana o en la naturaleza de las cosas. En el segundo caso —versión positivista del Estado de Derecho— se niega la existencia de ese Derecho previo y exterior al Estado, desarrollándose la teoría de la autolimitación, a la que hemos aludido con anterioridad en este trabajo. Pues bien, en ambos casos, se puede llegar a la conclusión, señala Troper, de la imposibilidad del

²⁷⁵ Vid. KELSEN, H., «Los fundamentos de la democracia», cit., p. 312-3.

²⁷⁶ Vid. TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., pp. 30 y ss.

Estado de Derecho. La comprensión iusnaturalista del mismo se caracteriza entre otras cosas por el hecho de que no ofrece garantías para la democracia y por ser incompatible con una teoría de la soberanía popular. Pero el rasgo, de los señalados por Troper, que interesa subrayar aquí es aquel según el cual el Estado de Derecho, en su versión iusnaturalista, se aleja del gobierno de las leyes para convertirse en un gobierno de los hombres. Ello es la consecuencia del hecho de que, en realidad, en un Estado de Derecho así concebido, hay que descubrir e interpretar los contenidos del Derecho natural, ámbito éste en el que los juicios de valor tienen una importante dimensión. Este contexto, en el que los jueces se presentan como los intérpretes del Derecho natural, se caracteriza por la incerteza en la identificación de aquel: «Ni aún aquellos que aceptan la idea de que existe un derecho natural pueden pretender que su contenido pueda ser objeto de un conocimiento cierto»²⁷⁷. Por ello, en resumidas cuentas, el juicio sobre la conformidad entre un

²⁷⁷ TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., p. 32. Kelsen subrayó en su momento la incapacidad del iusnaturalismo a la hora de identificar los contenidos de la idea de justicia. En efecto, las propuestas al respecto son dispares y contradictorias: «No hay, como imaginan los partidarios de esta teoría, una sola sino numerosas normas de justicia diferentes y opuestas; si las normas de justicia no son, como quieren los teóricos del derecho natural, inmanentes a la naturaleza, entonces no podrán ser encontradas o deducidas en la naturaleza, sino que en realidad lo que ocurre es que vienen presupuestas por dichos teóricos: por todas estas razones cada uno de éstos llega, según la norma de justicia por él propuesta, a resultados muy diferentes y contradictorios» (Vid. KELSEN, H., «Justicia y Derecho natural», en VVAA, *Crítica del Derecho natural*, introd. y trad., de Elías Díaz, Taurus, Madrid, 1966, p. 142; ID., «La doctrina del Derecho natural y el Positivismo jurídico», trad. de E. Bulygin, en *Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho*, Fontamara, México, 1991, p. 133; ID., «La doctrina del Derecho natural ante el tribunal de la ciencia», en *¿Qué es justicia?*, ed. y trad. de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1982, p. 83). La disparidad de propuestas es algo que se constata al observar la historia de las teorías iusnaturalistas. Esa disparidad es la que le permite afirmar a Kelsen que «con los métodos de la teoría del Derecho natural, y en lo que se refiere a la justicia, se puede probar todo y, por lo tanto, no se prueba nada» («Justicia y Derecho natural», cit., p. 142).

acto del Estado y el Derecho natural no es sino expresión «de una decisión, es decir, de las preferencias de su autor»²⁷⁸. Por ello, concluye Troper, el Estado de Derecho en esta perspectiva no es un Estado sometido al Derecho, sino un Estado sometido al juez.

Por otra parte, la comprensión positivista del Estado de Derecho también plantearía problemas, en opinión de Troper. La cuestión de la justificación de la autolimitación es uno de ellos. Pero Troper alude también al problema planteado desde el momento en que en el sistema jurídico existen reglas vagas y ambiguas, que muchas veces reconducen a instancias valorativas y que en todo caso, necesitan ser interpretadas. En estos casos, el intérprete goza de un ámbito de libertad considerable de manera que el gobernante, en definitiva, está sometido al mismo intérprete: estamos, por tanto, ante un gobierno de los hombres, frente al ideal del Estado de Derecho, vinculado al gobierno de las leyes.

La tesis defendida por Timothy Endicott es posiblemente más matizada que la de Troper²⁷⁹. Endicott parte de la constatación de la ineliminable vaguedad del lenguaje del Derecho. La vaguedad es un rasgo esencial del Derecho. Si ello es así, se plantea la cuestión de la compatibilidad o no entre la realidad del Derecho y el ideal del imperio de la ley. Un lenguaje jurídico vago en teoría puede facilitar la tarea de un gobierno arbitrario. En este sentido, Endicott señala que normalmente se mantiene que un gobierno es arbitrario si concurren todas o alguna de las tres situaciones siguientes²⁸⁰: 1) la voluntad del legislador no se encuentra limitada; 2) los Poderes públicos actúan de manera inconsistente, no tratando igual a casos similares;

²⁷⁸ TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», cit., p. 32.

²⁷⁹ Vid. ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», ID., *Vagueness in Law*, Oxford University Press, 2000, pp. 185 y ss. (existe traducción castellana: *La vaguedad en el Derecho*, trad. De J. A. del Real y J. Vega Gómez, Dykinson, Madrid, 2006).

²⁸⁰ Vid. ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», cit., p. 186.

3) sus decisiones son impredecibles, es decir, los ciudadanos carecen de guía alguna en relación a las posiciones jurídicas que ocupan, a los derechos y deberes que les afectan. La tesis de Endicott es que una cierta falta de límites, determinada inconsistencia y cierta impredecibilidad, no necesariamente implican arbitrariedad en el sentido peyorativo del término. En última instancia, la arbitrariedad vendría determinada por la concurrencia de un cuarto rasgo o característica, al que no siempre se alude cuando se plantea el concepto: un gobierno es arbitrario cuando sus actuaciones se apartan de la razón del Derecho. Por ello, cuando la vaguedad del Derecho supone contradicción con la razón del Derecho, nos encontramos en el territorio de la arbitrariedad.

Para Endicott, la vaguedad del Derecho es insuprimible²⁸¹. Desde ese punto de vista, el resultado necesario sería la existencia de un cierto grado de arbitrariedad en el gobierno, como consecuencia de la presencia de los tres elementos a los que se ha aludido en el párrafo anterior. No obstante, es posible —mantiene el profesor de Oxford— intentar conciliar dicha presencia con el ideal del imperio de la ley. Para ello, adopta como punto de partida la consideración del concepto de «déficit» del imperio de la ley²⁸². En una determinada comunidad se pueden producir déficits en las exigencias del imperio de la ley en aquellos casos en los que la Administración, por ejemplo, no actúa de acuerdo con el dictado de las normas jurídicas. Si esos casos son generalizados, se puede llegar a la conclusión de que en esa comunidad no rige el imperio de la ley. Para Endicott, el problema que se plantea con la vaguedad es distinto, ya que ésta, de ineliminable presencia en un sistema jurídico, no necesariamente supone un déficit respecto al imperio de la ley. Al contrario, «el incremento en la precisión [del Derecho] puede

²⁸¹ Vid ENDICOTT, TH. A. O., «Law is necessarily vague», *Legal Theory*, 7, 2001, pp. 379 y ss.

²⁸² Vid. ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», cit., p. 191.

incrementar la arbitrariedad»²⁸³. Así, por aludir a alguno de los ejemplos a los que recurre Endicott, las exigencias de precisión del Derecho que supusieran la eliminación de las posibilidades del cambio de las normas del sistema jurídico, implicarían un déficit del imperio de la ley en el cuarto sentido de la idea de arbitrariedad al que se ha aludido, desde el momento en que se incrementaría la irracionalidad del Derecho: es impensable un sistema jurídico que no contenga mecanismos de cambio²⁸⁴; por otra parte, el hecho de que el sistema jurídico tenga que estar configurado de tal manera que sea capaz de guiar las conductas de los individuos (vid, infra. Raz) no quiere decir que el sistema nunca pueda cambiar: sólo exige que la perspectiva del cambio no imposibilite el uso de las normas existentes en ese momento como guía de las conductas²⁸⁵.

En definitiva, señala Endicott, la vaguedad es un déficit del imperio de la ley cuando conduce a la arbitrariedad justamente en el sentido menos explorado de éste término, es decir, cuando implica un alejamiento de la razón del Derecho. Cuando los poderes públicos utilizan la vaguedad del Derecho para imposibilitar que los individuos se guíen por las normas jurídicas, y

²⁸³ ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», cit., p. 192. *Cursivas* en el texto.

²⁸⁴ Cabe recordar en este punto la necesidad de las reglas secundarias de cambio señalada por Hart. A. AARNIO se ha referido a la necesaria confluencia del respeto a la estabilidad con la flexibilidad exigida por las circunstancias, a la hora de eliminar la incertidumbre de los contenidos del sistema jurídico, en *Lo racional como razonable*, trad. de E. Garzón Valdés, revisión de E. Garzón Valdés y R. Zimmerling, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 32.

²⁸⁵ Vid. ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», cit., p. 193. Los otros ejemplos, que podrían proponerse en apoyo de la tesis según la cual la precisión del Derecho supone siempre el incremento del imperio de la ley, y a los que alude Endicott son los referidos a la existencia, en el marco de un sistema de adjudicación, de órganos que toman decisiones finales no sometidos por tanto a un ulterior control por parte de un órgano superior; y el caso en el que se afirma que el imperio de la ley, para ser efectivo, debería regular todas las facetas de la vida social.

para impedir que las normas jurídicas actúen como guía de las conductas diferenciada de la voluntad particular de los poderes públicos, se distancian de la razón del Derecho. Entonces, concluye Endicott, la vaguedad supone un déficit para el imperio de la ley²⁸⁶.

En realidad, estamos ante el problema planteado por la presencia de ciertos rasgos (vaguedad, textura abierta) en los Ordenamientos que pueden llegar a dificultar la consecución del ideal de certeza en el que se asienta el imperio de la ley. Pero, posiblemente, en última instancia la certeza completa no sea sino eso, un ideal. Ello, en primer lugar, por la propia constitución lingüística del Derecho; en segundo lugar, porque, como ha recordado Hart, «somos hombres y no dioses», lo cual implica que, a la hora de regular de manera no ambigua y por adelantado los casos, a través de reglas generales, nos encontramos con dos obstáculos. En primer lugar, una relativa ignorancia de los hechos; en segundo lugar, una relativa indeterminación de propósitos. El legislador es incapaz de conocer de manera anticipada todas las dimensiones de los hechos futuros, sus posibles combinaciones y también sus posibles excepciones. Esa impredecibilidad de los hechos del mundo por parte del legislador condiciona el producto normativo a través del cual el legislador pretende regular esos hechos; e influye de manera evidente en la predecibilidad que el destinatario de las normas espera de la acción normativa de los poderes públicos en general. Como señala Hart, «Si el mundo en que vivimos estuviera caracterizado únicamente por un número finito de notas y éstas, junto con todos los modos en que pudieran combinarse, fueran conocidas por nosotros, podríamos formular provisiones por adelantado para toda posibilidad. Podríamos elaborar reglas cuya aplicación a los casos particulares nunca exigiera una nueva elección. Todo podría ser conocido y, por ello mismo, las reglas podrían especificar por adelantado la

²⁸⁶ Vid. ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», cit., p. 203.

solución para todos los problemas (...). Obviamente, ese mundo no es el nuestro...»²⁸⁷. Entiendo que la reflexión de Hart tiene el sentido de llamar la atención sobre las dificultades de materializar las exigencias del imperio de la ley, entre las que la claridad y la predecibilidad ocupan un lugar relevante, pero no pretende certificar la imposibilidad del mismo. La constatación de esas dificultades es compatible con una concepción gradual del cumplimiento de las exigencias del imperio de la ley.

d) Sobre el valor moral del imperio de la ley

La siguiente cita de López Calera resume bien la tesis que se adopta como punto de partida: «Precisamente la misma existencia del Derecho, al margen de sus concretos contenidos morales, es una prueba de la necesidad que tiene el Poder de adquirir unas ciertas formas de racionalización que sin duda le limitan. Todo Poder crea Derecho y actúa según Derecho. Pero en cuanto se «juridifica», ha entrado ya inevitablemente en un cierto orden de racionalidad. La forma jurídica significa, como mínimo, la expresión de una previsión de lo que puede o no puede hacer el poderoso, de lo que pueden o no pueden hacer los súbditos. La forma jurídica al establecer anticipadamente modelos de comportamiento y de manera estable, impide en alguna medida la arbitrariedad y el capricho absoluto del Poder. Por ello Kant defendió el valor moral del Derecho en sí: la misma existencia del Derecho, al margen de sus contenidos materiales, sobre los que no cabe consenso universal, es ya en sí un valor ético»²⁸⁸.

Como señalé con anterioridad, a partir de la afirmación de la relación necesaria entre el imperio de la ley y el concepto de Derecho, se plantean determinadas cuestiones. Nos interesa en este momento centrarnos en las consecuencias derivadas de la

²⁸⁷ HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, cit., p. 160.

²⁸⁸ LÓPEZ CALERA, N. M., *Derecho y Poder: ¿La razón de la fuerza o la fuerza de la razón?*, Academia de Jurisprudencia y Legislación, Granada, 1991, p. 20.

afirmación del sentido moral del imperio de la ley. El hecho, de que, como ha recordado Summers, una teoría formal del imperio de la ley no centre su atención en los contenidos de las normas, sea *content-independent*, no quiere decir que de ella no se deriven consecuencias axiológicas²⁸⁹.

Se ha afirmado, pienso que con razón, que si bien es cierto que la satisfacción de los requisitos del imperio de la ley no garantiza la moralidad de un sistema jurídico, también lo es que las limitaciones a las que se somete al Poder normativo tienen consecuencias morales²⁹⁰. En este sentido se ha propuesto caracterizar al imperio de la ley como un «principio de moralidad institucional»²⁹¹. Así, el imperio de la ley, en primer lugar, crea condiciones en las que se realiza la justicia formal, en el sentido de que garantiza la regularidad del trato de las circunstancias similares; en segundo lugar, supone limitaciones formales al ejercicio del Poder; en tercer lugar, el imperio de la ley garantiza la certeza del Derecho que, entendida como el saber a qué atenerse, se presenta como un requisito imprescindible de la realización de la autonomía individual²⁹². Cierta-

²⁸⁹ Vid. SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», cit., p. 135.

²⁹⁰ Vid. ESCUDERO ALDAY, R., *Positivismo y moral interna del Derecho*, cit., pp. 417 y ss.

²⁹¹ Vid. JOWELL, J., «The rule of law today», JOWELL, J., OLIVER, D., (eds.), *The Changing Constitution*, third edition, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 57 y 72.

²⁹² Sobre la relación entre la certeza y la predictibilidad del Derecho, de un lado, y la autonomía individual, de otro, vid., entre muchos, WALDRON, J., «The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory», cit., pp. 84-85 en particular. Por su parte, KELSEN desvinculó el *rule of law* respecto de la libertad individual: «... el principio del 'rule of law' no garantiza la libertad del individuo, sino solamente la posibilidad de que éste individuo prevea, hasta un cierto límite, la actuación de los órganos de aplicación del Derecho, es decir, de los órganos administrativos y judiciales, y adapte, en consecuencia, su conducta a esta actuación prevista (...). El principio del 'rule of law' no garantiza la libertad del individuo sometido al gobierno, porque este principio no se refiere a la relación entre el gobierno y el gobernado, sino una relación interna al gobierno, la relación entre las funciones de creación del Derecho y de apli-

mente estamos, como reconoce Rafael Escudero, ante elementos constitutivos del sistema jurídico, que tienen valor moral, pero que no aseguran la moralidad del mismo. Esos elementos, entendidos desde una perspectiva formal, poseen *per se* relevancia práctica, con independencia del contenido de las normas²⁹³. La moralidad o inmoralidad del sistema jurídico, y de las normas que lo componen es, por el contrario, una cuestión que depende en última instancia del contenido de las normas. Podríamos afirmar que alguna de las exigencias del imperio de la ley, como por ejemplo la imparcialidad en la aplicación de la ley suponen, como afirmó Hart, «el germen de la justicia» o «una forma mínima de justicia»²⁹⁴. Pero el mismo Hart rápidamente añadía, en referencia a la moral interna del Derecho: «...si esto es lo que significa la conexión necesaria del Derecho y la moral, podemos aceptarla. Infortunadamente, es compatible con una enorme iniquidad»²⁹⁵. Por lo tanto, podemos afirmar que imperio de la ley no es sinónimo de Derecho justo; el imperio de la ley posibilita, aunque no asegura, el carácter justo del Derecho. Ello no obliga a dejar de reconocer el valor moral que

cación del mismo; su finalidad es la conformidad de la segunda a la primera. El efecto del 'rule of law' es la racionalización de la actividad del gobierno, es decir, de los procedimientos de creación y de aplicación del Derecho. Su meta no es la libertad, sino la seguridad, la seguridad jurídica o *Rechtssicherheit*, como es llamada en la jurisprudencia alemana», «Los fundamentos de la democracia», cit., p. 311. En este punto Kelsen no asume la tesis, compartida en este trabajo, según la cual la existencia de condiciones de seguridad es un requisito de la libertad. Por otra parte, el *rule of law*, entendido como imperio de la ley, no afecta exclusivamente a la acción de los poderes públicos, sino que también vincula a los individuos, tanto en sentido restrictivo (normas que impiden acciones), como facultativo (normas que posibilitan o permiten acciones).

²⁹³ No obstante, dicha relevancia termina de definirse precisamente por dicho contenido. R. GUASTINI mantiene la tesis de la irrelevancia práctica del imperio de la ley en el caso de que el Derecho no establezca límites sustantivos al Poder, en «Implementing the Rule of Law», cit., p. 95.

²⁹⁴ HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, cit., p. 255.

²⁹⁵ HART, H. L. A., *El concepto de Derecho*, cit., p. 256. Vid. también WALDRON, J., «The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory», cit., p. 93.

se desprende de las exigencias del imperio de la ley. Ciertamente, no hay nada que desde el punto de vista lógico determine la incompatibilidad entre un sistema jurídico que, como tal, satisface los requisitos del imperio de la ley y el hecho de que dicho sistema jurídico incluya contenidos injustos. No obstante, se ha afirmado, dicha satisfacción, incluso cuando el contenido del sistema sea moralmente reprochable, tiende a asegurar los valores que inspiran al idea del imperio de la ley²⁹⁶. En ese sentido es en el que se habla del carácter tendencial del imperio de la ley en relación con la justicia²⁹⁷.

Si se afirma el sentido moral del imperio de la ley, y al mismo tiempo su relación necesaria con el concepto de Derecho, surge la pregunta sobre el tipo de relación entre el Derecho y la moral que se está defendiendo. Se ha mantenido la tesis según la cual un determinado grado de cumplimiento de las exigencias del imperio de la ley es imprescindible no para la justicia del Derecho, sino para su misma existencia. Si el imperio de la ley tiene un valor moral y si su existencia es imprescindible en el Derecho, desde el momento en que lo distingue de la arbitrariedad, entonces parece que el Derecho tiene un rasgo necesario que tiene valor moral, con lo cual estaríamos frente a la afirmación de la relación necesaria entre el Derecho y la moral.

Ciertamente, la posición respecto a esta cuestión varía en función de la concepción del imperio de la ley que se maneje. Así, si se considera que los requisitos del imperio de la ley tienen la función de establecer las condiciones que permitan que el Derecho sea obedecido, se está manteniendo en definitiva una concepción instrumental al respecto. Como vamos a ver a continuación, ésta es la posición de J. Raz. Si por el contrario se entiende que el imperio de la ley adquiere sentido en el mar-

²⁹⁶ Vid. SUMMERS, R. S., «A formal Theory of the Rule of Law», cit., p. 140.

²⁹⁷ Vid SUMMERS, R. S., *La naturaleza formal del Derecho*, cit., pp. 70-71.

co de un universo moral, como afirma F. Laporta, se está proponiendo de manera directa una lectura moral del mismo. La cuestión que se plantea es la de saber hasta qué punto las características del imperio de la ley son en realidad rasgos básicos de la idea de Derecho o si por el contrario el imperio de la ley es entendido como un deber ser en relación con el Derecho, una meta a alcanzar. Los argumentos empleados respectivamente por Joseph Raz y por Francisco Laporta pueden sernos de utilidad a la hora de plantearnos esta cuestión.

En su artículo «El Estado de Derecho y su virtud»²⁹⁸, Raz señala que el imperio de la ley puede ser entendido en un sentido amplio o en un sentido restringido. En el primer caso, significa que «la gente debe obedecer el derecho y regirse por él»; en el segundo, se utiliza para señalar que «el gobierno debe ser regido por el derecho y sometido a él»²⁹⁹. La idea de imperio de la ley debe utilizarse, señala Raz, en el primer sentido, ya que en el segundo se incurre en una auténtica tautología. En efecto, las actividades de un gobierno no autorizadas por el Derecho no pueden ser consideradas del gobierno como tal, careciendo de efectos jurídicos e incluso pudiendo ser ilícitas. Si el imperio de la ley se entiende como la afirmación de que los individuos deben actuar en el marco y de acuerdo con lo establecido por la ley, entonces puede ser observado como un ideal político, como una meta a alcanzar por un sistema jurídico, del que se puede carecer o no, en mayor o menor medida. Raz señala que, al ser el imperio de la ley una de las virtudes que un sistema jurídico puede tener, es compatible con situaciones no democráticas o con gobiernos desconocedores de la igualdad y de los derechos de los individuos.

²⁹⁸ Incluido en ID., *La autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y moral*, trad. y notas de R. Tamayo Salmorán, UNAM, México, 1982, pp. 263 y ss. Como señala el traductor, se ha traducido «rule of law» como «Estado de Derecho», en el sentido de «imperio de la ley». En este sentido se utiliza en este trabajo. Un análisis crítico de la posición de Raz es el de F. VIOLA en *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi*, cit., pp. 77 y ss.

²⁹⁹ RAZ. J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 265.

Pero el imperio de la ley no significa exclusivamente que los individuos deban guiarse por el Derecho y deban obedecerlo. Esta vertiente tiene que ser completada por otra, que es aquella según la cual «el derecho tiene que ser de tal manera que la gente pueda ser guiada por él»³⁰⁰. Entre ambas vertientes hay una implicación lógica. Parece evidente que no se puede exigir lo primero sin cumplir la segunda condición. Un Derecho no susceptible de ser obedecido no puede pretender ser obedecido. Como afirma con rotundidad Raz, «si el derecho debe ser obedecido *tiene que ser capaz de guiar el comportamiento de sus súbditos*. Debe ser de tal manera que los súbditos puedan encontrar lo que es y actuar en base a él»³⁰¹. Por lo anterior, Raz defiende que su concepción es formal, ya que no dice ni quien debe crear el Derecho, ni qué es lo que se debe mandar: descansa sobre la idea según la cual el Derecho debe poder constituir una guía efectiva para las conductas de los individuos.

Para lograr ese objetivo deben satisfacerse determinados principios. Algunos de ellos (los tres primeros) pretenden que el Derecho esté configurado de manera que pueda guiar efectivamente las conductas de los sujetos, mientras que el resto sirve para evitar distorsiones y desviaciones internas en el sistema jurídico que impedirían el logro de ese objetivo. Raz, señala los más importantes: 1) todas las disposiciones jurídicas deben ser prospectivas, abiertas y claras; 2) las disposiciones jurídicas deben ser relativamente estables; 3) el establecimiento de disposiciones jurídicas particulares debe ser guiado por disposiciones jurídicas, abiertas, estables, claras y generales; 4) la independencia del Poder judicial debe ser garantizada; 5) los principios de la justicia natural deben garantizarse³⁰²; 6) los tribunales deben tener la capacidad de poder revisar el cumpli-

³⁰⁰ RAZ, J. «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 267.

³⁰¹ *Ibidem*. Cursivas en el texto.

³⁰² Raz se refiere a principios como *nemo iudex in causa sua*, o *audi altera partem*.

miento de estos principios; 7) los tribunales deben ser fácilmente accesibles; 8) a los órganos encargados de la prevención criminal y dotados de discrecionalidad no se les debe permitir pervertir el Derecho.

A la vista de lo anterior se puede plantear la siguiente cuestión: ¿por qué se considera conveniente que un sistema jurídico este configurado de acuerdo con los anteriores principios?, ¿en qué radica su utilidad? Raz ofrece tres respuestas. El Imperio de la ley es un útil instrumento a la hora de evitar la arbitrariedad. El imperio de la ley no puede evitar todas las formas de arbitrariedad, pero sí las más importantes. No puede impedir que un gobernante dicte una norma tendente a asegurar intereses personales no identificados con los públicos, pero sí puede evitar que una norma se modifique de manera indiscriminada, secreta o atribuyéndole efectos retroactivos. En todo caso Raz reconoce la dificultad de fijar con claridad la noción de arbitrariedad. Así señala que «parece, sin embargo, que un acto es ejercicio de poder arbitrario sólo si fue hecho, sea con indiferencia en cuanto a si sirven los propósitos los cuales son los únicos que pueden justificar el uso de tal poder o con la creencia de que no los sirve. La naturaleza de los propósitos varía con la naturaleza del poder. Esta condición representa al ‘poder arbitrario’ como un concepto subjetivo. Todo depende de la forma de pensar de los hombres sobre el poder. (...) Alrededor de su núcleo subjetivo la noción de poder arbitrario ha producido un fuerte contorno objetivo. En virtud de que universalmente se cree que está mal usar los poderes públicos para fines privados, cualquier uso de este tipo, en sí mismo, es una instancia de poder arbitrario»³⁰³.

Por otra parte, el imperio de la ley permite que los individuos puedan «escoger estilos y formas de vida, fijar objetivos a largo plazo y dirigir efectivamente la vida de uno hacia ellos»³⁰⁴. Ello es posible siempre que existan estructuras de estabilidad y seguridad en el marco de las cuales los individuos puedan pro-

³⁰³ RAZ, J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 275.

³⁰⁴ *Ibidem*.

gramar y desarrollar sus acciones. El Derecho se presenta, según Raz, como un instrumento idóneo al respecto ya que, por una parte, estabiliza relaciones sociales y, por otra, crea bases estables y seguras, a través de su propia autolimitación, que van a permitir el desarrollo de planes por parte de los individuos. Esta segunda es la vertiente vinculada al imperio de la ley.

En tercer lugar, el imperio de la ley es una exigencia que debe cumplir un Ordenamiento jurídico que pretenda ser respetuoso con la dignidad humana, desde el momento en que se considera que ésta supone el reconocimiento de la capacidad que tienen los individuos para organizar su futuro. Esa capacidad se identifica con la autonomía. Evidentemente, no todas las ocasiones en las que un sujeto carece de esa capacidad son identificables con carencias del imperio de la ley. Hay causas naturales o situaciones achacables a los individuos que pueden provocar esa incapacidad. En muchas ocasiones las violaciones de la dignidad y de la autonomía derivan de acciones humanas. Raz habla en este sentido de los insultos, de la esclavitud y de la manipulación³⁰⁵. En el caso del insulto, existe una ofensa para la dignidad humana si se niega la autonomía de la persona o su mérito para ser tratada como individuo autónomo. Por su parte, la esclavitud supone la negación de las posibilidades que tiene el individuo de manipular los elementos y las situaciones que le rodean³⁰⁶. La manipulación se produce allí donde se modifican de manera intencionada los gustos, preferencias y posibilidades del sujeto³⁰⁷.

³⁰⁵ Vid. RAZ, J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 276.

³⁰⁶ Raz señala que no se refiere a la esclavitud en su acepción más extendida, que supone una situación prolongada en el tiempo, sino también a aquellos caso en los que la negación de la posibilidad de manipulación y maniobra se localiza en situaciones concretas.

³⁰⁷ RAZ subraya diferencias entre esclavitud y manipulación: «Manipulación —en otras palabras— es manipulación de la persona, de aquellos factores relevantes a su autonomía los cuales son internos a él. La esclavitud es la eliminación del control cambiando los factores externos de la persona», «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 276.

Pero el Derecho también puede violar la dignidad de las personas. Evidentemente, a estas alturas de la historia parece que esta afirmación no necesita demasiadas demostraciones. No obstante, y circunscribiéndonos al imperio de la ley, Raz reconoce que ciertamente el imperio de la ley *per se* no garantiza que no se produzcan esas violaciones. Pero, «la deliberada violación del estado de derecho [imperio de la ley], viola la dignidad humana»³⁰⁸. ¿De qué manera violaciones del imperio de la ley afectan a la dignidad y a la autonomía humana? Se señalan al respecto dos situaciones: cuando el Derecho crea incertidumbres o cuando lleva a malograr y frustrar expectativas: «Conduce a incertidumbre cuando el derecho no permite a la gente prever los desarrollos futuros o formarse expectativas definidas (como en caso de vaguedad y la mayoría sde los casos de muy amplia discrecionalidad). Conduce a expectativas frustradas cuando la apariencia de estabilidad y certidumbre que estimula a la gente a confiar y planear en base al derecho existente se encuentra destruida por la creación retroactiva del derecho o al impedir una adecuada aplicación del derecho, etc.»³⁰⁹.

Raz no está de acuerdo con tesis como las de Fuller, que afirman, partiendo de la idea de que los principios del imperio de la ley son indispensables para la existencia del Derecho, la existencia de un vínculo entre el Derecho y la moral. Para Raz, el valor del imperio de la ley es esencialmente negativo: consiste en su capacidad para evitar los peligros que se pueden derivar del ejercicio del poder arbitrario que inevitablemente puede crear el Derecho. Así, el imperio de la ley «es una virtud negativa en dos sentidos: la conformidad a él no causa bien, salvo impidiendo el mal y el mal que se evita es el mal que únicamente pudo haberse producido por el propio derecho»³¹⁰. De manera que el valor del imperio de la ley consistiría en evitar los males que se derivan de la posibilidad de que el Derecho no sea

³⁰⁸ RAZ, J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 277.

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ *Ibidem*.

claro, estable, irretroactivo, etc. Como los principios del Estado de Derecho, en términos generales, no son de presencia obligatoria en el Ordenamiento jurídico, de ello se deriva que en el Ordenamiento no siempre se pueden evitar esos males. Por tanto, desde esta perspectiva, el imperio de la ley no garantizaría *necesariamente* ninguna virtud al Derecho.

Pero esta cuestión puede ser analizada desde otra perspectiva, que es la que asume Raz cuando señala que «la conformidad al Estado de derecho [imperio de la ley] es esencial para asegurar cualquier propósito que el derecho está destinado a alcanzar»³¹¹. El Derecho puede lograr fines directos o indirectos. Los primeros son aquellos que se aseguran a través del cumplimiento del Derecho (se identifican con el mismo), mientras que los segundos son los que se derivan, no necesariamente, de dicho cumplimiento. Pues bien, para Raz, el respeto a los principios del imperio de la ley no hace sino garantizar la realización de los fines directos del Derecho. Ello es posible gracias a que, de acuerdo con esos principios, los individuos conocen las reglas y actúan en consecuencia. En la medida en que el Derecho actúe como instrumento de guía de los comportamientos, podrá alcanzar los objetivos propuestos. Pero estos objetivos pueden ser buenos o malos. En efecto, Raz no emite una valoración moral de esos objetivos. Se limita a señalar la indispensabilidad de los principios del imperio de la ley para poder materializar esos objetivos. De la misma manera que el hecho de que la hoja de un cuchillo esté bien afilada no es un valor moral del cuchillo sino que es una exigencia para que el cuchillo pueda cortar, (que es su función, con independencia de que el cuchillo se utilice para curar o para dañar, teniendo en cuenta que si no corta bien no será un buen cuchillo), la satisfacción de las exigencias del imperio de la ley son el criterio que sirve para certificar la excelencia del Derecho. Pero esta excelencia no debe ser considerada desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista instrumental o funcional.

³¹¹ RAZ, J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 280.

Es un requisito para que el Derecho cumpla correctamente con sus funciones, con independencia del juicio moral que puedan merecer dichas funciones: «El derecho para ser derecho debe ser capaz de guiar el comportamiento, aunque sea ineficientemente. Como otros instrumentos, el derecho tiene la específica virtud, moralmente neutral, de ser neutral en cuanto al fin para el cual el instrumento es empleado, es la virtud de eficiencia; la virtud del instrumento como instrumento. Para el derecho esa virtud es el estado de derecho [imperio de la ley]. Así, el estado de derecho [imperio de la ley] es una virtud inherente al derecho, pero no una virtud moral en cuanto tal»³¹².

Por su parte, Francisco Laporta subraya de manera más acentuada, en mi opinión, las dimensiones morales del imperio de la ley. Adelantándome a las conclusiones, afirmaré en este momento que aunque el desarrollo de la argumentación es en muchos puntos paralelo al de Raz, las conclusiones a las que llega Laporta difieren en algunos puntos de las de aquel. O, mejor que de conclusiones, habría que hablar de presupuestos, ya que parte de la consideración del imperio de la ley como universo ético. Si bien la cita es larga, merece ser recogida porque resume bien la posición adoptada por Laporta: «...hay que dejar desde el principio bien sentado que el imperio de la ley es, efectivamente, eso: un universo ético; es decir, no es una «propiedad» del Derecho, algo inherente a la mera existencia empírica del orden jurídico, algo que nace ya con la mera norma jurídica, sino que es un postulado metajurídico, una exigencia ético-política o un complejo principio moral que está más allá del puro derecho positivo; o dicho en términos familiares, que no se refiere al derecho que «es», sino al derecho que «debe ser». No se realiza, pues, en la mera legalidad. La legalidad puede, sí, producir una cierta «seguridad» (...), pero la legalidad como tal tanto puede incorporar como traicionar las exigencias del imperio de la ley, porque éste no aparece con la mera existencia de normas jurídicas, sino con la vigencia de

³¹² RAZ, J., «El Estado de Derecho y su virtud», cit., p. 282.

unas normas que incorporen algunos rasgos muy particulares. Es decir, el imperio de la ley es un complejo imperativo moral dirigido al sistema jurídico y que lleva en sí tanto un haz de exigencias materiales respecto a su contenido como un conjunto de exigencias formales respecto a su estructura»³¹³.

Laporta parte de la consideración del principio ético de autonomía individual, que supone el reconocimiento del sujeto como protagonista a la hora de planificar y proyectar sus acciones y su trayectoria; la autonomía implica capacidad de autogobierno, entendida como un ideal regulativo, «en el sentido de que toda nuestra comprensión de la cultura descansa en la presuposición de que es deseable que los seres humanos se definan a sí mismos a través de su propia capacidad de decisión»³¹⁴. Esta capacidad se puede ver dificultada desde el momento en que el individuo se encuentra incluido en una sociedad en la que hay un gobierno que produce normas que se imponen coactivamente: «Cuando estoy sujeto a normas que se me imponen si es necesario mediante una apelación a la fuerza, es decir, cuando soy el sujeto obligado por normas jurídicas, entonces, y en la medida en que lo soy, *no soy* un agente moral autónomo, porque ser un agente con esas características parece excluir, por definición, la acción del poder político sobre mi conducta»³¹⁵. Pero, si el principio de autonomía es una exigencia moral, la inclusión en una sociedad parece también algo inevitable. Estamos frente a una tensión entre algo exigido y algo inevitable. Señala Laporta que dicha tensión se pretende solucionar, en el marco de nuestra cultura político-jurídica, justificando la creación del Poder político y del Derecho de un modo prudencial: constatada la existencia de conflictos de intereses en el grupo humano, es necesaria la institución de una

³¹³ LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», *Doxa*, n.º 15-16, 1994, p. 135.

³¹⁴ LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 37.

³¹⁵ LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», cit., p. 137.

autoridad que pueda actuar disuasoriamente y que pueda ejercer la coacción y el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. No obstante, de la existencia de esa autoridad, dotada en principio de un poder ilimitado, también se pueden derivar peligros para la autonomía personal: «La suerte de los propósitos y proyectos de los seres humanos bajo un poder ilimitado de estas características no sería, desde luego, muy envidiable y la dignidad del hombre entendida como autonomía individual estaría supeditada nuevamente a los excesos de un mecanismo tan veleidoso, insaciable e impredecible como el que más»³¹⁶. Para evitar estos peligros existen tres ideales básicos, de carácter moral: el imperio de la ley, los derechos del hombre y el principio democrático.

¿De qué manera explica Laporta la relación que existe entre imperio de la ley y autonomía personal, sentando por tanto las bases de la afirmación según la cual el imperio de la ley constituye un universo ético? La vida cotidiana y las decisiones que los individuos toman en su transcurso son incomprensibles sin el condicionamiento derivado de la existencia de normas jurídicas. En efecto, el Derecho puede facilitar esas decisiones o, por el contrario dificultarlas. Laporta asume la distinción, desarrollada entre otros por J. Elster, entre dos contextos en los cuales se pueden adoptar decisiones: el contexto paramétrico y el contexto estratégico. El primero se caracteriza por su estabilidad, constancia y fijeza, mientras que en el segundo, los componentes que lo configuran están sometidos a variaciones. El grado de predecibilidad o previsibilidad es mayor en un contexto o paramétrico que en uno estratégico³¹⁷. Pues bien, el Dere-

³¹⁶ LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», cit., p. 137.

³¹⁷ «... en el seno de contextos del primer tipo (paramétricos) se abren ante el individuo-decisor las posibilidades de proyectar con razonable seguridad sus acciones y anticipar sus consecuencias. En el seno de contextos del segundo tipo (estratégicos), por su carácter cambiante, inesperado e inseguro el individuo-decisor tiene muchas más dificultades a la hora de construir o configurar algún proyecto estable porque se ve forzado a responder «a la defen-

cho tiene mucho que decir a la hora de la configuración de los contextos de decisión como paramétricos o estratégicos. A través del imperio de la ley el Derecho constituye contextos paramétricos de decisión, ya que crea condiciones de estabilidad que le permiten al individuo adoptar decisiones en un marco de credidumbre, previsibilidad y predecibilidad, no sólo de los elementos del contexto, sino también de las consecuencias de sus decisiones y acciones. Desde el momento en que los contextos de decisión dejan de ser estratégicos para convertirse en paramétricos, podemos generar expectativas basadas en la probabilidad y en la regularidad³¹⁸.

Para que la constitución de dichos contextos paramétricos pueda tener lugar a través del imperio de la ley, el Derecho debe constituirse de una determinada manera; estamos ante los requisitos del imperio de la ley, que son identificados por Laporta de la siguiente manera: 1) el Derecho debe estar constituido por un conjunto de normas, entendidas como reglas, ya que sólo así se pueden crear condiciones de regularidad en el marco de la cuales los individuos puedan adoptar decisiones en contextos paramétricos: «el imperio de la ley nos recuerda que la autonomía individual sólo es posible en un contexto social *regulado*, es decir, sometido a normas»³¹⁹; 2) las normas jurídi-

siva» y caso por caso a los desafíos y respuestas imprevistas que el contexto le vaya lanzando» LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», cit., p. 139. Por su parte, Albert CALSAMIGLIA ha utilizado la distinción entre racionalidad paramétrica y racionalidad estratégica para establecer la conexión entre la primera y la racionalidad jurídica tradicional —vinculada a la concepción tradicional de la ciencia jurídica—, de un lado, y entre la segunda y la racionalidad propia de los sistemas jurídicos contemporáneos —vinculados al modelo del jurista innovador que «subordina el principio de sujeción a la ley al de la resolución a decuada de los conflictos», y que «se aparta de la ley cuando considera que es necesario para encontrar una solución *mejor*», en CALSAMIGLIA, A., «Justicia, eficiencia y optimización de la legislación», cit., pp. 49 y 62-63 (las citas se encuentran en p. 62).

³¹⁸ Vid. LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 49.

³¹⁹ LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», cit., p. 140.

cas deben tener una determinada estructura: deben ser emitidas por una autoridad reconocida y ser generales, prospectivas, estables, claras y ciertas; 3) desde el punto de vista dinámico, el referido a la interpretación y aplicación del Derecho, el imperio de la ley exige determinados requisitos institucionales, condiciones de imparcialidad, sometiendo al mismo tiempo a la argumentación a determinadas exigencias. El principal requisito institucional es el de la separación de poderes, a través de la cual se garantiza la existencia de una institución independiente a la que puede acudir el individuo cuando se producen casos de violación del Derecho o problemas en la interpretación del mismo, de manera que se pueda asegurar la autonomía individual desde el momento en que se sabe que nadie va a poder «establecer limitaciones, atribuir responsabilidades ni acordar sanciones que no estuvieran previstas de antemano por la norma»³²⁰. Por otro lado, las condiciones de imparcialidad se identifican con los denominados «principios de justicia natural», tendentes a asegurar la imparcialidad del juez en el proceso y la igualdad de las partes en el mismo. Por último, las exigencias de argumentación hacen referencia a la primacía del razonamiento deductivo, que toma como premisa básica a las normas jurídicas, entendidas como reglas generales y ciertas, y que excluye preferencias personales y premisas fácticas apoyadas en hechos no probados.

Como se puede observar, la dimensión moral del imperio de la ley es afirmada en mayor medida por Laporta. Raz subraya la cuestión de que el imperio de la ley es un requisito para que el Derecho cumpla sus fines: guiar las conductas. Pero para ello debe estar configurado de manera que pueda efectivamente guiar esas conductas. El imperio de la ley sería la condición a cumplir por el Ordenamiento jurídico si quiere en efecto alcanzar sus fines. Pero Raz no dice nada en relación con la calificación moral de esos fines. Esos fines pueden ser buenos o malos;

³²⁰ LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», cit., p. 143.

con el Derecho se pueden hacer cosas correctas o incorrectas desde el punto de vista moral, pero para poder hacer esas cosas es necesaria una herramienta adecuada. La adecuación o excelencia de esa herramienta viene determinada por los principios del imperio de la ley. Es evidente que esta propuesta está basada en una concepción instrumental de dichos principios. Laporta, por su parte, no presta atención a esta concepción instrumental, aunque reconoce que la satisfacción de las exigencias del imperio de la ley es compatible con grandes dosis de injusticia³²¹. Se centra en la idea según la cual el imperio de la ley constituye un universo ético desde el momento que es un instrumento de garantía de la autonomía y de la dignidad humanas. La cuestión que surge aquí es que, en realidad, la garantía de la dignidad es una consecuencia derivada del imperio de la ley: el Derecho debe configurarse de acuerdo con las exigencias del imperio de la ley porque ello parece imprescindible para poder lograr su objetivo que es la guía de las conductas; y como consecuencia de ello y dado el carácter de esos principios, se garantiza la dignidad. De lo contrario se podría estar afirmando que la finalidad del Derecho es garantizar la dignidad. Desde un punto de vista normativo puede ser así, pero no desde un punto de vista descriptivo. Creo que las estrategias son diferentes en ambos casos: Raz se preocupa por la finalidad del Derecho (guiar conductas) y se plantea la necesidad de que, para lograr esa finalidad, el Derecho se constituya de una determinada manera. Laporta parte de la base de que el Derecho debe garantizar la dignidad y la autonomía, y para ello debe estar configurado de determinada manera.

A la vista de lo anterior, parece evidente que determinadas posiciones en relación con el valor moral del imperio de la ley pueden asociarse a su vez a una cierta comprensión de la relación entre el Derecho y la moral. En efecto, como se señaló con

³²¹ Vid. LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley y seguridad jurídica», DÍAZ, E., COLOMER, J. L., (eds.), *Estado, justicia, derechos*, Alianza, Madrid, 2002, p. 127.

anterioridad, si se responde afirmativamente a la pregunta sobre las consecuencias morales del imperio de la ley, se plantea la cuestión de hasta qué punto no se está incurriendo en un planteamiento iusnaturalista, desde el momento en que a una característica formal del Derecho se le asocian rasgos morales.

En este punto, el recurso a la distinción entre iusnaturalismo en sentido fuerte e iusnaturalismo en sentido débil cobra sentido. El iusnaturalismo en sentido débil establece una conexión necesaria entre el Derecho y la moral. Pero no porque el Derecho, en su ser, sea expresión de valores morales, sino porque es un medio para alcanzar fines que merecen una valoración moral positiva. Así, el Derecho está conectado con la moral desde el momento en que permite crear condiciones de paz, seguridad, certeza. Son estos objetivos los que tienen un carácter moral que, a través de la relación medio-fin que se establece con el Derecho, repercutiría en éste. A diferencia de lo que ocurre con el iusnaturalismo en sentido débil, el iusnaturalismo en sentido fuerte predica el carácter moral directamente del Derecho, en cuanto Derecho, sin depender de su carácter instrumental respecto a ciertos fines, objetivos o consecuencias³²².

Las exigencias del imperio de la ley tienen carácter moral en la perspectiva del iusnaturalismo en sentido débil. Es decir, tienen un valor moral positivo desde el momento en que aparecen como requisitos necesarios, o simplemente medios, para alcanzar objetivos de los que sí se predica una evaluación moral positiva. Pero a partir de ese momento, un Derecho que cumpla con las exigencias del imperio de la ley puede tener unos contenidos que merezcan una evaluación moral negativa.

Pues bien, ¿desde qué punto de vista no hay diferencias entre el iusnaturalismo en sentido débil y el positivismo defen-

³²² Como se puede observar, la distinción coincide con aquella otra entre iusnaturalismo ontológico e iusnaturalismo deontológico. Vid. PASSERIN D'ENTREVES, A., *La dottrina del diritto naturale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1962, pp. 161 y ss.

dido en momentos anteriores de este trabajo, y derivado de la posición mantenida respecto a la relación entre el Derecho y la moral? Parece evidente que esta cuestión se puede plantear en el escenario de las relaciones entre el Derecho y la moral. Sabemos que, genéricamente considerados, el positivismo jurídico se ha diferenciado del iusnaturalismo en su diferente enfoque de la relación entre ambos sistemas normativos. Mientras el positivismo ha afirmado que existe una relación contingente entre el Derecho y la moral, el iusnaturalismo ha afirmado el carácter necesario de dicha relación. Pues bien, conviene llevar a cabo algunas acotaciones al respecto:

1) Ambos —el Derecho y la moral—, son sistemas normativos. En este sentido, les son de aplicación los criterios de evaluación predicables de estos sistemas: validez, eficacia y justicia o moralidad. Son sistemas normativos que como tales pertenecen a la esfera del deber ser: establecen modelos de comportamientos que deben ser seguidos por los individuos. Y dicho establecimiento no se hace a partir de una suspensión del juicio sobre su corrección moral. Desde el momento en que cualquier sistema normativo regulador de las conductas humanas expresa una opción moral, podemos afirmar que existe una conexión entre el Derecho (entendido como sistema normativo) y la moral.

2) Del hecho de que exista conexión entre el Derecho y la moral no se puede deducir que la moral con la que se conecta el Derecho sea necesariamente la moral merecedora de un juicio positivo, la moral correcta. Se puede afirmar, así, la conexión necesaria entre el Derecho y la moral y la relación contingente entre el Derecho y la moral correcta. Es evidente que en el primer caso estamos manejando un concepto neutro de moral que, desde el punto de vista analítico, es compatible con contenidos justos o injustos, morales o inmorales.

Esta comprensión de la relación que se establece entre el Derecho y la moral es compatible con el iusnaturalismo en sentido débil (y con el positivismo metodológico). En principio, nada parece excluir la posibilidad de que un sistema jurí-

dico cree condiciones de seguridad y certeza en el marco de los cuales una determinada minoría cultural va a ser discriminada e incluso masacrada. Los miembros de esa minoría disponen, con el suficiente grado de estabilidad, previsibilidad, claridad, certeza, de la información sobre las consecuencias de sus actos o de su pertenencia al grupo o minoría en cuestión. Como señala un Radbruch especialmente sensible a los problemas de moralidad del Derecho, «en verdad, toda ley positiva lleva consigo un valor, sin consideración de su contenido: es siempre mejor que ninguna ley, ya que crea al menos seguridad jurídica»³²³. Pues bien, podríamos plantearnos cómo se puede calificar la anterior situación a partir de la propuesta de comprensión del Derecho presentada por el iusnaturalismo en sentido débil. Parece que estaríamos obligados a emitir dos juicios morales. Uno de ellos estaría referido a la estructura del Ordenamiento, mientras que el otro lo estaría al contenido del mismo, es decir, a lo que ordena, prohíbe o permite. En el caso del ejemplo anterior, estaríamos ante un sistema jurídico que satisface los criterios establecidos por Fuller a la hora de identificar la moral interna del Derecho. Desde ese punto de vista, qué duda cabe de que el juicio moral sería *prima facie* positivo. Pero ese juicio moral positivo no sería posible en el caso de que examináramos los contenidos normativos de las anteriores estructuras.

De acuerdo con lo anterior, se podría llegar a la conclusión de que un Ordenamiento jurídico que satisfaga las exigencias de moralidad del iusnaturalismo en sentido débil puede ser, al mismo tiempo, un Ordenamiento jurídico que podría ser considerado injusto o inmoral. Lo anterior permitiría concluir que entre un iusnaturalismo en sentido débil, como el aquí presentado, y un positivismo que afirme la no necesaria relación entre el Derecho y la moral correcta existen diferencias muy tenues y que en todo caso serían de matiz.

³²³ RADBRUCH, G., *Arbitrariedad legal y Derecho suprallegal*, cit., p. 35.

e) Imperio de la ley y crisis de la ley

Me parece que en este momento de la reflexión sobre el imperio de la ley puede ser necesario hacer una referencia a la cuestión de la crisis de la ley, ya que podría pensarse que pudiera existir una cierta relación entre dicha crisis y la del imperio de la ley, de manera que la crisis de la ley acarrearía la de la idea de imperio de la ley. Por ello, parece pertinente una referencia a los diversos sentidos en los que se puede hablar de crisis de la ley, para analizar el grado de afectación de las exigencias del imperio de la ley entendido como imperio del Derecho.

Cuando se habla de crisis de la ley se alude a circunstancias o factores de distinto tipo³²⁴. Aunque es difícil deslindar claramente la naturaleza política o jurídica de algunas circunstancias, sí podemos afirmar que existen algunos factores de tipo predominantemente político que influyen en esa «crisis». Así, por ejemplo, el debilitamiento del imperio de la ley se constata, se afirma, «cuando el derecho deja de cumplirse y el Estado no interviene. Organizaciones delictivas que actúan impunemente ante la pasividad, cuando no la complicidad, de la policía, absoluciones judiciales injustificables (jurídicamente) aunque perfectamente explicables (socialmente), son ejemplos de esta abdicación de la legalidad que no sólo contribuye a paliar el conflicto social, sino que además crea una situación en la que muchos ciudadanos no tienen protegidos sus derechos y enerva ‘de manera preocupante’ la confianza de la población en un Estado que ni siquiera se muestra capaz de garantizar el orden y la seguridad»³²⁵. También se alude a las patologías de la

³²⁴ Vid. GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», cit.; PRIETO SANCHÍS, L., «Del mito a la decadencia de la Ley. La Ley en el Estado constitucional», ID., *Ley, principios, derechos*, Dykinson, Madrid, 1998; HIERRO, L., «El imperio de la ley y la crisis de la ley», cit., pp. 17 y ss.

³²⁵ GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», cit. p. 30.

democracia liberal, una de cuyas expresiones máximas es la de la corrupción; o a la, en ocasiones plagada de demoras y dificultades añadidas, situación y tratamiento que reciben algunos derechos sociales³²⁶.

En todo caso, me interesa detenerme en los factores «jurídicos» que provocarían esa crisis de la ley. Todos ellos no harían sino ratificar, desde diversos ángulos y perspectivas, la idea según la cual la ley habría perdido la posición de primacía que ocupaba tradicionalmente en los Ordenamientos jurídicos. En este sentido, el factor de referencia es el que viene determinado por la transformación del sentido y del valor de la Constitución. Ya no podemos hablar de un texto meramente programático, que *toca tierra* cuando es desarrollado por el legislador. La Constitución es, además de la norma suprema del Ordenamiento, directamente vinculante y aplicable³²⁷. Todo ello afecta de manera directa a la ley, que ya no es la norma central del Ordenamiento: está subordinada a la Constitución, adquiere validez de acuerdo con las condiciones —formales y materiales— especificadas por ésta. Lo cual tiene consecuencias importantes en lo que afecta a la concepción de la división de poderes, que ahora sufre una reformulación desde el momento en que el legislador ya no es soberano: está sometido a la Constitución y a un órgano específico que controla, desde el punto de vista de su constitucionalidad, sus decisiones normativas. La soberanía, hoy, se reconduce a la Constitución y al Poder que la crea, que no es el legislador sometido a ella.

³²⁶ Vid. GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», cit., pp. 31-33. Me he referido a la cuestión en ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «Argumentos para una teoría de los derechos sociales», *Revista de Derecho del Estado*, Universidad Externado de Colombia, n.º 24, julio 2010, pp. 45 y ss.

³²⁷ Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «La Constitución como norma jurídica», en ID., *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Cívitas, Madrid, 1982, pp. 35 y ss.; BLANCO VALDÉS, R. L., *El valor de la Constitución*, Alianza, Madrid, 1994.

Por otra parte, es cierto que la «soledad» que tradicionalmente había caracterizado la posición de la ley en la ordenación jerárquica de las fuentes ha desaparecido, desde el momento, en primer lugar, en que los Ordenamientos estatales hoy reciben del exterior, de las organizaciones en las que se integran los Estados, normas en ocasiones de directa validez y aplicabilidad y que muchas veces están, en la estructura del Ordenamiento jurídico, por encima de la ley. En segundo lugar, se alude también a la situación que se produce en aquellos Estados con una estructura en la que se articula un reparto territorial del Poder con directas consecuencias para el Ordenamiento jurídico desde el momento en que los centros que comparten la imputación del Poder político con el Estado «central» tienen reconocida capacidad normativa. Lo que ocurre en tal caso no sería, en mi opinión, una pérdida de la posición central de la ley, sino una pérdida de esa «soledad» a la que antes se aludió por parte de la ley del Estado central, que ahora se ve acompañada por otras leyes (con sus mismas características, y por tanto sometidas a las mismas críticas) dictadas por otras autoridades, que no son sino el modo que tiene el Estado de manifestar su presencia en determinados territorios.

También es cierto que hoy la ley ha perdido sus tradicionales rasgos de generalidad y abstracción. Dicha pérdida posiblemente puede explicarse a la luz del desarrollo del Estado social, en el marco del cual la necesidad de constante intervención y decisión se manifiesta necesariamente en la puesta en marcha de un proceso de multiplicación de normas —leyes en este caso, pero no sólo— lo cual redundaría no sólo en la calidad técnica del «producto», sino también en su falta de generalidad y abstracción. Hoy, como todos sabemos, las leyes-medida están pensadas para solucionar problemas, en algunos casos puntuales, y, en todo caso, han perdido esos rasgos tradicionales. La ley general y abstracta es el principal instrumento del Estado a la hora de crear condiciones de acción pero no es entendida, en su momento, como un instrumento de acción. Está vinculada, en este sentido, «con un Estado que se limitaba a crear las condiciones mínimas ambientales para que los sistemas social y

económico, supuestamente autorregulados, actuaran con arreglo a su propia dialéctica, es decir, la ley creaba un orden para la acción de otros, pero ella misma no era —normalmente— un instrumento de acción o intervención del Estado en el curso de los acontecimientos»³²⁸. Por otra parte, esta concepción de la ley está vinculada también a una determinada idea de la racionalidad que admite que el parlamento, foro en el que se desarrolla la discusión en condiciones de libre concurrencia (en claro paralelismo con una determinada concepción del mercado) es el ámbito propicio para generar decisiones racionales. Es en realidad la idea de que existe «una racionalidad objetiva que encierra tanto un *logos* (unas relaciones necesarias entre las cosas) como un *nomos* (cuya expresión es el derecho natural), que hay un orden objetivo inmanente a la realidad asequible al entendimiento, sea partiendo de unos principios seguidos de un discurso lógico, sea mediante un proceso de análisis y síntesis»³²⁹. Cuando desaparecen las condiciones en las que se basa esta concepción de la ley, se transforma la concepción misma.

¿Quiere decirse con ello que no tiene sentido aludir a la generalidad y a la abstracción como rasgo de ninguna norma jurídica? Esos rasgos pueden seguir siendo predicados de otra norma, la Constitución. Ahora la norma general y abstracta es la Constitución. El carácter general, abstracto e incluso abierto de las normas constitucionales explica que, en ocasiones, se haya afirmado que las normas constitucionales —o alguna de ellas— son principios (o, por lo menos, funcionan como principios). Ello tiene como consecuencia necesaria una reconsideración de la labor de los sujetos intérpretes de la Constitución. Este carácter de las normas constitucionales, se podría pensar, facilita— es más, exige— la introducción de planteamientos morales, de valoraciones y la puesta en marcha de técnicas

³²⁸ GARCÍA PELAYO, M., *Las transformaciones del Estado contemporáneo*, Alianza, Madrid, 1982, p. 62.

³²⁹ *Ibidem*.

específicas, como la ponderación. Es cierto que estas circunstancias obligan a una reformulación de una determinada concepción de la seguridad jurídica, concepto básicamente vinculado al imperio de la ley, ya que, «si en el centro de la noción misma de Estado de Derecho se encuentra la exigencia de predecibilidad de las decisiones del poder, entonces la constante interinidad de la ley bajo el parámetro constitucional socava bastante dicha predecibilidad y con ella la certeza del Derecho»³³⁰. Pero no significa su destrucción. Como afirma Marina Gascón, «tan sólo pone de manifiesto la incidencia que tienen en la actuación del juez las condiciones reales en las que se está llamado a operar en el Estado constitucional y la necesidad de que en estos casos se esmere la argumentación para no renunciar a valores como la previsibilidad, la imparcialidad, la seguridad, la igualdad en la aplicación de la ley y el carácter no arbitrario de la decisión judicial»³³¹. Y por otra parte, desde una determinada perspectiva, se podría afirmar que la Constitución, al constituir un marco de estabilidad y previsibilidad que en la actualidad ya no puede garantizar la ley, que hoy es rápida, inestable, cambiante, también contribuye a la seguridad jurídica³³².

³³⁰ LAPORTA, F. J., «Materiales para una reflexión sobre racionalidad y crisis de la ley», *Doxa*, n.º 22, 1999, p. 326.

³³¹ GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», cit. p. 34. No obstante, en todo caso cabría plantearse hasta qué punto no fue ficticia una idea de la seguridad jurídica vinculada a una concepción silogística de la aplicación del Derecho en la que el juez era la boca muda que pronunciaba las palabras de la ley. Podríamos preguntarnos si realmente, y con independencia de los postulados teóricos de una determinada concepción, los jueces nunca introdujeron planteamientos valorativos, morales, e incluso personales, en la construcción de sus decisiones, o si realmente los jueces nunca tuvieron la necesidad de completar el arsenal instrumental que les suministraba el ordenamiento jurídico desde el momento en que ya disponían de toda la información precisa para adoptar una determinada decisión.

³³² Vid. GARCÍA PELAYO, M., «Estado legal y Estado constitucional de Derecho», ID., *Obras completas*, vol. III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 3036; ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, trad. de M. Gas-

En todo caso, si pensamos en las exigencias éticas expresadas a través del imperio de la ley, no exclusivamente las vinculadas a un concepto fuerte (la ley como instrumento de protección y garantía de los derechos), sino vinculadas al favorecimiento de la autonomía personal, podríamos afirmar que la Constitución (entendida no exclusivamente como norma suprema sino como norma suprema que garantiza derechos) contribuiría a ese favorecimiento, por lo menos desde dos perspectivas: a) al carecer de una menor carga contingente respecto a la ley, permite que el individuo adopte decisiones estratégicas, por lo menos en mayor medida que en relación con la ley, y b) el carácter principal que tienen gran parte de sus normas, por lo menos en lo que en el ámbito de los derechos se refiere, y la consiguiente necesidad de ponderación de los pesos relativos de las pretensiones y posiciones, puede contribuir a una más completa consideración de los matices y vertientes de los diversos casos en cuestión, asegurando de esta manera una respuesta más adecuada por parte del Ordenamiento³³³.

2.2.3. El principio de legalidad selectiva: los contenidos del Estado de Derecho y el carácter sustantivo de los derechos fundamentales

Como se ha señalado en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, el concepto material de Estado de Derecho implica la presencia de dos elementos concurrentes: el imperio de la ley, de un lado, y la presencia de determinados contenidos normativos, de otro. Hasta ahora, nos hemos detenido en el análisis de determinadas dimensiones del imperio de la ley. Se ha intentado subrayar, entre otras cuestiones, la necesaria concurrencia de sus requisitos a la hora de caracterizar como tal un

cón, Trotta, Madrid, 1995, pp. 39-40 (con epílogo de G. PECES-BARBA, «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», pp. 157 y ss., que desaparece en las siguientes ediciones de la obra de Zagrebelsky).

³³³ Vid. al respecto, MacCORMICK, N., «Retórica y Estado de Derecho», *Isegoría*, n.º 21, 1999, pp. 5 y ss.

sistema jurídico y, como consecuencia de ello, la insuficiencia de una comprensión exclusivamente formal del Estado de Derecho, centrada solamente en el imperio de la ley.

La reflexión sobre la insuficiencia del concepto formal de Estado de Derecho a la hora de presentar los rasgos propios del Estado de Derecho en la cultura jurídica contemporánea y, sobre todo, a la hora de diferenciar y sustantivizar al Estado de Derecho como tal respecto a otros modelos de Estado, nos sitúa ante la necesidad de ir más allá y de completar la caracterización del Estado de Derecho, en sus dimensiones sustanciales o materiales. Como ya se ha señalado también en momentos precedentes de este trabajo, esta caracterización permite enfocar correctamente la relación que se establece entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional y también analizar de manera adecuada alguno de los problemas que se plantean de manera especial en el seno de éste último.

De manera sintética, se puede afirmar que el Estado de Derecho material supera al Estado formal en la consideración del significado de la legalidad. En efecto, en el Estado de Derecho formal la legalidad y el imperio de la ley no son considerados desde el punto de vista de los contenidos. El principio de legalidad es analizado desde un punto de vista formal y estructural. La exigencia es la de la propia operatividad del imperio de la ley, la de poder responder a las preguntas sobre quién manda y cómo se manda desde los datos conocidos que nos suministra el propio Ordenamiento jurídico. En el Estado de Derecho formal, podríamos afirmar, el principio de legalidad no se encuentra acompañado de adjetivo calificativo alguno.

En este sentido, a la hora de marcar las diferencias entre el sentido y significado del imperio de la ley y del principio de legalidad que se maneja respectivamente en ambos modelos de Estado de Derecho, me parece muy ilustrativa la caracterización del principio de legalidad como de «legalidad selectiva»³³⁴.

³³⁴ Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho», cit., p. 102. Me he referido a esta cuestión anteriormente

Cuando se hace referencia a la ley en el Estado de Derecho material, no se está pensando en una ley en la que cabe cualquier contenido. La ley en el Estado de Derecho no es cualquier tipo de ley³³⁵. En este contexto, el imperio de la ley no es una mera técnica formal. Su sentido, que se añade y completa el que se ha analizado hasta ahora, viene determinado por su origen y por su contenido. Estamos, pues, ante algo más que una mera técnica formal de gobierno. Así se podría caracterizar una concepción políticamente neutral del imperio de la ley. Pero esa neutralidad desaparece en el Estado de Derecho material, cuyo ámbito es el de la democracia.

Se acaba de señalar que la ley en el Estado de Derecho material se caracteriza tanto por su origen como por su contenido. Elías Díaz ha subrayado la importancia de la primera dimensión, la del origen, al proponer una concepción del imperio de la ley directamente vinculada a la voluntad popular. En efecto, parte de la consideración del Estado de Derecho como Estado sometido al Derecho, en el que su poder y su actividad están regulados y controlados por la ley. Pero por ley se debe entender «la formalmente creada por el órgano popular representativo (...) como expresión de la voluntad general»³³⁶. La conexión, por tanto, entre imperio de la ley en el marco del Estado de Derecho, de un lado, y soberanía popular, de otro, es explícita: «Si la ley, el ordenamiento jurídico, no posee ese origen democrático, podrá haber después imperio de la ley (de esa ley no democrática), pero nunca Estado de Derecho»³³⁷. Por

en «Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales», cit., pp. 91 y ss.

³³⁵ Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución», *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 10, 1984, p. 12.

³³⁶ DÍAZ, E., *Estado de Democrático y Sociedad democrática*, cit., p. 30. Vid también ID., «Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales», *Sistema*, n.º 125, 1995.

³³⁷ DÍAZ, E., «Estado de Derecho y derechos humanos (seguido de diez tesis)», VVAA., *Ética Pública y Estado de Derecho*, Fundación Juan March, Madrid, 2000, p. 28.

tanto, el Derecho en el que piensa Elías Díaz no es cualquier tipo de Derecho. Es por el contrario un Derecho democrático, gracias a su origen y a sus contenidos. En cierto sentido, aunque no de una manera absoluta, los contenidos se explican por el carácter democrático del Derecho. A partir de ahí, puede reconocer que «no todo «imperio de la ley» es ya, por ello, Estado de Derecho: que no hay tal si la ley proviene de una voluntad individual absoluta y no de una asamblea de representación popular libremente elegida; es decir, que no hay Estado de Derecho si la ley no es expresión de la voluntad general, o —admitámoslo— de lo que, en cada momento, más se acerca a la verdadera voluntad general»³³⁸. En definitiva Elías Díaz nos sitúa frente a la relación entre el Estado de Derecho y la democracia: el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia³³⁹.

Pero también hemos afirmado que el Derecho, la ley, en el Estado de Derecho, se caracteriza por su contenido. Es aquí donde los derechos fundamentales y los valores y principios vinculados a ellos³⁴⁰ pasan a primera línea. El contenido material del Derecho en el modelo de Estado de Derecho que se comparte en estas líneas tiene su núcleo en los derechos fundamentales y en la concepción moral de la que éstos son expresión. Es la presencia de estos contenidos, la que diferencia al Estado de Derecho material respecto al formal, de un lado, y la que lo vincula al Estado Constitucional, de otro; y por otra parte constituye «el mayor rasgo de orgullo» del Derecho del Estado constitucional³⁴¹.

³³⁸ DÍAZ, E., *Estado de Democrático y Sociedad democrática*, cit., p. 31.

³³⁹ Vid. DÍAZ, E., «Estado de Derecho y legitimidad democrática», DÍAZ, E., COLOMER, J. L., (eds.), *Estado, justicia, derechos*, cit., p. 75.

³⁴⁰ Piénsese en los valores superiores o en los principios de organización del Poder. Vid. al respecto PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, cit., pp. 357 y ss.; ID., *El sistema de los derechos fundamentales*, Quadern de Treball, n.º 1, Centre d'Estudis de drets Humans-Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.

³⁴¹ Vid. ZAGREBELSKY, G. *El Derecho dúctil*, cit., p. 114.

Cuando, en referencia al Estado de Derecho material, hablamos de contenidos, y de legalidad selectiva, es evidente que no estamos haciendo referencia a cualquier contenido ni a cualquier legalidad. Por el contrario, estamos haciendo referencia a una cuestión a la que en realidad ya había aludido Kelsen a la hora de analizar la noción de Constitución³⁴² y a la que se refiere Ferrajoli —ya lo hemos visto— cuando habla del proceso de positivación del Derecho natural³⁴³; a la constitucionalización de los principios de justicia a la que alude Zagrebelsky, a esa novedad histórica en la que nos fijamos en un momento anterior de este trabajo y en cuyas consecuencias nos vamos a detener en este momento.

En efecto Luigi Ferrajoli señala que lo que caracteriza al Estado de Derecho es precisamente la introducción en su Ordenamiento jurídico de los principales contenidos de justicia que durante siglos fue contribuyendo a configurar el iusnaturalismo racionalista. Dicha positivación supone una conversión de los que eran exclusivamente criterios de legitimación externa en criterios de legitimación interna. Ya me referí a esta cuestión en el contexto de la reflexión sobre las relaciones entre el Derecho y la moral. Por otra parte, el rango constitucional del que normalmente gozan esos derechos, le lleva a Ferrajoli a reformular el concepto de validez y mostrar su diferencia con el concepto de vigencia. Dejo esta cuestión para un momento posterior. Además, la incorporación de los derechos al Ordena-

³⁴² En efecto, Kelsen diferencia entre Constitución en sentido estricto y Constitución en sentido amplio. La segunda se caracteriza por contener, además de las reglas sobre los órganos y los procedimientos legislativos, también un catálogo de derechos y libertades. Kelsen tiene en cuenta esta distinción para diferenciar posteriormente entre inconstitucionalidad formal e inconstitucionalidad material. Vid. KELSEN, H., «La garantie juridictionnelle de la Constitution (la Justice constitutionnelle)», *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l'Etranger*, 1928, pp. 205 y 206.

³⁴³ Vid. también HABERMAS, J., «Derecho natural y revolución», en ID., *Teoría y praxis. Estudios de filosofía social*, trad. de S. Más Torres y C. Moya, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 87 y ss.

miento se produce en forma de incorporación limitativa³⁴⁴. A través de estas dimensiones se va articulando progresivamente la propuesta de Ferrajoli, que se caracteriza por el reconocimiento de la importancia de la presencia en el Ordenamiento jurídico del Estado de Derecho de elementos de justicia sustancial y de las consecuencias que para la articulación del mismo se derivan de lo anterior.

Pero, junto a todo lo anterior, el concepto de derechos fundamentales que presenta Ferrajoli es formal o estructural. Puede llamar la atención esta especie de giro o cambio de discurso y, ciertamente, la compatibilidad entre una concepción sustancial del Estado de Derecho y la posterior ‘retirada’ hacia un esquema de explicación formal de los elementos (los derechos fundamentales) nucleares de dicha concepción, merece ser analizada con cierto detenimiento³⁴⁵.

Para Ferrajoli los derechos fundamentales son «todos aquellos derechos que corresponden universalmente a «todos» o en cuanto ‘personas naturales’, o en cuanto ‘ciudadanos’ o en cuanto personas naturales ‘capaces de obrar’ o en cuanto ‘ciudadanos capaces de obrar’³⁴⁶. Para él, esta definición se caracteriza por ser *formal y estructural*, siendo éste un rasgo compartido por todas las definiciones ofrecidas en sede teórica, que no nos dicen ni cuáles son los derechos en un ordenamiento concreto, ni cuáles, de hecho, son protegidos o garantizados, ni cuáles deben serlo, sino qué son los derechos fundamentales.

Según Ferrajoli, una definición formal y estructural del concepto de derecho fundamental se caracteriza por identificar «los rasgos formales y estructurales gracias a los cuales son (o es justo que lo sean) tutelados, por el derecho positivo, aquellas

³⁴⁴ Me he referido a esta cuestión en «Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales», cit.

³⁴⁵ He desarrollado anteriormente estos argumentos en ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «Los derechos fundamentales en *Principia Iuris* (o los límites de la teoría del Derecho)», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXIX, 2013, pp. 35 y ss.

³⁴⁶ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Bari, 2007, I, p. 726.

expectativas y aquellos intereses reconocidos por él y establecidos como derechos fundamentales»³⁴⁷. Estos rasgos son los siguientes: 1) en primer lugar, Ferrajoli se refiere al carácter universal de la imputación de tales derechos. Estamos frente a una universalidad lógica y avalorativa, referida a la cuantificación universal de la clase de sujetos que son titulares de derechos. Para Ferrajoli, la universalidad así concebida está en la base de la igualdad jurídica entendida como igualdad en derechos. Es importante subrayar que aquí, universalidad e igualdad tienen un carácter puramente lógico, no dependen de la naturaleza de las necesidades, bienes o intereses protegidos, tampoco del correspondiente fundamento axiológico; 2) en segundo lugar, su referencia extensional a los estatus personales que forman su presupuesto y que denotan otras tantas clases de personas de las que es predicable la universalidad de todos y cada uno de los tipos de derechos fundamentales. Para Ferrajoli, estos status, cuya identificación deriva de nuestra experiencia jurídica, son tres: la personalidad, como estatus de las personas naturales o físicas, la ciudadanía, como status de la persona-ciudadano, y la capacidad de obrar como status de la persona capaz de obrar.

En definitiva estamos frente a una definición formal en un doble sentido: «en el sentido en que no dice nada sobre los contenidos de tales derechos, es decir sobre la naturaleza de los comportamientos que son objeto de las expectativas positivas o negativas en las que consisten; y en el sentido de que no dice nada sobre la extensión concreta de las clases de sujetos identificados, en los diferentes ordenamientos jurídicos, por el status de persona, de ciudadano o de capaz de obrar, como titulares de los correspondientes tipos de derechos»³⁴⁸.

A partir de una específica tipología de los derechos³⁴⁹, se derivan algunas consecuencias de esta definición formal y

³⁴⁷ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 726.

³⁴⁸ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 729.

³⁴⁹ Ferrajoli presenta una tipología de los derechos fundamentales de acuerdo con determinados criterios: a) los sujetos titulares (derechos de la

estructural de derechos fundamentales. En primer lugar, las definiciones y las tipologías ofrecidas «tienen un valor teórico —gracias a su carácter formal— del todo independiente de la actual fase de desarrollo de tales derechos e incluso de la experiencia jurídica moderna»³⁵⁰; de manera que en Occidente, al menos desde el Derecho Romano, siempre han existido derechos fundamentales, si bien en muchas ocasiones limitados a categorías restringidas de sujetos³⁵¹. En segundo lugar, Ferrajoli expone las ventajas de su definición, derivadas de su carácter teórico, formal y estructural. En efecto, en un escrito anterior a *Principia Iuris* señalaba que, de un lado, es válida para cualquier ordenamiento, «con independencia de los derechos fundamentales previstos o no previstos en él, incluso los ordenamientos totalitarios y los premodernos»; de otro, al ser independiente de los bienes protegidos, es ideológicamente neutral: «es válida cualquiera que sea la filosofía jurídica o política que se profese: positivista o iusnaturalista, liberal o socialista e incluso antiliberal y antidemocrática»³⁵².

persona/derechos del ciudadano, derechos primarios/derechos secundarios, derechos humanos/derechos públicos/derechos civiles/ derechos políticos); b) su contenido o el tipo de expectativas que constituyen su significado prescriptivo (sociales/individuales [que a su vez se pueden distinguir en libertades de, libertades para, potestades de o derechos de autonomía; c) la conjugación de los dos criterios anteriores (derechos políticos/derechos civiles/derechos de libertad y derechos sociales). Sabido es, además, que Ferrajoli desarrolla su tipología de los derechos fundamentales a partir de una distinción radical que es la que existe entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales (Vid. *Principia Iuris*, cit., I, p. 759 y ss.): universalidad e indisponibilidad de los primeros, frente a singularidad y disponibilidad de los segundos; los primeros consisten en normas tético-deónticas, son *ex lege*, y los segundos en normas hipotético-deónticas, son *ex contractu*; los derechos fundamentales operan en el marco de relaciones verticales, de Derecho público, mientras que los derechos patrimoniales lo hacen en relaciones horizontales, de Derecho privado (Vid. *Principia Iuris*, cit., I, p. 759 y ss.)

³⁵⁰ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 736.

³⁵¹ Vid también FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», en ID., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, edic. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, cit., pp. 23-24.

³⁵² FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 20.

En definitiva, Ferrajoli nos propone una definición de los derechos que se caracteriza por ser: a) estipulativa: «ni verdadera ni falsa como tal, sino solamente más o menos adecuada a la finalidad explicativa de la teoría en relación con cualquier ordenamiento jurídico, cualesquiera que sean los derechos (e incluso si no hubiera derechos) allí tutelados como fundamentales»³⁵³; b) formal: «dirigida a identificar los rasgos estructurales que, en función de dicha finalidad (explicativa), convenimos en asociar a esta expresión, y que determinan la extensión de la clase de derechos identificados por ella, cualesquiera que sean (o nos parezca justo que sean) sus contenidos»³⁵⁴; c) pero también, en mi opinión, descontextualizada, ya que no considera la relevancia de la experiencia histórica y de la realidad jurídica a la hora de proponer la definición de derecho fundamental. Así, la descontextualización no es manifestación de una equivocación en la identificación del contexto, sino de una falta de reconocimiento de la relevancia del mismo. El carácter teórico de la definición implica que la misma «prescinde de la circunstancia de hecho de que tales derechos se encuentren formulados en cartas constitucionales o leyes fundamentales, e incluso del hecho de que aparezcan enunciados en normas de derecho positivo»³⁵⁵; en definitiva, su definición tiene un valor teórico «del todo independiente de los sistemas jurídicos concretos e incluso de la experiencia constitucional moderna»³⁵⁶.

Pues bien, en mi opinión, el análisis crítico de la definición de derechos fundamentales propuesta por Ferrajoli está condicionado por dos razones básicas: en primer lugar, la definición está basada en una distinción analítica, esto es verdadera por definición, que es la distinción entre derechos fundamentales y

³⁵³ FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», en ID., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, cit., p. 290.

³⁵⁴ Ibidem.

³⁵⁵ FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 20.

³⁵⁶ FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 23.

derechos patrimoniales³⁵⁷; en segundo lugar, Ferrajoli nos dice que lo que nos está ofreciendo es una definición estipulativa que, en tanto tal, escapa al juicio de verdad o falsedad (a diferencia de las definiciones léxicas), por lo cual debe ser admitida en función de su mayor o menor adecuación a la finalidad explicativa. La opción metodológica y epistemológica de Ferrajoli es perfectamente legítima y marca las condiciones y posibilidades del análisis crítico. Su estrategia consiste, en el marco de una determinada metateoría del Derecho —que nos muestra en la Introducción a *Principia Iuris*— en establecer unos criterios epistemológicos y metodológicos que condicionan los desarrollos a través de los cuales nos presenta la Teoría del Derecho y de la democracia del constitucionalismo contemporáneo. El método axiomático certifica la validez interna de las sucesivas tesis. Desde este punto de vista, la definición de derecho fundamental presentada por Ferrajoli adquiere sentido dentro de su universo conceptual y metodológico. Por eso, creo que lo más productivo, en su caso, ha de ser cuestionar no los desarrollos internos de la teoría sino dirigir, por elevación, el análisis a la consideración de si, en el caso de los derechos fundamentales, las exigencias de la aproximación teórica, tal y como ésta nos es presentada por Ferrajoli (es decir circunscrita «al análisis de los conceptos técnico-jurídicos y de sus relaciones sintácticas»³⁵⁸), derivan en una presentación limitada del objeto de análisis. En palabras de Danilo Zolo, de lo que se trataría es de preguntarnos «si no sería preferible un uso epistemológicamente más débil, pero no por ello menos plausible desde el punto de vista semántico» de la noción de derecho fundamental³⁵⁹.

³⁵⁷ Vid. FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», cit., p. 331.

³⁵⁸ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 19.

³⁵⁹ Vid. . ZOLO, D., «Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los «derechos fundamentales». A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, cit., p. 80.

Desde el momento en que lo que nos ofrece Ferrajoli es una estipulación, es lógico plantear, por una parte, que seguramente esa definición —esa forma de comprender qué son los derechos fundamentales— no va a ser la única posible. El propio Ferrajoli, con ocasión de los debates en torno a su concepto de derecho fundamental, ha reconocido que la diversidad de enfoques y de disciplinas desde las que se pueden abordar los derechos está en muchas ocasiones tras las divergencias al respecto³⁶⁰; por otra parte, y dado que una propuesta estipulativa debe ser valorada en función del mayor o menor éxito a la hora de «satisfacer las finalidades explicativas que se persiguen con ella», es posible analizar si otras alternativas son preferibles a la hora de explicar qué son los derechos fundamentales. Evidentemente aquí nos podemos encontrar con el problema de que, en virtud del carácter de esas alternativas, estaremos forzando el marco establecido por la perspectiva teórica, tal y como nos la presenta Ferrajoli. Pero posiblemente sea una buena ocasión para plantear entonces lo que podrían ser los límites de la teoría. En definitiva, nos estaríamos planteando si la complejidad de los derechos fundamentales puede reconducirse a un esquema totalmente formal o estructural; en otros términos si esta estrategia es capaz de recoger las diversas vertientes de la realidad de los derechos: es decir, si la definición formal es la más útil a la hora de saber qué se está diciendo cuando se habla de derechos fundamentales. La utilidad de una definición va a depender de su capacidad para reflejar, en la medida de lo posible, las dimensiones de la realidad que se pretenden explicar; pero también va a depender de su carácter reconocible por la comunidad de hablantes³⁶¹ y de su capacidad orientadora en un ámbito problemático³⁶². De manera que

³⁶⁰ Vid. FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», cit., p. 287.

³⁶¹ Vid. JORI, M., «Ferrajoli sobre los derechos», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, cit., p. 131.

³⁶² Vid. ZOLO, D., «Libertad, propiedad e igualdad en al teoría de los «derechos fundamentales». A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli», cit., p. 80.

se puede defender la tesis según la cual la definición de derechos fundamentales propuesta por Ferrajoli no alcanzaría completamente las finalidades explicativas a la hora de explicar qué son los derechos fundamentales debido precisamente a su condición descontextualizada y a su carácter formal. Como se verá, las dos cuestiones están relacionadas de alguna manera.

La definición es descontextualizada porque prescinde de la experiencia histórica a la hora de explicar qué son los derechos fundamentales hoy; y porque nos ofrece una idea de derecho fundamental que establece distancias entre el concepto mismo y su posición constitucional (o, en términos generales, jurídica). La consideración de la historia a la hora de explicar el surgimiento y evolución de conceptos y métodos no es algo extraño para la ciencia jurídica³⁶³. En relación con los derechos fundamentales, la historia nos sirve para entender el surgimiento, en un determinado contexto cultural, social y político, de la idea de acuerdo con la cual el individuo es titular de determinadas pretensiones morales cuyo reconocimiento y garantía deben constituir la razón de ser del Estado. La historia nos sirve también para entender el surgimiento y el significado del moderno concepto de Constitución, que incluye el reconocimiento y garantía de los derechos (art. 16 de la Declaración de 1789). Y nos permite comprender también cómo la garantía de la paz y de los derechos constitucionalmente estipulados

³⁶³ Felipe González Vicén desarrolló una visión de la Filosofía del Derecho en clave de concepto histórico (Vid. GONZÁLEZ VICÉN, F., «La filosofía del Derecho como concepto histórico», en ID., *Estudios de Filosofía del Derecho*, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 1979). Por su parte, Gregorio Peces-Barba ha basado su teoría de los derechos fundamentales en el carácter histórico del concepto mismo y en la relevancia del análisis histórico a la hora de comprender no sólo cómo es que los derechos han llegado a significar lo que significan hoy, sino a la hora de desentrañar precisamente ese significado (Vid. PECES-BARBA, G., «Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales», cit.). Y Antonio Pérez Luño ha propuesto una visión de la Filosofía del Derecho en la que historia y sistema se exigen mutuamente (Vid. PÉREZ LUÑO, A.-E., *La Filosofía del Derecho en perspectiva histórica*, Universidad de Sevilla, 2009, «Introducción», p. 21).

han llegado a ser la *razón social* de la democracia constitucional³⁶⁴. Pues bien, posiblemente el concepto de «razón social» es difícilmente comprensible en su significado y consecuencias excluyendo la experiencia histórica. De la misma manera que los contenidos de la democracia constitucional, que nos permiten identificar su dimensión liberal y su dimensión social, no son fijados de una vez por todas en el marco de un discurso estrictamente teórico, sino que tienen mucho que ver con conquistas sociales, movimientos políticos o dimensiones económicas, el constitucionalismo, entendido como una segunda revolución en la modernidad jurídica (tras aquella que significó la aceptación del principio de legalidad como criterio de reconocimiento de lo jurídico), también es el resultado de un proceso histórico que Ferrajoli identifica al señalar que el contractualismo y el iusnaturalismo forman parte del proyecto político e intelectual que da sentido a esa progresiva ampliación de la esfera pública de los derechos y de sus garantías cuya historia no es sino la del constitucionalismo³⁶⁵. En realidad, Ferrajoli reconoce que la historia del constitucionalismo no es teórica, «sino social y política, dado que ninguno de estos derechos cayó del cielo sino que todos fueron conquistados mediante rupturas institucionales: las grandes revoluciones americana y francesa, los movimientos decimonónicos por los estatutos, y, en fin, las luchas obreras, feministas, pacifistas y ecologistas de este siglo»³⁶⁶. En definitiva, el estudio de la propuesta de Ferrajoli nos permite observar que para analizar uno de los conceptos nucleares de una propuesta que forma parte de un proceso histórico (el del constitucionalismo y el Estado constitucional), se excluye la consideración de la historia del análisis del concepto.

Pero la «descontextualización» a la que estoy haciendo referencia también tendría que ver con el discurso que Ferrajoli

³⁶⁴ Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., II, pp. 305 y ss.

³⁶⁵ Vid. FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 40.

³⁶⁶ *Ibidem*.

desarrolla en relación con la naturaleza constitucional de los derechos. Asistimos a una explícita desvinculación entre la definición de derecho fundamental y la experiencia constitucional moderna³⁶⁷; a una reivindicación de la independencia entre la definición y la fase de desarrollo de los derechos fundamentales en el Derecho constitucional³⁶⁸. En este sentido, me parece interesante plantear hasta qué punto podemos entender la actualidad y la operatividad jurídica de los derechos en los sistemas constitucionales excluyendo la alusión a una determinada forma de entender la Constitución, que no sería sino el resultado del desarrollo del concepto de Constitución y manifestación de la experiencia constitucional moderna. En otros términos, lo que se plantea es si podemos entender hoy tanto el sentido de los derechos fundamentales como del concepto de Constitución sin el marco constituido por el constitucionalismo moderno.

Para Ferrajoli el rasgo distintivo de los derechos fundamentales respecto a los otros derechos subjetivos, y en particular respecto a los derechos patrimoniales es su forma universal, «y no ya el valor de las necesidades y de los intereses protegidos por ellos, que son su fundamento axiológico, y tampoco el eventual rango constitucional, que es solamente una técnica de protección»³⁶⁹. Ciertamente, el lugar secundario que ocupa el carácter constitucional de los derechos en la propuesta de Ferrajoli nos sitúa frente al problema del origen de la fuerza limitadora de los derechos frente al Poder (o los poderes). Lo cual en el caso de Ferrajoli es especialmente desafiante, ya que una definición formal como la suya excluye explícitamente cualquier referencia a un sistema normativo suprapositivo del que pudiera derivar la imperatividad de las normas de derechos, siendo tajante al negar la existencia de derechos naturales o pre-jurídicos³⁷⁰.

³⁶⁷ Vid. FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 23.

³⁶⁸ Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 736.

³⁶⁹ FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 40.

³⁷⁰ Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 727.

No parece demasiado arriesgado afirmar que en las democracias constitucionales la obligatoriedad jurídica del respeto a la esfera de lo indecible deriva de la inclusión en la Constitución de esos contenidos que se quieren sustraer a la disponibilidad de las mayorías o de los mercados. Precisamente es de su naturaleza constitucional de donde deriva la resistencia de los derechos frente a la voluntad del Poder³⁷¹. Pero lo cierto es que en *Principia Iuris*, pareciera existir una cierta «oscilación» entre la afirmación de que la garantía de los derechos se deriva de su forma universal, y la de que el carácter «preordenado» a cualquier poder decisonal por parte de los derechos fundamentales es una consecuencia de «su estipulación como derechos fundamentales en normas normalmente constitucionales»³⁷². Ferrajoli en su caracterización de los límites entre la teoría y la dogmática, se cuida de no definir los derechos a partir de los datos suministrados por la experiencia constitucional, pero en ocasiones los elementos de acuerdo con los cuales se justifican las elecciones conceptuales vienen determinados por la experiencia constitucional. En este sentido, parecería que la justificación de la elección de la identidad de persona, ciudadano o capaz de obrar como las categorías definitorias de los derechos, radicaría en que estas tres identidades siempre han sido los parámetros tanto de la inclusión como de la exclusión jurídica de los seres humanos³⁷³. Y cuando se habla aquí de inclusión o exclusión jurídica se está tomando como referencia una determinada realidad jurídica. Por otra parte,

³⁷¹ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., *Estudios sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990, p. 97.

³⁷² FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 731.

³⁷³ Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 736. Anteriormente, había señalado que «personalidad, capacidad de obrar y ciudadanía son conceptos vacíos cuyo valor teórico reside precisamente en el hecho de que (...) tanto la igualdad como la desigualdad en los derechos fundamentales, tanto la inclusión como la exclusión de los seres humanos de las clases de sus titulares, se han decidido siempre conforme a ellas», «Los derechos fundamentales en la teoría del Derecho», cit., p. 157.

en un escrito anterior a *Principia Iuris*, había señalado que «la teoría del derecho y de los derechos a la que trato de contribuir tiene, de hecho, como referencia empírica a los ordenamientos jurídicos de las democracias modernas que son, justamente, todos capitalistas»³⁷⁴. En definitiva, parece que Ferrajoli si bien se propone prescindir de la experiencia jurídica a la hora de explicar que es un derecho fundamental, no logra del todo prescindir de esa experiencia, y en particular de la experiencia constitucional.

Pero una de las ventajas de la definición de los derechos fundamentales es, en opinión del autor, la neutralidad ideológica derivada de su carácter formal y estructural, de manera que no está vinculada a la protección de ciertas necesidades e intereses y es aplicable a todos los ordenamientos jurídicos. Podemos, en este punto, plantear dos cuestiones. En primer lugar podemos preguntarnos si es posible y útil una definición axiológicamente neutral de los derechos. En segundo lugar, si la caracterización de los derechos fundamentales que nos ofrece Ferrajoli es tan neutral como en principio se dice.

En relación con la posibilidad y la utilidad de la neutralidad axiológica en este ámbito, parecería que estamos planteando dos cuestiones distintas. Pero en realidad podemos considerar ciertas vinculaciones. Se trataría de analizar por una parte si cabe una definición de derechos fundamentales que renuncie a cualquier referencia axiológica, y si, de ser esto así, esta presentación de los derechos fundamentales permitiría entender su significado y rol en los sistemas jurídicos de las democracias constitucionales.

La neutralidad axiológica de la definición de derechos propuesta por Ferrajoli deriva del hecho de que el elemento básico que permite identificarlos no está constituido por la referencia a un conjunto de valores, principios, a una propuesta axiológica en definitiva, sino más bien por el carácter universal de su

³⁷⁴ FERRAJOLI, L., «Los derechos fundamentales en la teoría del Derecho», cit., p. 166.

imputación. Aquí la universalidad viene determinada por «la cuantificación universal de los sujetos que son titulares de los mismos [de los derechos]»³⁷⁵. Ello le lleva a afirmar que, de la misma manera que determinados derechos que intuimos como fundamentales, como la libertad de pensamiento o los derechos políticos, en aquellos ordenamientos en los que no fueran universales, dejarían de ser fundamentales, «a la inversa, si fuera establecido como universal un derecho absolutamente fútil, como por ejemplo el derecho a ser saludados por la calle por los propios conocidos o el derecho a fumar, el mismo sería un derecho fundamental»³⁷⁶.

En este punto es interesante centrar la cuestión en la compatibilidad entre la idea de neutralidad axiológica y los derechos fundamentales. Estos son una propuesta moral positivizada, juridificada. Si nos preguntáramos por el punto de vista sobre la justicia asumido por los sistemas jurídicos de las democracias constitucionales, necesariamente tendríamos que referirnos a la posición de los derechos en esos ordenamientos, a sus estrategias de reconocimiento y garantía. Lo que se positiviza es el contenido de un discurso moral que incluye la prioridad de determinados valores o principios (dignidad, libertad, igualdad) y una posición en relación con determinados aspectos a través de los cuales se articula ese proyecto moral, entre los que podríamos destacar una determinada idea del individuo, una cierta forma de entender las relaciones entre el individuo y la colectividad, y un discurso sobre el carácter instrumental de las instituciones, cuya existencia adquiere sentido desde el momento en que están encaminadas a satisfacer las exigencias de los principios y valores de referencia.

Es evidente que esta forma de entender los derechos fundamentales no tiene nada de axiológicamente neutro. Pero lo que me interesa plantear en este momento es si podemos entender su significado político, y moral, y las razones que están detrás

³⁷⁵ FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 40.

³⁷⁶ FERRAJOLI, L., «Derechos fundamentales», cit., p. 21.

de sus niveles de operatividad jurídica sin hacer referencia a esos contenidos de moralidad. Esos contenidos constituirían la razón de ser de los derechos, su fundamento. No creo que podamos renunciar al fundamento —o, si se prefiere, a la naturaleza de los intereses protegidos— a la hora de explicar qué son los derechos fundamentales, es decir, de qué hablamos a principios del siglo xxi cuando decimos que los individuos son titulares de derechos fundamentales³⁷⁷. Pienso que cuando Ferrajoli, en *Diritto e Ragione*, se refiere a la estructura normativa del Estado de Derecho y alude a la transformación de los que tradicionalmente habían sido criterios de justificación externa en criterios de legitimación interna, y al proceso de positivación del derecho natural, no está renunciando a las dimensiones sustanciales de los derechos a la hora de explicar su significado y su función³⁷⁸. Implícitamente, Ferrajoli estaría asumiendo que no cualquier contenido puede formar parte de un derecho fundamental, por muy universalizado en lo que a su titularidad e inalienable en cuanto a su ejercicio sea, ya que estaría acotando los contenidos de los derechos fundamentales —al menos en su origen, a la hora de explicar la aparición de los derechos en los ordenamientos— cuando hace referencia a la tradición del iusnaturalismo racionalista. El proceso de constitucionalización del Derecho natural nos permite identificar los derechos fundamentales cuando centramos la atención en las Constituciones a partir de la segunda mitad del siglo xx. Sin esa constitucionalización no podemos hablar de derechos fundamentales. Pero lo que se consitucionaliza no es cualquier contenido, sino sólo aquel vinculado con lo que podríamos considerar «el discurso de los derechos». Podría afirmarse —posiblemente Ferrajoli lo haría— que una cosa es el concepto de

³⁷⁷ Sobre la relevancia de la conexión entre el problema conceptual y el problema justificatorio en los derechos, vid. DE ASÍS ROIG, R., *Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación dualista*, Dykinson, Madrid, 2001.

³⁷⁸ Vid. FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., pp. 353 y ss.

derecho fundamental y otra el proceso de positivación del Derecho natural. No obstante la necesidad de conceptualizar los derechos fundamentales surge a partir de la constatación de una realidad jurídica y política que hay que teorizar.

En definitiva, una presentación del concepto de derecho fundamental que renuncie a la referencia a su dimensión sustancial puede tener dificultades a la hora de justificar las razones de la esfera de lo indecible. Y también va a permitir, teóricamente, incluir contenidos que difícilmente tienen que ver con una determinada filosofía moral y política, que es la de los derechos entendidos como exigencia de la dignidad humana. Estas circunstancias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la utilidad explicativa de la definición.

En realidad, cabría plantearse hasta qué punto la definición de derecho fundamental propuesta por Ferrajoli es tan axiológicamente neutral como en teoría se presenta. Creo que no. Es posible encontrar algunas dimensiones en la caracterización de los derechos fundamentales por parte de Ferrajoli que nos permiten identificar aspectos que, antes de identificarse con una aproximación neutral, se distancian de ella.

En primer lugar, existen «elementos de identificación axiológica», que Ferrajoli sitúa en el ámbito del fundamento de los derechos³⁷⁹ y que identifica con el nexo entre los derechos fundamentales y las ideas de igualdad, paz y democracia, y su función con ley del más débil. Así las cosas, de lo anterior podría deducirse que también el fundamento es importante la hora de identificar a los derechos, en su significado y en su función. Ferrajoli va a señalar que cuando pensamos en el fundamento de los derechos estamos situándonos en el ámbito de la teoría de la justicia y no en el de la Teoría del Derecho. Pero, ¿hasta qué punto el fundamento de los derechos, y sus contenidos, no actúan como límite o condicionante en relación con

³⁷⁹ Vid. FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», cit., p. 365

el concepto? Considerar un determinado fundamento nos obliga a admitir que no todo puede formar parte del contenido de un derecho fundamental, contrariamente a lo que afirma Ferrajoli. Es decir, el fundamento de los derechos (que tiene determinados contenidos y se construye a partir de ciertos nexos en torno a los cuales se elabora el discurso de los derechos) nos impide, por ejemplo, afirmar la independencia entre la definición de los derechos y los bienes protegidos por éstos. Esos nexos ya implican una elección en relación con ciertos valores. Lo cual implica también, delimitar el terreno de juego en el que cabe hablar de derechos fundamentales con sentido, a no ser que estemos dispuestos a admitir que cualquier exigencia —siempre y cuando esté asegurada de manera universal— puede convertirse en un derecho universal. Pero entonces, podríamos distinguir entre derechos basados o fundados en buenas razones y otros que no lo son (parece que las razones en favor de la no discriminación por motivos ideológicos, por ejemplo, son más atendibles que aquellas otras en favor de la pretensión de ser saludado por la calle, si es que estamos hablando de derechos fundamentales). Si esta distinción no fuera posible, entonces podríamos dudar del grado de influencia de aquello que podríamos denominar el «discurso de los derechos» en la identificación de los mismos. Y podríamos tener alguna dificultad a la hora de justificar por qué la igualdad ante la ley, o la posición del más débil, merecen especial atención. Sólo si se asume alguna posición normativa, que implica de por sí una elección o una opción, podemos justificar por qué la igualdad ante la ley es preferible a la discriminación.

En segundo lugar, sólo si se asume una determinada opción pueden justificarse los límites operativos en la democracia constitucional. Teniendo en cuenta que los derechos son límites y que la Constitución es un Derecho sobre el Derecho, no va a ser irrelevante saber en nombre de qué se limita al Poder. ¿Existen las mismas razones para limitar al poder en virtud de una expectativa vinculada a la libertad que con otra vinculada a la supremacía de una raza sobre otra?

En definitiva, estoy reivindicando la necesidad de trascender la definición axiológicamente neutral de derecho fundamental como requisito para entender no sólo su sentido, sino también su posición, función y significado dentro de la democracia constitucional. En realidad, el mismo Ferrajoli asumiría esto cuando establece que las elecciones que subyacen a la construcción del lenguaje formalizado de la teoría no son extrañas a consideraciones y opciones de carácter ético y político³⁸⁰. Pienso que en *Principia Iuris* hay un reconocimiento explícito cuando se afirma que «ciertamente la convención jurídica de la forma universal de lo derechos fundamentales es el producto histórico de una opción política y moral»³⁸¹. La preferencia en favor de una definición formal o estructural y la reivindicación de una universalidad en sentido estrictamente lógico implica que, paradójicamente, las características formales de los derechos tienen connotaciones sustanciales³⁸². La decisión de excluir contenidos del parecer de la mayoría y de la negociación que se desarrolla en el mercado no pueden dejar de tenerlas. A no ser que se afirme que cualquier contenido, siempre que se universalice, se va a convertir en derecho fundamental. Pero entonces, posiblemente, la dignidad de los derechos quedaría en entredicho y su fuerza emancipadora reducida ¿Podrían seguir siendo considerados como la ley del más débil? Las revoluciones, los movimientos sociales y las rupturas institucionales que han jalonado la sucesiva ampliación de la esfera pública de los derechos perderían relevancia.

El examen crítico de los rasgos de la propuesta conceptual de Ferrajoli en relación con los derechos fundamentales sirve para poner de manifiesto la importancia de las dimensiones sustanciales o materiales en dicho concepto y, a través de éste, en la comprensión material del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado vinculado a unos determinados con-

³⁸⁰ Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, pp. 22-23.

³⁸¹ FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., II, p. 61.

³⁸² Vid. FERRAJOLI, L., *Principia Iuris*, cit., I, p. 821.

tenidos, que se especifican a través de la opción axiológica asumida por el Ordenamiento en forma de derechos fundamentales. El Estado de Derecho, por tanto, no es un modelo de organización jurídica neutra desde el punto de vista axiológico (en realidad, ninguna organización jurídico-política lo es). Asume una determinada perspectiva moral y axiológica, que es la representada por la tradición de los derechos humanos desarrollada a lo largo de la modernidad. Es precisamente la vinculación con esta tradición lo que sustantiviza al Estado de Derecho.

El análisis del sentido del proceso de constitucionalización del Derecho natural al que alude Ferrajoli puede ser complementado con la referencia a las consecuencias del «Derecho por principios» que se presenta como el modelo que Zagrebelsky utiliza para caracterizar al Ordenamiento del Estado constitucional. Las propuestas de Ferrajoli y de Zagrebelsky comparten un cierto ‘aire de familia’ en el que predomina un discurso crítico del positivismo jurídico que se asocia a una concepción formal del Estado de Derecho.

En efecto, para Zagrebelsky el Estado constitucional se caracteriza por una apertura de su Ordenamiento a normas de principio en las que se integran principios de justicia y derechos, que se presentan en realidad hoy como la reproducción de «los temas que durante siglos habían sido el caballo de batalla de las diversas versiones del Derecho natural»³⁸³. La introducción de estos contenidos en las estructuras del Derecho positivo no significa que éstas dejen de tener carácter jurídico. Por el contrario, la positivación de las normas que materializan «la prerrogativa del Derecho natural», esto es, la definición de la justicia y de los derechos, no implica la desvinculación de los mecanismos de producción normativa. Dichas normas se reconducen, en su existencia jurídica, a la Constitución. Cuando hablamos de Constitución, estamos hablando de una creación jurídica, «la máxima de todas las creaciones jurídicas»³⁸⁴.

³⁸³ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 114.

³⁸⁴ *Ibidem*.

No obstante, los contenidos constitucionales —añade Zagrebelsky— se caracterizan por el sentido y los rasgos del «momento constitucional», que es el escenario de la superación de los intereses particulares en un contexto pluralista, el del consenso. Para Zagrebelsky, «aunque en el proceder de las asambleas constituyentes no falten, claro está, los acentos partidistas, los principios de las constituciones pluralistas, para posibilitar un pacto común en el que cada parte pueda reconocerse (y en vista del cual esté dispuesta a renunciar a algo de sí y a reconocedr algo de los otros), se asemejan, en su formulación universalista y abstracta, a los principios de derecho natural»³⁸⁵. Así, el momento constitucional es el de la concordia, a diferencia del momento legislativo que es el de la discordia. La Constitución se presenta como el reflejo de un «orden natural histórico-concreto de las sociedades políticas secularizadas y pluralistas»³⁸⁶; es expresión de un equilibrio objetivo entre las preferencias particulares. En ese sentido, Zagrebelsky afirma la existencia de una *semejanza funcional* entre el Derecho natural y los principios que tienen cabida en el Derecho constitucional. En presencia del Derecho constitucional no estamos frente al Derecho natural; es, por el contrario, *como sí* estuviéramos frente al Derecho natural³⁸⁷. En definitiva, el Derecho constitucional, a través de los principios de justicia incorporados en su seno, reemplaza en sus funciones al Derecho natural.

Por último, hay que señalar que la opción por un concepto material de Estado de Derecho, entendido como expresión de una determinada concepción de la moralidad y resultado de la inclusión de ciertos criterios de justicia es compatible con una

³⁸⁵ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 115.

³⁸⁶ *Ibidem*.

³⁸⁷ Vid. ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 119. Vid. LLANO ALONSO, F. H., *El formalismo jurídico y la teoría experiencial del Derecho. Un estudio iusfilosófico en clave comparativa*, Tirant, Valencia, 2009, pp. 179 y ss.

definición positivista del Derecho³⁸⁸. Desde una concepción positivista del Derecho se puede defender un concepto material de Estado de Derecho. El positivista que, como consecuencia de la presencia de determinados contenidos en su interior, reconozca que el Estado de Derecho merece un juicio moral positivo, sabe al mismo tiempo que no todo Estado y que no todo Ordenamiento merece dicha evaluación. La perspectiva positivista permite comprender el sentido del proceso de positivación del Derecho natural al que alude Ferrajoli y no desemboca necesariamente en una consideración positiva irrestricta de cualquier Ordenamiento.

2.2.4. *Estado de Derecho y derechos fundamentales: algunas consecuencias*

En definitiva, y recapitulando, la presencia de normas de derechos fundamentales en un Ordenamiento como el del Estado de Derecho tiene muy diversas consecuencias. En este momento me referiré a alguna de ellas.

En primer lugar, dicha presencia es el núcleo del proceso de constitucionalización del Derecho natural. Si todo Ordenamiento jurídico asume una determinada concepción de la moralidad, lo cierto es que aquella vinculada al Estado de Derecho la que se expresa a través de los derechos fundamentales y los valores y principios relacionados o derivados de ellos. Esa moralidad es especialmente relevante desde la perspectiva de las sociedades democráticas, desde el momento en que se identifica como dimensiones y contenidos considerados básicos en relación con un determinado modelo de convivencia. Sin esos contenidos, el modelo deja de ser reconocible como tal; en efecto, parece difícilmente identificable como Estado de Derecho

³⁸⁸ P. P. CRAIG, establece la vinculación entre la concepción formal del *rule of law* y el positivismo en «Formal and substantive conceptions of the rule of law», cit., p. 55.

un sistema jurídico-político democrático que no reconozca, proteja y garantice derechos fundamentales, y que consiguientemente no organice de acuerdo con éstos un cierto modelo de convivencia.

Además, la presencia de contenidos materiales —que asumen básicamente la forma de derechos fundamentales— en las Constituciones, es expresión de un determinado concepto de Constitución, que incluye necesariamente reconocimiento y protección de derechos, de acuerdo con el modelo que encontramos ya señalado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esos derechos fundamentales constituyen el núcleo de lo que tradicionalmente se ha considerado la parte dogmática del texto constitucional. El reconocimiento de esta parte tiene consecuencias formales y estructurales, que van más allá de la mera recepción jurídica de una determinada opción axiológica. Estas consecuencias se identifican con la arquitectura del Estado constitucional organizada en torno a los mecanismos destinados a garantizar la supremacía de la Constitución y por tanto de los derechos en ella contenidos. De esa arquitectura derivan cuestiones referidas, por ejemplo, a la interpretación de las disposiciones materiales o a la tensión entre Constitución y democracia³⁸⁹.

También, esa presencia de dimensiones morales en las Constituciones del Constitucionalismo plantea algunos elementos de crítica dirigidos al positivismo jurídico, que se puede sintetizar de la siguiente manera: el Derecho del constitucionalismo incluye necesariamente un conjunto de derechos, valores y principios morales, y por tanto, justifica la afirmación de una conexión necesaria entre el Derecho y la moral. Estamos ante una crítica que quiere estar dirigida a la línea de

³⁸⁹ Vid. BARRANCO AVILÉS, M. C., «Los contenidos materiales de las Constituciones y la posibilidad del constitucionalismo positivista», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*, Ediciones Universidad Salamanca, 2006, pp. 339 y ss.

flotación del positivismo jurídico, desde el momento en que pretende descalificar la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. No obstante, la inclusión de las dimensiones morales manifestadas en forma de derechos y valores, que sirve para caracterizar al constitucionalismo contemporáneo, es un rasgo de específicos Ordenamientos, y no del Derecho. Quiere decirse con ello que, en realidad, aunque el Derecho del constitucionalismo no se puede comprender y analizar sin tener en cuenta ese punto de vista moral asumido, lo cierto es que el Derecho (que no necesariamente es el del constitucionalismo), puede seguir siendo identificado sin la presencia de ese punto de vista moral específico que, si bien es necesario en el Derecho del Estado de Derecho, no lo es en el Derecho genéricamente considerado. De esta manera, se puede seguir afirmando la viabilidad del positivismo como propuesta de aproximación neutral del Derecho. El positivismo jurídico, y más específicamente el positivismo metodológico, supone la afirmación de la irrelevancia del punto de vista moral como elemento determinante del reconocimiento jurídico del mismo. Así, la presencia de puntos de vista morales en el sistema no niega la validez de la aproximación positivista, desde el momento en que precisamente ésta propone que aquellos no sean tomados en consideración a la hora de la identificación y análisis del Derecho³⁹⁰.

³⁹⁰ M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO han señalado que el positivismo incluyente sería merecedor de crítica ya que «su tesis distintiva —que la relación entre Derecho y moral es contingente, pues es conceptualmente concebible un sistema jurídico cuyos tests de validez no impliquen referencias a la moral— es de escaso interés para los juristas: pues aun concediendo que tales sistemas sean posibles, lo que es indudable es que no se trata de nuestros sistemas, de los Derechos del Estado constitucional, ni tampoco de los que cabe razonablemente prever», «Dejemos atrás el positivismo jurídico», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZALEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*, cit., p. 773. Me parece evidente que en este punto se está planteando la cuestión de la función de la Teoría del Derecho positivista, a la que se puede responder al menos desde dos planteamientos básicos: por una parte —este parecería ser el que

En segundo lugar, la presencia de determinados contenidos sustanciales en el Ordenamiento jurídico del Estado de Derecho es un elemento que pone de manifiesto la naturaleza mixta de los sistemas jurídicos. Conviene subrayar en este sentido que, en realidad, el carácter mixto no es un rasgo exclusivo de un tipo de Ordenamiento específico, como es el del Estado de Derecho, sino más bien de todo sistema jurídico.

La afirmación del carácter mixto del sistema deriva de la constatación de que la validez de sus componentes, de las normas que lo integran, depende de la satisfacción tanto de requisitos formales como materiales. Si consideramos los rasgos que nos permiten constatar la inclusión de una determinada norma en un sistema, reconocemos la presencia, de un lado, de exigencias formales. La norma pertenecerá al sistema si es el resultado de la decisión tomada por una determinada autoridad, que disfruta de competencia al respecto, mediante un procedimiento establecido. Pero lo anterior es un requisito necesario y no suficiente. Hace falta añadir a lo anterior la dimensión material o sustancial, referida a la relación entre el contenido de la norma en cuestión y el de las normas superiores del sistema. De acuerdo con ello, la norma jurídica será válida cuando satisfaga condiciones tanto formales como materiales. Así, el sistema jurídico no es exclusivamente estático, es decir un sistema en el que «las normas valen por su contenido.... la conducta determinada por ellas es vista como debida por su contenido; en tanto su contenido puede ser referido a una norma bajo cuyo contenido el contenido de las normas que constituyen el orden admite ser subsumido como lo particular bajo lo universal... Puesto que todas las normas de un orden de este tipo están ya contenidas en el contenido de la norma presu-

asumirían Atienza y Ruiz Manero— el que señalaría que la Teoría del Derecho debe explicar el Derecho tal y como éste se presenta en determinadas circunstancias, que bien pueden ser las del constitucionalismo; por otra, el que afirma que de lo que se trata en realidad es de ofrecer una explicación no vinculada necesariamente a un modelo específico y contextual de Derecho.

puesta, puede deducírselas mediante una operación lógica, una inferencia de lo general a lo particular»³⁹¹; ni tampoco exclusivamente dinámico, es decir un sistema en el que «la norma fundante ... no contiene otra cosa que el establecimiento de un hecho productor de normas, el facultamiento de una autoridad normadora o, lo que significa lo mismo, contiene una regla que determina cómo deben producirse las normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma fundante básica»³⁹²; presenta por el contrario una naturaleza mixta.

Sin embargo, es cierto que en realidad el problema de la consideración del sistema jurídico como sistema mixto se presenta de manera más evidente en relación con las decisiones últimas del sistema, entendiendo por tales aquellas que se localizan en las zonas superiores del mismo, una vez que lo entendemos jerárquicamente estructurado. Es precisamente en este contexto en el que se plantea la cuestión de los límites materiales de las decisiones últimas. Ello supone la consideración de que en el Ordenamiento jurídico existen decisiones últimas no sometidas a limitaciones ulteriores. En este sentido, Bruno Celano ha señalado que «el poder de decisión de última instancia (poder de decisión última, no sujeto a revisión por parte de poderes ulteriores; decisión ‘soberana’) no es eliminable. Los ordenamientos jurídicos son sistemas normativos dinámicos; existe en ellos no obstante, un poder de decisión no sujeto a revisión. Por razones conceptuales, no todo poder de decisión es sometible a normas que vinculen a la decisión»³⁹³. Parece que se estaría pensando, entonces, en un órgano como el Tribunal Constitucional, o en otro que pareciera no estar sometido a norma alguna, subrayándose así la naturaleza autoritativa del derecho; lo cual, parece ser problemático, desde el momento en

³⁹¹ KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., p. 203.

³⁹² KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., p. 204.

³⁹³ CELANO, B., «Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto», *Filosofia Politica*, a. XIX, n. 3, dicembre 2005, p. 440.

que, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, actúa sometido a una norma superior, como la Constitución. Así, en el interior del sistema jurídico, la dimensión autoritativa (que se vincula de manera específica con la vertiente dinámica del mismo) se lleva a cabo en el marco de normas, aunque las autoridades últimas puedan, en efecto, llevar a cabo una reforma de la Constitución, por ejemplo. Pero esa reforma se llevará a cabo siempre en el marco de lo establecido por ella misma. Ciertamente, el Poder no sometido es el Poder entendido como Poder Constituyente en sentido originario; cuando nos referimos a él, lo estamos haciendo a una realidad que ya no forma parte del Derecho, aunque lo condiciona.

Pues bien, pienso que la naturaleza constitucional de los derechos fundamentales, componente básico e imprescindible del Estado de Derecho, pone de relieve las consecuencias derivadas de la presencia de contenidos sustantivos en el Ordenamiento. En este caso, pensamos en contenidos específicos como los derechos. Pero esas consecuencias también se derivarían si los contenidos fueran otros, y por tanto si la perspectiva moral asumida por el sistema fuera diferente. Lo que determina, por tanto, el carácter mixto del sistema jurídico del Estado de Derecho es en última instancia la naturaleza constitucional de los derechos y no el significado moral de los mismos.

En tercer lugar, debemos ser conscientes de las dificultades que presenta la identificación del contenido moral del Estado de Derecho. Sabemos que el proceso de constitucionalización del Derecho natural provoca la existencia de una «dimensión ética sustancial»³⁹⁴ del Estado de Derecho. Pues bien, los principios, valores y derechos a través de los cuales se expresa esa dimensión constituyen un material normativo que presenta evidentes problemas en lo que a su determinación e interpretación se refiere. Estos problemas están referidos al necesario desarrollo de un discurso moral a la hora de interpretar esa dimen-

³⁹⁴ Vid. CELANO, B., «Diritti, principi e valori nello status costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione», *Analisi e diritto*, 2004, p. 56.

sión material del Estado de Derecho y a la determinación de su contenido y de su significado. Parece razonable afirmar el necesario recurso a argumentos sustanciales a la hora de establecer el sentido de los derechos. La actividad de atribución de sentido y de significado de los derechos implica el desarrollo de un determinado discurso moral que no se reduce a la ponderación mediante la cual se intenta solucionar un conflicto entre derechos. Pero en realidad los problemas de indeterminación vienen provocados por los rasgos que caracterizan el contexto social y cultural en el que en muchas ocasiones los derechos han de ser interpretados.

Los grupos humanos se constituyen como agregados de individuos a partir de determinados elementos de cohesión. Ciertamente, esos elementos pueden ser de diverso tipo, culturales, religiosos, económicos, o más o menos circunstanciales como por ejemplo la necesidad de colaboración en la defensa mutua frente a un agresor o un peligro común. En todo caso, las sociedades humanas también comparten internamente determinados principios que bien pueden ser identificados con una cierta concepción de la moralidad, de la justicia. Posiblemente ello, además de ser una exigencia pragmática, es también expresión de la necesidad antropológica de encontrar referentes morales comunes y compartidos.

Pues bien, los derechos fundamentales constituyen el mínimo moral común y compartido en el Estado de Derecho, el núcleo de una ética pública cuyo sentido básico no es tanto el de generar una voluntad de imposición como el de significar un referente de adhesión individual libre. Ferrajoli ha denunciado la falsedad de la tesis de acuerdo con la cual los derechos fundamentales deben ser compartidos desde el punto de vista moral por todos, o por la mayoría, de los miembros de una sociedad: «La teoría garantista del estado constitucional de derecho, basada en la separación laica entre derecho y moral, no sólo no supone sino que tampoco requiere, ni debe requerir, la adhesión a los valores ético-políticos que éste incorpora jurídicamente. Son, de hecho, estos mismos valores los que imponen no imponer ningún tipo de ética o de credo político, ni

siquiera democrático o liberal, lo cual debe respetarse incluso frente a quienes no los compartan, sean subversivos o delincuentes. (...) El paradigma liberal-democrático, en pocas palabras, no puede imponer jurídicamente las condiciones pragmáticas de la propia efectividad. En caso de que lo hiciera, entraría en contradicción consigo mismo, dado que negaría sus propios principios»³⁹⁵. Es cierto que la imposición de un credo moral, como puede ser por ejemplo el vinculado a los derechos fundamentales, es contradictorio con el sentido del modelo liberal, debido a que éste está basado en el reconocimiento del valor de la autonomía individual. Sin embargo, la cuestión a la que me refiero no es tanto la de la imposición de credos morales, como la de la existencia de elementos compartidos que generen un sentimiento de adhesión entre los miembros de una comunidad. El propio Ferrajoli ha señalado que en realidad, la existencia de un cierto componente de adhesión social es una condición pragmática respecto a cualquier sistema normativo, pero en especial en relación con los derechos fundamentales y la democracia, «que son construcciones sociales cuyo mantenimiento depende, más allá de las garantías jurídicas, de un cierto grado de consenso en torno a los valores sometidos a ellos»³⁹⁶. Es precisamente a ese núcleo de consenso al que me estoy refiriendo; núcleo de consenso que indefectiblemente presentará componentes morales.

En realidad, la historia de los derechos está jalonada de episodios que expresan perfectamente esa vocación de punto de encuentro a la que me he referido. Pensemos, por ejemplo, en el significado del proceso de subjetivización del Derecho Natural, basado en la unidad religiosa, que da paso a la reivindicación de los derechos naturales compatible con la pluralidad de explicaciones religiosas, y que caracteriza el inicio de la

³⁹⁵ FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», cit., pp. 366-367.

³⁹⁶ FERRAJOLI, L., «Los fundamentos de los derechos fundamentales», cit., p. 366.

Modernidad. Desde este punto de vista, ese proceso puede ser analizado desde dos perspectivas. Por una parte, se puede considerar que es una necesidad interna del propio iusnaturalismo, ya que la ruptura de la unidad religiosa le obliga a identificar referentes comunes (los derechos naturales) que no dependan de esquemas religiosos —que a partir de la ruptura pasan a ser particulares—. Por otra parte, puede ser expresión, relacionado con lo anterior, de la necesidad de ese referente moral común. Otro ejemplo es el del proceso de universalización de los derechos que no sólo debe ser interpretado como una exigencia de la construcción de una comunidad internacional desde el punto de vista político, sino como una dinámica de identificación de los elementos básicos de una comunidad moral. La universalidad moral de los derechos implica la identificación de un referente común y en este sentido posiblemente se puede enmarcar en una dinámica inacabada que se inicia en el proceso de subjetivización del Derecho Natural.

Asumiendo una estructura axiológica que se apoya en el reconocimiento de la autonomía individual, los derechos son un elemento central de la ética pública que constituye la plataforma normativa que permite la construcción y desarrollo de los planes de vida individuales. Sin embargo, el establecimiento del sentido y contenido de ese mínimo moral común y compartido constituye una tarea más o menos laboriosa y exigente desde el punto de vista intelectual, que está en función, entre otras cosas, del tipo de sociedad en la que nos tengamos que poner manos a la obra a la hora de identificar ese mínimo; está condicionada por el pluralismo ético que caracteriza de manera creciente el entorno social en el que nos desenvolvemos y que se vincula, al menos en su versión fuerte, en primer lugar, a la afirmación de la existencia de una pluralidad de bienes o valores fundamentales y, en segundo lugar, a la tesis del carácter irreductible de esos bienes o valores a una jerarquía común³⁹⁷.

³⁹⁷ Vid. BARBERIS, M., «L'eterogeneità del bene. Giuspositivismo, giusnaturalismo e pluralismo etico», *Analisi e diritto*, 2002-2003, pp. 13-18. Como

Ciertamente el escenario constituido por una sociedad en la que existe un consenso en relación a las normas morales básicas es muy diferente a aquel otro constituido por el encuentro de tradiciones o culturas caracterizado por ser precisamente encuentro de propuestas no coincidentes en afirmaciones que para aquellas parecen irrenunciables. Es sólo en relación con el primer escenario cuando se puede afirmar que «el sistema constitucional de los derechos fundamentales, en cuanto supone la suprema expresión del orden axiológico de la comunidad, proyecta su unidad de sentido al resto del sistema normativo, siendo el postulado-guía hermenéutico de todo el ordenamiento jurídico y político, al tiempo que religa la constitución formal con la constitución material»³⁹⁸. En el segundo escenario, los problemas de identificación de los derechos como mínimos morales son más agudos. Esa identificación constituye uno de los retos de los contemporáneos Estados de Derecho.

2.3. El Estado Constitucional como Estado de Derecho

Procede en esta parte de la investigación caracterizar el modelo de articulación del Derecho que conocemos como Estado constitucional. El análisis de los rasgos básicos de dicha articulación permitirá mantener la afirmación según la cual el Estado constitucional no es sino una manifestación del Estado de Derecho, en la que asistimos a un perfeccionamiento de la idea básica y compartida por ambos, que es la de limitación del

señala Barberis, la versión fuerte del pluralismo ético implica la admisión conjunta de las dos tesis señaladas, mientras que las versiones débiles consistirían en la afirmación de alguna de ellas solamente. Vid. también BARBERIS, M., «I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico», *Analisi e diritto*, 2005, pp. 1-20, en especial pp. 1-7.

³⁹⁸ PÉREZ LUÑO, A. E., «La metamorfosis del sistema de los derechos fundamentales y la crisis del positivismo jurídico», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*, cit., p. 641.

Poder. Todo ello, presupone una comprensión material o sustancial del Estado de Derecho, como la que se ha articulado anteriormente en este trabajo. A continuación intentaremos caracterizar el Estado constitucional como auténtico Estado de Derecho material. Para ello, será necesario hacer referencia también al constitucionalismo, como movimiento intelectual en el marco del que adquiere sentido el Estado constitucional, y a la idea de Constitución que maneja el constitucionalismo y que opera en el Estado constitucional. Lo anterior parece importante ya que, como posteriormente veremos, no todo Estado con Constitución es un Estado constitucional.

2.3.1. *El constitucionalismo y su Constitución*

Una exigencia metodológica se impone en este momento. Hasta ahora se ha prestado atención a la estructuración de un determinado modelo de articulación de las relaciones entre el Derecho y el Poder como es el Estado de Derecho y a la importancia que en dicho esquema tiene la limitación jurídica del Poder político. Si queremos perseverar en esta línea metodológica, nos vemos obligados a marcar diferencias conceptuales entre Estado Constitucional y constitucionalismo o, más específicamente, neoconstitucionalismo. Podemos estipular en este momento, sin perjuicio de efectuar ulteriores matizaciones, que el Estado constitucional presenta unas estructuras jurídicas a partir de las cuales se desarrolla una reflexión teórica que conocemos, en la actualidad, como neoconstitucionalismo.

Maurizio Fioravanti ha definido el constitucionalismo moderno como «el conjunto de doctrinas que a partir de la mitad del siglo XVIII han valorado de diferentes maneras el término-concepto de ‘constitución’ con el fin de facilitar y lograr la consecución de dos operaciones decisivas: la proyección de una forma de gobierno inspirada en el principio de la reducción y de la contención de la dimensión del arbitrio político y la correlativa e inescindible afirmación histórica de los dere-

chos individuales y de sus formas de garantía»³⁹⁹. Si hubiera que resumir el sentido del constitucionalismo en pocas palabras, y si ello fuera posible, creo que se podría caracterizar como una propuesta doctrinal en relación con la limitación del Poder a través del Derecho. Desde esta perspectiva, el constitucionalismo supondría la última etapa de una historia larga en siglos que es en buena medida la de la (alguna) filosofía política en su intento de controlar y racionalizar el Poder. Es importante subrayar que el ámbito en el que el constitucionalismo se pone manos a la obra es precisamente el mundo del Derecho, de las instituciones y de las normas jurídicas. En efecto, los límites que el constitucionalismo propone son límites jurídicos⁴⁰⁰; los mecanismos a través de los cuales se intenta limitar el Poder están constituidos por principios e instituciones jurídicas como, por ejemplo, el imperio de la ley, el principio de separación de poderes, la rigidez constitucional o el instituto del control de constitucionalidad. Es precisamente la dimensión limitadora del constitucionalismo la que permite vincularlo al garantismo⁴⁰¹.

La cuestión de la caracterización del constitucionalismo se presenta como ciertamente complicada. Estamos frente a un movimiento intelectual con plasmaciones prácticas que presenta muy diversas dimensiones y manifestaciones. En todo caso, sí parece un aspecto común de la doctrina la identificación de

³⁹⁹ FIORAVANTI, M., «Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra otto e novecento*, II, cit., p. 797.

⁴⁰⁰ Vid. GOZZI, G., «Storia e prospettive del costituzionalismo», en BONGIOVANNI, G., (ed.), *La Filosofia del Diritto Costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*, Clueb, Bologna, 1998, p. 13, en donde se afirma además que los criterios de distinción entre el constitucionalismo antiguo y el moderno consisten en las modalidades de instrumentos mediante los cuales se imponen los límites al Poder. Mauro BARBERIS ha subrayado la relevancia del carácter jurídico de los límites a la hora de caracterizar el constitucionalismo en «Costituzione (e costituzionalismo)», ID., *Etica per giuristi*, Laterza, Bari, 2006, pp. 119 y ss.

⁴⁰¹ Vid. FERRAJOLI, L., «Garantías», *Jueces para la Democracia*, n.º 38, julio 2000, pp. 39 y ss.

constitucionalismos más o menos exigentes en función de la satisfacción de mayores o menores requisitos. Así, Carlos Nino, a partir de la genérica identificación de la idea de constitucionalismo con la de gobierno limitado, reflejó una serie de significados o sentidos del concepto, hasta ocho en total⁴⁰², que varían en su robustez o intensidad, y que se determinan en función de las exigencias que se satisfacen en cada caso. Así, el constitucionalismo se identifica con: 1) la teoría del *rule of law*, y de la limitación de los poderes a través de reglas; 2) la presencia de una Constitución, norma suprema cuya garantía está asegurada a través de la previsión de mecanismos de reforma complejos en relación con los que se exigen para reformar las leyes; 3) las restricciones formales impuestas desde la Constitución a las leyes y que pueden consistir por ejemplo en la exigencia de generalidad, irretroactividad, publicidad, estabilidad; 4) un sistema de separación de poderes; 5) la inclusión en la Constitución del reconocimiento de derechos que deben ser respetados por los poderes del Estado; 6) la existencia de un mecanismo de control judicial de constitucionalidad encaminado a proteger esos derechos; 7) el origen democrático de determinadas instituciones de gobierno; 8) en fin, un modelo particular de democracia, que se puede identificar con el desarrollo de mecanismos participativos y representativos. Nino subraya el hecho de la mayor o menor robustez y solidez del constitucionalismo en función de la presencia de un mayor o menor número de los requisitos citados. Pues bien, a partir de lo anterior, es posible distinguir diversos conceptos de constitucionalismo, más fuertes o más débiles, lo cual depende de la mayor o menor atención que en la caracterización del mismo se preste a los contenidos de la Constitución. Así, un constitucionalismo débil —afirma Nino—, puede existir en un régimen no democrático (Nino propone el ejemplo del régimen de Pinochet en Chile) en el que una determinada articulación del Orde-

⁴⁰² Vid. NINO, C. S., *La constitución de la democracia deliberativa*, cit., pp. 16-17.

namiento sirve para impedir ciertos abusos y supone una mínima limitación al Poder. El concepto débil de constitucionalismo no se refiere a los contenidos sustanciales de la Constitución. Por el contrario el constitucionalismo más fuerte es el más condicionado por los derechos y libertades contenidos en la Constitución, protegidos mediante mecanismos reforzados.

Michel Troper también se refiere diversas acepciones de 'constitucionalismo', y distingue entre el constitucionalismo *lato sensu*, el constitucionalismo *stricto sensu*, y el constitucionalismo *strictissimo sensu*⁴⁰³. El constitucionalismo *lato sensu* afirma la necesidad en todo Estado de una Constitución, como medio para evitar el despotismo; el constitucionalismo *stricto sensu*, añade, a la existencia de la Constitución, el hecho de que ésta esté basada en ciertos principios encaminados a impedir el despotismo o a garantizar la libertad política; en fin, el constitucionalismo *strictissimo sensu* afirma la necesidad del control de constitucionalidad de las leyes como medio imprescindible para alcanzar los objetivos a los que se acaba de aludir.

Pues bien, teniendo en cuenta las anteriores aportaciones de Nino y Troper, el constitucionalismo en el que se piensa en este trabajo es el más robusto, en la terminología del primero, o el más estricto, de acuerdo con la del segundo.

No podemos profundizar aquí en la cuestión de las consecuencias que a partir de esos rasgos se derivan en relación con el concepto de Derecho. Ello no supone ignorar el intenso debate que se ha planteado en el marco de la Teoría del Derecho en relación con la relectura a la que el constitucionalismo ha sometido a algunas afirmaciones básicas del positivismo jurídico. Creo que aquí está justificado un excursus al respecto.

Recurriendo a una estrategia por lo demás muy utilizada por gran parte de la doctrina⁴⁰⁴, me limitaré a recordar en este

⁴⁰³ Vid. TROPER, M., «El concepto de constitucionalismo y la moderna teoría del Derecho», cit., pp.183-184.

⁴⁰⁴ Entre la abundante bibliografía, y de manera no exhaustiva, vid. PRIETO SANCHÍS, L., «El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y

momento que el constitucionalismo no presenta consecuencias similares en relación con cada uno de los «positivismos» caracterizados en su momento por Norberto Bobbio: positivismo teórico, positivismo metodológico y positivismo ideológico. En relación con el positivismo teórico, qué duda cabe de que el modelo de Ordenamiento jurídico presentado por el constitucionalismo somete a revisión, y con razón, alguna de sus afirmaciones básicas⁴⁰⁵. Pensemos, por ejemplo, en la reformulación de la posición de la ley en la estructura de las fuentes (cambio de posición que en ocasiones se relaciona con la crisis de la ley), o en la insuficiencia de la concepción lógico-silogística de la interpretación y de la aplicación del Derecho a la hora de enfrentarse con las normas principales que caracterizan el Derecho del Estado constitucional. Por otra parte, existen buenas razones para afirmar que el constitucionalismo puede llegar a coincidir con el positivismo ideológico a la hora

el iusnaturalismo? A propósito de «El Derecho dúctil» de Gustavo Zagrebelsky», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996, pp. 125 y ss.; ID., *Constitucionalismo y Positivismo*, Fontamara, México, 1997; ID., «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., pp. 123 y ss.; POZZOLO, S., *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 15-17; PINO, G., «Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale», *Analisi e diritto*, 1998, pp. 203 y ss; COMANDUCCI, P., «Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico», trad. de M. Carbonell, en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, pp. 75 y ss.; ID., «Constitucionalización y neoconstitucionalismo», en COMANDUCCI, P., AHUMADA, M. A., GONZÁLEZ LAGIER, D., *Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 85 y ss.; GARCÍA FIGUEROA, A., «La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, pp. 159 y ss.

⁴⁰⁵ Se ha señalado a este respecto que en realidad la auténtica oposición es la que existe entre constitucionalismo y positivismo teórico, desde el momento en que en ambos casos se están proponiendo modelos o tipos concretos de Derecho, cosa que no ocurre ni en el caso del positivismo metodológico ni en el del positivismo ideológico. Vid. SASTRE ARIZA, S., *Ciencia jurídica positivista y neoconstitucionalismo*, McGraw Hill, Madrid, 1999, pp. 143 y ss.; ID., «La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., pp. 239 y ss.

presentarse como un tipo de formalismo ético, y por tanto, le son aplicables las mismas críticas⁴⁰⁶. Y respecto al positivismo metodológico, que por otra parte es posiblemente el mejor positivismo que se puede mantener en la actualidad o, en otros términos, el positivismo a favor del cual concurren mejores razones, pienso que sus tesis centrales referidas al origen social de las fuentes del Derecho y a la posibilidad —y conveniencia— de una definición del concepto de Derecho en términos moralmente neutrales, pueden seguir siendo defendidas.

En realidad, los problemas que en su caso pudiera plantear el constitucionalismo en relación con la tesis de las fuentes sociales del Derecho no serían definitivos. Como ha señalado taxativamente Josep Aguiló, «el Derecho o es orden de la conducta social o no es Derecho. Lo que ocurre es que esta tesis no da para vertebrar un movimiento porque en realidad nadie la niega»⁴⁰⁷. En relación con la otra tesis, la referida a la posibilidad de una definición del Derecho no condicionada moralmente (que, como sabemos, reconduce a la cuestión de las relaciones entre el Derecho y la moral), pienso que se puede afirmar que la definición o determinación axiológica que presenta el Derecho del Estado constitucional, no impide una aproximación neutral al mismo. Como tampoco se vería impedida por el Derecho de otro tipo de Estado cuya opción axiológica fuera radicalmente opuesta a la del Estado constitucional. Es posible llevar a cabo una tarea descriptiva en relación con un sistema normativo que incluye contenidos morales. Sabemos que, en realidad, todo sistema jurídico (pertenezca o no al grupo de ordenamientos jurídicos que incluimos en el constitucionalismo) incluye contenidos evaluables moralmente (otra cosa es el tipo de evaluación —positiva o negativa— de la que sean merecedores). De ser cierto lo anterior, cabría plantearse hasta qué

⁴⁰⁶ Vid. al respecto, RODRÍGUEZ URIBES, J. M., *Formalismo ético y constitucionalismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

⁴⁰⁷ AGUILÓ REGLA, J., «Sobre la Constitución del Estado Constitucional», *Doxa*, n.º 24, 2001, p. 457.

punto los problemas que el constitucionalismo le presenta al positivismo metodológico son ciertamente falsos o ficticios y, en todo caso, novedosos. Ciertamente, en realidad, no es el constitucionalismo el que reta al positivismo, sino más bien el hecho de que el Derecho mismo es un orden normativo de las conductas humanas que implica criterios de valoración moral de las mismas. El hecho de que en el constitucionalismo esos contenidos se identifiquen con la moral que en un contexto democrático e ilustrado pudiéramos considerar correcta no debe ser un elemento que obstaculice la posibilidad de una aproximación no condicionada moralmente, de la misma manera que tampoco lo debería ser el hecho de que esos contenidos se identificaran, en su caso, con la moral incorrecta. Por tanto, ¿el reconocimiento de que el Ordenamiento jurídico invariablemente incluye contenidos morales supone una quiebra del positivismo? Hay que recordar de nuevo en este punto la necesidad de identificar bien de qué positivismo jurídico se está hablando: una de las objeciones al planteamiento del constitucionalismo es precisamente que pretende construir una crítica indiscriminada a un positivismo respecto del cual no se efectúan diferenciaciones internas y que, como tal, no existe. En todo caso, el reconocimiento que nos estamos planteando —referido a la presencia de contenidos morales en el Derecho— no supone una quiebra del positivismo metodológico ya que éste propone una determinada manera de aproximarse a un objeto —el Derecho— que es válida con independencia de la configuración de ese objeto. Frente a la cuestión de si el método de conocimiento de un sistema que incluye contenidos morales determinados tiene que ser diferente del método de conocimiento de otro sistema que incluye otros contenidos (susceptibles de evaluación moral en todo caso), la respuesta es negativa. Es posible un conocimiento neutro del objeto aunque éste no sea neutro en su contenido⁴⁰⁸. Recordemos que es pre-

⁴⁰⁸ «...aunque para comprender lo que es el Derecho sea menester prestar atención a la perspectiva del participante (...) la teoría del Derecho ha de

cisamente Hart, uno de los principales valedores del positivismo metodológico, el que —respondiendo a los planteamientos de Dworkin— en su último trabajo defiende la posibilidad de seguir ofreciendo un concepto moralmente neutro de Derecho, asumiendo la inclusión de dimensiones morales en los criterios de identificación de normas⁴⁰⁹.

Retomando el hilo argumental de esta parte del trabajo, procede señalar a continuación qué concepto de Constitución es el que maneja el constitucionalismo. Ello es un requisito de la justificación de la idea según la cual de la misma manera que no todo Estado con Derecho es un Estado de Derecho, tampoco todo Estado con Constitución es un Estado constitucional. Por otra parte, parece evidente que la indagación sobre el sentido del constitucionalismo y, por extensión, del Estado constitucional exige este paso. En este punto es importante tener en cuenta que la Constitución no es un fin en sí misma (de la misma forma que ninguna otra norma jurídica lo es), sino que adquiere sentido en relación con un fin u objetivo a alcanzar, que se identifica, en nuestro ámbito de estudio, con la garantía de los derechos a través de la implementación de técnicas de limitación del Poder. Esta idea es la que nos ofrece la clave para entender la Constitución del constitucionalismo. Y también nos

mantenerse externa y neutral frente a su objeto: se pueden describir creencias sin necesidad de compartirlas; y se pueden identificar normas por su contenido (además de por su promulgación) sin necesidad de hacerse partícipe o comprometerse con el mismo», L. PRIETO SANCHÍS, «Neoconstitucionalismos: un catálogo de problemas y argumentos», cit., p. 57. Desde un punto de vista crítico, vid. PORCIELLO. A., «Algunas cuestiones metateóricas relativas a la cuestión de la observación del fenómeno jurídico: una berve comparación entre positivismo jurídico metodológico y neoconstitucionalismo», *Derechos y Libertades*, 22, 2010, pp. 27 y ss.

⁴⁰⁹ Vid. HART. H. L. A., «Postscript», ID., *The concept of Law*, second edition, ed. by P. A. Bulloch and J. Raz, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 238 y ss. Entre nosotros ha defendido la tesis según la cual la presencia de contenidos morales en las Constituciones no impide un conocimiento neutral de las exigencias constitucionales MORESO, J. J., «Algunas consideraciones sobre la interpretación constitucional», *Doxa*, n.º 23, 2000, pp. 105 y ss.

permite comprender por qué la Constitución del constitucionalismo tiene un «fuerte componente de liberación política»⁴¹⁰.

Aunque parezca obvio, no por ello es menos importante recordarlo: la Constitución es la gran herramienta del constitucionalismo. En efecto, la materialización de las exigencias constitucionalistas vinculadas a la limitación del Poder y a la afirmación de esferas de garantía respecto a los derechos y libertades, se logra a través de la implementación de un texto constitucional caracterizado por determinados rasgos a los que vamos a aludir a continuación, y que se presenta —permítaseme la expresión— como la auténtica protagonista del Ordenamiento jurídico. Creo que es a esta idea a la que han querido aludir diversos autores cuando han intentado caracterizar la presencia de la Constitución en el sistema jurídico. Mostraré algunos ejemplos.

Maurizio Fioravanti ha identificado el siglo xx como aquel en el que se produce una auténtica ampliación del campo de la Constitución: «Es un campo amplísimo, que termina coincidiendo con toda la sociedad y comprendiendo todas las instituciones y los objetos que antes (...), eran celosamente reservados a la disciplina del Código civil, o estaban en todo caso bien lejanos de la esfera de lo constitucionalmente relevante: la familia, la empresa, la propiedad, el trabajo, en el fondo el conjunto de las relaciones civiles y económicas»⁴¹¹. Por su parte, Riccardo Guastini, en el marco de una reflexión sobre los requisitos que permiten hablar de ‘constitucionalización’ del Ordenamiento, se ha referido a ésta como a un proceso de transformación en el que el Ordenamiento se encuentra ‘impregnado’ por las normas constitucionales: «Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una

⁴¹⁰ Vid. AGUILÓ REGLA, J., «Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional», *Doxa*, n.º 26, 2003, p. 290.

⁴¹¹ FIORAVANTI, M., «Costituzione e politica: bilancio di fine secolo», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra otto e novecento*, II, cit., p. 877.

Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales»⁴¹². Entre nosotros, Carlos de Cabo ha aludido a la ‘hiperconstitucionalización’ del sistema jurídico en el marco del análisis de las causas de las transformaciones actuales de la ley. En este sentido, es posible identificar causas internas al propio sistema, que en términos generales determinan una disminución en la importancia jerárquica de la ley que tiene como origen el aumento en la complejidad estructural del sistema. De Cabo señala dos factores. En primer lugar, alude a los nuevos desarrollos del Derecho internacional y del Derecho comunitario; en segundo lugar se refiere a las consecuencias de la normatividad constitucional, de la que la hiperconstitucionalización se nos presenta como una manifestación principal, a través de la progresiva extensión de los ámbitos de la Constitución, en relación inversamente proporcional a la reducción del ámbito de la ley⁴¹³. La hiperconstitucionalización se desarrolla en dos direcciones. En primer lugar, a través de una extensión del ámbito de los derechos de manera que su presencia se refuerza en numerosas cuestiones; en segundo lugar, y conectada directamente con la anterior, en la localización en la Constitución de un cada vez mayor número de cuestiones, de manera que la reducción del ámbito de la legislación a la que se acaba de aludir supone evidentemente una reducción de los espacios en los que actúa el legislador.

Los tres ejemplos a los que se acaba de aludir —Fioravanti, Guastini, De Cabo— son coincidentes en la idea de fondo: la Constitución del constitucionalismo expande su presencia por todo el Ordenamiento jurídico, mostrando su influencia en ámbitos cuya regulación correspondía antes a otras instancias,

⁴¹² GUASTINI, R., «La «constitucionalización» del Ordenamiento jurídico: el caso italiano», trad. de J. M. Lujambio, en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., p. 49.

⁴¹³ Vid. CABO, C. de, *Sobre el concepto de ley*, Trotta, Madrid, 2000, p. 80.

y condicionando de manera directa la actuación de determinados operadores jurídicos. Este condicionamiento es evidente en el caso del legislador.

En relación con la tipología de la Constitución, debemos ser conscientes de la existencia de múltiples propuestas al respecto. Es evidente que este trabajo no constituye la sede adecuada para marcar los hitos importantes en el desarrollo histórico de la idea de Constitución, para desarrollar de manera completa y profunda una tipología constitucional, ni tampoco para condensar las funciones de la Constitución, sin las que no se puede entender gran parte de la cultura jurídica moderna⁴¹⁴. El objeto estricto de nuestra atención en este momento está constituido por la cuestión del tipo de Constitución en la que el constitucionalismo está pensando cuando desarrolla su propuesta.

Para ello, voy a hacer referencia a algunas propuestas en relación con la clasificación de las Constituciones. Posiblemente una de las clasificaciones construida a partir de tipos más amplios es la propuesta por Fioravanti, cuando hace referencia a la Constitución de los antiguos, a la Constitución medieval, y a la Constitución de los modernos. La primera, la Constitución de los antiguos, está vinculada a la búsqueda de la forma de

⁴¹⁴ Como puede comprenderse, la bibliografía al respecto es inabarcable. No obstante, podemos citar algunas referencias importantes, evidentemente sin afán de exhaustividad: BARBERIS, M., «Progetto per la voce 'Costituzione' di una enciclopedia», *Filosofia Politica*, a. V, n.º 2, 1991, pp. 351 y ss.; FIORAVANTI, M., *Stato e costituzione: materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli editore, Torino, 1993; ID., *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, trad. de M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2001; ID., *Le scienze del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra otto e novecento*, II, cit.; MATTEUCCI, N., «Costituzionalismo», ID., *Lo Stato moderno*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 127 y ss.; ID., *Organización del Poder y libertad. Historia del Constitucionalismo moderno*, trad. de Fco. Javier Ansuátegui y Roig y M. Martínez Neira Trotta, Madrid, 1998; VOLPE, G., *Il costituzionalismo del Novecento*, Laterza, Bari, 2000; ZAGREBELSKY, G., *Società, stato, costituzione*, Giappichelli editore, Torino, 1988; ID., «Storia e costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds.), *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 35 y ss.

gobierno ideal; forma de gobierno que en Atenas, con Clístenes pero sobre todo con Pericles, tiene un carácter básicamente democrático. La forma democrática de gobierno en Atenas implica primacía de la asamblea de los ciudadanos a la hora de adoptar decisiones colectivas; el reconocimiento del derecho de palabra y de propuesta en la Asamblea a los ciudadanos atenienses sin discriminación (*isegoria*); el reconocimiento del derecho de todos a acceder a los altos cargos y a las magistraturas; la alternancia anual de los gobernantes o la rendición pública de cuentas⁴¹⁵. Así, estamos frente a un modelo en el que la idea de democracia estaría vinculada a la de igualdad (*isonomia*).

Posiblemente, existe en Platón y Aristóteles una compartida vinculación de la noción de *Politeia* (Constitución) a la de estabilidad y permanencia que está en el origen de la idea de *patrios politeia*, de la Constitución de los antepasados, y que podría ser considerado como un antecedente remoto de la idea de Constitución mixta que, como veremos, se desarrolla en el constitucionalismo medieval⁴¹⁶. En este punto podemos tener buenas razones para afirmar que la idea de que la Constitución (que por supuesto en el escenario de los antiguos no se refiere al texto dotado de ciertas características formales que hoy conocemos), está vinculada a la idea de equilibrio es una herencia que la Constitución de los modernos recibe de la Constitución de los antiguos y que encontramos en Aristóteles y luego en Polibio y en Cicerón. En todo caso, es Fioravanti el que caracteriza la Constitución de los antiguos de acuerdo con determinados rasgos⁴¹⁷. Así, la Constitución de los antiguos se diferencia de la Constitución de los modernos por el hecho de que en el primer caso no existe un centro de imputación de la soberanía, un Poder soberano al que haya que limitar (como veremos

⁴¹⁵ Vid. FIORAVANTI, M., *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*, cit., pp. 17-18.

⁴¹⁶ Puede consultarse RUIZ RUIZ, R., *Los orígenes del republicanismo clásico. Patrios Politeia y Res Publica*, Dykinson, Madrid, 2006.

⁴¹⁷ Vid. FIORAVANTI, M., *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*, cit., pp. 30-31.

posteriormente la tensión entre la Constitución y la soberanía caracteriza de manera evidente al constitucionalismo contemporáneo). La Constitución de los antiguos no es entendida como una norma —tal y como hoy la entendemos— dedicada a regular determinadas instituciones, sino que se presenta como un ideal a perseguir, a satisfacer, es decir, un «gran proyecto de conciliación social y política». Siendo así las cosas, cabe una reflexión, y es la referida a la inviabilidad de interpretar esta concepción de la Constitución a la luz de la relación entre el Derecho y el Poder, desde el momento en que la Constitución no podría considerarse como el resultado de, al fin y al cabo, una imposición. La razón de ello posiblemente radica en que la Constitución de los antiguos no es tanto una realidad específicamente jurídica como cultural, política y moral.

Frente a la consideración de la Constitución de los antiguos como un orden político ideal, la Constitución medieval comienza a identificarse con una regulación jurídica dada. Si bien en el contexto de los antiguos la Constitución aparece como un ideal regulativo no específicamente jurídico, la Constitución medieval supone el reflejo de un orden de convivencia dado en el Derecho. Por poner un ejemplo, en el ámbito de las libertades y privilegios gremiales y laborales a las que se ha referido la doctrina a la hora de bucear en los antecedentes remotos de los derechos fundamentales, la Constitución ratifica y preserva la situación efectiva de reconocimiento y disfrute de esos privilegios. Pero lo interesante en este punto es constatar que ello se hace a través del Derecho. De esta manera, «la Edad Media puede describirse como la edad en la que el discurso sobre la Constitución deja de pertenecer de manera exclusiva al campo político y moral, del perfeccionamiento del hombre a través de la experiencia de la ciudadanía política común, y comienza a entrar en el mundo del Derecho, a convertirse en discurso jurídico, que nace de la práctica social. Por eso, hablar de la Constitución medieval significa hablar de reglas, de límites, de pactos y contratos, de equilibrio»⁴¹⁸.

⁴¹⁸ FIORAVANTI, M., *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*, cit., p. 38.

A partir de la obra de autores como Juan de Salisbury, Tomás de Aquino, Henry Bracton, Marsilio de Padua, François Hotman, Johannes Althusius, John Fortescue o Edward Coke, asistimos a un extenso y complejo período en lo que a la configuración de una idea se refiere, en la que en todo caso se observa una recuperación de la idea de Constitución mixta como lugar de encuentro de los distintos factores en tensión en el plano político, y por tanto contrario a cualquier pretensión absolutista, y a una reivindicación de la capacidad de la Constitución de ser una garantía de estabilidad y permanencia de un determinado modelo político. Estamos pensando en definitiva en la Constitución mixta que constituye una de las principales reivindicaciones frente al Poder absoluto de la monarquía a lo largo de los procesos revolucionarios de Inglaterra en el siglo xvii⁴¹⁹.

Pero, en todo caso, la Constitución vinculada al modelo del Estado Constitucional es identificable con la Constitución de los modernos. Estamos frente a una concepción de la Constitución que adquiere significado histórico y operatividad práctica en el marco del constitucionalismo y de sus exigencias. Adelantemos en este momento que por constitucionalismo podemos entender «el conjunto de doctrinas que a partir de la mitad del siglo xviii han valorado de diferentes maneras el término-concepto de ‘constitución’ con el fin de facilitar y lograr la consecución de dos operaciones decisivas: la proyección de una forma de gobierno inspirada en el principio de la reducción y de la contención de la dimensión del arbitrio político y la correlativa e inescindible afirmación histórica de los derechos individuales y de sus formas de garantía»⁴²⁰. Estamos por tanto ante una filosofía política centrada en la idea de *límite*, en la reivin-

⁴¹⁹ Vid. DORADO PORRAS, J., *La lucha por la Constitución. Las teorías del Fundamental Law en la Inglaterra del siglo xvii*, cit.

⁴²⁰ FIORAVANTI, M., «Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra otto e novecento*, II, cit., p. 797.

dicación de la necesidad urgente de limitar al Poder. Esta necesidad surge asociada a la reivindicación de los derechos de los individuos. Lo que se trata de limitar es precisamente el ejercicio del Poder en su potencialidad lesiva respecto a la libertad del sujeto. De esta manera, acabamos de introducir en la narración probablemente los dos grandes vértices o referencias en torno a las cuales se articula el discurso y la problemática del constitucionalismo: el Poder y los derechos. Pero el Poder del que estamos hablando en este momento está revestido de un rasgo que lo caracteriza a partir de la modernidad y al que ya hemos aludido: la soberanía. El constitucionalismo es por tanto una estrategia a la hora de limitar ese Poder perpetuo, absoluto e indivisible del que hablaba Bodino en *Les six livres de la République*; una estrategia encaminada a lograr que ese poder no sea perpetuo, absoluto e indivisible —atributos de la soberanía— y por tanto disminuya su peligro frente a las libertades.

Es precisamente en la Constitución de los modernos cuando se profundiza en la idea de los límites y las garantías frente al Poder a través de dos operaciones que hasta mediados del siglo XVII habían sido imposibles: «La primera consistía en la división del poder soberano, es decir, en la individualización de una pluralidad de poderes públicos contrapesados entre ellos y, por ello, limitados recíprocamente (...). La segunda operación consistía en la posibilidad de individualizar un límite legal a la extensión de los poderes del soberano, de poder oponer a esos poderes una *norma fundamental*, quizás para garantía y tutela de los derechos de los individuos»⁴²¹.

En uno de sus últimos escritos, Francisco Tomas y Valiente aludía a cuatro conceptos de 'Constitución': histórico, sociológico, racional-normativo y mínimo⁴²². De acuerdo con el con-

⁴²¹ FIORAVANTI, M., *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, cit., p. 86.

⁴²² Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., «Constitución», en DÍAZ, E.-RUIZ MIGUEL, A., (eds.), *Filosofía Política II: Teoría del Estado*, Trotta-CSIC, Madrid, 1996, pp. 46-50.

cepto histórico, la Constitución se identifica con la idea de tradición, que ejerce una atracción vinculante a la que se encuentra sujeto el legislador histórico y que condiciona por tanto el contenido de la Constitución escrita. En segundo lugar, la Constitución sociológica expresa el conjunto de condiciones y factores que caracterizan y definen los rasgos de una sociedad. Esos rasgos, que van desde la naturaleza y el clima (Montesquieu) hasta el tipo de relaciones económicas imperantes en el grupo social (Marx), ejercen también un influjo determinante en la Constitución, que se presenta como su reflejo. En tercer lugar, el concepto racional-normativo sumerge a la Constitución de lleno en el mundo del Derecho. A partir de las experiencias revolucionarias norteamericana y francesa⁴²³, la Constitución se presenta como un proyecto —por tanto orientado hacia el futuro— de organización jurídico-política del Estado. La Constitución, en este sentido, se presenta como el elemento normativo último del sistema jurídico. En fin, el significado del concepto mínimo de constitución es incomprensible sin tener en cuenta el tantas veces citado artículo 16 de la Declaración de 1789: «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la separation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution». El concepto mínimo se refiere a la Constitución con contenidos. Y no cualesquiera contenidos, sino aquellos a través de los cuales se materializa lo que ha sido una de las preocupaciones principales de la teoría política liberal, esto es «la reflexión sobre la insoslayable necesidad histórica de controlar, frenar y dividir el poder»⁴²⁴.

Por su parte, Aguiló lleva a cabo una distinción que puede sernos útil⁴²⁵. En efecto, propone diferenciar entre Constitu-

⁴²³ Vid. BLANCO VALDÉS, R., *El valor de la Constitución*, cit. También, COMANDUCCI, P., *Assaggi di metaetica*, Giappichelli editore, Torino 1992, pp. 168 y ss.

⁴²⁴ BLANCO VALDÉS, R., *El valor de la Constitución*, cit., p. 29.

⁴²⁵ Vid. AGUILÓ REGLA, J., «Sobre la Constitución del Estado Constitucional», cit., pp. 435 y ss.

ción necesaria y Constitución contingente. La Constitución necesaria, que resultaría de la propuesta del positivismo normativista, se identifica con el conjunto de normas fundamentales de un sistema jurídico-político que establecen los criterios para determinar la identificación, la unidad y la continuidad o permanencia del Derecho. Esta Constitución, además de ser necesaria, actúa *ex post*: «una vez que se ha producido la estabilización de las conductas jurídicas y políticas de una comunidad, que se ha generado una práctica jurídica y política, que se puede hablar de expectativas fundadas de conducta, puede determinarse el conjunto de normas que de hecho operan como fundamentales en esa comunidad»⁴²⁶. Junto a lo anterior, la Constitución necesaria se caracteriza también por implicar una práctica social y por carecer de carácter justificativo, es decir por no ser fuente de deberes morales genuinos. La idea de Constitución contingente implica que no todo sistema jurídico dispone de una Constitución en este sentido. De acuerdo con lo anterior, es posible que un sistema jurídico carezca de Constitución. Dicha situación se puede producir en dos casos: en aquellos casos en los que se maneja la idea de Constitución formal-rígida, y en aquellos otros en los que la idea de Constitución a la que se alude es la propuesta por el constitucionalismo. En efecto, son fácilmente imaginables situaciones en la que, o bien no exista una Constitución formal, o bien la Constitución que exista no coincida con las coordenadas intelectuales y políticas del constitucionalismo.

Pues bien, la Constitución del constitucionalismo se nos presenta como una Constitución contingente, garantizada a partir de la presencia de diversos mecanismos específicos que la diferencian del resto de normas del sistema y vinculada al ideario constitucionalista. Son estos mecanismos los que le permiten llevar a cabo su función limitativa del Poder políti-

⁴²⁶ AGUILÓ REGLA, J., «Sobre la Constitución del Estado Constitucional», cit., p. 438.

co⁴²⁷. En el constitucionalismo la consideración formal y material de la Constitución guardan cierta relación entre sí. En efecto, la Constitución es la norma superior del sistema, la norma suprema. Su carácter supremo está garantizado a través de la operatividad de determinados mecanismos de protección (rigidez, procedimientos agravados de reforma). Pero no cualquier norma suprema protegida es una Constitución para el constitucionalismo. Para poder serlo, la norma suprema debe superar lo que podríamos considerar el test de los contenidos. Recordemos que, estamos frente a un modelo de «Constitución Ferrajoli» y no de «Constitución Kelsen»⁴²⁸. La Constitución debe acoger en su seno determinados contenidos que se vinculan en última instancia al ideario de la democracia liberal: derechos y libertades. En relación con éstos, su constitucionalización y la forma de la Constitución, a partir de su resistencia, actúa como elemento de garantía.

En definitiva, la Constitución es «norma normarum», norma entre las normas, norma que prevalece en su colisión con cualquier otra de las normas que componen el sistema jurídico. Esta posición de la Constitución en realidad descansa en una determinada filosofía política en la que la noción de pacto social, de un lado, y de *higher law*, de otro, ocupan un lugar relevante. En ambos casos, la influencia del iusnaturalismo es patente. Así, la Constitución se interpreta como expresión de un pacto que, en la versión de John Locke y de su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*, tiene como finalidad asegurar la garantía de la libertad. Como ha señalado Eduardo García de

⁴²⁷ Vid. GUASTINI, R., «Sobre el concepto de Constitución», en CARBONELL, M. (ed.), *Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos*, Trotta, Madrid, 2007, pp. 16-17.

⁴²⁸ La distinción es de Luis PRIETO SANCHÍS en *El constitucionalismo de los derechos*, cit., p. 69. La diferencia es asimilable a aquella otra entre modelo sustantivo y modelo procedimental de Constitución (vid. POZZOLO, S., «Reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la Constitución», en CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*, cit., pp. 212 y ss.

Enterría, «la libertad individual no es así sólo el origen de la sociedad, sino, a la vez, su finalidad última, su estatuto esencial. La libertad deja de ser una franquicia frente al poder, una reducción o un límite a ese poder, ineludible y fatal y siempre ajeno; pasa a ser precisamente el objeto mismo del poder político, que ha comenzado por surgir de ella; pasa a ser el mismo canon de la vida colectiva, porque la sociedad que el poder está llamado a sostener ha de ser una sociedad compuesta precisamente de hombres libres, con capacidad para actuar a su albur, en el gobierno de sí mismos y de sus bienes, en la elección de su futuro, en la negociación y formación de sus pactos»⁴²⁹. Y la Constitución tiene como finalidad básica asegurar el disfrute de esa libertad. Y para garantizar ese cometido la Constitución se sitúa en una posición de primacía jurídica, expresión en el mundo del Derecho de la primacía moral de los derechos y libertades que ella reconoce y garantiza.

2.3.2. *El Estado constitucional y la materialización del Derecho*

La caracterización del Estado constitucional debe partir de la consideración del papel que desempeña la Constitución en el seno del Ordenamiento. En este sentido, la Constitución se caracteriza por ocupar una determinada posición privilegiada en el interior del sistema. Esa posición la sitúa en el plano superior de la jerarquía de las fuentes, y se define por su carácter vinculante y obligatorio para todos, poderes públicos y ciudadanos, a partir del cual podemos comprender la necesidad imprescindible y el sentido de específicos mecanismos de protección. También sabemos que cuando en el seno del constitucionalismo y del Estado constitucional hablamos de Constitución, no hacemos referencia a cualquier norma, sino que estamos pensando en una norma definida, entre otras cosas,

⁴²⁹ GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, cit., p. 296.

por la inclusión de determinados contenidos, a través de los cuales se expresa la opción sustancial y axiológica del constitucionalismo contemporáneo. Es a esta sustancialización específica y particular de la Constitución y, a través de ella, del Ordenamiento a lo que se alude —como veremos— cuando se hace referencia a la materialización, o rematerialización, del Derecho en el Estado constitucional.

En resumidas cuentas, son las ideas anteriores las que nos permiten entender la caracterización del Estado constitucional y las que dotan de sentido a sus procedimientos y estructuras. En efecto, si analizamos algunas de las propuestas en relación con dicha caracterización, creo que todas ellas desembocan en el papel de la Constitución. Propongo aludir a alguna de ellas a continuación.

Pérez Luño ha caracterizado el Estado constitucional a partir de la constatación de un triple desplazamiento que se produce en los Ordenamientos jurídicos democráticos y contemporáneos⁴³⁰: de la primacía de la ley a la primacía de la Constitución; de la reserva de ley a la reserva de Constitución; y del control jurisdiccional de la legalidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad. Conocida es también la identificación que Robert Alexy propone del modelo de sistema jurídico del constitucionalismo, frente al legalismo⁴³¹, a partir de cuatro contraposiciones: norma en vez de valor; subsunción en vez de ponderación; independencia del derecho ordinario en vez de la omnipresencia de la Constitución; autonomía del legislador democrático dentro del marco de la Constitución en lugar de la onnipotencia judicial apoyada en la Constitución. Por su parte, Luis Prieto ha señalado que el Estado constitucional supone una transformación en relación con la propuesta positivista de las fuentes del Derecho, vinculada a la cual se

⁴³⁰ Vid. PÉREZ LUÑO, A. E., «Estado constitucional y derechos de la tercera generación», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XVI, 1997, pp. 547 y ss. A esta caracterización me referiré más adelante.

⁴³¹ Vid. ALEXY, R., *El concepto y la validez del Derecho*, cit., p. 160.

presenta también una reformulación de la teoría de la interpretación y de la aplicación del Derecho⁴³².

Pues bien, no me interesa tanto profundizar en todos y cada uno de los rasgos señalados —que, por lo demás han sido convenientemente estudiados entre nosotros— como subrayar la idea de que todos ellos pueden reconducirse a la presencia de la Constitución, tal y como la entiende el constitucionalismo contemporáneo. Es decir, una norma suprema dotada de específicos contenidos, que se articulan internamente en muchas ocasiones a través de específicas normas (principios y valores), y que se garantiza mediante mecanismos de protección que distinguen y diferencian a la Constitución respecto al resto de las normas del Ordenamiento

En realidad, los anteriores rasgos pueden ser entendidos vinculados, de manera más o menos directa, a la idea según la cual el Derecho del Estado Constitucional se caracteriza por su «materialización».

Cuando La Torre habla de «rematerialización» hace referencia a la «creciente orientación de las normas estatales hacia valores sustantivos y su reformulación (por lo que concierne a su contenido) como actos administrativos, es decir, como intervenciones directas y específicas en *todos* los ámbitos de la vida social»⁴³³. Para el análisis de este concepto parte, como antes lo hiciera Habermas, de la distinción entre racionalidad formal y racionalidad material del Derecho tal y como fuera estipulada por Max Weber. La Torre utiliza el concepto de materialización o rematerialización para explicar el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional a partir de la presencia de contenidos sustantivos en la Constitución que necesariamente condicionan la acción normativa de éste. También Habermas

⁴³² Vid. por ejemplo PRIETO SANCHÍS, L., *Constitucionalismo y Positivismo*, cit., pp. 15 y ss.; ID., «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., pp. 124 y ss.

⁴³³ LA TORRE, M., «Derecho y conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde una perspectiva europea», cit., p. 70.

se refiere como punto de partida a la explicación weberiana de la materialización del Derecho formal burgués que se produce a partir del desarrollo jurídico del Estado social, y que tiene como consecuencia una transformación de las funciones y de la estructura del sistema jurídico. Dicha transformación tiene lugar desde el momento en que el Derecho «queda instrumentalizado para las tareas configuradoras de un legislador que ha de satisfacer exigencias de justicia social, con redistribuciones de tipo compensador, con operaciones de regulación y control sistémicos de tipo estabilizador y con intervenciones transformadoras»⁴³⁴. Ello implica la desintegración del concepto formal de Derecho elaborado por la Pandectística y por la Jurisprudencia de conceptos. La introducción de consideraciones finalistas, de programas políticos, de aspectos vinculados a la planificación y a la redistribución, presentan como resultado un producto normativo que es difícilmente compatible con la propuesta, ordenada y vinculada a la previsibilidad, originada en la Ciencia jurídica formalista del siglo XIX. Se sientan así las bases de un proceso de materialización del Derecho, que llega hasta nuestros días y que caracteriza el sentido de los Ordenamientos jurídicos de las democracias constitucionales, en los que «los principios morales del derecho natural racional se han convertido (...) en derecho positivo»⁴³⁵.

La idea de materialización del Derecho, tal y como es manejada por Habermas, y la de positivación o constitucionalización del Derecho natural empleada por Ferrajoli, tienen un mismo sentido, aunque los enfoques respectivos son diferentes. Si bien Ferrajoli no trabaja con la idea habermasiana según la cual el procedimiento —cuya utilidad aumenta en las sociedades pluralistas⁴³⁶— es el mecanismo a través del cual la legalidad se transforma en legitimidad, la vinculación entre legalidad y legitimidad se produce en su obra como resultado de la aproxima-

⁴³⁴ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 537.

⁴³⁵ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 545.

⁴³⁶ Vid. HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., pp. 554 y 555.

ción entre los criterios de legitimación externa y de legitimación interna. Es esta aproximación, como hemos visto en un momento anterior de este trabajo, la que constituye la novedad histórica del Estado constitucional de Derecho.

Para Ferrajoli, el Estado constitucional de Derecho —expresión el Estado de Derecho en sentido fuerte⁴³⁷—, supone una mutación de las condiciones de validez propias del modelo del paleopositivismo, en términos del autor. En efecto, la materialización del Derecho en sede constitucional tendría como consecuencia la aparición, junto a la racionalidad formal propugnada por el positivismo, de una nueva racionalidad, ahora sustancial⁴³⁸. Y esa nueva racionalidad condiciona el concepto de validez. Merece la pena que nos detengamos en el análisis del concepto de validez que propone Ferrajoli, pues posiblemente resume una forma de concebir las consecuencias de la materialización del Derecho que pienso que refleja el punto de vista constitucionalista al respecto. Por otra parte, el concepto de validez defendido por el constitucionalismo constituye un fiel reflejo de las conclusiones a las que se llega —entre sus filas— en materia de relación entre el Derecho, el Poder y la moral.

Para Ferrajoli —lo acabamos de señalar— la novedad histórica del Estado de Derecho consiste en la inclusión en el Ordenamiento de los criterios de legitimación que tradicionalmente habían sido externos al Ordenamiento jurídico mismo, convirtiéndolos así en normas de legitimación interna. La separación entre ambos criterios —señala Ferrajoli— es uno de los logros del pensamiento jurídico moderno. Dicha separación permite diferenciar los enfoques descriptivos de los prescriptivos o críticos respecto al Derecho positivo. No obstante, la anterior

⁴³⁷ Vid. FERRAJOLI, L., «Entrevista a L. Ferrajoli», (G. Pisarello y R. Soriano), *Isonomía*, n.º 9, 1998, p. 187.

⁴³⁸ Vid. FERRAJOLI, L., «Democrazia e costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*, cit., p. 321.

separación se ha confundido —continúa Ferrajoli— con otra tesis, que sería diferente en su sentido, y que es la que afirma la separación entre el Derecho positivo como hecho y el Derecho natural como valor, es decir entre el ser y el deber ser del Derecho. Como consecuencia de lo anterior se afirmarí­a que los juicios relativos a la legitimación interna son auténticos juicios de hecho, referidos a la existencia de las normas, mientras que los relativos a la legitimación externa serían juicios de valor.

El error de la anterior identificación, que en realidad es —señala Ferrajoli— el de la tradición positivista, consiste precisamente en la identificación entre los conceptos de validez y positividad del Derecho. El positivismo siempre ha propugnado la comprensión de la validez como existencia jurídica. El juicio de validez sería así un juicio de existencia. Ferrajoli atribuye al positivismo una concepción formal de la validez (ya que no referida «a valoraciones del significado o contenido normativo de las normas producidas»⁴³⁹), vinculada «a ordenamientos jurídicos de estructura elemental en los que el legislador es *legibus solutus*, de manera que cualquier norma emanada por los sujetos y en las formas queridas por él es una norma válida»⁴⁴⁰. Frente a estos Ordenamientos, «de estructura elemental», los Ordenamientos de los Estados constitucionales están vinculados a una concepción de la validez que bien podría considerarse como más exigente, desde el momento en que la vertiente formal de la validez es complementada por una dimensión material: la validez de una norma no está en función exclusiva de exigencias formales, sino que además «depende igualmente del significado de los enunciados normativos producidos, y más exactamente de la valoración de la conformidad de su contenido con el «deber ser» jurídico establecido por normas superiores»⁴⁴¹. Según

⁴³⁹ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 355. Vid. también *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, I, p. 531.

⁴⁴⁰ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 355. *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, I, p. 531.

⁴⁴¹ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 355.

Ferrajoli, la estructura normativa del Estado de Derecho (en el sentido de Estado constitucional) se caracteriza por cuatro rasgos, que son los que determinan la complejidad de estos ordenamientos⁴⁴²: 1) en primer lugar, «la pertenencia de las normas vigentes a niveles diversos y jerárquicamente ordenados, cada uno de los cuales se configura como normativo respecto del inferior y como fáctico en relación con el superior»; 2) en segundo lugar, «la incorporación a las normas superiores de obligaciones y prohibiciones que disciplinan la producción de las normas inferiores y cuya observancia es condición de la efectividad de las primeras y de la validez de las segundas»; 3) en tercer lugar, «las antinomias producidas por la violación de las normas superiores por parte de las inferiores y por la simultánea vigencia de unas, aun cuando inefectivas, y de las otras, no obstante su validez»; 4) y por último, «la consiguiente ilegitimidad jurídica que en alguna medida afecta siempre a los poderes normativos, legislativo y judicial y que es tanto mayor cuanto más amplia pero inefectiva resulte la incorporación limitativa de los deberes a los niveles más altos del ordenamiento».

Por lo tanto, en los Estados constitucionales estaríamos en presencia de Ordenamientos de estructura compleja que, a partir, y como consecuencia, del proceso de positivación del Derecho natural incluyen dimensiones del ser y del deber ser. De la constatación de la diferencia entre el ser y el deber ser *del* Derecho, se pasa ahora a la de la diferencia entre el ser y el deber ser *en* el Derecho.

Para Ferrajoli lo anterior obliga a una redefinición o recomprensión de conceptos básicos de la Teoría del Derecho, entre los que destaca el de validez. Esta recomprensión es posiblemente el efecto más importante que se deriva de la inclusión de contenidos materiales en las constituciones⁴⁴³. Ferrajoli propo-

⁴⁴² Vid. FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 872.

⁴⁴³ Vid., PEÑA FREIRE, A. M., *La garantía en el Estado constitucional de Derecho*, Trotta, Madrid, 1997, p. 87.

ne una diferenciación entre el concepto de validez y el de vigencia, vinculada a la superación de la identificación de la validez con la existencia jurídica. En efecto, para Ferrajoli, vigencia es «la validez sólo *formal* de las normas tal cual resulta de la regularidad del acto normativo»; validez es «la validez también *sustancial* de las normas producidas, es decir, de sus significados o contenidos normativos»⁴⁴⁴. Así, «para que una norma exista o esté en vigor es suficiente que satisfaga las condiciones de validez formal, condiciones que hacen referencia a las formas y los procedimientos del *acto normativo*, así como a la competencia del acto de que emana. Para que sea válida, se necesita por el contrario que satisfaga las condiciones de validez sustancial, que se refieren a su contenido, o sea, a su *significado*»⁴⁴⁵. Desde este punto de vista, la constatación de la satisfacción de las condiciones de vigencia se presenta como un juicio de hecho: se trata, al fin y al cabo, de comprobar si el acto de producción de una norma ha cumplido los requisitos formales establecidos. Por el contrario, la determinación de la validez depende de la adecuación entre los contenidos de la norma concreta y los de las normas superiores, que en el Estado constitucional incluyen valores y dimensiones morales; así, la constatación de la validez exige llevar a cabo juicios de valor, de los que, a diferencia de los juicios de hecho, no se puede predicar su verdad o falsedad. Existe por tanto una «disociación estructural»⁴⁴⁶ entre los juicios de vigencia y los juicios de valor, que necesariamente se manifiesta en la existencia de un ámbito de valoratividad y discrecionalidad asociado a estos últimos⁴⁴⁷.

⁴⁴⁴ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 359.

⁴⁴⁵ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 874.

⁴⁴⁶ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 875.

⁴⁴⁷ Vid., PEÑA FREIRE, A. M., *La garantía en el Estado constitucional de Derecho*, cit., pp. 98 y ss. Es cierto que Ferrajoli, en una respuesta a sus críticos, matiza la identificación respectiva de los juicios de vigencia como juicios de hecho, y por tanto verificables y susceptibles de un juicio de falsabilidad, de un lado, y de otro, de los juicios de validez como juicios de valor a los que por tanto no les es aplicable la consideración de falsos o verdaderos (vid.

De manera que para Ferrajoli, la vigencia se vincula a la validez formal y la validez a la validez formal más la validez sustancial. Una norma vigente existe, pertenece al Ordenamiento jurídico, aunque no sea válida. Así, podemos tener normas inválidas (por no satisfacer condiciones sustanciales), que sin embargo pertenecen a un determinado Ordenamiento jurídico y por tanto —en principio— son jurídicas. Podría pensarse que estamos ante dos conceptos de validez, uno menos exigente y otro más exigente, que incluye juicios de hecho y juicios de valor. Según Ferrajoli, «validez y vigencia coinciden en los Estados absolutos, que tienen como única norma acerca de la producción el principio de mera legalidad *quod principi placuit legis habet vigorem*; no coinciden por el contrario en los modernos Estados de Derecho, que están dotados de normas acerca de la producción que vinculan la validez de las leyes al respeto de condiciones también sustanciales o de contenido, en primer lugar los derechos fundamentales»⁴⁴⁸.

«Note critiche ed autocritiche intorno alla discussione su *Diritto e ragione*», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli ed., Torino, 1993, pp. 465 y ss.) Ferrajoli señala al respecto que en todo caso en el juicio de vigencia existe una referencia a un hecho empírico (el acto normativo), mientras que en el juicio de validez se plantea una cuestión referida al significado de la norma en cuestión. Así, tendría sentido afirmar «la taxatividad de las normas constitucionales sobre la formación y, en general, de todas las normas formales sobre la vigencia: desde la precisión de los requisitos de forma, a la de las esferas de competencia, hasta el carácter unívoco de todos los procedimientos. Pero sería vana una pretensión análoga para las normas constitucionales sustanciales, algunas de las cuales se expresan inevitablemente en términos vagos y valorativos» (ibidem, p. 472). Por ello, lo que termina por caracterizar los juicios de validez o invalidez no es tanto su carácter de juicios de valor sino su «opinabilidad» derivada de la vaguedad de las normas a las que están referidos. De ello se deriva que estos juicios no pueden ser a-valorativos: «la no-valoratividad de un juicio es en realidad un corolario no tanto del carácter valorativo de los términos empleados, cuanto de su vaguedad, que comporta de manera inevitable una discrecionalidad interpretativa que se expresa a través de elecciones normativas y no puramente cognitivas» (ibidem, p. 475).

⁴⁴⁸ FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., p. 360.

Pues bien, creo lo anterior puede dar pie a algunas reflexiones. El punto de partida de la propuesta de Ferrajoli en este tema está constituido por la introducción de contenidos sustanciales en el Ordenamiento jurídico. En efecto, como ya se ha señalado con anterioridad, el Estado constitucional se caracteriza, entre otras cosas, por la positivación de contenidos morales en forma —no exclusiva, pero sí principalmente— de derechos fundamentales, positivación que se produce generalmente en los niveles normativos más elevados del Ordenamiento. A partir de ahí, se derivan determinadas consecuencias, que en ciertas vertientes afectan a una cierta comprensión de las relaciones del Derecho con el Poder y con la moral.

La propuesta de Ferrajoli es un buen exponente del reflejo que las novedades del constitucionalismo han tenido en el marco de la reflexión filosófica sobre el Derecho. Voy a plantear algunas cuestiones en relación con ella, aunque ello suponga volver sobre algunos temas abordados anteriormente: 1) ¿hasta qué punto la positivación de contenidos morales supone una novedad del constitucionalismo que obligue a reformular posiciones mantenidas durante tiempo por la Teoría del Derecho, o por lo menos por parte de un sector —de adscripción positivista— de la misma?; 2) ¿en qué medida la distinción entre validez y vigencia es incompatible con el positivismo denunciado por Ferrajoli?

1) El constitucionalismo se nos presenta — por parte de Ferrajoli— como novedoso en lo que se refiere a la positivación de contenidos morales, a partir de la cual se refuerzan y matizan las dimensiones controladoras y limitadoras del ejercicio del Poder por parte del Derecho. Creo que en este punto cabe plantear la duda de si el constitucionalismo es de verdad novedoso en lo que a la positivación de contenidos morales se refiere, o en lo que se refiere, por el contrario, a la positivación de *específicos y determinados* contenidos morales⁴⁴⁹. La diferencia

⁴⁴⁹ Vid. DE ASÍS ROIG, R., *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, cit., p. 99.

de sentido es importante en ambos casos, de la misma manera que también son diferentes las consecuencias que se pueden extraer. En efecto, parece que lo novedoso del constitucionalismo es en realidad la positivación de *determinados* contenidos morales, entre los cuales destacan los derechos fundamentales y los valores a ellos asociados. Estos contenidos reflejan en buena medida la herencia ilustrada recibida por el Derecho moderno. Por tanto, en lo que destaca el constitucionalismo es en la positivación de determinadas —unas y no otras— dimensiones morales.

Y es que posiblemente no sea imaginable —lo hemos señalado en este trabajo— un Derecho sin dimensiones morales. La presencia de dimensiones morales, de contenidos y de opciones sobre lo bueno y lo malo, es inevitable. Parece evidente que una cosa es reconocer esa presencia y otra muy distinta es valorar desde el punto de vista de su corrección moral los contenidos concretos. El Derecho incluye contenidos morales, sean estos los expresados por los derechos asumidos por el constitucionalismo o los principios y creencias en los que se apoya un régimen despótico. En ambos casos estamos ante opciones morales.

Por tanto, si por algo destaca en este sentido el constitucionalismo no es por constituir un caso de apertura a la moral, sino por serlo de apertura a una cierta opción moral, que es la de los derechos, y en términos generales la del proyecto ilustrado. La propuesta ilustrada, en muchos sistemas democráticos, ha dejado de ocupar una posición, en términos generales, crítica respecto al Ordenamiento, pasando a constituir la opción moral del mismo.

El constitucionalismo no tiene por qué implicar en este sentido una crítica respecto a una concepción positivista de la relación entre el Derecho y la moral, a no ser que se esté pensando en un positivismo que bien podríamos considerar como inocente o trasnochado. La crítica constitucionalista al positivismo en muchas ocasiones se dirige o bien a tesis, pretendidamente positivistas, que ya no se mantienen, o bien que

no son predicables de todos los planteamientos positivistas⁴⁵⁰. En este sentido, el positivismo, que posiblemente ha acabado siendo una posición que defiende una determinada estrategia metodológica de aproximación al concepto de Derecho, se muestra compatible con la constatación de la presencia de dimensiones morales en el Derecho, si bien suspende el juicio moral en relación con sus concretos contenidos. Lo cual posiblemente supone adoptar una posición plenamente consecuente con la consideración del Derecho como sistema normativo de regulación de las conductas humanas y de articulación del conjunto social de acuerdo con criterios axiológicos.

2) ¿En qué medida la distinción entre validez y vigencia es incompatible con el positivismo denunciado por Ferrajoli?

Gran parte de los comentarios y reflexiones suscitados por la propuesta de Ferrajoli están enfocados precisamente a la distinción entre validez y vigencia. En el debate que se generó con ocasión de la publicación de *Diritto e ragione*, se afirmó, entre otras cosas, que con la distinción propuesta, Ferrajoli parecía limitarse a dar nombres distintos a dos cosas que tradicionalmente habían sido consideradas como especies del mismo genero, ésto es la validez formal y la validez material⁴⁵¹; también se aludió a la posibilidad de que la distinción tuviera la función de reforzar el carácter persuasivo de la exposición de los principios garantistas, no siendo indispensable desde el

⁴⁵⁰ Este es el argumento genérico desarrollado por N. HOERSTER en «En defensa del positivismo jurídico», en ID., *En defensa del positivismo jurídico*, trad. de Jorge M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1992, pp. 9 y ss. Sobre la pluralidad de tesis identificadas por el positivismo, es ya clásico el planteamiento de HART, en «Positivism and the Separation of Law and Morals», cit., p. 57, n. 25. Vid. también NINO, C. S., *La validez del Derecho*, cit., p. 146; ID., *Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica*, Fontamara, México, 1993, p. 76.

⁴⁵¹ Vid. JORI, M., «La cicala e la formica», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli ed., Torino, 1993, pp. 81-82.

punto de vista teórico⁴⁵². En todo caso, me interesa aquí reflexionar sobre la supuesta incompatibilidad entre la distinción entre vigencia y validez y el positivismo al que alude Ferrajoli, incapaz de asumir la diferencia entre los conceptos de vigencia, validez y eficacia.

El mismo Ferrajoli admite que la distinción entre vigencia y validez supone una radicalización de la diferencia entre validez formal y validez sustancial, y que es imprescindible para entender la configuración positiva del Derecho moderno caracterizado por «la disciplina constitucional de sus contenidos»⁴⁵³. La vigencia se refiere, nos recuerda Ferrajoli, a la forma de los actos normativos, es decir, «al conjunto de los requisitos empíricos (formalidades, procedimientos, competencias y similares) que hacen de un acto lingüístico preceptivo una decisión jurídica»; por su parte, la validez se refiere «al significado de esos mismos actos, es decir a las normas producidas por ellos»⁴⁵⁴. En el primer caso estamos ante normas formales, referidas a la forma de los actos normativos, mientras que en el segundo estamos en presencia de normas sustanciales, referidas a su significado.

No obstante, creo que se pueden intentar diferenciar al menos dos planos en la posición de Ferrajoli. Por una parte, la diferencia misma entre vigencia y validez y, por otra, la separación entre positividad y validez. Recordemos que, en efecto, Ferrajoli afirma la posibilidad de normas positivas pero inválidas, que es lo mismo que decir normas pertenecientes a un Ordenamiento, pero inválidas. Es evidente que nos hallamos ante un problema de estipulación de significados de conceptos con los que trabaja la Teoría del Derecho, pero eso no exime de

⁴⁵² Vid., LUZZATI, C., «Sulla giustificazione della pena e sui conflitti normativi», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, cit., p. 155.

⁴⁵³ Vid. FERRAJOLI, L., «Note critiche ed autocritiche intorno alla discussione su *Diritto e ragione*», cit., p. 468.

⁴⁵⁴ Vid. FERRAJOLI, L., «Note critiche ed autocritiche intorno alla discussione su *Diritto e ragione*», cit., p. 467.

la responsabilidad de fijar esos significados, sin que ello deba entenderse en el sentido de que se asume una posición esencialista al respecto.

En su oposición al positivismo dogmático, Ferrajoli critica la concepción kelseniana de la validez jurídica, identificándola, junto a la de Bobbio, como el paradigma del positivismo jurídico⁴⁵⁵. Pues bien, la distinción entre los conceptos de vigencia y validez, tal y como los entiende Ferrajoli, demuestra que este autor se aferra a una distinción típicamente kelseniana, como lo es la que diferencia, en lo que al fundamento de validez se refiere, entre sistemas normativos dinámicos y sistemas normativos estáticos. La superación de dicha distinción parece necesaria para entender la connotación del concepto de validez en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos, entre los que se incluyen los de los sistemas constitucionales. Recordemos que los sistemas normativos dinámicos son aquellos en los que la pertenencia de un enunciado al sistema depende de la satisfacción de condiciones formales, reconducibles a un procedimiento en el que se cumplen las exigencias del principio de legalidad. Por el contrario, los sistemas estáticos establecen criterios materiales de pertenencia, identificados con la correspondencia que se establece entre el contenido de un enunciado y el de la norma superior del sistema⁴⁵⁶. Kelsen afirmaba que los Ordenamientos jurídicos eran sistemas dinámicos, mientras

⁴⁵⁵ Es justo señalar, en este punto, que, como ha recordado A. PÉREZ LUÑO, si bien la concepción del Derecho de Kelsen ha sido y el objetivo de críticas por parte del constitucionalismo (y no sólo, añadido, del constitucionalismo), su aportación es imprescindible para entender puntos básicos de éste. Piénsese, por ejemplo, y sin ir más lejos, en la concepción jerárquica del Ordenamiento y en la reconducción de la validez al carácter normativo de la Constitución, o en la idea de control de constitucionalidad. De esta manera, «paradójicamente, sin la sombra tutelar de Hans Kelsen, el más importante iuspositivista de nuestro siglo, determinados presupuestos teóricos y prácticos de la concepción actual del Estado constitucional resultarían inconcebibles», «Estado constitucional y derechos de la tercera generación», cit., p. 563.

⁴⁵⁶ Vid. KELSEN, H., *Teoría Pura del Derecho*, cit., pp. 203 y ss.

que los ordenamientos morales eran un caso de sistemas estáticos. Sin embargo, si queremos explicar cómo se desenvuelven los mecanismos de pertenencia a los sistemas jurídicos, más allá del hecho de que nos encontremos ante un Ordenamiento constitucional o no, la separación kelseniana entre sistemas dinámicos y sistemas estáticos es difícilmente sostenible⁴⁵⁷. Y ello, porque, más allá del sentido que dicha distinción tuviera en el contexto de la teoría pura, los sistemas jurídicos, incluyan los contenidos de los sistemas constitucionales u otros, configuran criterios de pertenencia que comparten y aúnan exigencias o rasgos de los sistemas dinámicos y de los sistemas estáticos. Como se ha señalado en un momento anterior, se ha afirmado en este sentido que, a este respecto, los sistemas jurídicos son sistemas mixtos⁴⁵⁸.

Ferrajoli, que presenta su propuesta en este punto como superadora de la —considerada por él— arcaica concepción kelseniana de la validez jurídica, parece utilizar una distinción que se antoja, a su vez, como imprescindible para comprender la anterior. Desde el momento en que se puede predicar la pertenencia al sistema de normas vigentes, es decir que satisfacen los criterios formales, parece que está proponiendo una concepción dinámica del Ordenamiento jurídico. Si la positividad de una norma puede depender de su vigencia —identificándose

⁴⁵⁷ Sobre la evolución de esta distinción en la obra de Kelsen, vid. GARCÍA AMADO, J. A., *Hans Kelsen y la norma fundamental*, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 17-27. También CUENCA GÓMEZ, P., «Acerca del carácter dinámico del sistema jurídico en la teoría de Kelsen y su compatibilidad con el constitucionalismo», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, n.º 15, 2007, pp. 1-37.

⁴⁵⁸ Vid. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «Positivism jurídico y sistemas mixtos», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*, cit., pp. 601 y ss.; CUENCA GÓMEZ, P., *El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica*, Dykinson, Madrid, 2008; ID. «Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez jurídica», *Anuario de Filosofía del Derecho*, n.º 25, 2008-2009, pp. 207-234. También, PRIETO SANCHÍS, L., *El constitucionalismo de los derechos*, cit., p. 13.

ésta con la satisfacción de requisitos formales— estamos ante una concepción de la primera que la entiende como meramente procedimental. Pero aquí nos encontramos con el problema de que dicha concepción parecería extraña en una concepción del Derecho como la del constitucionalismo, que se caracteriza por subrayar la importancia de los contenidos sustanciales del sistema, alojados básicamente en la norma superior del sistema, y por profundizar en los mecanismos limitadores del Poder, de los que los sistemas de control de constitucionalidad no son sino una manifestación cualificada, dada su trascendencia para la configuración de los contenidos del sistema.

Si la interpretación anterior es correcta, podríamos llegar a la conclusión de que se defienden al mismo tiempo, por parte de Ferrajoli, dos concepciones de la pertenencia al sistema, en función de que nos situemos en un discurso sobre la vigencia o en un discurso sobre la validez. En el primer caso, las condiciones de vigencia se vincularían a las de un sistema dinámico, mientras que en el segundo las condiciones de validez añadirían además las de un sistema estático. En cualquier caso, queda pendiente la cuestión de hasta qué punto los conceptos de vigencia y validez desempeñan la misma función en una teoría de los límites del concepto de Derecho⁴⁵⁹.

2.3.3. *Estado de Derecho y Estado constitucional*

Aunque es cierto que se puede dudar de la utilidad y del interés de discutir sobre la distinción o no entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional⁴⁶⁰, creo que una aproxima-

⁴⁵⁹ Una visión crítica de la distinción de Ferrajoli entre validez y vigencia puede encontrarse en CUENCA GÓMEZ, P., «La compleja teoría de la validez jurídica de Principia Iuris. Una revisión crítica», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, núm. 26, 2012, pp. 57-81.

⁴⁶⁰ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Del mito a la decadencia de la Ley. La Ley en el Estado constitucional», cit., p. 34.

ción a la cuestión puede ser esclarecedora en este trabajo. Respecto a la relación entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional podemos encontrar dos posiciones básicas. Por una parte, la de aquellos que enfocan la relación en términos de ruptura, de manera que cuando hablamos de Estado de Derecho y de Estado constitucional estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Por otra, la de aquellos que señalan que el Estado constitucional se presenta como una manifestación, una prolongación, o incluso un perfeccionamiento del propio Estado de Derecho⁴⁶¹. A lo anterior quizás quepa añadir la posibilidad de identificar posiciones intermedias.

A la hora de analizar la cuestión de las relaciones entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional hemos de ser conscientes de los distintos enfoques que se nos plantean como posibles. En efecto, podemos centrarnos, en primer lugar, en el estudio de las condiciones estructurales de ambos modelos, prestando atención a la cuestión de las semejanzas y diferencias entre los Ordenamientos del Estado de Derecho y del Estado constitucional. En segundo lugar, cabe indagar el concepto de Derecho vinculado a ambos modelos. En este sentido, es relevante analizar la capacidad del constitucionalismo —o neoconstitucionalismo— a la hora de someter a revisión (y en muchos casos a descalificación) afirmaciones básicas del positivismo jurídico, que se nos presenta como la propuesta conceptual en relación con el Derecho vinculada de manera más estrecha al Estado de Derecho. Es cierto que ambas perspectivas están conectadas entre sí. La propuesta conceptual en relación con el Derecho presentada por el constitucionalismo contemporáneo se apoya en los datos suministrados con la configuración efectiva de los sistemas jurídicos constitucionales. Por ello, cualquiera que sea la perspectiva que se asuma,

⁴⁶¹ Me he ocupado de algunos rasgos que permiten afirmar el carácter histórico y evolutivo del Estado constitucional en ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «El Estado constitucional: apuntes para una comprensión de su significado histórico», *Revista de Historiografía*, n.º 9, V, 02/2008, pp. 81 y ss.

conviene tener presentes las conclusiones a las que en su caso se pueda llegar en ambos casos.

No obstante lo anterior, creo que, siendo conscientes de la afinidad de las dos perspectivas a las que acabo de aludir, es posible discriminar y centrarse en alguna de ellas. Mi intención en esta ocasión es la de analizar hasta qué punto las estructuras del Estado constitucional permiten hablar de un modelo claramente diferenciado en relación con el Estado de Derecho. Por lo tanto, me interesa estudiar modelos de Derecho, y no tanto conceptos de Derecho, aunque, reitero, éstos se nos presentan como el resultado de la reflexión intelectual a partir de aquellos. La razón por la que me interesa centrarme en las estructuras viene determinada por el hecho de que en la última parte de la investigación pretendo reflexionar sobre algunos aspectos de las consecuencias institucionales y estructurales que se derivan, en relación con las exigencias de un sistema democrático, del hecho de que dicho sistema asuma, al más alto nivel, una determinada concepción de los derechos.

Entre nosotros, Antonio E. Pérez Luño se ha ocupado, entre otros, de analizar, por una parte, los datos de los ordenamientos jurídicos democráticos actuales en los que se asienta el desarrollo del Estado constitucional y, por otra, los planteamientos teóricos a partir de los cuales se afirma que el Estado Constitucional es en realidad una alternativa al Estado Constitucional y no el resultado de una transformación o prolongación del Estado de Derecho⁴⁶². En efecto, y respecto a la primera dimensión de las aludidas, la de los datos suministrados por los ordenamientos jurídicos, cabría plantearse, antes de señalarlos, hasta qué punto preceden a la reflexión doctrinal no siendo, en realidad, el resultado de ésta. En efecto, si se observan esos datos, bien podríamos afirmar que los defensores de la sustantividad del Estado constitucional respecto al Estado de Derecho en realidad se han limitado, a la hora de caracterizar

⁴⁶² Vid. PÉREZ LUÑO, A., «Estado constitucional y derechos de la tercera generación», cit.

a aquel, a levantar acta de sus rasgos y notas definitorias, desarrollando de esta manera una labor descriptiva y no prescriptiva. En todo caso, y con independencia de lo anterior, observamos —así lo señala Pérez Luño— en los Ordenamientos jurídicos actuales una triple transición (ya referida anteriormente): de la primacía de la ley a la primacía de la Constitución; de la reserva de ley a la reserva de Constitución; del control jurisdiccional de la legalidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad.

La primera transición adquiere sentido en presencia de muchos factores. Así, entre otros factores, de los fenómenos de infraestatalidad y supraestatalidad en cuanto a la producción de normas jurídicas y a integración de determinadas fuentes en el Ordenamiento jurídico. Es evidente que estos fenómenos caracterizan la configuración y el funcionamiento de los Ordenamientos jurídicos democráticos, por lo menos de nuestro entorno. En ocasiones se presentan estos fenómenos como el resultado de la debilidad de la ley: la ley ha perdido su primacía y su posición preferente en el Ordenamiento jurídico y por ello se desarrollan estos fenómenos. Posiblemente la cuestión podría enfocarse desde otra perspectiva: la complejidad de las relaciones sociales y de las estructuras en las que se integran los comportamientos humanos (objetivo último de las normas jurídicas) obliga a un reposicionamiento del lugar y de las características de la ley: en efecto, no todas las leyes son hoy normas generales y abstractas. Por otra parte, la primacía de la Constitución podría también analizarse directamente vinculada al desplazamiento de la ley. Con independencia de la necesidad de adecuación de la ley a las nuevas realidades sociales, no hay que olvidar que la supremacía de la Constitución es en realidad el resultado de la superación de la concepción que la entendía como norma programática, declaración de principios, sin valor vinculante directo, y cuya aplicabilidad exige el posterior desarrollo normativo por parte del legislador. Es evidente que tomarse en serio la Constitución como norma superior del Ordenamiento jurídico, directamente aplicable y vinculante respecto a todos (poderes e individuos) supone afirmar la nece-

sidad de establecer mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad (tercera de las transiciones señaladas por Pérez Luño), y en ese sentido se entiende en nuestro siglo la aportación kelseniana en relación con los mecanismos de control de constitucionalidad.

Por su parte, la segunda de las transiciones antes señaladas (de la reserva de ley a la reserva de constitución) también puede entenderse en directa relación con la complejidad social. La idea según la cual determinadas materias deben ser reguladas exclusivamente a través de un determinado tipo de norma (le ley en este caso) implica que esa norma ocupa una determinada posición en el Ordenamiento jurídico y que los mecanismos de formación de la misma le dotan de una determinada singularidad respecto a otras normas. Hoy, asistimos no sólo a la proliferación de instrumentos normativos indisociables de la actividad y objetivos del Estado social, sino también a la proliferación de leyes-medida, caracterizadas por la concreción y especificidad no sólo de las situaciones reguladas sino también de las propias regulaciones. Nada más alejado de esa norma general y abstracta en la que pensaba Rousseau cuando señalaba su concepto de ley. Ello, además de otros factores podría explicar el hecho de que la consideración de determinadas materias entre las que destacan «los aspectos básicos del *status* jurídicos de los ciudadanos»⁴⁶³, exige la reconducción de la reserva de su regulación a la Constitución o a normas que ocupan una posición cualificada (tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material) en la estructura del ordenamiento jurídico, como las leyes orgánicas, entre nosotros.

Por otra parte, tiene también razón Pérez Luño cuando condensa los planteamientos que defienden la contradicción entre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de la siguiente manera: «1) la pérdida de la función de legitimidad

⁴⁶³ PÉREZ LUÑO, A., «Estado constitucional y derechos de la tercera generación» cit., p. 551.

del Estado de Derecho, al quedar reducido a Estado de mera legalidad; 2) el rechazo del positivismo jurídico en cuanto ideología responsable de la involución del Estado de Derecho y en cuanto teoría incapaz de explicar, de forma adecuada los rasgos básicos de los sistemas jurídicos del presente»⁴⁶⁴.

La primera afirmación insiste en desvincular al Estado de Derecho de la idea de legitimidad. De acuerdo con lo anterior, y en contraposición al Estado constitucional que se caracterizaría por la presencia de contenidos normativos sustanciales «fuertes», el Estado de Derecho sería una estructura exclusivamente formal. Creo que dicha crítica pierde sentido cuando se mantiene, como se hace en estas líneas, una concepción sustancial del Estado de Derecho. Desde ese momento, la desvinculación entre legalidad y legitimidad ya no se puede seguir manteniendo⁴⁶⁵. La presencia en un Ordenamiento jurídico de normas de derechos fundamentales, con rango constitucional, vincula, a la hora de determinar la validez de las normas, los aspectos formales y sustanciales. Es evidente que si se admite la posibilidad de hablar de un concepto estrictamente formal de Estado de Derecho, determinado exclusivamente por la presencia del imperio de la ley, el mismo se puede reducir a mera legalidad (esta es la denuncia que se efectúa frente a la comprensión estrictamente positivista y formalista del Estado de Derecho), pero la otra opción, la de concepción sustancial o material, obliga a dotar de contenido a esa legalidad, contenido que, como poco, va a estar determinado por la presencia de normas de derechos fundamentales en ese ordenamiento jurídico; ello, con independencia del modelo —liberal o social— de Estado de Derecho en el que estemos pensando.

Ello nos permite afirmar que, en realidad, el Estado constitucional no es sino una prolongación, desarrollo o especifica-

⁴⁶⁴ PÉREZ LUÑO, A., «Estado constitucional y derechos de la tercera generación», cit., p. 560.

⁴⁶⁵ Vid. HABERMAS, J., «¿Cómo es posible la legitimidad por vía de la legalidad?», *Doxa*, n.º 5, 1988, pp. 21 y ss.

ción del Estado de Derecho. La opción por un concepto material de Estado de Derecho contribuye en este sentido a difuminar las diferencias entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. En efecto, el Estado constitucional es caracterizado en ocasiones acentuando los rasgos y consecuencias de la positivación de derechos. Por ejemplo, Perfecto Andrés señala como rasgos los siguientes: 1) «la incorporación al Orden jurídico positivo de un cuadro de valores, los conocidos como *derechos fundamentales* del ideario liberal, dotados de garantías formales de cierto grado de eficacia potencial; y también de algunos derechos *sociales*, que cuentan con una protección bastante más débil, desde el momento en que su prestación aparece prácticamente confiada a la discrecionalidad estatal»; 2) «la consagración del principio de legalidad, que implica el imperativo de sumisión de la acción de todas las instancias del poder a la ley general y abstracta, y, consecuentemente, al control judicial de la legalidad de sus actos»; 3) «la funcionalización del ejercicio de todos los poderes a la garantía del disfrute de los derechos del primer orden y a la efectividad de los del segundo»⁴⁶⁶. A la luz de esta caracterización, surge la cuestión sobre las auténticas diferencias entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Los dos aspectos básicos, la vinculación a la ley y el reconocimiento —con las consecuencias derivadas de dicho reconocimiento— del Estado de Derecho se reproducen en el modelo del Estado constitucional.

De lo anterior se podría afirmar que tienen razón aquellos que señalan que, en realidad, asistimos a una transformación del Estado de Derecho, que hoy asumiría la forma del Estado constitucional. No nos podemos detener en este momento a examinar todos y cada uno de los aspectos de dicha transformación. Si tuviéramos que señalar algún elemento a partir del cual se pudiera obtener una consideración global de la situación, posiblemente se podría aludir al hecho —por otra parte

⁴⁶⁶ ANDRÉS IBÁÑEZ, P., «Introducción», en ID. (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Trotta, Madrid, 1996, p.10.

evidente— de que, si bien el Estado de Derecho se caracteriza por el principio de legalidad, el Estado constitucional se vincula al principio de constitucionalidad⁴⁶⁷. Tanto el principio de legalidad como el principio de constitucionalidad implican la idea de control, de límite, de sujeción al Derecho, que es imprescindible en el Estado de Derecho; pero, se podría afirmar, el Derecho en el que se está pensando en cada caso no es el mismo. Si se me permite la comparación, en el Estado de Derecho se piensa exclusivamente en el Derecho de la ley y en el Estado constitucional se piensa en última instancia en el Derecho de la Constitución. En ambos casos la idea de la vinculación al Derecho se mantiene firme. Lo que sí es cierto es que, dadas las características de los textos constitucionales contemporáneos, las consecuencias de esa vinculación son bien específicas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la presencia de principios y valores en las Constituciones con todo lo que eso implica en relación con la necesidad de una determinada argumentación racional y con la reformulación de la actividad judicial. Por lo que afecta a la idea de control, límite, se desarrolla tanto en el Estado de Derecho como en el Estado constitucional. En todo caso, podríamos afirmar que existen problemas que se plantean de forma específica en el Estado constitucional. Podemos pensar, por ejemplo, en la tensión que se produce entre derechos y Constitución, de un lado, y democracia, de otro. En efecto, en el Estado constitucional, en el que la actividad del legislativo debe desarrollarse en el marco de lo establecido por la Constitución, los contenidos de la Norma superior del Ordenamiento constituyen un límite infranqueable, incluso frente a las decisiones del Poder legislativo. Esta tensión en realidad es la que se produce entre determinados contenidos, los derechos que aparecen en la Constitución, y las decisiones, que, de acuerdo con la regla de las mayorías (criterio básico en democracia), se toman en el legislativo. Ello nos sitúa frente a

⁴⁶⁷ Vid. GARCÍA PELAYO, M., «Estado legal y estado constitucional de Derecho», cit., pp. 3028 y ss.

problemas, en los que no nos podemos detener aquí, como son, por ejemplo el de los límites de la deliberación política en democracia, el del origen y criterios de identificación de esos contenidos inalterables, entre otros. En todo caso, sí cabe subrayar aquí que este problema se plantea básicamente en el Estado constitucional, en el que el imperio de la ley toma forma de principio de constitucionalidad que vincula a todos los poderes, incluido aquel que antes había constituido la sede en la que se adoptaban las decisiones últimas: el Poder legislativo.

Pues bien, a continuación intentaré identificar aportaciones representativas respecto al tipo de relación que se puede predicar entre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional. Aludiré en primer lugar a los planteamientos negadores de la continuidad entre ambos modelos, dejando para después aquellas propuestas que, desde diferentes perspectivas, reconocen la relación en términos de continuidad.

En relación con los planteamientos negadores de la continuidad entre ambos modelos creo que sobresale la propuesta de Gustavo Zagrebelsky⁴⁶⁸. Procede, por tanto analizar la propuesta de comprensión del Estado constitucional que nos presenta el Catedrático de Turín. De lo que se trata es, en su opinión, de explorar las razones del «cambio genético» que presenta el Estado constitucional frente al Estado de Derecho, a partir de la prevención ante la tentación denunciada por Zagrebelsky consistente en considerar que el Estado constitucional no es sino una «versión particular» del Estado de Derecho: «...es aconsejable no dejarse seducir por la continuidad histórica e intentar, por el contrario, poner en claro las diferencias»⁴⁶⁹.

⁴⁶⁸ Vid. ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit.. La obra de Zagrebelsky ha dado lugar a interesantes debates, entre los cuales se puede destacar el publicado en el volumen XIII del *Anuario de Filosofía del Derecho*, con trabajos de M. Gascón, E. Alberti, P. Andrés, R. Blanco Valdés, J. A. García Amado, A. García Figueroa, R. Guastini, L. Prieto y A. Ruiz Miguel.

⁴⁶⁹ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 22.

Zagrebelsky identifica el Estado de Derecho, como superador del «Estado de fuerza» (*Machtstaat*) y del Estado de Policía (*Polizeistaat*), y lo vincula con un valor en concreto, como es la eliminación de la arbitrariedad. Es la consolidación del Estado de Derecho la que permite la afirmación de la primacía de ley (*lex facit regem*) sobre el Poder (*rex facit legem*). No obstante, recuerda Zagrebelsky, en un inicio, el Estado de Derecho se nos presenta como una estructura formal no vinculada a contenidos, abriéndose así la posibilidad de su utilización desde perspectivas no necesariamente vecinas a sus presupuestos originariamente liberales, consistentes en «el condicionamiento de la autoridad del Estado a la libertad de la sociedad, en el marco del equilibrio recíproco establecido por la ley»⁴⁷⁰.

El Estado de Derecho está vinculado en su significado al principio de legalidad, que descansa sobre una determinada concepción de la ley definida a partir de las notas de generalidad y abstracción. La ley se presenta como la pieza principal de un sistema jurídico que, en ausencia de una norma constitucional que ejerza la supremacía normativa de forma consistente, posibilita el desarrollo del programa político liberal-burgués. La idea de código resume en sí y refleja los rasgos de la ley: «la voluntad positiva del legislador, capaz de imponerse indiferenciadamente en todo el territorio del Estado y que se enderezaba a la realización de un proyecto político basado en la razón (la razón de la burguesía liberal, asumida como punto de partida); el carácter deductivo del desarrollo de las normas, *ex principiis derivationes*; la generalidad y la abstracción, la sistematicidad y la plenitud»⁴⁷¹.

Pues bien, en contraste con este modelo, el Estado constitucional se presenta para Zagrebelsky como el resultado de una transformación, a través de la que se expresa un auténtico ‘cambio genético’, que pivota sobre el cambio que afecta a la posición que ocupa la ley en el Ordenamiento. La primacía

⁴⁷⁰ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 23.

⁴⁷¹ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 32.

normativa ya no se presenta como un predicado de la ley, que ha dejado de ocupar de manera efectiva el vértice de la estructura normativa, lugar en el que ahora se asienta la Constitución. Es a partir de ese momento cuando a la ley se le exige conformidad y adecuación con la Constitución. La nueva localización de la ley en el seno del Ordenamiento va acompañada por una reformulación de sus características y rasgos distintivos. Por una parte, se predica una crisis del principio de legalidad a partir de la incapacidad que muestra la ley a la hora de regular por entero la actividad administrativa, que tiene su manifestación más acusada en el desarrollo de los aspectos interventores, promocionales, y de planificación. Por otra, y conectado con lo anterior, la ley pierde progresivamente sus rasgos de generalidad y abstracción, pudiendo asistir a una «pulverización del derecho legislativo»⁴⁷². Como consecuencia de todo ello, señala Zagrebelsky, la comprensión unitaria del Ordenamiento se presenta ciertamente como problemática. Esa era una comprensión operativa en referencia a una sociedad como la liberal-burguesa que se caracterizaba por la unificación de sus intereses y de sus dimensiones valorativas y axiológicas, y no por una dispersión de las mismas. La concepción del Derecho del siglo xix, sobre la que se asentó el modelo del Estado de Derecho, es incapaz de asumir el reto que le presenta la regulación de las sociedades contemporáneas, que se caracterizan por su complejidad estructural. El recurso a la Constitución se muestra, por tanto, como imprescindible. Es ella la que va a dotar de unidad al sistema jurídico. Como señala Zagrebelsky, «la ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de mediación. Es destronada a favor de una instancia más alta. Y esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras divididas en su interior y concurrenciales. Una función inexistente en otro

⁴⁷² ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 37.

tiempo, cuando la sociedad política estaba, y se presuponía que era en sí misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el principio de constitucionalidad es el que debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad»⁴⁷³. Estamos ante una unificación de rasgos ciertamente difusos, ya que la intención de Zagrebelsky no es la de referirse a una mera sustitución de la ley por la Constitución. En complicada compatibilidad con la idea anterior, concluye que «lo que se viene operando en éste [en el Estado constitucional] no es en absoluto una unificación, sino una serie de divisiones, cuya composición en unidad no puede proponerse en los términos lineales con que en el pasado se realizaba la coherencia del ordenamiento bajo la ley»⁴⁷⁴.

Aunque la opción metodológica que se ha asumido en esta investigación no aconseja afrontar en este momento con profundidad la cuestión de las consecuencias teóricas que el constitucionalismo en general, y Zagrebelsky en particular, extraen de la configuración del Ordenamiento en el Estado constitucional, sí cabe recordar aquí que se defiende una reformulación de la comprensión del Derecho defendida por el positivismo jurídico. En este caso, el positivismo se identifica en términos generales con el positivismo decimonónico, y se considera un «residuo histórico» cuya supervivencia sólo se explica por la fuerza de la tradición que impide a los juristas desprenderse de una inercia mental que los vincula a una concepción caduca del Derecho. Esta concepción es caduca porque, se afirma, es incapaz de afrontar intelectualmente con consistencia los rasgos del Derecho del constitucionalismo, como son la independencia de los derechos respecto a la ley, la separación entre las exigencias de la justicia y la ley, y una configuración del Derecho en la que los principios pasan a ocupar una posición desconocida hasta ahora que obliga a reformular no sólo el significado de la labor de los jueces (los señores del Derecho), sino

⁴⁷³ ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*, cit., p. 40.

⁴⁷⁴ *Ibidem*.

también la posición del legislador⁴⁷⁵. Pero como ha señalado, en mi opinión con razón, Riccardo Guastini, una cosa es la descripción del Estado constitucional que Zagrebelsky, que es acertada, y otra cosa son los argumentos que de ella se pueden derivar en contra del positivismo jurídico⁴⁷⁶. Y ello porque, entre otras cosas y de manera breve, si una de las tesis principales del positivismo jurídico es aquella según la cual las normas jurídicas son el resultado de actos a través de los cuales se expresan voluntades humanas, no se entiende muy bien por qué se vincula esta tesis a una necesaria identificación entre el Derecho y la ley, entendida ésta como una norma específica del Parlamento. Dicha vinculación incurre en una concepción restringida, históricamente particular y por tanto deformada, del Derecho y desconoce que tan acto de voluntad es la ley que dicta el Parlamento como la Constitución. Si esto es así, no se

⁴⁷⁵ Un análisis crítico al respecto es el de G. PECES-BARBA, «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», pp. 157 y ss. Me he ocupado anteriormente de este tema en «¿Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli» *Derechos y Libertades*, n.º 2, 1993-1994, pp. 113 y ss.

Como es sabido, una de las principales tesis defendidas por Zagrebelsky en su libro es precisamente aquella que subraya la importancia de la función desempeñada por los nuevos «señores del Derecho», los jueces, en la tarea de integración de las dimensiones de la ley, los derechos y la justicia, en el Estado constitucional. Aunque es justo reconocer que precisamente al final de su obra matiza su posición: «Podemos, por tanto, corregir la afirmación con que comenzábamos este epígrafe. Hoy, ciertamente, los jueces tienen una gran responsabilidad en la vida del derecho desconocida en los ordenamientos del Estado de derecho legislativo. Pero los jueces no son los señores del derecho en el mismo sentido en que lo era el legislador en el pasado siglo. Son más exactamente los garantes de la complejidad estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir, los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia. Es más, podríamos afirmar como conclusión que entre Estado constitucional y cualquier «señor del derecho» hay una radical incompatibilidad. El derecho no es un objeto propiedad de uno, sino que debe ser objeto del cuidado de todos» (p. 153).

⁴⁷⁶ Vid. GUASTINI, R., «Derecho dúctil, Derecho incierto», trad. de M. Gascón, *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996-97, pp. 112-113.

comprende hasta qué punto el positivismo, que va mucho más allá de la identificación del Derecho con la ley, puede ser puesto en entredicho por el Estado constitucional. A partir de esta tesis, el positivismo propone la separación entre el Derecho y la moral. Por tanto, no sería un problema para él la separación entre la justicia y la ley, ya que nunca —con excepción de las posiciones extremas del positivismo ideológico, que coinciden en sus conclusiones con el iusnaturalismo— ha afirmado que existiera una vinculación necesaria entre ambos.

Por otra parte existen planteamientos que si bien no afirman la ruptura radical, plantean una evolución a partir de la cual es posible llegar a la conclusión de que estamos ante dos modelos diferentes. Así, Ferrajoli distingue dos significados de «Estado de Derecho»⁴⁷⁷. Por una parte, un sentido débil o formal según el cual el Estado de Derecho se identifica con aquel sistema en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercidos en la forma y a través de los procedimientos establecidos en ésta. Por otra, un sentido fuerte o sustancial según el cual en el Estado de Derecho los poderes públicos están también sometidos a los contenidos establecidos en las normas constitucionales. Ferrajoli utiliza esta distinción para afirmar la tesis según la cual los anteriores significados se corresponden con dos diferentes modelos normativos de Derecho. En el primer caso, hace referencia al modelo *paleoiuspositivista del Estado legislativo de Derecho*; en el segundo, al modelo *neoiuspositivista del Estado constitucional de Derecho*⁴⁷⁸. Para Ferra-

⁴⁷⁷ Vid. FERRAJOLI, L., «Lo Stato di diritto fra passato e futuro», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, p. 349. También ID., *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, cit., pp. 29 y ss.

⁴⁷⁸ De acuerdo con lo anterior, parecería correcta la interpretación según la cual Ferrajoli vincula el Estado de Derecho en sentido débil al Estado legislativo de Derecho, y el Estado de Derecho en sentido fuerte o sustancial al Estado constitucional. Por eso llama la atención el hecho de que Ferrajoli, de manera explícita (Vid. «Lo Stato di diritto fra passato e futuro», cit., n. 2, p. 377) afirme que Estado de Derecho en sentido fuerte y Estado constitucional no son sinónimos. Para Ferrajoli, tanto el principio de estricta legalidad

joli, si bien el Estado legislativo de Derecho supuso una importante transformación de las estructuras del Derecho premoderno, el Estado constitucional, a partir de las consecuencias derivadas de la rigidez constitucional, presenta un nuevo paradigma que supone «el Estado de Derecho y el positivismo jurídico en su forma extrema y más completa»⁴⁷⁹.

En relación con las posiciones que defienden la continuidad o, al menos, la inexistencia de una ruptura, podemos observar planteamientos ciertamente maximalistas, como el de Danilo Zolo cuando subraya la superfluidad semántica del término ‘Estado constitucional’, a no ser que se entienda «en el sentido muy general de ‘Estado provisto de Constitución’, y por tanto dotado de un ordenamiento, escrito o consuetudinario, aprobado o compartido por la mayoría de los ciudadanos, que define los principios generales y diseña las instituciones fundamentales de la comunidad política»⁴⁸⁰. Creo que de la misma manera que existen razones para desestimar la tesis de la ruptura radical entre Estado de Derecho y Estado constitucional, tampoco se debe caer en la posición opuesta consistente en afirmar que, en modo alguno, existan diferencias. Pero esas diferencias no son sustantivas. El Estado constitucional se caracteriza por el hecho de que los criterios de validez establecidos por la norma básica se encuentran en sede constitucional. A partir de ahí, el Estado constitucional «no es una superación del Estado de

como el Estado de Derecho en sentido fuerte suponen el sometimiento de la ley a principios normativos como las libertades fundamentales y la separación de poderes. Pero Ferrajoli subraya el hecho de que dicho sometimiento puede ser de hecho y no de derecho, desde el momento en que existen países en los que se produce incluso en ausencia de una constitución escrita, como es el caso de Inglaterra. Por tanto, en última instancia, para Ferrajoli lo que definirá al Estado constitucional será la presencia de mecanismos de rigidez constitucional a partir de la presencia de una constitución escrita, otorgando de esta manera al carácter constitucional-formal de los límites impuestos al legislador, frente al carácter constitucional-material de dichos límites.

⁴⁷⁹ FERRAJOLI, L., «Lo Stato di diritto fra passato e futuro», cit., p. 357.

⁴⁸⁰ ZOLO, D., «Teoria e critica dello Stato di diritto», cit., p. 86, n. 129.

Derecho, sino su etapa superior. Un Estado de Derecho, hoy, no se concibe sin Constitución»⁴⁸¹. Es precisamente la Constitución la que supone un límite al legislador, y por lo tanto al Poder, en una —importante— de sus diferentes dimensiones normativas. Sabemos que son diferentes las formas en las que la Constitución puede suponer un límite a la actividad legislativa⁴⁸². Recordemos que la Constitución puede imponer límites formales o materiales a la legislación. En el primer caso, la Constitución impone criterios que regulan los procedimientos a través de los cuales se forma la ley, mientras que en el segundo caso, las normas constitucionales vinculan el contenido de la ley. Si en el primer caso se le imponen al legislador determinados procedimientos, en el segundo se le imponen restricciones en cuanto al contenido⁴⁸³.

La profundización en la dimensión limitativa del Poder es la que permite considerar que el Estado constitucional es la «superación positiva y enriquecedora» del Estado de Derecho y no su negación⁴⁸⁴; es un modelo perfeccionado de Estado de Derecho: «...el mejor Estado de Derecho es y ha tendido a ser Estado constitucional de Derecho»⁴⁸⁵. En ese sentido, «El Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización, pues si la esencia del Esta-

⁴⁸¹ G. PECES-BARBA, «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», cit., p. 167.

⁴⁸² Vid. GUASTINI, R., «La constitución como límite a la actividad legislativa», trad. de A. Greppi, *Derechos y Libertades*, 8, 2000, pp. 241 y ss.

⁴⁸³ Ahora bien, esas restricciones pueden tener distintos sentidos en función del contenido del mandato constitucional. En efecto, las restricciones pueden tener un sentido negativo (por ej., las exigidas por el respeto de los derechos-autonomía) o positivo (como las derivadas de la materialización de las exigencias de los derechos de prestación Vid. al respecto, ASÍS ROIG, R. de, *Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al Poder*, Dykinson, Madrid, 2000.

⁴⁸⁴ PRIETO SANCHÍS, L., «El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? A propósito de «El Derecho dúctil» de Gustavo Zagrebelsky», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996, p. 126.

⁴⁸⁵ DÍAZ, E., *Curso de Filosofía del Derecho*, cit., p. 110.

do de Derecho es el sometimiento del poder al Derecho, sólo cuando existe una verdadera Constitución ese sometimiento comprende también al legislativo. Y esto en sí mismo no es ninguna novedad»⁴⁸⁶. En otros términos: «el constitucionalismo no es sino una continuación de la idea de imperio de la ley llevada hasta la Constitución misma»⁴⁸⁷.

De todas maneras, hay que ser consciente que hablar de perfección del Estado constitucional respecto al Estado de Derecho implica asumir la imperfección de éste. Conviene llamar la atención sobre este punto. Es el propio Elías Díaz el que ha denunciado la «extremosa contraposición doctrinal que de modo esencialista (¿iusnaturalista?) quiere establecerse entre un casi perverso Estado legislativo de Derecho y un casi perfecto Estado constitucional de Derecho. En esta perspectiva con frecuencia se tiende a degradar, casi a demonizar, al primero como producto espurio de los políticos y de las vulgares mayorías mientras que se deifica y ensalza al segundo como resultado excelso de la obra hermeneútica de sabios juristas y expertos minoritarios»⁴⁸⁸. Pues bien, si de perfecciones o

⁴⁸⁶ PRIETO SANCHÍS, L., «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», cit., p. 129.

⁴⁸⁷ LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 221.

⁴⁸⁸ DÍAZ, E., «Estado de Derecho y legitimidad democrática», cit., p. 86. Elías DÍAZ ha retomado este tema últimamente en *El derecho y el poder. Realismo crítico y filosofía del derecho*, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 71 y ss. Creo que este es un punto de vista compartido por Francisco Laporta, al criticar la excesiva «condescendencia» de algunos autores respecto a «ciertos ingredientes que se estiman novedosos de los órdenes jurídicos presididos por una Constitución» (LAPORTA, F. J., «Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y Francisco Laporta», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, Iustel, n.º 0, octubre 2008, p. 48). A partir de ahí se recuerda que las decisiones judiciales deben reconducirse siempre a la ley, se reivindica una reinención de la ley y se propone, en definitiva, un modelo que puede resumirse de la siguiente manera: «...el núcleo más importante y decisivo del Ordenamiento jurídico debe estar integrado por un cuerpo coherente de leyes generales y abstractas a las que se ha de tributar una deferencia privilegiada, y que frente a esa exageración tan de moda de adscribirle todas las tareas normativas a la

imperfecciones hablamos, debemos recordar que la perfección que pudiera significar en la actualidad el Estado constitucional frente al Estado de Derecho es similar a la que en su día supuso éste frente al modelo del Estado legal, de acuerdo con la caracterización de los mismos propuesta por Carré de Malberg. En efecto, el Estado de Derecho (*État de droit*) supone, respecto al Estado legal (*État legal*) un perfeccionamiento de las garantías individuales y de los mecanismos de limitación al Poder al menos desde dos puntos de vista. Por una parte, el Estado de Derecho se entiende destinado a asegurar las libertades y derechos de los sujetos. El interés del Estado legal es otro: la subordinación de la autoridad administrativa al Poder legislativo. Por otra parte, el Estado de Derecho implica no sólo la dependencia de la acción normativa de la Administración respecto a la ley, sino que a la vez subordina la ley a las normas constitucionales⁴⁸⁹. No nos podemos detener en este momento en esta cuestión. Baste señalar que frente a aquellos que denuncian las insuficiencias del Estado de Derecho frente al Estado constitucional en materia de garantías y de limitación del Poder, se puede afirmar el pleno protagonismo del Estado de Derecho en esta tarea. El Estado de Derecho, así, sienta las bases sobre las que posteriormente transcurre el Estado constitucional: sin el primero es inconcebible el segundo.

En definitiva, asistimos a una «reubicación del principio de legalidad» que se produce en el seno del Estado constitucional

Constitución y a sus innumerables intérpretes, y de reclamar su presencia en todos y cada uno de los pequeños y grandes conflictos que se suscitan cotidianamente, es preciso hoy volver a reafirmar la confianza en el legislador y a plantearse con seriedad los términos de su reconstrucción y presencia. El mensaje para la reflexión sería, pues, este: menos neoconstitucionalismo y más neocodificación» (LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 167).

⁴⁸⁹ Vid. CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, cit., pp. 451 y ss.; REDOR, M.-J., *De l'Etat legal a l'Etat de droit. L'Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française 1879-1914*, cit.,; LAQUIÈZE, A., «*État de droit et sovranità nazionale in Francia*», cit., pp. 288-301.

y que lo diferencia del Estado de Derecho⁴⁹⁰; en otras palabras, estamos en presencia de un «redimensionamiento del principio de legalidad» en el que el recurso a un nivel de juridicidad superior al de la ley asegura la garantía de valores y contenidos axiológicos frente a las decisiones políticas ordinarias⁴⁹¹. La alteración en la posición de la ley supone su desaparición del vértice absoluto de la jerarquía de las fuentes y en su subordinación a la Constitución. Esta es una novedad importante del Estado constitucional respecto al Estado de Derecho⁴⁹², de la que derivan, en cascada, el resto de rasgos de éste, entre los que destaca una reformulación del principio de separación de poderes⁴⁹³. De lo que se trata es de una profundización en la idea de limitación y garantía asumida por el constitucionalismo, que se presenta aquí como heredero de los postulados del Estado de Derecho. Asistimos a una ampliación de los ámbitos del imperio de la ley, del que ya no escapan decisiones del poder político. La idea de imperio de la ley (en el sentido restringido al que se acaba de aludir) se ve superada por la de imperio de la Constitución, norma vinculante y obligatoria.

La afirmación del imperio de la Constitución y del Estado constitucional no transforma en lo básico el sentido de las exigencias del Estado de Derecho material o sustancial, a no ser que se afirme que aludir a la profundización de las estrategias de limitación del Poder, que ahora afectan de lleno al Parlamento y a la ley, supone hablar de algo radicalmente diferente en su sentido a la idea de limitación del Poder consustancial al

⁴⁹⁰ Vid. MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades multiculturales*, Tecnos, Madrid, 2001, pp. 149 y ss.

⁴⁹¹ Vid. PEÑA FREIRE, A. M., *La garantía en el Estado constitucional de Derecho*, cit., pp. 57-58.

⁴⁹² Vid. GARCÍA PELAYO, M., «Estado legal y Estado constitucional de Derecho», cit., pp. 3029 y ss.; vid. también FARALLI, C., «Stato», en BARBERÀ, A., (ed). *Le basi filosofiche del Costituzionalismo*, Laterza, Roma, 1998, p. 188.

⁴⁹³ Vid. al respecto GARCÍA PASCUAL, C., *Legitimidad democrática y Poder judicial*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1996, pp. 121 y ss.

propósito del Estado de Derecho. La vinculación a los contenidos constitucionales se impone a los poderes del Estado. Esta profundización afecta a lo que podríamos considerar el equilibrio clásico que hasta ahora se había mantenido entre los poderes, desde el momento en que asistimos a un desarrollo de los mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad.

Por último, creo que la materialización del Derecho implícita en el Estado constitucional es en realidad un dato que, conscientes de las consecuencias derivadas de la reubicación del principio de legalidad y su transformación en principio de constitucionalidad, es ya constatable en el Derecho del Estado de Derecho material o sustancial, tal y como se entiende el mismo a lo largo de este trabajo. Recordemos que aquí se ha efectuado una propuesta consistente en la identificación del Estado de Derecho a partir de dos elementos básicos: el imperio de la ley y la dimensión sustancial del Derecho. En este sentido, el Derecho del Estado de Derecho es ya la expresión de una materialización, expresada a través de la opción axiológica asumida⁴⁹⁴. Lo que variaría, en su caso, es la sede última de esa opción, con las consecuencias que de ello se derivan a partir de la afirmación del principio de constitucionalidad, que no es sino la afirmación contemporánea, en el marco de los Ordenamientos jurídicos democráticos, del imperio de la ley entendido

⁴⁹⁴ De manera que la dimensión liberadora del constitucionalismo ya se encontraría en el Estado de Derecho: «... si la idealidad del Estado de Derecho, la del Estado liberal, la del Estado democrático y la del Estado social se consideran componentes agregados del constitucionalismo, es fácil darse cuenta que el sentido de los mismos es centralmente erradicar los males característicos (y probados) de las dominaciones políticas: la arbitrariedad, el autoritarismo, la exclusión política y la exclusión social», AGUILÓ REGLA, J., «Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional», cit., p. 291. Desde este punto de vista, la «rematerialización» del Derecho que se produce en el constitucionalismo no sería una exclusiva aportación de éste. La aportación del constitucionalismo consistiría en la ubicación de determinadas materias más allá de la disposición del legislador (vid. PRIETO SANCHÍS, L. «Sobre el neoconstitucionalismo y sus implicaciones», cit., pp. 113-114).

como imperio del Derecho. En definitiva, el Estado constitucional no supondría una superación, sino más bien una profundización en la tensión que caracteriza la arquitectura del Estado de Derecho, la tensión entre Derecho y política que, ahora, adquiere perfiles nuevos y que se presenta en forma de «contraposición entre ley e interpretación, entre *voluntad* política y *razón* técnica, entre legitimación a través de la representación y legitimación a través de la argumentación, entre la política que establece el derecho y el derecho que limita la política»⁴⁹⁵.

⁴⁹⁵ BIN, R., *Lo Stato di diritto*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 58.

IV. LAS RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES

1. SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL

Como se ha señalado al principio de este trabajo, si nos propusiéramos la tarea de identificar problemas o cuestiones que, con una u otra apariencia, reaparecen constantemente en la reflexión iusfilosófica a lo largo del tiempo, podríamos señalar, entre otras, la de la tensión entre razón y voluntad, no sólo en lo que se refiere al origen del Derecho, sino también en lo que atañe a los mecanismos de interpretación y aplicación del mismo. En efecto, el tradicional contraste entre el iusnaturalismo y el positivismo puede ser analizado a la luz de dicha tensión. También, algunas cuestiones que han centrado el interés de la Teoría del Derecho durante los últimos tiempos, como por ejemplo la distinción entre reglas y principios, o el desarrollo de las teorías de la argumentación jurídica, son analizables en clave de tensión razón-voluntad.

Creo que el constitucionalismo contemporáneo, o el neo-constitucionalismo, constituye un óptimo escenario en el que, ciertamente de manera renovada y con otros matices, reaparece la tensión entre razón y voluntad, tensión que se reproduce en la relación entre el Derecho y el Poder. La razón es la de la Constitución y los derechos, la de los contenidos sustantivos

protegidos a través de su inclusión en el texto constitucional. La voluntad es la de las mayorías que toman decisiones en el marco de un sistema democrático. La tensión es la que se produce en este caso entre una razón para la que las decisiones mayoritarias significan un potencial peligro, y una voluntad mayoritaria que puede verse limitada en sus posibilidades por las «razones constitucionales».

La posición privilegiada y prevalente de las Constituciones en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos parece, a estas alturas, una conquista consolidada. En efecto, ya se han superado aquellas épocas —identificadas con las del Estado *legislativo* de Derecho— en las que el texto constitucional era entendido como una mera declaración de principios, sin carácter vinculante y directamente imperativo, respecto a la cual, por tanto, el legislador tenía las manos libres gozando de un amplio margen de independencia. Por el contrario, hoy la Constitución es la norma superior del sistema jurídico que, a partir de la aplicación del principio de jerarquía normativa, se caracteriza por ser directamente aplicable y vinculante respecto a todos. En ocasiones, los propios textos constitucionales reflejan bien esta idea. Podemos recordar el enunciado del artículo 9.1 de la Constitución española de 1978: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico.»

Esta posición específica de la Constitución respecto al resto de normas del sistema viene garantizada a través de diferentes mecanismos. Pensemos, por ejemplo, en la presencia de procedimientos, más o menos exigentes y agravados, de reforma constitucional, cuya función es regular de manera específica la reforma del texto constitucional, marcando así las diferencias entre las posibilidades de transformación de dicho texto y las del resto de normas del Ordenamiento. Podemos hacer referencia, así, a la existencia de salvaguardas absolutas, a la exigencia de mayorías o quorums cualificados, a los mecanismos de demora, a la necesidad de ratificación por parte de los Estados en el caso de los sistemas federales, o a la obligatoria ratifica-

ción por la vía del referendium⁴⁹⁶. Estos son algunos de los mecanismos que contribuyen a dotar a la Constitución de rigidez⁴⁹⁷. Otra de las estrategias que aseguran la específica posición de la Constitución es la existencia y actuación de específicos órganos que ejercen una función consistente en controlar la constitucionalidad de las normas inferiores. La existencia de esos órganos, que pueden o no insertarse orgánicamente en el seno del Poder judicial, parece una exigencia obvia de la primacía y superioridad constitucional; en efecto, de nada serviría afirmar dichos rasgos y al tiempo no establecer mecanismos que fiscalizaran la adecuación a la Constitución por parte de las normas inferiores, empezando por la ley. Por otra parte, la rigidez constitucional puede venir determinada por la existencia de cláusulas de intangibilidad, esto es, por la inclusión en el texto constitucional de contenidos que se presentan como inmodificables. Piénsese, por ejemplo, en el artículo 139 de la Constitución italiana de 1947 («La forma republicana no podrá ser objeto de revisión constitucional»), en el artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 («Es inadmisibile toda modificación de la presente Ley fundamental que afecte a la división de la Federación en Estados o al principio de la cooperación de los Estados en la legislación o a los principios consignados en los artículos 1º y 20»)⁴⁹⁸, o en el art. 290 de la Consti-

⁴⁹⁶ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, trad. de J. Mundó, Gedisa, Barcelona, 2002, pp. 124 y ss. Vid. también LAPORTA, F. J., «El ámbito de la Constitución», *Doxa*, n.º 24, 2001, pp. 465 y ss.

⁴⁹⁷ Uno de los estudios clásicos al respecto es el de James BRYCE, *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, en donde se caracterizan las Constituciones rígidas como aquellas «que poseen una autoridad superior a la de las otras leyes del Estado y son modificadas por procedimientos diferentes a aquellos por los que se dictan y revocan las demás leyes», p. 94.

⁴⁹⁸ Artículo 1: «1) La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. 2) El pueblo alemán se identifica, por tanto, con los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mun-

tución portuguesa de 1976, que establece una amplia lista de aspectos sobre los que la revisión constitucional está limitada⁴⁹⁹.

do. 3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a título de derecho directamente aplicable».

Artículo 20: «La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social. 2) Todo poder público emana del pueblo. Ese poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por medio de órganos particulares de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 3) El poder legislativo está sometido al ordenamiento constitucional; los poderes ejecutivo y judicial a la ley y al derecho, 3) Contra cualquiera que intente derribar ese orden todos los alemanes tienen el derecho a la resistencia cuando no fuera posible otro recurso».

Una posición crítica respecto a las cláusulas de intangibilidad como la del art. 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn es la de E. W. BÖCKENFORDE, cuando considera que «no son un reflejo de la libertad democrática, sino más bien una limitación sustantiva de ésta, en tanto se sitúan más allá de las condiciones constitutivas de la formación democrática de la voluntad. Tienen como objetivo impedir una «revolución legal», esto es, una transformación que destruye por medios legales los fundamentos del orden político y jurídico, y por eso pretenden vincular jurídicamente también a las generaciones futuras. Son en realidad un signo de que una comunidad política —en este caso la del pueblo alemán después de 1918 y, especialmente, después de la perversión del ordenamiento estatal en la época de 1933-1945— *ha perdido la confianza en sí misma*», «La democracia como principio constitucional», ID., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, cit., p. 81. *Cursivas nuestras*.

⁴⁹⁹ Art. 290: «De los límites materiales de la revisión. Las leyes de revisión constitucional tendrán que respetar: a) la independencia nacional y la unidad del Estado; b) la forma republicana de gobierno; c) la separación de las Iglesias y el Estado; d) los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; e) los derechos de los trabajadores, de las comisiones de trabajadores y de las asociaciones sindicales; f) la coexistencia del sector público, del sector privado y del sector cooperativo y social de propiedad de los medios de producción; g) la existencia de planes económicos en el ámbito de una economía mixta; h) el sufragio universal, directo, secreto y periódico en la designación de los titulares electivos de los órganos de soberanía, de las regiones autónomas y del poder local, así como el sistema de representación proporcional; i) el pluralismo de expresión y organización política, incluyendo los partidos políticos, y el derecho a la oposición democrática; j) la separación e interdependencia de los órganos de soberanía; l) el control de la constitucionalidad por acción o por omisión de normas jurídicas; m) la independencia de los Tribunales; n) la autonomía de las entidades locales; o) la autonomía político-administrativa de los archipiélagos de las Azores y las Madeira»

Debe tenerse en cuenta también que la justificación de los mecanismos de rigidez constitucional posiblemente no es la misma en función de las partes de la Constitución en las que estemos pensando. En relación con la regulación de la estructura de órganos y procedimientos constitucionales, existen razones a favor de una deseable estabilidad. Sin embargo, en lo que se refiere a la regulación de derechos, podemos encontrar razones a favor de la inmutabilidad en el reconocimiento de los mismos, junto a razones que justifiquen la posibilidad de modificación por parte de mayorías que están en desacuerdo con la regulación constitucional de los derechos. En estos casos, la rigidez constitucional puede parecer insuficiente a unos, y excesiva a otros⁵⁰⁰. Junto a esto, cabe añadir que en realidad la opinión que se tenga respecto a la rigidez constitucional puede estar en función de la intensidad de su implementación, ya que la rigidez constitucional es una cuestión de grado. En este sentido, depende de factores jurídico-formales, como el número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe producirse y concurrir para proceder a la reforma constitucional, el tipo de mayorías exigidas para la reforma, y la necesidad de intervención o no por parte del pueblo⁵⁰¹.

Los mecanismos que aseguran la rigidez constitucional pueden ser en realidad instrumentos muy útiles para cumplir la función básica que el constitucionalismo atribuye a la Constitución: la de control y límite del Poder. En efecto, la vigencia de una Constitución supone la imposición de límites y controles frente al Poder. Así, la Constitución tiene una función de asegurar las libertades y los derechos de los individuos. Esto nos permite comprender, recordémoslo, que el concepto de

⁵⁰⁰ Vid. FERRERES COMELLA, V., «Una defensa de la rigidez Constitucional», *Doxa*, n.º 23, 2000, p. 29.

⁵⁰¹ Vid. FERRERES COMELLA, V., «Una defensa de la rigidez Constitucional», cit., pp. 30-31. Como señala Ferreres, estos requisitos jurídico-formales adquieren su sentido en un contexto más amplio, determinado por los rasgos del sistema de partidos, la historia del país, y la existencia de tradiciones conservadoras o progresistas en ese país (op. cit., pp. 32-33).

Constitución manejado por el constitucionalismo contemporáneo es estrecho o restringido en el sentido en que no se puede afirmar que todo texto que ocupe una posición superior en la jerarquía de las fuentes sea, *per se*, una Constitución de acuerdo con el discurso constitucionalista. Para ello, es necesario identificar ciertos contenidos (derechos) y funciones (control, límite del Poder). Evidentemente, este concepto de Constitución es heredero del sentido del ya citado artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El concepto restringido de Constitución es en buena medida paralelo al concepto restringido y material de Estado de Derecho: no todo Estado es Estado de Derecho; para poder hablar de Estado de Derecho, dotando al término de sustantividad, es necesario identificar determinados elementos, que en líneas básicas se reconducen a la idea de imperio de la ley y a la de reconocimiento y garantía de derechos.

Pues bien, podemos plantearnos alguna de las consecuencias que se derivan de la presencia de contenidos garantizados de manera rígida en las Constituciones. Esta presencia está vinculada al concepto material de Estado de Derecho. Como se podrá observar, dicha presencia plantea problemas que vuelven a demostrar, una vez más, que las cuestiones de Filosofía del Derecho, de Filosofía moral y de Filosofía política no forman compartimentos estancos y desvinculados entre sí.

Formulando la cuestión de manera esquemática, podemos adoptar como tesis de partida la idea de que el constitucionalismo, con la función atribuida a la Constitución, tiene dimensiones que pueden entrar en conflicto con exigencias y mecanismos de la democracia. En efecto, desde el momento en que en un texto constitucional se excluyen de las posibilidades de reforma determinados aspectos del mismo, se está tomando una decisión de amplia trascendencia jurídica y política, ya que se está produciendo una exclusión, en relación con determinadas materias, del principal protagonista en lo que se refiere a las decisiones políticas en democracia: la ciudadanía. En el marco de un sistema democrático, la garantía de determinados derechos puede requerir una delimitación del ámbito de lo

decible por las mayorías, situando determinadas cuestiones en lo que Bobbio ha considerado el ámbito de lo no opinable o no negociable y Ferrajoli ha denominado el ámbito de lo indecible. De manera que, para evitar la tiranía de las mayorías se emprenden estrategias que pueden limitar la regla básica de adopción de decisiones colectivas en democracia, esto es la regla de las mayorías. La construcción de ámbitos de lo indecible que, como veremos, se lleva a cabo en contextos intersubjetivos cotidianos, tiene una especial trascendencia en su aplicación a los sistemas democráticos, debido, básicamente, al deseable carácter deliberativo de los mismos. En efecto, el sistema democrático, es cierto, es el sistema de la regla de las mayorías, pero también es el sistema de la deliberación, de la discusión y del contraste. Son estos ámbitos los de la política, y a través de estas estrategias se tiende a dotar de racionalidad a las decisiones resultantes. La exclusión de cuestiones de la discusión supondría, en definitiva, una restricción del ámbito de lo político; en resumidas cuentas, una reducción del ámbito y de las posibilidades de la democracia⁵⁰², que se resume, en palabras de Gustavo Zagrebelsky, de esta manera: «La Constitución —en pocas palabras— es aquello sobre lo que no se vota; o mejor, en referencia a las constituciones democráticas, es aquello sobre lo que no se vota más, porque ya se ha votado una vez por todas, al principio»⁵⁰³.

Estamos situados, por tanto, en el ámbito de las objeciones democráticas al constitucionalismo. Podemos señalar al respecto varias objeciones, aunque aquí nos centraremos exclusivamente en una de ellas. Por una parte, el constitucionalismo

⁵⁰² P. P. PORTINARO alude a la evolución en sentido antidemocrático del constitucionalismo desde el momento en que se sustrae a los ciudadanos organizados políticamente el poder de redefinir extensivamente las reglas del juego social en «Dal custode della Costituzione alla Costituzione dei custodi», en GOZZI, G., (ed.), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 433.

⁵⁰³ ZAGREBELSKY, G., *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Einaudi, Torino, 2005, p. 22.

plantea el problema de la justificación de los mecanismos de control de constitucionalidad. La primacía constitucional, sin la cual es incomprensible el constitucionalismo, exige de manera necesaria la creación y el funcionamiento de mecanismos de fiscalización de la acción normativa de las autoridades, comenzando por el propio legislador. Esos mecanismos se reconducen a instituciones (como el Tribunal constitucional) que en muchas ocasiones forman parte orgánica del Poder judicial. Es evidente que en este contexto se presentan relevantes problemas de legitimidad de esas instituciones y de su actividad controladora de la producción normativa del legislador democrático⁵⁰⁴. Se habla en estos casos, de acuerdo con Alexander Bickel, de «objeción contramayoritaria»⁵⁰⁵, desde el momento en que estamos en presencia de un órgano judicial —normalmente— que tiene la capacidad de imponer su parecer a la institución más directamente vinculada al principio de las mayorías, como es el parlamento democrático⁵⁰⁶. Por otra parte, el constitucionalismo plantea el problema de los límites de la deliberación, de las limitaciones de los ámbitos materiales en los que es posible la decisión del legislador democrático. En esos

⁵⁰⁴ Las claves históricas de comprensión de la justicia constitucional, en perspectiva filosófico-jurídica, han sido planteadas por G. PECES-BARBA, en «Notas sobre la justicia constitucional desde la Filosofía del Derecho», *Cuadernos de Derecho Público*, 14, 2002, pp. 9 y ss.

⁵⁰⁵ Vid. BICKEL, A., *The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar of Politics*, Yale University Press, New Haven, 1962: «la dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema (...) cuando la Corte Suprema establece como inconstitucional una ley o una acción de un Ejecutivo elegido, tuerce la voluntad de los representantes populares aquí y ahora(...). El control judicial pertenece en su totalidad a un ámbito diferente a la democracia, y es esa la razón de que pueda formular la acusación de que el control judicial es antidemocrático» (pp. 16 y ss. Traducción del autor).

⁵⁰⁶ Vid., entre muchos otros, GARGARELLA, R., *La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial*, Ariel, Barcelona, 1996; FERRERES COMELLA, V., *Justicia constitucional y democracia*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.

casos podemos hablar de «objeción democrática en sentido estricto». Propongo que a continuación nos centremos en esta segunda objeción. No obstante, parece adecuado reconocer que los problemas a los que se refieren ambas objeciones están estrechamente vinculados. En efecto, la primacía constitucional, de la que se derivan restricciones a la producción normativa del legislador vinculada al principio de las mayorías, implica la existencia de mecanismos de control de constitucionalidad⁵⁰⁷. Ciertamente, las cuestiones a las que se refieren las dos objeciones están ordenadas lógicamente, ya que de lo que se trata en un caso es de determinar las razones del sometimiento de la legislación a la Constitución protectora de derechos, mientras que en otro caso se plantea el papel que debe desempeñar el Poder judicial a la hora de articular la garantía de esos derechos. En este sentido, la primera cuestión, que es en la que aquí nos centramos, es previa desde el punto de vista lógico a la segunda. En todo caso, asumimos que las críticas a la rigidez constitucional deben ser diferenciadas de aquellas otras dirigidas a la supremacía de la Constitución, que justifica la existencia de los mecanismos de justicia constitucional⁵⁰⁸.

⁵⁰⁷ En este punto nos podemos encontrar con un problema en relación con los términos que utilizamos y que debemos aclarar. Desde el momento en que los problemas a los que hacen alusión las referidas objeciones están vinculados, se ha propuesto incluirlas a todas genéricamente dentro de la «objeción contramayoritaria» (vid. BAYÓN, J. C., «Derechos, democracia, Constitución», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., p. 214). No obstante, como la intención en este momento no es la de profundizar en la fundamentación del control de constitucionalidad, diferenciaremos entre la objeción democrática en sentido estricto y la objeción contramayoritaria.

⁵⁰⁸ La necesidad de esta distinción ha sido subrayada por Luis Prieto: «Si hay buenas y numerosas razones en favor de la Constitución, es más, si la existencia de un norma parece consustancial a cualquier ejercicio democrático genuino, entonces el argumento democrático no milita en contra de su existencia, en contra de la existencia de normas superiores que regulen y limiten el poder de los órganos del Estado, sino en contra de la existencia de normas inmodificables por la mayoría» Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Constitución y democracia» en ID., *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, cit., p. 154.

Así, estaríamos *en principio* ante una tensión entre Constitución y democracia, que se puede manifestar, en otros términos, en la tensión entre derechos y regla de las mayorías⁵⁰⁹. Moreso ha identificado el problema al afirmar que «en realidad, la democracia representativa, entendida como un método de decisión mediante el voto de la mayoría, está en contradicción con la idea de primacía de la constitución, entendida como restricción al conjunto de decisiones que pueden tomarse por mayoría»⁵¹⁰. Se ha señalado al respecto que «representación y principio mayoritario, de un lado y derechos del otro no pueden más que mirarse con recíproca sospecha»⁵¹¹. Un planteamiento rápido de la cuestión, puede provocar cierta perplejidad: en efecto, todos estamos convencidos de que existen ciertos contenidos, derechos, valores, consustanciales a la democracia, imprescindibles para que ésta se realice, y sin los cuales, el sistema de referencia no parecería ser democrático; en otras palabras, podemos tener intuiciones sobre la deseabilidad de no reformular constantemente determinadas cuestiones, que de alguna manera deberían gozar de un cierto blindaje. Pero al mismo tiempo, sabemos también que lo anterior supone una restricción a la capacidad, característica de los sistemas democráticos, que tienen los destinatarios de las normas, la ciudadanía, de intervenir en la formación de las decisiones sobre las cuestiones que les afectan, contribuyendo de esta manera a cualificar, en la mayor medida de lo posible, esas

⁵⁰⁹ Tensión identificable con la que se puede producir entre la *legitimación por mayorías* y la *legitimación por libertades*, vid., LAPORTA, F. J., «Norma básica, constitución y decisión por mayorías», *Revista de las Cortes Generales*, n.º 1, 1984, p. 50.

⁵¹⁰ MORESO, J. J., *La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 165.

⁵¹¹ LA TORRE, M., «Discutiendo de democracia. Representación política y derechos fundamentales», trad. de F. J. Ansuátegui, *Derechos y Libertades*, n.º 3, 1994, p. 256. Vid. MACCORMICK, N., «Constitucionalismo y democracia», *Anuario de Derechos Humanos*, 5, 1988-89, pp. 367 y ss.

decisiones como autónomas⁵¹². Los sistemas jurídicos democráticos son, en este sentido, menos heterónomos que los no democráticos. Y esa restricción a la capacidad de autonormación, puede terminar, en definitiva, limitando operatividad al principio de las mayorías. En definitiva, la cuestión que estoy proponiendo es la que ha planteado Ernesto Vidal: con el constitucionalismo y con la imposición de límites a las decisiones por mayorías, «¿no se estaría tutelando mediante un catálogo de verdades inatacables, la autonomía individual, el pluralismo y el relativismo, que constituyen el fundamento de la decisión democrática?»⁵¹³.

En todo caso, somos conscientes de que esta restricción se produce en los sistemas democráticos. Es un dato insoslayable que cualquier análisis de los sistemas jurídicos democráticos debe tener en cuenta. Desde este punto de vista, se produce también una disminución de la capacidad creadora del Poder político respecto a las normas jurídicas, de manera que se ve afectada la misma idea de soberanía —hoy puesta en entredicho y sometida a revisión⁵¹⁴—, vinculada al monopolio de la creación de normas jurídicas por parte del Poder estatal. Sabido es que la idea de soberanía es uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción del Estado moderno, y además también es una de las ideas básicas de las primeras propuestas positivistas. La negación de la posibilidad que pueda tener el

⁵¹² Creo que J. HABERMAS condensa bien la cuestión cuando escribe: «... en cuanto se conciben [los derechos] como ingredientes del derecho positivo, salta a la vista que no le pueden ser encasquetados al legislador soberano, por así decir, en términos paternalistas. Pues los destinatarios del Derecho no podrían entenderse simultáneamente a sí mismos como autores de él si el legislador se limitara a encontrar ahí los derechos del hombre como hechos morales, respecto a los que no pudiera hacer otra cosa que positivizarlos. Por otra parte, el legislador, pese a su autonomía, no debe poder decidir nada que vulnere los derechos del hombre», *Facticidad y validez*, cit., p. 653.

⁵¹³ VIDAL GIL, E., «Justificación de la democracia y límites a la decisión por mayorías», *Doxa*, 15-16, 1994, p. 235.

⁵¹⁴ Vid. FERRAJOLI, L., *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale*, Laterza, Roma, 1997.

Poder político, a través de mecanismos democráticos, de regular determinadas cuestiones, pudiera aproximar algunas dimensiones del constitucionalismo a aquella propuesta iusnaturalista según la cual existen regulaciones, que en última instancia se reconducen al ámbito de lo éticamente correcto, que escapan de las manos del legislador. A esta cuestión me referiré posteriormente. También analizaré —evidentemente, sólo en lo que afecta a nuestro tema— el problema de las autorrestricciones aplicadas a la conducta humana, ya que parece claro que la decisión que puede tomar una determinada comunidad que, al dictar una Constitución, excluye ciertas cuestiones de la agenda política, es un caso de autorrestricción. El análisis de esa restricción en relación con aquello que se puede, o no, discutir y luego decidir, de acuerdo con las cláusulas constitucionales, tiene que ser necesariamente distinto cuando los afectados por la restricción ya no son aquellos que han tomado la decisión, sino los integrantes de otra generación, posterior en el tiempo, a la que se impone esa restricción. Parece evidente también que en este punto aparecen nuevos problemas referidos a la justificación o no de la imposición de la restricción, y que nos sitúan, en mi opinión, ante el problema del paternalismo. Concluiré exponiendo una perspectiva que pretende explicar la contradicción entre constitucionalismo y democracia en términos de tensión consustancial a las democracias constitucionales.

Como se observará, en esta parte del trabajo parto de la conexión básica entre democracia y regla de las mayorías, ya señalada anteriormente. No obstante, reconozco que dicha conexión debe establecerse con las necesarias cautelas, en la medida en que la democracia incluye, junto a las reglas de las mayorías —que funciona como procedimiento básico en la adopción de decisiones colectivas—, otros elementos imprescindibles, entre los que se encuentran de manera esencial los derechos de los individuos. En efecto, sin derechos de participación para todos no hay democracia, por mucho que el criterio seguido en la toma de decisiones sea el de la regla de las mayorías. Kelsen y Bobbio se han referido a esta cuestión. Así,

Kelsen escribe: «...debe considerarse la participación en el gobierno, es decir, en la creación y en la aplicación de las normas generales e individuales del ordenamiento social que constituyen la comunidad como la característica esencial de la democracia»⁵¹⁵. Por su parte, Bobbio ha señalado con razón que lo que caracteriza a la democracia es ser el gobierno *de la mayoría* antes que ser el gobierno *mediante el principio de la mayoría*: el sufragio universal constituiría, antes que la regla de las mayorías, el rasgo distintivo de la democracia⁵¹⁶. Por lo tanto, si bien es cierto que se puede mantener la conexión entre democracia y regla de las mayorías, hay que tener en cuenta que ésta no es un mecanismo exclusivo de los sistemas democráticos, de la misma manera que tampoco lo es que en los sistemas democráticos la regla de las mayorías sea el único criterio que se utiliza en la toma de decisiones colectivas⁵¹⁷. Lo anterior no impide considerar, por una parte, la relevancia del principio de las mayorías para un correcto funcionamiento del sistema democrático y, por otra, que uno de los problemas que plantea el constitucionalismo en relación con la democracia vienen determinados, precisamente, por las restricciones a las que se someten a las mayorías en cuanto a los contenidos de sus decisiones.

Es evidente que el planteamiento de la relación entre constitucionalismo y democracia que aquí se asume no es el único posible. Pero en todo caso me parece un estadio preliminar de una reflexión —que tendrá que ser desarrollada en otro lugar— encaminada a superar una concepción de la democracia apoyada únicamente en la regla de las mayorías, y a justificar las virtudes de la democracia deliberativa que complementen la

⁵¹⁵ KELSEN, H., «Los fundamentos de la democracia», cit., p. 210.

⁵¹⁶ Vid. BOBBIO, N., «La regola di maggioranza: limiti e aporie», recogido en ID., *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp. 393 y ss. Vid. también LA TORRE, M., «Discutiendo de democracia. Representación política y derechos fundamentales», cit., pp. 238-239.

⁵¹⁷ Vid. BOBBIO, N., «La regola di maggioranza: limiti e aporie», cit., p. 383.

operatividad del criterio de las mayorías —irrenunciable en democracia— con la aportación de la deliberación colectiva como mecanismo de selección de preferencias⁵¹⁸. De manera que la presente reflexión puede ser interpretada como un intento de demostrar la necesidad del estudio de un modelo de democracia deliberativa que complemente y supere en sus exigencias argumentativas a la democracia mayoritaria; y también, como un intento de justificar la necesidad de comprender la Constitución de un modo no estático, ésto es, no delimitada y diseñada de una vez por todas⁵¹⁹.

En todo caso, y antes de continuar, es necesario tener bien presentes dos puntos que necesariamente obligan a que el aná-

⁵¹⁸ La bibliografía en materia de democracia deliberativa es amplia. No obstante, y lógicamente de manera no exhaustiva, podemos señalar las siguientes referencias: BOHMAN, J., REHG, W., (eds.), *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, Massachusetts Institute of Technology, 1997; ELSTER, J., (comp.), *La democracia deliberativa*, trad. de J. M. Lebrón, Gedisa, Barcelona, 2001; FISHKIN, J., *Democracia y deliberación: nuevas perspectivas para la reforma democrática*, trad. de J. Malem, Ariel, Barcelona, 1995; FREEMAN, S., «Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment», *Philosophy and Public Affairs*, 29/4, 2000, pp. 371 y ss.; HABERMAS, J., RAWLS, J., *Debate sobre el liberalismo político*, intr. de F. Vallespín, trad. de G. Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1998; HONGJU KOH, H., SLYE, R. C., (eds.), *Deliberative Democracy and Human Rights*, Yale University Press, 1999; RAWLS, J., *El derecho de gentes y «Una revisión de la idea de razón pública»*, trad. de H. Valencia, Paidós, Barcelona, 2001; MARTÍ, J. L., *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Marcial Pons, Madrid, 2006.

⁵¹⁹ «El carácter de fundaciones de constitución que a menudo confirman y sellan el éxito de las revoluciones políticas, sugiere la engañosa imagen que las Constituciones así nacidas proceden de un limitarse a consignar, a hacer constar normas estáticas, sustraídas al tiempo y resistentes al cambio histórico. La primacía que, desde la perspectiva de la técnica jurídica, tiene la Constitución sobre las leyes simples, pertenece a la sistemática de los principios del Estado de derecho; pero esa primacía sólo significa una fijación *relativa* del contenido de las normas constitucionales. (...) toda Constitución es un proyecto que sólo puede cobrar *consistencia* en el modo de una interpretación constitucional sostenida, impulsada continuamente hacia delante en todos los planos de la producción de normas», HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 195.

lisis de estos temas sea prudente. Como ha recordado Cass Sunstein en primer lugar, tanto el concepto de democracia como el de constitucionalismo se pueden entender de diversas maneras y pueden desempeñar funciones diferentes⁵²⁰; en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, las dificultades para analizar la relación entre constitucionalismo y democracia en abstracto son importantes. La tensión, que puede parecer evidente, cuando la cuestión se plantea en abstracto, puede desvanecerse si se analizan, por ejemplo, las restricciones constitucionales en un sistema concreto y se observan los dispositivos institucionales instaurados para proteger a las minorías. No obstante, y aún siendo consciente de que el constitucionalismo constituye un campo propicio para la difuminación de las fronteras entre la Filosofía y la Teoría del Derecho, de un lado, y la dogmática constitucional, de otro, creo que la perspectiva propia de la Filosofía del Derecho implica una cierta dosis de abstracción en el planteamiento de estas cuestiones, lo cual facilita la aproximación a las mismas.

2. IUSNATURALISMO Y CONSTITUCIONALISMO

Frente a la dispersión e indefinición de los centros de producción normativa que caracterizó a la situación premoderna, la construcción del Estado moderno, que corre paralela a la del Derecho moderno, tuvo como uno de sus puntos básicos la idea de soberanía, que implicaba, entre otras cosas, el monopolio de

⁵²⁰ Vid. SUNSTEIN, C., «Constituciones y democracias: epílogo», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*, estudio introductorio de A. Herrera, trad. de M. Utrilla de Neira, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 344 y ss. En relación con el concepto de democracia, no descubrimos nada si reconocemos que se pueden manejar conceptos más o menos complejos. Vid al respecto, M. BOVERO, *Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores*, trad. de L. Córdova Vianello, Trotta, Madrid, 2002, en especial el punto 2: «Los adjetivos de la democracia», pp. 37 y ss.

la producción jurídica por parte del Estado, de manera que, en el marco de un determinado territorio —aquel sobre el que la nueva forma de organización del Poder político ejercía su dominio— el único centro de producción normativa era el constituido por la autoridad estatal o por aquellas autoridades a las que se hubiera atribuido capacidad de producción a través de mecanismos de reconocimiento o delegación. La idea de soberanía, junto al monopolio de la producción de moneda o al no reconocimiento de autoridad superior en el marco de las relaciones externas, implica también la libertad del Poder político a la hora de dotar de contenidos a las normas jurídicas. Concebido el Derecho como un instrumento de dominio, que se materializa a través de una propuesta de ordenación de las conductas humanas en sociedad, el Poder estatal tiene la capacidad de llevar a cabo dicha ordenación desvinculado ya de las ataduras al Derecho natural. Eso supone afirmar que, al menos en teoría y desde una perspectiva maximalista, los condicionantes sustanciales a la hora de producir normas jurídicas vienen determinados por las condiciones de posibilidad/imposibilidad de las conductas exigidas. Pero más allá de esto, y contemplando siempre la eventualidad de normas jurídicas inmorales o injustas, el Poder estatal es autónomo en lo que a la creación de normas jurídicas se refiere. Es evidente que el positivismo jurídico, al menos en alguna de sus primeras propuestas, es heredero de esta construcción, desde el momento en que identifica el Derecho con los mandatos del soberano y que reclama la independencia de esos mandatos respecto a las ataduras de un sistema normativo supra-positivo. Como es sabido, la propuesta de John Austin constituye un buen ejemplo al respecto.

Pues bien, ¿en qué sentido se puede identificar una deriva o tentación iusnaturalista en el constitucionalismo contemporáneo? El iusnaturalismo se puede caracterizar por las tesis que defiende y también por los efectos de esas tesis. C. S. Nino ha afirmado que, en resumidas cuentas, el iusnaturalismo puede caracterizarse señalando que afirma dos tesis principales: «a) Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios

morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. b) Una tesis acerca de la definición del concepto de Derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de «jurídicos» si contradicen aquellos principios morales o de justicia»⁵²¹. Si asumimos las dos tesis de Nino, de la segunda tesis, de la que señala la necesidad de una adecuación entre los contenidos del Derecho positivo y los del Derecho natural para que aquel pueda ser considerado como Derecho válido, se deriva la restricción del ámbito de los contenidos del Derecho positivo. Es decir, aunque el Poder quisiera mandar o prohibir determinadas cosas mediante normas, debería respetar determinados límites, los del Derecho natural, si quiere que esas normas sean auténticas normas jurídicas. En este esquema observamos en definitiva una restricción del ámbito de maniobrabilidad del Poder político a la hora de dictar normas. Téngase en cuenta que las restricciones de las que hablamos no sólo afectan al Poder constituido (lo cual es lógico en un sistema jurídico jerarquizado en el que rige el imperio de la ley) sino que también se predicán del Poder constituyente, ya que los sistemas de Constituciones rígidas no sólo implican mecanismos de control de constitucionalidad, sino también limitaciones a las posibilidades de reforma constitucional. Pues bien, no tanto la restricción de los contenidos, cuanto la imperativa vinculación del Poder político a unos contenidos, que incluso se sitúan fuera de la influencia de las decisiones de las mayorías, es lo que constituye el rasgo que permitiría identificar una tentación iusnaturalista en algunas dimensiones del constitucionalismo contemporáneo⁵²². Creo que Anna Pintore ha expresado este problema cuando se ha

⁵²¹ NINO, C. S., *Introducción al análisis del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1987, p. 28. Vid también, FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «El iusnaturalismo», en GARZÓN VALDÉS, E., LAPORTA, F. J., (eds.), *El Derecho y la Justicia*, Trotta-CSIC-BOE, Madrid, 1996, pp. 55 y ss.

⁵²² Vid. CATANIA, A., «Diritto naturale e diritto positivo nella tradizione occidentale. Costituzione e diritti umani», *Ragion Pratica*, 1998/11, pp. 123 y ss.

preguntado por la justificación de los contenidos constitucionales, que básicamente asumen la forma de derechos, que prevalecen no sólo sobre el juego político democrático, en el que la regla de las mayorías desempeña, al menos hasta ahora, un papel imprescindible, sino sobre el Poder constituyente: «Estos derechos inatacables por considerarse inscritos en el mismo contrato social constitucional acaban por asemejarse irresistiblemente a los del viejo Derecho natural»⁵²³.

Conviene subrayar algo que se acaba de señalar. La deriva iusnaturalista no viene determinada por la inclusión de contenidos morales en las Constituciones, que por tanto vinculan al legislador, sino por la exclusión de esos contenidos del ámbito de discusión de la política y específicamente del ámbito de la discusión política que tiene lugar a la hora de plantear o emprender una reforma constitucional. Sólo así se puede entender en sus justos términos el sentido y consecuencias de la positivación del Derecho natural a la que alude Luigi Ferrajoli y la vinculación entre criterios de legitimación externa e interna⁵²⁴, a la que nos hemos referido anteriormente. Otra cosa es que, además de positivizar esos contenidos, se afirme que sobre esos contenidos no se puede discutir o transaccionar.

No obstante, la seguida aquí es una de las posibles estrategias a la hora de mostrar los vínculos entre el iusnaturalismo y el constitucionalismo. Caben otras posibilidades de análisis. En este sentido, Troper ha señalado la existencia de un vínculo lógico entre constitucionalismo e iusnaturalismo. En otros términos, está planteando el problema al que Nino identificaba como «el teorema fundamental de la Filosofía del Derecho», ya aludido también en este trabajo. En efecto, el problema que le plantea al positivismo en relación con la Constitución es el de la fundamentación de su carácter obligatorio. Como sabemos, la estrategia kelseniana consiste precisamente en admitir la

⁵²³ PINTORE, A., «Democracia sin derechos. En torno al Kelsen democrático», *Doxa*, n.º 23, 2000, p. 143.

⁵²⁴ Vid. FERRAJOLI, L., *Derecho y razón*, cit., pp. 535 y ss.

hipótesis de que la Constitución es obligatoria. Por el contrario, la solución que el constitucionalismo ofrece a esta cuestión lo vincula —señala Troper— al iusnaturalismo. Para el constitucionalismo, la voluntad que se expresa mediante la Constitución no se caracteriza por ser histórica o contextual; por el contrario, se caracteriza por estar orientada hacia un determinado fin. Es esta orientación finalista la que reconduce la obligatoriedad de la Constitución al Derecho natural. La voluntad que está detrás de la Constitución «pretende realizar un fin justo, justo por naturaleza: la libertad política, y se esfuerza en lograrlo a través de la estructura misma del Poder, a través de sus principios constitutivos, separación de poderes, o gobierno representativo, es decir, en definitiva, a través de su propia naturaleza. La respuesta del constitucionalismo es, por tanto, sencilla: la Constitución se impone en virtud de su naturaleza; el fundamento de su carácter obligatorio es el derecho natural»⁵²⁵.

Para mostrar algunos ejemplos de la deriva iusnaturalista del constitucionalismo, aludiré expresamente a algunas aportaciones, pudiéndose constatar que en algunos casos, si se me permite la expresión, se ha cedido frente a la tentación. Comencemos por Nicola Matteucci, que en los años sesenta entabla un debate con Bobbio que en muchos extremos se adelanta a la discusión actual. En 1963 publicó un artículo, «Positivismo giuridico e costituzionalismo»⁵²⁶, en el que, en el marco de un

⁵²⁵ TROPER, M., «El concepto de constitucionalismo y la moderna teoría del Derecho», cit., p. 186.

⁵²⁶ MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, anno XVII, n.º 3, 1963. Bobbio responderá a Matteucci en una carta que ha sido publicada en MARGIOTTA, C., «Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci», *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, a. XXX, n. 2, dicembre 2000, pp. 387 y ss. A la posición de Bobbio se ha referido recientemente S. POZZOLO en «Un constitucionalismo ambiguo», en CARBONELL, M. (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, cit., pp. 207-210.

análisis de aspectos relevantes de la obra de Norberto Bobbio, analizaba la idea —que por otra parte constituye un referente del constitucionalismo—, según la cual la Constitución debe significar un límite jurídico del Poder legislativo: «El constitucionalismo —señala Matteucci— en la medida en que afirma la exigencia de convertir en superiores e inmodificables las normas fundamentales, no hace más que retomar un motivo propio de la tradición iusnaturalista, aquel para el que la ley no es la simple expresión de una voluntad soberana, sino que debe fundarse sobre principios de razón comunes a todos los hombres»⁵²⁷. La instauración de ese límite jurídico del Poder legislativo, solo es posible «en la medida en que se vean encarnados en la Constitución los grandes principios ético-políticos de nuestra civilización, principios que la razón puede descubrir o que cada uno puede sentir espontáneamente y que ciertamente la fuerza no puede crear e imponer»⁵²⁸. Tengo la impresión de que aquí se vinculan aspectos cuya relación no tiene carácter necesario, ya que una cosa es la positivación de principios ético-políticos, y otra cosa es que esa positivación sea el resultado necesario de un cognoscitivismo objetivista o de un subjetivismo. Lo cual no impide reconocer que entre los méritos históricos reconocidos al iusnaturalismo figura el de haber establecido pautas de racionalidad y legitimidad al Derecho y al Poder político a partir de la inclusión en el sistema jurídicos de los derechos naturales como resultado del proceso de subjetivización del Derecho natural. Para Matteucci esos principios, «valores jurídicos existentes porque pertenecen a toda una tradición de civilización, que escapan al monopolio del legislador»⁵²⁹ logran, a través de su positivación, crear un mar-

⁵²⁷ MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», cit., p. 1047.

⁵²⁸ MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», cit., p. 1042.

⁵²⁹ MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», cit., p. 1094.

co de seguridad más allá del sometimiento al Poder político y de los vaivenes de sus decisiones⁵³⁰. En este sentido, el constitucionalismo supondría el retorno a la exigencia medieval *lex supra regem*, desde el momento en que la norma constitucional, en su contenido, representa un *prius* respecto al Poder⁵³¹. En definitiva, concluye Matteucci, «el derecho natural es el único antídoto frente al dogma de la omnipotencia del legislador»⁵³².

También Luigi Ferrajoli se ha planteado la cuestión que nos ocupa, subrayando la naturaleza pacticia de las constituciones en los sistemas democráticos, en las que los derechos, que configuran el ámbito de lo *indecidible*, preceden a la democracia misma. Ese carácter precedente justifica, así lo señala Ferrajoli, la existencia de límites a los que se somete el poder de revisión de la Constitución (piénsese en el art. 139 de la Constitución italiana). En efecto, junto a los límites implícitos y relativos, existen límites explícitos y absolutos que nos permiten remontarnos al artículo 16 de la Declaración de 1789. Esos límites se presentan como insuperables por parte del Poder político, de manera que forman parte de un criterio *metajurídico*⁵³³. La existencia de esos límites insuperables y la afirmación de su naturaleza metajurídica permite plantear hasta qué punto Ferrajoli, que se presenta como un crítico de lo que él ha denominado en repetidas ocasiones el modelo paleopositivista no es, en realidad, un crítico del positivismo en sentido más amplio.

En tercer lugar, quiero referirme a la idea del «coto vedado» desarrollada por Ernesto Garzón Valdés. En el marco de la

⁵³⁰ Precisamente, una de las críticas que BOBBIO dirige al Derecho natural es la que le acusa de ser incapaz de alcanzar los objetivos que el Derecho positivo está llamado, y capacitado, a asegurar, como la certeza y la seguridad, Vid, «Algunos argumentos contra el Derecho Natural», cit., pp. 219 y ss.

⁵³¹ Vid. MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», cit., pp. 1047-48.

⁵³² MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», cit., p. 1098.

⁵³³ FERRAJOLI, L., «Democrazia e costituzione», cit., p. 330.

reflexión sobre la justificación ética de la representación en democracia, el profesor argentino se pregunta hasta qué punto puede ser sometido a discusión parlamentaria todo tipo de cuestiones. En este sentido afirma que existen buenas razones para excluir determinados temas, referidos a los bienes básicos o primarios de una sociedad, del ámbito de la negociación parlamentaria. La justificación moral de la protección de esos bienes es algo que no depende del consenso. Y además, esas razones son razones morales fuertes: la exclusión está «eticamente impuesta»⁵³⁴. De lo que se trata, entonces, es de identificar los criterios operativos a la hora de incluir/excluir determinadas cuestiones del ámbito de negociación, lo cual es especialmente importante, habida cuenta de que Garzón considera que el mero acuerdo sobre determinados contenidos no es relevante desde el punto de vista moral, sino desde el momento en que esos contenidos escapan al consenso fáctico de los sujetos. Así, Garzón ofrece algunos criterios: a) En primer lugar, los bienes que son considerados «básicos para la realización de todo plan de vida» se excluyen del ámbito de la negociación; b) en segundo lugar, la delimitación de ese ámbito es algo que no puede depender del consenso fáctico al que en su caso pudieran llegar representantes y representados, desde el momento en que un consenso fáctico sólo sirve para identificar la moral positiva vinculada a una cierta comunidad en un momento concreto. Por el contrario, la identificación de esos bienes básicos para la realización de todo plan de vida es una cuestión de moral crítica o esclarecida, cuya fundamentación no puede depender de acuerdos coyunturales; c) en tercer lugar, y de alguna manera conectado con lo anterior, la vigencia y operatividad de los derechos que forman parte del coto vedado no está en función de los deseos y preferencias de los individuos que integran la

⁵³⁴ GARZÓN VALDÉS, E., «Representación y democracia», *Doxa*, n.º 6, 1989, p. 156. Sobre el coto vedado vid. también ID., «Instituciones suicidas», *Isegoría*, n.º 9, 1994, pp. 115-116 e ID., *Consenso, legitimidad y democracia*, Fontamara, México, 2013, pp. 33 y ss.

comunidad. El sujeto que no valore esos bienes y no acepte la garantía de esos derechos actuará irracionalmente, contra sus propios intereses, y puede ser incluido en la categoría de los incompetentes básicos, respecto de los cuales la adopción de medidas paternalistas se encontraría justificada desde el punto de vista ético⁵³⁵; d) en cuarto lugar, se señala que respecto a aquellos que defiendan los bienes básicos incluidos en el coto vedado, no rige el «principio de no dictadura», según el cual «no existe ningún individuo cuyas preferencias son automáticamente las preferencias de la sociedad, independientemente de las preferencias de todos los otros»⁵³⁶; e) en quinto lugar, el coto vedado tiene una tendencia expansiva que no es sino reflejo de la tendencia expansiva de la ética. Dicha tendencia dependería tanto de factores cognitivos como materiales; f) en sexto lugar, podemos preguntarnos hasta qué punto queda relegada u oscurecida la actividad de los representantes en relación con los contenidos del coto vedado. En principio, tendríamos buenas razones para sospechar, a la vista de lo anterior, que los representantes no tienen nada que decir o acordar en relación con esos bienes, ya que están excluidos de la negociación y el ámbito de trabajo de los representantes es precisamente el de la negociación. En todo caso, los representantes pueden negociar sobre los deseos secundarios, aquellos deseos de los individuos que no interfieren en la materialización de los bienes primarios. Así como en referencia a los bienes primarios se suspendía la vigencia del principio de no dictadura, en relación con los deseos secundarios, señala Garzón, se deben atender las preferencias de los sujetos. Pero no en todos los casos. En aquellos casos en los que la satisfacción de un deseo secunda-

⁵³⁵ Vid. GARZÓN VALDÉS, E., «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, ID., *Derecho, ética y política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 361 y ss.

⁵³⁶ Garzón toma el principio de ARROW, K. J., «Values and Collective Decision-Making», en LASLETT, P., RUCIMAN, W. G., (eds.), *Philosophy, Politics and Society*, Third Series, Oxford, 1967, p. 226.

rio ponga en peligro la consecución de un bien básico debería aplicarse una cláusula cautelar según la cual «deberán satisfacerse los deseos secundarios de los representados siempre que, sobre la base de la información de que dispone el representante, su satisfacción no implique el sacrificio de algún bien básico o la frustración de deseos secundarios que los propios representados valoran más que el deseo secundario de cuya satisfacción se trata»⁵³⁷.

La propuesta de Ernesto Garzón plantea cuestiones importantes. Muchas de ellas se pueden resumir en el argumento de acuerdo con el cual, la determinación del contenido del coto vedado no puede considerarse una cuestión situada más allá de la política, sino más bien, genuinamente política⁵³⁸. Por ejemplo, nos podemos plantear la cuestión de la compatibilidad entre la idea de coto vedado y lo que Alfonso Ruiz Miguel ha identificado como uno de los principios básicos de la democracia: aquel según el cual «cada uno tiene derecho a participar en las decisiones colectivas que le afectan»⁵³⁹. Parece evidente que, a priori, la idea de coto vedado entra en conflicto con este principio, ya que supone la negación de esa participación del sujeto en determinadas cuestiones, siendo así que esas cuestiones le afectan directamente, desde el momento en que, como reconoce el propio Garzón, se refieren a bienes básicos. Pero, como señala también Ruiz Miguel, hay que tener en cuenta la posibilidad de dos tipos de decisiones: de un lado, aquellas «simples o de primer nivel», con directas consecuencias en la realidad; de otro, las decisiones de segundo nivel o «metadecisiones», «que no afectan directamente a la realidad sino al propio ejercicio del derecho de decisión: son las decisiones a propósito de

⁵³⁷ GARZÓN VALDÉS, E., «Representación y democracia», cit., p. 158.

⁵³⁸ Vid. BAYÓN, J. C., «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», en VVAA., *Constitución y derechos fundamentales*, BETEGÓN, J, LAPORTA, F. J, PRIETO, L, DE PÁRAMO, J. R. (coords.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 84 y ss.

⁵³⁹ RUIZ MIGUEL, A., «Problemas de ámbito de la democracia», *Doxa*, n.º 6, 1989, p. 103.

si se debe, y cuando, tomar una decisión»⁵⁴⁰. El principio básico de la democracia implica también el reconocimiento del derecho que tiene el sujeto a tomar decisiones de segundo nivel: «Sólo si puedo determinar que algo me afecta —y en esa posibilidad de determinación está la decisión de segundo nivel—, de modo que ponga en marcha el mecanismo para adoptar una decisión sobre ello —y esta otra decisión es ya de primer nivel—, participo en un sistema democrático»⁵⁴¹. Junto a las decisiones de primer y de segundo nivel, existirían las de tercer nivel o *metametadecisiones*, «que suministran el marco imprescindible en el que actuar democráticamente o, con otra formulación, que proporcionan las reglas últimas y principales del juego democrático: precisamente, las decisiones del triple ámbito relativo a quién, dónde y cómo de la decisión política, es decir, de los sujetos que deben decidir y sobre los que se puede decidir, del espacio territorial en el que y sobre el que se debe decidir y, en fin, de la forma de decidir, que comprende la determinación de las materias sobre las que se puede o no se debe decidir»⁵⁴². Para Ruiz Miguel, el ámbito de la *metametadecisión* no necesita expresa justificación democrática: «A primera vista parece que es tan innecesario justificar democráticamente esas decisiones de tercer nivel como innecesario legitimar democráticamente el propio principio de que cada cual tiene derecho a participar en la decisión de lo que le afecta»⁵⁴³.

⁵⁴⁰ *Ibidem*.

⁵⁴¹ RUIZ MIGUEL, A., «Problemas de ámbito de la democracia», cit. p. 104.

⁵⁴² RUIZ MIGUEL, A., «Problemas de ámbito de la democracia», cit. p. 105.

⁵⁴³ RUIZ MIGUEL, A., «Problemas de ámbito de la democracia», cit. p. 106. No obstante, y aunque no se pueda profundizar en la cuestión en este momento, parece que la justificación democrática de decisiones sobre la determinación de los sujetos que pueden participar en las decisiones que les afectan adquiere progresivamente carácter más imperativo en un contexto caracterizado por la proliferación de flujos de inmigrantes

En relación con la idea del coto vedado, surge también la cuestión referida a la definición de sus contenidos y a los criterios de inclusión de los mismos: ¿quién y cómo toma la decisión de reservar, con la garantía del coto vedado, determinados contenidos? Es una cuestión importante, teniendo en cuenta que Garzón atribuye al contenido del coto vedado una *función moralizante*: «No es que el «coto vedado» surja porque los ciudadanos son agentes morales o sujetos que simpatizan con el bien común, sino que es él el que fija las condiciones para ser un ciudadano moral. La génesis de la moralidad ciudadana proviene de este «coto vedado» y no al revés»⁵⁴⁴. Esta es una cuestión problemática, también, desde el momento en que las concepciones de los individuos en torno a la esencialidad o indispensabilidad de determinados derechos evolucionan: posiblemente, los derechos que hoy consideramos esenciales no son los mismos que se habrían imaginado en su caso nuestros abuelos ni son los que se imaginarán nuestros nietos. Ya se ha señalado que Garzón, además, señala la expansión de ese coto vedado (directamente vinculada a la tendencia expansiva de la ética), tendencia que va a estar determinada por factores cognitivos y materiales⁵⁴⁵. El problema que se plantea es enton-

con pretensiones de estabilidad en los países de destino. Javier DE LUCAS se refiere al problema de la definición de «los afectados» en relación con la justificación democrática las decisiones en «Sobre la justificación de la democracia representativa», *Doxa*, n.º 6, 1989, p. 195. Sobre el carácter lógicamente anterior al proceso democrático de las decisiones sobre el universo de participantes que forman parte en dicho proceso, vid. LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., pp. 239-240.

⁵⁴⁴ GARZÓN VALDÉS, E., «Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho», cit., p. 18.

⁵⁴⁵ Como ha señalado Javier DE LUCAS, («Sobre la justificación de la democracia representativa»), sería interesante saber cómo, si es que ello es posible, se pueden compatibilizar el «expansionismo» al que alude Garzón, con posiciones como la de Laporta, que denuncian la pérdida de fuerza de los derechos como consecuencia de la sucesiva proliferación de generaciones de derechos. Vid. LAPORTA, F., «Sobre el concepto de derechos humanos», y

ces el de la progresiva reducción del escenario en el que se debe desarrollar la negociación política, lo cual implicaría una reducción del ámbito y de las posibilidades de la democracia⁵⁴⁶. Por eso, en principio, no sería, en este caso, una postura despreciable la de aquellos que señalan que el seguimiento de estrategias como las anteriores nos aproxima a explicaciones vecinas al iusnaturalismo a partir de la defensa de la tesis de la existencia de determinados contenidos jurídicos inalterables y consolidados ¿Hasta qué punto el contenido de ese coto vedado no cumple una función semejante la que podría desempeñar el Derecho natural?: aquí también se están limitando los contenidos de las decisiones del Poder político. Por eso se ha señalado el carácter funcionalmente iusnaturalista del constitucionalismo, desde el momento en que éste desarrolla una teoría de la limitación del Poder a partir de la afirmación de unos contenidos materiales, los derechos, que escapan del ámbito de cecisión del Poder y que por lo tanto están protegidos frente él⁵⁴⁷.

«Respuesta a Pérez Luño, Atienza y Ruiz Manero», ambos trabajos en *Doxa*, n.º 4, 1987, pp. 44 y 74-75, respectivamente.

⁵⁴⁶ Vid. VIDAL GIL, E., «Justificación de la democracia y límites a la decisión por mayorías», cit., p. 237.

⁵⁴⁷ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos», cit., pp. 58-59, y también, «Algunos desafíos al constitucionalismo de los derechos: globalización y multiculturalidad», en ID., *El constitucionalismo de los derechos*, cit., pp. 225-227. También, TAMANAHA, B. Z., *On the Rule of Law. History, Politics, Theory*, cit., p. 56. No obstante, el propio Luis Prieto se ha encargado de matizar la correspondencia entre el constitucionalismo y el iusnaturalismo, a partir de dos motivos. En primer lugar, la existencia de diversas paternidades en el constitucionalismo; en segundo lugar, el hecho de que el recurso al Derecho natural haya desempeñado en determinadas circunstancias históricas una función conservadora y justificativa respecto al poder establecido (vid. «Presupuestos ideológicos y doctrinales de la justicia constitucional» en ID, *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, cit., p. 33).

3. CONSTITUCIÓN Y AUTORRESTRICCIÓN

3.1. Sobre la necesidad de limitar las decisiones mayoritarias en democracia

En el marco del constitucionalismo contemporáneo, la Constitución cumple una función básica, que es la de controlar y limitar al Poder⁵⁴⁸. En efecto, junto a otros mecanismos como la separación de poderes, la inclusión de dimensiones sustanciales y procedimentales en los textos constitucionales supone responder de determinada manera a las cuestiones referidas al qué, quién y cómo se debe mandar. Ese control, en este caso, se materializa a través del establecimiento de contenidos vinculantes que así complementan la función de *indirizzo* que lleva a cabo el texto constitucional.

Los derechos, núcleo básico de la dimensión vinculante de la Constitución, asumen un papel protagonista en la función de limitar y controlar al Poder, desde el momento en que su positivación supone el establecimiento obligaciones para el Poder⁵⁴⁹. Su efectividad y las consecuencias de su positivación constituyen una de las claves de comprensión del constitucionalismo contemporáneo, para la cual es imprescindible tener presente la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. Como ha señalado Jon Elster, el constitucionalismo se refiere a los «límites sobre las decisiones mayoritarias; de modo más específico, a los límites que en cierto sentido son autoimpuestos. Tales límites pueden adoptar variedad de formas y ser de procedimiento o sustantivos, así como obstruir o tan sólo hacer más lento el proceso del cambio legislativo»⁵⁵⁰.

⁵⁴⁸ Función que, por otra parte, no es la única desempeñada por la Constitución. G. PECES-BARBA se ha referido a las funciones de seguridad, de justicia y de legitimidad en *Diez lecciones sobre Ética, Poder y Derecho*, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 103 y ss.

⁵⁴⁹ Vid. PRIETO SANCHÍS, L., *Estudios sobre derechos fundamentales*, cit., pp. 111 y ss. También, DE ASÍS ROIG, R., *Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al Poder*, cit.

⁵⁵⁰ ELSTER, J., «Introducción», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*, cit., p. 34.

Hablar de límites a las decisiones mayoritarias en democracia tiene especial trascendencia. Es cierto que la democracia es más que el principio de las mayorías y que, además, éste no debe ser confundido con el imperio o la tiranía de las mayorías⁵⁵¹. Pero, en todo caso, y más allá de las reconocidas virtudes de la deliberación, el criterio último de adopción de decisiones parece necesariamente vinculado a la regla de las mayorías. Y el régimen mayoritario tiene una innegable capacidad potencial de vulneración de derechos. Es también Elster el que se ha referido a las formas en que un sistema mayoritario puede poner en peligro los derechos⁵⁵². Así, se puede aludir, en primer término, a la tentación a la que siempre puede estar sometido el gobierno de la mayoría a perpetuarse en su posición mediante un aumento de las posibilidades de reelección. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad que puede tener una mayoría parlamentaria para introducir determinados cambios en el sistema electoral o para influir en los medios de comunicación, cuya influencia a la hora de provocar o impedir cambios políticos parece de innegable presencia en las sociedades actuales. Debe tenerse en cuenta también, en segundo lugar, que las mayorías también están sometidas a la influencia de intereses creados y de pasiones momentáneas que pueden poner en peligro a las minorías. En tercer lugar, esas pasiones pueden ser permanentes, como las que se encuentran detrás de muchos de los episodios de fanatismo a los que hemos asistido y seguimos asistiendo en nuestra época.

La posibilidad de estos peligros hace necesaria la creación, desde el propio sistema democrático, de mecanismos anti-

⁵⁵¹ Vid. Kelsen, H., *Esencia y valor de la democracia*, trad. de la 2ª edic. alemana por R. Luengo Tapia y L. Legaz Lacambra, Labor, Barcelona, 1934, pp. 81 y ss.

⁵⁵² Vid. Elster, J., «Régimen de mayorías y derechos individuales», en Shute, S., Hurley, S., (eds.) *De los derechos humanos*, trad. de H. Valencia, Trotta, Madrid, 1998, pp. 170 y ss.

mayoritarios. La democracia, apoyada en el principio de las mayorías, necesita defenderse frente a alguna de las consecuencias de este principio. Y el constitucionalismo (en su dimensión de límite al régimen de las mayorías), con los mecanismos de la justicia constitucional, la separación de poderes y la existencia de un sistema de frenos y contrapesos, como los existentes en los sistemas bicamerales y en aquellos en los que el ejecutivo tiene capacidad de veto, es uno de estos mecanismos de defensa.

3.2. Restricciones individuales y restricciones colectivas

La función de límite desarrollada por las Constituciones se lleva a cabo, por ejemplo, mediante medidas restrictivas de la capacidad de decisión a través de los mecanismos democráticos. La cuestión que nos debemos plantear es la del sentido y justificación de las medidas autorrestrictivas vinculadas al constitucionalismo, y que suponen la decisión de una sociedad de limitar su poder soberano. Pero antes del análisis de la autorrestricción en el ámbito del constitucionalismo, conviene ser consciente de que es posible enfocar la cuestión de las autorrestricciones (*self-binding*), y de las restricciones en general, desde un punto de vista más amplio.

En *Ulises desatado*⁵⁵³, donde como veremos Jon Elster retoma y en cierto sentido reformula alguna de las tesis mantenidas anteriormente en *Ulises y las sirenas*⁵⁵⁴, el autor noruego

⁵⁵³ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, trad. de J. Mundó, Gedisa, Barcelona, 2002.

⁵⁵⁴ Vid. ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad* (1984), trad. de J. J. Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. Vid también ID., *Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad*, trad. de E. Lynch, Península, Barcelona, 1988; e ID., «Intertemporal Choice and Political Thought», en LOEWENSTEIN, G., ELSTER, J., (eds.), *Choice over time*, Russell Sage Foundation, New York, 1992, pp. 35 y ss.

propone las líneas básicas de una teoría de las restricciones⁵⁵⁵. Las cuestiones principales a la que debería responder una teoría de las restricciones son las siguientes: ¿cuál es la razón por la que los individuos en determinadas ocasiones desean restringir su libertad de acción y de elección?, ¿a través de qué mecanismos y procedimientos llevan a cabo estas restricciones?⁵⁵⁶. Sabemos que en ciertos momentos los sujetos consideran beneficioso protegerse —podríamos decir blindarse— respecto a las consecuencias de la actuación de acuerdo con sus pasiones, o respecto a los efectos de los cambios de preferencias o inconsistencias temporales. En esos casos, señala Elster, el sujeto considera que *menos es más*, es decir, que la restricción o eliminación de posibilidades futuras le pueden suponer un provecho mayor que la amplitud de las mismas. Esas restricciones, consideradas beneficiosas, pueden ser de dos grandes tipos: *accidentales* y *esenciales*⁵⁵⁷. Por una parte, las restricciones *accidentales* son aquellas que, si bien sujetan al individuo, no son elegidas por éste con la intención de generar un provecho. Cabe la posibilidad que el sujeto haya optado por ellas con otra motivación, que se deban a la voluntad de otro o que incluso no dependan de voluntad alguna. Las restricciones *esenciales* son aquellas a las que se somete un individuo, autoimponiéndose las, con la intención de alcanzar un beneficio. Observamos, por tanto, que en el caso de las restricciones esenciales, la tendencia del sujeto a alcanzar un beneficio o provecho juega un papel determinante.

Junto a lo anterior, conviene resaltar también que de la misma manera que son variadas las razones que pueden provocar las restricciones, también lo son los mecanismos de los que el

⁵⁵⁵ Vid. al respecto, LLANO ALONSO, F. H., *El formalismo jurídico y la teoría experiencial del Derecho. Un estudio iusfilosófico en clave comparativa*, cit., pp. 121 y ss.

⁵⁵⁶ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 15.

⁵⁵⁷ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 18.

sujeto se puede servir a tal fin. Aunque no nos podemos detener en este momento en todas y cada una de las posibilidades exploradas por Elster al respecto, sí podemos recordar alguna de ellas⁵⁵⁸. En efecto, un sujeto se puede marcar como objetivo, por ejemplo, la superación de las pasiones, de los efectos del interés propio, o el evitar los cambios de preferencias perniciosos. Y para ello, puede emprender acciones consistentes, entre otras, en la eliminación de opciones, en la imposición de costes, en la fijación de recompensas, en la creación de demoras, o en el cambio de preferencias.

En estos casos se considera que el individuo actúa de manera racional. La racionalidad se predica de nuestras decisiones cuando éstas favorecen medios que permiten lograr nuestros fines. En el marco de esta relación entre medios y fines, el mismo Elster ha señalado, junto a la teoría de la racionalidad perfecta (construida sobre la comprensión de la racionalidad humana como la capacidad de relacionarse con el futuro)⁵⁵⁹, la necesidad de una teoría de la racionalidad imperfecta, aplicable a aquellos casos en los que un sujeto puede conseguir por medios indirectos aquellos mismos fines que otro individuo racional habría podido lograr directamente⁵⁶⁰. Como es sabido, el ejemplo de referencia es el del momento de la *Odisea* en el que Ulises, con la intención de resistir a los cantos de las sirenas, pide a sus acompañantes que le aten al mástil del barco y que en el caso de que posteriormente, al oír esos cantos, implore que le suelten, no atiendan su súplica⁵⁶¹. Estamos ante un

⁵⁵⁸ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 20.

⁵⁵⁹ John R. SEARLE ha señalado que, a diferencia de los animales, «gran parte de las decisiones que tomamos tiene que ver con la organización del tiempo más allá del presente inmediato», *Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío*, trad. de L. M. Valdés Villanueva, Círculo de Lectores, Madrid, 2000, p. 14.

⁵⁶⁰ Vid. ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 66.

⁵⁶¹ «...pero atádmeme con fuertes lazos, en pie y arrimado a la parte inferior del mástil —para que esté allí sin moverme— y las sogas líguense al mis-

caso en el que un sujeto, consciente de la debilidad de su voluntad (*akrasia*), recurre a un mecanismo que le va a permitir alcanzar el fin deseado, en este caso el de superar la tentación de los cantos de sirena, si bien por medios indirectos. Desde el punto de vista teórico, la debilidad de la voluntad implica el siguiente esquema: «a) el juicio de que X es bueno; b) el juicio de que Y es bueno; c) el juicio de que atendiendo a todas las circunstancias, X es mejor que Y; d) el hecho de que Y es elegido»⁵⁶². Autores como John Searle han subrayado lo común y frecuente de la debilidad de la voluntad debido a la *brecha* que se produce entre las intenciones y las decisiones de llevar a cabo las acciones que materializan esas intenciones. Para entender la existencia de dicha *brecha*, tenemos que ser conscientes de que la causalidad de las intenciones es de un tipo muy específico, en el que la noción de continuidad necesaria⁵⁶³ entre intenciones y acciones se difumina: «en el caso de los deseos y las intenciones, una vez que las causas están presentes, todavía no obligan al agente a actuar; el agente tiene que actuar *de acuerdo con razones* o de acuerdo con su intención. En el caso de la acción voluntaria hay (...) una brecha, una cierta holgura entre el proceso de deliberación y la formación de la intención y, de nuevo, hay una brecha entre la intención y emprender la acción de forma efectiva»⁵⁶⁴.

mo. Y en el caso de que os ruegue o mande que soltéis, atadme con más lazos todavía», HOMERO, *Odisea*, trad. de L. Segala Estalela, Círculo de Lectores, Barcelona, 1971, Canto XII, p. 470. La de Ulises sería una racionalidad instrumental o estratégica. Un análisis crítico de la racionalidad estratégica es el llevado a cabo por M. E. RODRÍGUEZ PALOP en «La sinrazón de la razón como estrategia. Razones en favor de la racionalidad de los agentes morales», *Derechos y Libertades*, n.º 27, junio 2012, pp. 177 y ss.

⁵⁶² ELSTER, J., *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, cit., p. 33.

⁵⁶³ Vid. BUNGE, M., *La causalidad*, trad. H. Rodríguez, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1997, pp. 201 y ss.

⁵⁶⁴ SEARLE, J., *Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío*, cit., p. 275. Vid también capt. 3: «El fenómeno de la brecha: del tiempo y del yo», pp. 91-126.

Ciertamente, la debilidad de la voluntad es uno de los efectos posibles de las pasiones, que provocan una brecha o una ruptura entre la intención del sujeto, vinculada a la razón o al propio interés, y la actuación efectiva del sujeto. Pero no es el único. Así, se alude también a la distorsión cognitiva o autoengaño, a la confusión cognitiva, y a la miopía⁵⁶⁵. En el caso de la distorsión cognitiva, el sujeto sufre un cambio en lo que hasta ese momento había considerado en relación con las consecuencias de una determinada actividad. La confusión cognitiva se refiere no tanto al cambio en relación con la consideración de las consecuencias, sino a la eliminación misma de dicha consideración. En fin, la miopía es la que se produce en el caso en el que el sujeto no es capaz de valorar las consecuencias de sus actuaciones, a diferencia de lo que haría si se encontrara en una situación en la que no estuviera sometido a las pasiones.

En todo caso, lo que interesa en este momento es subrayar que la técnica del «atarse a sí mismo» constituye un ejemplo de mecanismo indirecto mediante el cual alcanzar fines y, en definitiva, relacionarse con el futuro. Estamos en presencia de una «racionalidad a través del tiempo»⁵⁶⁶. En realidad, y volveremos posteriormente sobre la cuestión, los individuos y las sociedades recurren frecuentemente a ella. Su operatividad se circunscribe al ámbito humano, ya que presupone «un espacio interior en el que están presentados los posibles estados. Para que las consecuencias futuras establezcan una diferencia en la elección presente, de alguna manera deben estar presentes en la conciencia y estar presentes como no realizadas y simplemente posibles; (...) esto es testimonio de una vida mental en sentido muy amplio»⁵⁶⁷. En todo caso, podemos comprender

⁵⁶⁵ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., pp. 22 y ss.

⁵⁶⁶ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 20.

⁵⁶⁷ ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 150 (vid. también p. 79).

qué es «atarse a sí mismo» a partir de la siguiente afirmación: «Atarse a sí mismo es llevar a cabo cierta decisión en el tiempo t_1 para aumentar la posibilidad de llevar a cabo otra decisión en el tiempo t_2 »⁵⁶⁸. La primera decisión adquiere su sentido encaminada a lograr que se creen las condiciones que permitan actuar en el segundo momento. Así pues, el sujeto consciente de que en determinados casos se produce una debilidad de su voluntad, se protege frente a su propia irracionalidad. Se opta entonces, frente a una racionalidad perfecta, por una racionalidad imperfecta o «segunda mejor», en la que, señala Elster de manera gráfica, se pierde «el sentido de aventura»⁵⁶⁹.

No obstante, es cierto que las estrategias Ulises no necesariamente tienen que ser interpretadas como respuestas frente a las situaciones de debilidad de la voluntad. Por ejemplo, Waldron analiza las estrategias de precompromiso como un caso paradigmático de autogobierno⁵⁷⁰, en donde la libertad implica el auto-control necesario para asegurar la autonomía en un momento futuro. Además, afirma también Waldron, el precompromiso puede funcionar no sólo en aquellos casos en los que los dos momentos (t_1 y t_2), se identifican con la lucidez y con la obcecación respectivamente. Por el contrario serviría también en los casos en los que se producen desacuerdos de opiniones

⁵⁶⁸ ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 71. En otro momento el propio Elster reformula la anterior caracterización: «En el momento t_1 , un individuo desea hacer A en el momento t_2 , pero anticipa que cuando llegue t_2 , puede hacer, o hará, B, a menos que esté impedido de hacerlo. En situaciones como ésta, el comportamiento racional en el momento t_1 puede conllevar medidas precautorias para evitar elegir B en el momento t_2 o, al menos, hacer esta elección más improbable», Vid., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 20.

⁵⁶⁹ ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 188.

⁵⁷⁰ Vid. WALDRON, J., «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», *Oxford Journal of Legal Studies*, 13/1, 1993, pp. 19 y ss.; ID., *Derecho y desacuerdos*, trad. de J. L. Martí y Á. Quiroga, est. prel. de R. Gargarella y J. L. Martí, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 305 y ss.

o pareciera a lo largo del tiempo. Pensemos en el ejemplo que nos propone Waldron⁵⁷¹. Una persona que se debate entre diversos credos religiosos, toma la decisión de, en un determinado momento, adoptar la fe de una cierta confesión. Tal es la seriedad de su empeño que toma la decisión, también, de no volver a leer aquellos libros que en el pasado le hicieron dudar. Y para ello los mete en un armario, entregando las llaves a un amigo, al que le exige que nunca se las devuelva, aunque se lo pida. No obstante, sigue albergando algunas dudas religiosas, y pasado un tiempo le pide a su amigo las llaves. La cuestión que plantea Waldron es la de identificar las diferencias entre este ejemplo y el de Ulises, o el del alcohólico que tras haber pedido a su mujer que esconda las llaves del mueble-bar, le pide a su mujer que le diga dónde están. Parece claro que el caso de los libros religiosos no es un caso de debilidad de la voluntad, sino de cambio de opiniones, de mero desacuerdo. No podemos decir que el momento t_2 sea cualitativamente diferente —en ningún caso superior— respecto al momento t_1 . Si la interpretación de Waldron es correcta, supondría una llamada de atención a la hora de trasladar de manera indiscriminada los esquemas y explicaciones de las autorrestricciones individuales vinculadas a casos de debilidad de voluntad a otras situaciones individuales o a todas y cada una de aquellas situaciones en las que se produce un precompromiso constitucional. Y ello porque en una sociedad plural y con capacidad dinámica, la diversidad de opiniones y la existencia de desacuerdos forma parte de lo razonable. Es cierto que en las sociedades se pueden producir «vuelcos» como consecuencia de la irrupción de las pasiones o de la irracionalidad colectiva, pero no todo desacuerdo interno, merece ser observado como un caso de embriaguez que justifique medidas restrictivas.

Teniendo en cuenta las anteriores prevenciones, creo que se pueden establecer paralelismos entre los mecanismos restricti-

⁵⁷¹ Se encuentra en WALDRON, J., «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», cit., p. 48, y en ID., *Derecho y desacuerdos*, cit., pp. 320-321.

vos de las conductas individuales y determinadas estrategias de restricción colectiva. En este caso, podemos aludir a las leyes mordaza o a las políticas de omisión, de un lado, y al precompromiso constitucional, de otro. En ocasiones las diferencias entre estas estrategias son muy difusas. Incluso se ha argumentado que es muy difícil considerar que las Constituciones funcionen en realidad como estrategias de precompromiso del tipo de la de Ulises. El propio Elster, en *Ulises desatado*, de alguna manera matiza afirmaciones anteriores. Es cierto que, como él mismo reconoce, en *Ulises y las sirenas* había llamado la atención sobre las cautelas que había que adoptar a la hora de asimilar las estrategias de restricción individual con las estrategias de restricción social. Ahora vuelve sobre el tema y plantea dos cuestiones⁵⁷². Por una parte, las Constituciones, más que establecer mecanismos de autorrestricción, tienden a vincular o a atar a otros. Por otra, existen casos en los que las Constituciones en realidad pueden carecer de poder de restricción. No creo que estas cuestiones sean insalvables, de manera que, así, no desautorizarían el enfoque que en este trabajo se da al tema. En primer lugar, es cierto que las Constituciones pueden atar a sujetos distintos a sus creadores, considerados éstos en sentido genérico, como generación. Es el propio Elster el que de manera explícita reconoce que se plantea el problema en relación con las generaciones futuras. En ese caso, «no hay una forma que esté libre de hipocresía en la que estos procedimientos puedan ser denominados como *autorre restrictivos*»⁵⁷³. Pienso que la cuestión de las generaciones futuras no invalida la validez de

⁵⁷² Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., pp. 115 y ss.

⁵⁷³ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 189. No obstante, en un momento anterior había afirmado que «crear una constitución que ate o restrinja a las generaciones futuras puede también —en un sentido amplio— ser visto como un acto de *autorrestricción*, a saber, si se espera que los agentes políticos del futuro alberguen las mismas razones para desear estar restringidos que albergaba la generación fundacional» (p. 119).

nuestro enfoque, desde el momento en que la consideración de los mecanismos autorre restrictivos se ve complementada, como veremos, con la de los heterorre restrictivos. No creo que los dos tratamientos sean excluyentes. La posibilidad de los primeros implica la de los segundos: «...si un conjunto de individuos pueden reforzar su poder mediante la limitación de su propia libertad, pueden, también, *reducir el poder de otros mediante la extensión de su libertad*»⁵⁷⁴. En segundo lugar, están aquellas situaciones en las que las Constituciones carecen de capacidad de atar. Pienso que este punto merece más comentarios. Debemos ser conscientes, en primer lugar, que el replanteamiento de las dimensiones limitativas de la Constitución puede entrar en conflicto con afirmaciones y exigencias básicas del Constitucionalismo, a las que hemos aludido en un momento anterior de este trabajo. No obstante es cierto que Elster enfoca en este caso el tema desde una perspectiva no estrictamente jurídica o que, por lo menos, trasciende a lo jurídico. Y ello es así porque piensa en dos situaciones concretas: aquella en la que los ciudadanos reaccionan frente a cualquier intento de ser atados, y aquella otra, posiblemente menos selectiva, en la que los ciudadanos reaccionan, no ya frente a cualquier atadura, sino frente a aquellas medidas difícilmente reformables y que significan obstáculos o barreras que se consideran intolerables desde el momento en que dificultan el cambio. En este punto Elster demuestra que es ciertamente consciente tanto de la pluralidad de posibles estrategias de restricción, como de la pluralidad de diferentes reacciones frente a las mismas.

En todo caso, la consideración de las diferencias entre las situaciones personales y las colectivas no le impide reconocer a Elster, al final, que «la idea del precompromiso constitucional no carece de sentido»⁵⁷⁵.

⁵⁷⁴ Vid. ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 117. Cursivas en el texto.

⁵⁷⁵ ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 118.

No obstante, se han señalado razones a favor de la tesis según la cual la vinculación que la Constitución ejerce sobre el futuro no se puede enfocar en términos de precompromiso-Ulises. Como vamos a ver hay algunas coincidencias con las afirmaciones del último Elster. En primer lugar, se señala que existe una diferencia importante entre el caso de Ulises y el de la Constitución. En el momento presente y en el momento futuro, Ulises es la misma persona. Por el contrario, en los casos de precompromiso constitucional las restricciones son impuestas por parte de unos individuos a otros. El tema se plantea en referencia a generaciones distintas. En segundo lugar, en el ejemplo de Ulises, nos encontramos en el primer momento con un individuo lúcido, racional y sobrio, que sabe detectar qué es lo mejor para él en el futuro, mientras que en el segundo momento el sujeto se torna irracional y sometido a las pasiones, a la debilidad de la voluntad o a la miopía. Si trasladáramos esa diferencia al caso del precompromiso constitucional, nos encontraríamos con un constituyente, o con una generación constituyente, lúcida y racional, y con unas generaciones posteriores entregadas a las pasiones y sin capacidad de discernir. Entonces, estaríamos ante un caso de paternalismo, ante una desconfianza no justificada en relación con las generaciones del futuro y con las mayorías democráticas que en su seno se pudieran producir. Además, en muchas ocasiones no es que no se pueda demostrar la racionalidad y la lucidez del legislador constituyente, sino que éste también está sometido a pasiones e intereses, con lo cual el precompromiso no se puede presentar en términos de racionalidad *versus* pasión⁵⁷⁶.

⁵⁷⁶ Vid. BAYÓN, J. C., «Derechos, democracia, Constitución», cit., pp. 223-225; GARGARELLA, R., «Il ruolo dei giudici di fronte al 'terreno proibito'», *Ragion Pratica*, 1998/10, p. 67; LAPORTA, F. J., «El ámbito de la Constitución», cit., pp. 459 y ss., en especial p. 464. LLANO ALONSO, F. H., *El formalismo jurídico y la teoría experiencial del Derecho. Un estudio iusfilosófico en clave comparativa*, cit., pp. 131-132.

Pues bien, creo que las objeciones frente a la interpretación de la Constitución en términos de precompromiso como el de Ulises no consiguen certificar lo desacertado de la estrategia seguida aquí. En todo caso, pienso que el enfoque que se sigue en este trabajo permite salvarlas. Es verdad que Ulises es la misma persona en los sucesivos momentos, lo que no ocurre en el caso de las Constituciones. Pero por eso, precisamente, propongo diferenciar de manera explícita entre casos de autorrestricción, de un lado, y de heterorrestricción, de otro. Además, las críticas basadas en el problema de la identidad están apoyadas en un presupuesto ciertamente problemático, y al que en buena medida le correspondería la carga de la prueba, como es aquel que admite que la identidad de los agentes individuales no es problemática y que cada agente individual posee en cada momento una sólo opinión sobre cuál debe ser su comportamiento.⁵⁷⁷ Como veremos posteriormente, en determinadas ocasiones, al igual que ocurre con Ulises, las sociedades y las generaciones presentes toman la decisión de atarse a sí mismas (autorrestricciones); en otros, asistimos a las ataduras de otros, de las generaciones futuras (heterorrestricciones). Es esta circunstancia la que permite, en su caso, plantear las heterorrestricciones como un caso de paternalismo, que es precisamente la circunstancia denunciada. Por último, no sé hasta qué punto el hecho de que en ocasiones el legislador no actúa de manera racional, desinteresada y libre de pasiones, impide enfocar el tema como aquí se hace, es decir como un problema de restricción de la libertad, ya sea de las generaciones presentes o de las futuras. Como mucho, conduce a identificar dos momentos de distinta calidad deliberativa, lo cual también es problemático.

⁵⁷⁷ Es la opinión de J. J. MORESO en «Sulla portata del vincolo preventivo», *Ragion Pratica*, 1998/10, pp. 76 y 77.

3.3. Autorrestricciones constitucionales

Una vez señalado lo anterior, y admitida la posibilidad de aplicar esquemas de la teoría de la restricción individual al caso colectivo, podríamos identificar a las leyes mordaza y a las políticas de omisión como casos de autorrestricción, relacionando por su parte al precompromiso con la heterorrestricción. La autorrestricción afecta al colectivo que toma la decisión de «atarse las manos» o de no tratar determinados temas, mientras que la heterorrestricción expande sus efectos en un ámbito más amplio, afectando en este caso a generaciones futuras. Las constituciones contemporáneas integran mecanismos identificables con ambos tipos.

Con la exclusión de determinadas cuestiones de la agenda política se está trasladando el ámbito en el que se debe producir la reflexión sobre dichas cuestiones. En este sentido, se produce una liberación de la esfera pública desde el momento en que se le exonera de su función de constituir el campo en el que esas cuestiones se deben dilucidar. El ejemplo de la localización de cuestiones religiosas en la esfera de lo privado demuestra que la distinción entre el ámbito de lo público y de lo privado a efectos de distinguir escenarios de deliberación «no sólo protege la esfera pública de incursiones indeseadas, sino que también libera a la esfera pública de problemas irresolubles»⁵⁷⁸. Se produce así una «privatización» de determinadas cuestiones que son excluidas de la discusión pública.

John Rawls se ha referido al «método de evitación» (*method of avoidance*) necesario desde el momento en que, a partir de la Reforma, las sociedades liberales se caracterizan por la existencia de una pluralidad de concepciones enfrentadas en relación con determinadas cuestiones cuya resolución definitiva no es posible. El método de evitación permite alcanzar el objetivo de la justicia como imparcialidad o equidad (*fairness*). La materia-

⁵⁷⁸ HOLMES, S. «Las reglas mordaza o la política de la omisión», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*, cit., p. 53.

lización del acuerdo político imprescindible vinculado a dicho objetivo puede exigir «evitar cuestiones filosóficas disputadas, así como también cuestiones morales y religiosas disputadas. No hacemos esto porque esas cuestiones sean poco importantes o se miren con indiferencia, sino porque las consideramos como demasiado importantes y reconocemos que no hay modo de resolverlas políticamente»⁵⁷⁹.

Bobbio, al identificar los límites a los que la regla de las mayorías se somete en un sistema democrático, se ha referido a los *límites de aplicación*, constituidos por materias en las que dicha regla no se aplica, ya sea por razones de oportunidad o de principio: «Son las materias cuya decisión confiada a la regla del mayor número sería inoportuna (no adecuada al fin) o incluso injusta»⁵⁸⁰.

Por su parte, Stephen Holmes señala diversas virtudes de esta separación de ámbitos y de la correspondiente atribución

⁵⁷⁹ RAWLS, J., «Justice as Fairness: Political, not Metaphysical», *Philosophy and Public Affairs*, 14, 1985, p. 230. Parecida en su sentido genérico al método de evitación rawlsiano, sería la caracterización del precompromiso como mecanismo de elusión, a la que alude MORESO (Vid. «Sulla portata del vincolo preventivo», cit., pp. 79 y 80), y cuya finalidad sería la de evitar un exceso de deliberación y de conflicto. No obstante, Moreso completa el argumento señalando los límites de la elusión de la deliberación. Así, está justificado recurrir a este mecanismo siempre y cuando las alternativas en juego sean indiferentes. En el caso en que no lo sean, entonces no se debe eludir la discusión y la elección so pena de que la política de la elusión se transforme en la «política de la injusticia». Creo que el argumento de Moreso viene a matizar al de Rawls. El hecho de que exista un conflicto entre alternativas u opciones altamente disputadas entre sí puede ser un argumento para poner en marcha políticas de omisión siempre y cuando la elección entre alguna de ellas no ponga en juego valores imprescindibles. En este caso, y desde una perspectiva realista, se trata, más que de evitar la discusión, suspendiendo la elección, de optar efectivamente por alguna de las alternativas (la que no ponga en juego los valores).

⁵⁸⁰ BOBBIO, N., «La regola di maggioranza: limiti e aporie», cit., p. 399. Junto a los derechos existen otras materias respecto de las cuales tampoco debe regir, señala Bobbio, la regla ya sea por razones objetivas (cuestiones científicas o técnicas) o por razones subjetivas (cuestiones de conciencia).

de cuestiones. En efecto, desde el momento en que se está liberando a la esfera pública de la responsabilidad de solucionar cuestiones o problemas que en muchas ocasiones son irresolubles o respecto a los cuales es difícil determinar una solución satisfactoria para todos, se está logrando evitar conflictos (ya que se evita una de las causas de los mismos, esto es la concurrencia de cuestiones enfrentadas y difícilmente reconciliables). Además, se produce una racionalización de los esfuerzos y una canalización de las energías sociales⁵⁸¹, que se encaminan a la resolución de otras cuestiones. Como Holmes señala, con la privatización de ciertas cuestiones, «una ciudadanía dividida puede capacitarse a sí misma para resolver sus *otras* diferencias racionalmente, por medio del debate público y el acuerdo»⁵⁸². Por otra parte, la reconducción de ciertos temas al ámbito de la deliberación privada puede contribuir, en definitiva, al surgimiento y estabilización de los regímenes democráticos.

Es notorio que el objetivo de la propuesta rawlsiana referida a la justicia como equidad es eminentemente «práctico, y no metafísico ni epistemológico»⁵⁸³. La perspectiva de Holmes en este punto es también evidentemente pragmática. Considera los beneficios de la parcelación de los ámbitos de deliberación, público y privado, teniendo en cuenta las consecuencias, ciertamente atendibles, de dicha parcelación. Sin embargo, no menciona otras razones que escaparían a un discurso consecuencialista como el suyo en este punto. Me refiero a la defensa de la consideración de que el ámbito privado es el contexto en el que han de localizarse determinados temas o cuestiones des-

⁵⁸¹ «¿Con qué objeto se van a despilfarrar recursos nacionales en una cuestión que jamás obtendrá un consenso generalizado, mientras existen problemas no menos apremiantes (...) acerca de los cuales todo el mundo conviene en que se debe hacer algo?», HOLMES, S. «Las reglas mordaza o la política de la omisión», cit., p. 80.

⁵⁸² HOLMES, S. «Las reglas mordaza o la política de la omisión», cit., p. 54.

⁵⁸³ RAWLS, J., «Justice as Fairness: Political, not Metaphysical», cit., p. 230.

de el momento en que esas cuestiones pertenecen a la esfera de la privacidad, de la individualidad, de la intimidad personal y por tanto es el señorío de la opinión individual el que debe ser atendido. Ciertas cuestiones vinculadas a la conciencia, a la religión, o a la sexualidad, por ejemplo, son propias del ámbito individual, no porque así se eviten conflictos —que también— sino porque, siempre que las opciones individuales no causen daños a terceros, es el sujeto el que tiene el protagonismo de la decisión. Lo anterior presupone evidentemente una concepción de las relaciones sociales en las que la noción de autonomía individual adquiere relevancia.

Por otra parte, también merecería la pena considerar que junto a las políticas de omisión, existen otras vías útiles a la hora de evitar conflictos entre las preferencias individuales. En este sentido, Ernesto Garzón Valdés se ha planteado la viabilidad de diversas estrategias al respecto: la que se podría identificar con Rousseau, según la cual hay que suponer que el ciudadano es un ser autónomo que actúa *cómo* un ser moral; la que se identifica con la hipocresía, y que entiende que el ciudadano es un ser autónomo que actúa *como si* fuera un ser moral; la que se identifica con la simpatía (Hume), predicada del ciudadano que asume la autonomía y los intereses de los demás, como si fueran los propios; y aquella, identificada con la propuesta del coto vedado —que ya conocemos—, y que entiende que, como el ciudadano no es un agente moral, puede estar sujeto a restricciones que, más que violar su autonomía, «crean las condiciones para que ella pudiera manifestarse». Entre la estrategia de la hipocresía y las políticas de omisión se pueden establecer distintas coincidencias.

En efecto, hemos podido constatar cómo en las políticas de omisión se produce una renuncia a colocar en la arena del debate público determinadas cuestiones, con la finalidad de no provocar la tensión del desacuerdo. En realidad, como en el caso de la hipocresía, el acuerdo es ficticio y retórico, desde el momento en que se simula dicho acuerdo. La exclusión de determinados temas del debate no significa acuerdo sobre esos temas, sino solamente acuerdo sobre el hecho de que la discusión sobre esos temas —debido precisamente al desencuentro difícilmente

reconciliable— no se debe producir. La tolerancia hacia las posiciones del otro, que no entramos a discutir, en las políticas de omisión, también se produce en el caso de la hipocresía, aunque ello vaya en cierto detrimento de la veracidad en las relaciones sociales: «de acuerdo con nuestro sistema de valores, algunos comportamientos que nos parecen reprochables en nuestro orden normativo básico, los aceptamos externamente en aras de la convivencia pacífica y respetuosa con aquellas personas cuyas concepciones de lo bueno no aceptamos internamente. Si ello es así, entonces la vida pública en una sociedad democrática liberal implicaría una notoria reducción de la veracidad»⁵⁸⁴. Es evidente que la hipocresía adoptada como regla general de actuación en las relaciones entre los sujetos, está sujeta a la crítica desde el momento en que impide traslucir las posiciones y los sentimientos del interlocutor. Pero en ciertas ocasiones optamos por callar para no herir al otro, ocultando de alguna manera nuestras preferencias, y podemos tener a nuestro favor buenas razones para tal actuación. De la misma manera que en las relaciones intersubjetivas, obviamos determinadas cuestiones para mantener alejado el conflicto, también en las relaciones sociales, desde una perspectiva finalista, estaría en ciertas ocasiones justificado actuar de acuerdo con esta estrategia, teniendo en cuenta, como señala Garzón, algunas ventajas al respecto: «Nos hemos vuelto más realistas y, además, hemos encontrado una vía que parece ser útil para asegurar la estabilidad de una democracia liberal en sociedades heterogéneas»⁵⁸⁵. En determinadas situaciones, actuar de acuerdo con la estrategia del *como si* no merece necesariamente un juicio moral negativo⁵⁸⁶.

⁵⁸⁴ GARZÓN VALDÉS, E., «Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho», cit., p. 13.

⁵⁸⁵ GARZÓN VALDÉS, E., «Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho», cit., p. 14.

⁵⁸⁶ J. R. DE PÁRAMO se ha referido a la *función civilizatoria* de la hipocresía en «Compromisos, grilletes de arena y nudos corredizos», ZAPATERO, V. (ed.), *Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, (1), cit., p. 444.

Por otra parte, la reducción de la agenda política plantea problemas e inconvenientes, que han sido reconocidos incluso por los defensores de las virtualidades de esta estrategia⁵⁸⁷. La democracia, a través de dicha reducción, y con la consiguiente exclusión del control de la mayoría respecto a determinados temas, tiende a volverse imperfecta. Se produce una trivialización de la discusión pública, desde el momento en que cuestiones consideradas relevantes, y también irresolubles, se apartan de ella y se reconducen a otros escenarios. Además, no siempre las reglas mordaza son neutrales, ya que la exclusión de un tema del debate puede favorecer determinadas posiciones. Junto a lo anterior, también es cierto que la prohibición de la generación de debate público en relación con ciertas materias, puede tener el efecto de acrecentar tensiones, ya que se está negando la posibilidad de que ciertos problemas, de compleja resolución, pero de importancia vital para algunos sujetos, se excluyan del ámbito de la negociación. Sabemos que en democracia existen instituciones que actúan como una válvula de escape de las tensiones sociales, a través de la creación de vías para la resolución de conflictos —que afectan al sujeto o que afectan al grupo— mediante la garantía, en algunos casos, de la posibilidad de negociación, y que formarían parte de lo que Peces-Barba ha denominado «la institucionalización de la resistencia» en el marco de los sistemas democráticos⁵⁸⁸. Junto a esto, hay que contar también con la posibilidad que de la «aversión al conflicto» provoque precisamente que la amenaza del conflicto de convierta una táctica tendente a asegurar posiciones políticas.

⁵⁸⁷ Vid. HOLMES, S. «Las reglas mordaza o la política de la omisión», cit., p. 85 y ss. Vid también SUNSTEIN, C., «Constituciones y democracias: epílogo», cit., pp. 356-357.

⁵⁸⁸ Vid. PECES-BARBA, G., «Desobediencia civil y objeción de conciencia», *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 5, 1988-89, p. 162. Ya James BRYCE se refirió a las tensiones sociales que se pueden producir como consecuencia de la difícil reforma de las constituciones rígidas en *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, cit., p. 135.

Robert A. Dahl también ha subrayado los problemas que se derivan de las políticas de omisión o de las reglas mordaza para la corrección de los procesos democráticos. En su opinión, los criterios que deben regir un proceso democrático son los siguientes: participación efectiva, igualdad de los votos en la etapa decisoria, comprensión esclarecida, y control final del programa de acción. Los procesos a través de los cuáles se toman decisiones en los sistemas democráticos incluyen dos etapas: por una parte, la que se refiere a la fijación del programa de acción; por otra, la que consiste en tomar la decisión. En el primer caso, se seleccionan los asuntos sobre los que se tiene que decidir posteriormente. Afirmar que el pueblo debe tener el control final sobre el programa de acción supone reconocer que «el demos debe ser el único que cuente con la oportunidad de resolver cómo se ordenarán, dentro del programa de acción, las cuestiones que deben decidirse mediante el proceso democrático»⁵⁸⁹. Ello no quiere decir que el pueblo tenga siempre que decidir directamente sobre todos los temas, ya que puede delegar en otras instancias. En todo caso, la reserva del control final sobre el programa de acción supone que se decide «1) qué cuestiones requieren o no requieren decisiones obligatorias; 2) de las que lo requieren, cuáles puede el demos resolver por sí mismo; 3) en qué condiciones delegará su autoridad»⁵⁹⁰. Dicha reserva supone reconocer que el pueblo tiene capacidad para decidir en relación con todos los temas, lo cual no es incompatible con la delegación que pudiera producirse respecto a alguno de ellos, pero sí con la enajenación de la posibilidad de decidir, ya que la enajenación del control final sobre el programa de acción supone vetar en absoluto el tratamiento de determinados temas. La delegación es revocable, mientras que la enajenación no lo es. Por ello, si las reglas mordaza suponen casos de enajenación del control final sobre el programa de acción, plantean,

⁵⁸⁹ DAHL, R. A., *La democracia y sus críticos*, trad. de L. Wolfson, Paidós, Barcelona, 1992, p. 140.

⁵⁹⁰ DAHL, R. A., *La democracia y sus críticos*, cit., p. 141.

de acuerdo con el esquema procedimental propuesto por Dahl, problemas que dificultan la corrección del proceso democrático.

En todo caso, conviene no perder de vista los peligros de la extrema rigidez de un sistema de autorrestricción constitucional. En efecto, de la misma manera que una comunidad puede encontrar buenas razones para atarse, también las puede encontrar para desatarse. Pueden darse nuevas situaciones que justifiquen esta pretensión⁵⁹¹. Pensemos por ejemplo en el mero cambio en la ideas y en las preferencias del grupo, que no necesariamente debe identificarse con el resultado de reacciones caprichosas. También es posible que el sistema haya mostrado sus fallos y carencias y se quiera proceder a la subsanación de los mismos. Puede ser que, en definitiva, factores externos aconsejen transformaciones en el sistema constitucional. Parece evidente que en estos casos la excesiva rigidez de las ataduras constitucionales puede significar un problema por lo menos igual de grave que el que se quiso solucionar en su momento con la estrategia autorre restrictiva⁵⁹².

4. LA «PARADOJA DE LA DEMOCRACIA»: HETERORRESTRICCIONES CONSTITUCIONALES

En el ámbito de las restricciones constitucionales, la paradoja de la democracia, enunciada por Jon Elster se refiere al efecto que dichas restricciones ejercen sobre las generaciones posteriores a aquella que las ha establecido y es enunciada de la siguiente forma: «Cada generación desea ser libre de atar a su sucesora, sin estar atada por sus predecesoras»⁵⁹³. Como el

⁵⁹¹ Vid. ELSTER, J., «Intertemporal Choice and Political Thought», cit., p. 42.

⁵⁹² Una estrategia dirigida a salvar estos problemas apoyándose en la alternativa de la abstracción constitucional es la presentada por FERRERES COMELLA, V., «Una defensa de la rigidez Constitucional», cit., pp. 29 y ss.

⁵⁹³ ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 159. También, vid. ID., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad*, cit., p. 159.

propio Elster admite, la paradoja de la democracia, considerando que la asamblea constituyente tiene auténtica existencia histórica, es «la más cercana analogía en sociedad» a aquella decisión que toma Ulises y que intenta condicionar la actuación futura de sus acompañantes.

El problema de la imposición de obligaciones y de vínculos entre diferentes generaciones ha constituido objeto de atención por parte de la Filosofía política de los últimos doscientos años, que no es sino el marco en el que, en términos generales, se desarrolla el constitucionalismo moderno. Podemos recordar algunos ejemplos. Kant, a la hora de desarrollar las consecuencias del concepto de Ilustración, denunció lo nefasto de la imposición de opiniones a las generaciones futuras, sobre todo en materia religiosa: «Una generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos (presuntamente circunstanciales), depurarlos del error y, en general, avanzar en el estado de su ilustración. Constituiría esto un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial radica precisamente en este progreso. Por esta razón, la posteridad tiene derecho a repudiar esa clase de acuerdos como celebrados de manera abusiva y criminal»⁵⁹⁴. Por otra parte, en la disputa entre Burke y Paine también podemos encontrar diferentes posiciones al respecto⁵⁹⁵, vinculadas sobre todo a una distinta

dad, precompromiso y restricciones, cit., p. 137. Una versión de la paradoja de la democracia es la que enuncia el historiador noruego Jens Arup Seip, y que trae a colación el propio Elster, recogiénola en la obra recién citada: «En política, la gente nunca trata de atarse a sí misma; sólo de atar a los demás» (p. 11). Por su parte, J. R. DE PÁRAMO ha señalado la similitud entre la paradoja de la democracia y «una de las contradicciones centrales del capitalismo: cada capitalista desea bajos salarios para sus propios trabajadores —lo que genera grandes ganancias— y altos salarios para todos los demás, lo que genera una alta demanda», «Compromisos, grilletes de arena y nudos corredizos», cit., p. 451.

⁵⁹⁴ KANT, I., «¿Qué es la Ilustración?», ID., *Filosofía de la Historia*, trad. de E. Imaz, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1985, p. 32.

⁵⁹⁵ Desde un punto de vista general, puede consultarse, FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «La polémica Burke-Paine», en PECES-BARBA, G., FERNÁN-

evaluación del peso de la tradición. En las *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, Edmund Burke reivindica el culto por los antepasados y por la tradición: el objetivo de cualquier reforma que se lleve a cabo en la sociedad debe ser el de conservar la tradición. Su desconfianza respecto al progreso le lleva a considerar que «el espíritu innovador es generalmente el efecto de un temperamento egoísta de limitadas perspectivas»⁵⁹⁶. El disfrute de las libertades es el resultado de la recepción de las mismas en herencia de las generaciones pasadas, respecto a las cuales el protagonismo de las generaciones actuales disminuye: «Al actuar siempre como si estuviéramos en presencia de nuestros venerables antepasados, el espíritu de la libertad —que por sí mismo conduce al desgobierno y al exceso— se templea con una severa gravedad»⁵⁹⁷. Frente a los peligros inherentes a toda destrucción de las instituciones, Burke exhorta a seguir el ejemplo de los antepasados⁵⁹⁸. El contraste con Thomas Paine es radical. En efecto, Paine, en *Derechos del hombre* nos ofrece una vigorosa reivindicación del derecho de las generaciones actuales a regirse por sus propios criterios. Dicha reivindicación supone una negación del derecho a gobernar a la posteridad: «Nunca ha existido, nunca existirá y nunca puede existir un parlamento, ni una categoría de hombres, ni ninguna generación de hombres, en ningún país, en posesión del derecho de vincular y controlar a la posteridad hasta *el fin de los tiempos*, ni de ordenar para siempre cómo se gobernará el mundo ni quién ha de gobernarlo, y por ende todas las cláusulas, leyes o declaraciones en virtud de las cuales sus autores tratan de hacer lo que no tienen el derecho ni las facultades de hacer, ni las facultades para ejecutar, son en sí mismas nulas de toda

DEZ, E., DE ASÍS, R. (dirs.), *Historia de los derechos fundamentales*, tomo II: «Siglo XVIII», vol. II: «La filosofía de los derechos humanos», Dykinson, Madrid, 2001, pp. 369 y ss.

⁵⁹⁶ BURKE, E., *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, trad. de E. Pujals, Rialp, Madrid, 1989, p. 66.

⁵⁹⁷ BURKE, E., *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, cit., p. 67.

⁵⁹⁸ Vid. BURKE, E., *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, cit., p. 252.

nulidad. Cada edad y cada generación deben tener tanta libertad para actuar por sí mismas *en todos los casos* como las edades y las generaciones que las precedieron»⁵⁹⁹. La cuestión del gobierno que se ejerce en cada generación es un asunto que afecta a esa generación y no debe extenderse más allá: «Las circunstancias del mundo cambian constantemente, y también cambian las opiniones de los hombres; y como a quien se gobierna es a los vivos y no a los muertos, son los vivos los únicos que tiene algún derecho en él. Lo que puede considerarse adecuado y juzgarse oportuno en una época, puede considerarse erróneo y juzgarse inoportuno en otra. En esos casos, ¿quiénes han de decidir, los vivos o los muertos?»⁶⁰⁰. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que ninguna generación disfruta del derecho a gobernar el mundo para siempre, Paine defiende el derecho a reformar la Constitución cuando así se considere necesario⁶⁰¹. Y un último ejemplo: en la *Correspondencia* de Thomas Jefferson también encontramos argumentos similares a los empleados por Paine. Posiblemente una de las cartas más significativas al respecto es la dirigida a James Madison el 6 de septiembre de 1789 en la que se propone el principio según el cual ninguna sociedad puede hacer una Constitución perpetua, ni una ley perpetua: «La tierra pertenece a los vivos, y no a los muertos»⁶⁰².

Pues bien, creo que es en el ámbito de las relaciones entre distintas generaciones en el que, de trasladar el esquema sobre las estrategias para superar las carencias derivadas de la debilidad de la voluntad analizadas por Elster, se pueden plantear problemas más relevantes. En efecto, si se quiere aplicar el modelo de racionalidad imperfecta a las relaciones intergene-

⁵⁹⁹ PAINE, Th., *Derechos del hombre*, trad., intr., cronología y notas de F. Santos Fontela, Alianza, Madrid, 1984, p. 36.

⁶⁰⁰ PAINE, Th., *Derechos del hombre*, cit., p. 40.

⁶⁰¹ Vid. PAINE, Th., *Derechos del hombre*, cit., pp. 217-219.

⁶⁰² JEFFERSON, Th., *Autobiografía y otros escritos*, est. prel. y redición de A. Koch y W. Peden, trad. de A. Escotado y M. Sáenz de Heredia, Tecnos, Madrid, 1987, p. 521.

racionales, nos encontraríamos con la situación en la que se niega competencia y racionalidad a las generaciones futuras, y en la que se entiende que seguir la decisión de la generación antigua supone en realidad actuar de manera racional. Si la racionalidad se identifica con la puesta en marcha de los medios tendentes a lograr la preservación y disfrute de los bienes básicos, se estaría otorgando protagonismo a la generación precedente a la hora de identificar y definir esos bienes. Y eso, evidentemente, exige una justificación y un análisis de las posibles contradicciones con los requisitos de los sistemas democráticos. No obstante, el presente análisis exige también actuar con la cautela necesaria desde el momento en que no existe una absoluta identidad entre las situaciones individuales y los contextos sociales, ya que como ha señalado Stephen Holmes, «las naciones no son como individuos en grande; y las constituciones se pueden interpretar mal (no sólo trivializarlas) si las comparamos con nuestras resoluciones de Año Nuevo...»⁶⁰³.

En su defensa del potencial carácter democrático del precompromiso constitucional, Holmes parte de las cuestiones que la constatación de la tensión dicho precompromiso y democracia permite plantear: «¿Cómo se puede reconciliar el ‘consentimiento de los gobernados’ con la garantía de un consentimiento ulterior mediante una convención constitucional? ¿Por qué un marco constitucional, ratificado hace dos siglos, debe ejercer tan enorme poder sobre nuestras vidas actuales? ¿Por qué solamente alguno de nuestros conciudadanos han sido facultados para impedir que se hagan enmiendas a la Constitución? ¿La revisión judicial, cuando está basada en una lealtad supersticiosa a la intención de sus creadores, es compatible con la soberanía popular?»⁶⁰⁴.

⁶⁰³ HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», ELSTER, J., SLAGSTAD, R., (eds.), *Constitucionalismo y democracia*, cit., p. 258.

⁶⁰⁴ HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», cit., p. 217.

Jon Elster ha señalado que «el despotismo y una democracia sumamente desarrollada, por no decir una democracia directa, se basan en el derecho de intervención en todos los dominios, mientras que la democracia constitucional está fundada sobre un conjunto de instituciones estables que no pueden ser anuladas una vez establecidas»⁶⁰⁵. Desde este punto de vista, la democracia implicaría la capacidad permanente de disposición sobre la agenda política, mientras que el constitucionalismo se caracteriza por la presencia de determinadas restricciones en esa agenda⁶⁰⁶. Así, si la función básica de una Constitución es la de formalizar esas restricciones («atar las manos de la comunidad»), podríamos situar como punto de partida del análisis la afirmación —quizás excesiva pero también indicativa del problema que estamos planteando— de que «el constitucionalismo es esencialmente antidemocrático»⁶⁰⁷. Asistiríamos a la pugna entre dos bandos enfrentados, el de los «demócratas, para quienes la constitución es un fastidio, y el de los constitucionalistas, para quienes la democracia es una amenaza. Algunos teóricos se preocupan de que la democracia quede paralizada por la camisa de fuerza constitucional. Otros temen que se rompa el dique constitucional arrastrado por el torrente democrático»⁶⁰⁸.

Me propongo, en lo que sigue, desarrollar un análisis de alguno de los problemas del precompromiso constitucional en su aplicación a las relaciones intergeneracionales. Anterior-

⁶⁰⁵ ELSTER, J., *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad*, cit., p. 159.

⁶⁰⁶ Hay que tener en cuenta que las restricciones no sólo pueden ser materiales, sino también personales, a través de la exclusión de determinadas personas o grupos de personas (extranjeros, inmigrantes) de la deliberación pública. No podemos profundizar en este momento en esta vertiente del problema.

⁶⁰⁷ HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», cit., p. 218.

⁶⁰⁸ HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», cit., p. 219.

mente, con el análisis de la teoría de las reglas mordaza, hici-mos referencia a las autorrestricciones constitucionales. En lo sucesivo, nuestra atención se refiere a los que bien pudiéramos denominar heterorrestricciones constitucionales.

Stephen Holmes es uno de los autores que ha defendido la idea según la cual el constitucionalismo y la democracia no implican una tensión irreconciliable: esa tensión, constituiría más bien uno de los mitos del pensamiento político moderno⁶⁰⁹. Por el contrario, un sistema de frenos y de precompromisos, como el propuesto por el constitucionalismo, puede tener el efecto de aumentar la libertad de los sujetos. Ello implica un cambio en la comprensión de los efectos de las medidas limitadoras establecidas por una Constitución, que ya no se referirían a la limitación de posibilidades de acción, a frenos, sino también a la generación de posibilidades⁶¹⁰. Ello se consigue desde el momento en que las Constituciones establecen *metali-mitaciones*, ésto es límites a los límites impuestos por la mayoría. En ese sentido, señala Holmes, el efecto que las imposiciones constitucionales sobre las generaciones posteriores se transforma: «Por medio de una Constitución, la generación *a* puede ayudar a la generación *c* a protegerse de ser vendida en esclavitud por al generación *b*. Para salvaguardar las posibilidades de los sucesores más distantes, los constitucionalistas restringen las posibilidades de sus sucesores más próximos»⁶¹¹. Así, Holmes subraya las capacidades posibilitantes de las res-

⁶⁰⁹ Vid., además de las obras citadas, HOLMES, S., *Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy*, The University of Chicago Press, 1995.

⁶¹⁰ Se podría hablar así de un «precompromiso capacitante» que no está en relación de vinculación directa con la imperfección o con la irracionalidad. Así, se señala que «incluso la persona más racional puede utilizar técnicas de autorrestricción para lograr más de lo que podría conseguir si lo hiciera de cualquier otro modo», ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 313.

⁶¹¹ HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», cit., p. 248.

tricciones constitucionales, la dimensión capacitadora y no incapacitadora de las reglas constitucionales. La distinción entre reglas regulativas y reglas constitutivas —distinción que se reproduce en el interior de las Constituciones— es útil al respecto. Las segundas posibilitan prácticas a futuro estableciendo marcos y criterios a los que han de ajustarse los desarrollos de esas prácticas.

Podemos encontrar en este punto cierta semejanza con algunos aspectos de la tesis desarrollada por Dworkin, al mantener que el conflicto entre constitucionalismo y democracia es ilusorio. Frente a los críticos del constitucionalismo, recelosos de un modelo que «disminuye el derecho democrático de la mayoría a tener el Derecho que quiere»⁶¹², la tesis de Dworkin es aquella según la cual los derechos son un prerequisite de la democracia. La democracia es, en este sentido, algo más que la regla de las mayorías. Hay determinadas estructuras que una mayoría no puede cambiar, ya que funcionan como prerequisites de la democracia. Dworkin se sirve de la distinción entre reglas constitucionales posibilitadoras (*enabling constitutional rules*) y reglas constitucionales limitadoras (*disabling constitutional rules*). Las primeras sirven para facilitar el surgimiento de la democracia, estableciendo por ejemplo, a la hora de la celebración de las elecciones, la organización del sistema electoral. Las segundas consistirían en restricciones que se imponen a aquellos que han sido elegidos a partir de las reglas posibilitadoras. La tesis de Dworkin es, frente a aquellos temerosos de que las reglas posibilitadoras se vean disminuidas por las reglas limitadoras, que ambas son precondiciones de la democracia. Dworkin defiende de esta manera una concepción constitucional de la democracia frente a una concepción mayoritaria⁶¹³, basada en la premisa mayoritaria (*majoritarian premise*), según

⁶¹² DWORKIN, R., «Constitutionalism and Democracy», *European Journal of Philosophy*, 3/1, 1995, p. 2.

⁶¹³ Vid. DWORKIN, R., *Freedom's Law. The moral reading of the American Constitution*, Harvard University Press, 1996, pp. 17 y ss.

la cual, «algo moralmente importante se pierde o se compromete siempre que una decisión política contradice lo que la mayoría de los ciudadanos preferiría o juzgaría como correcto si ellos reflexionaran sobre la base de una información adecuada»⁶¹⁴.

Dworkin vincula la concepción constitucional de la democracia a una determinada concepción de la acción colectiva. La acción colectiva puede ser entendida de dos maneras⁶¹⁵. La acción colectiva es *estadística* cuando el grupo es el resultado de las acciones individuales de los sujetos miembros del grupo sin que exista ningún sentimiento de que se está actuando como un grupo. Se puede afirmar, por ejemplo, que en la sesión de ayer la cotización del euro descendió respecto al dólar, y en realidad dicho descenso no es el resultado de la actividad de un determinado grupo con sustantividad propia, sino el producto de determinadas acciones individuales concurrentes, respecto de las cuales se puede llevar a cabo una lectura común, como consideración conjunta de sus resultados. La acción colectiva es *comunitaria* (*communal*) cuando no puede ser comprendida como el resultado estadístico de actividades individuales, sino que presupone una entidad diferente y separada respecto a la de los individuos. El ejemplo de la responsabilidad colectiva es ilustrativo al respecto para Dworkin: muchos alemanes se sienten responsables no de lo que otros alemanes hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, sino de lo que Alemania hizo.

A partir de lo anterior, la distinción entre acción colectiva estadística y acción colectiva comunitaria le permite a Dworkin distinguir entre dos concepciones de la democracia. Así, en primer lugar, una concepción estadística de la democracia, según la cual las decisiones políticas son el resultado de los votos de la mayoría; en segundo lugar, una concepción comunitaria de

⁶¹⁴ DWORKIN, R., *Freedom's Law*, cit., p. 21.

⁶¹⁵ Vid. DWORKIN, R., «Constitutionalism and Democracy», cit., pp. 3 y ss.; ID., *Freedom's Law*, cit., pp. 19 y ss.; ID., *A Bill of Rights for Britain*, Chatto Counter Blasts, London, 1990, pp. 35 y ss.

la democracia que afirma que en democracia las decisiones políticas son tomadas por una entidad diferente a la mera mayoría considerada estadísticamente: el pueblo no es en este sentido el resultado de la agregación de sujetos individualmente considerados. Según Dworkin, nuestra posición sobre las precondiciones de la democracia está condicionada por las anteriores concepciones de la democracia. Podría parecer en este sentido que si se asume una concepción estadística de la democracia los derechos no son precondiciones. Sin embargo en ambas concepciones los derechos forman parte de los componentes de esas precondiciones. En realidad, señala Dworkin, el simple hecho de que una decisión haya sido adoptada por una mayoría no suministra legitimidad moral que justifique el sometimiento de la minoría a la decisión mayoritaria. Por eso, la concepción estadística de la democracia es insuficiente respecto a la comunitaria desde el momento en que su propuesta necesita ser complementada por ulteriores elementos. Reconociendo la pluralidad de respuestas posibles en función de las respectivas posiciones que se mantengan en cuestiones de moralidad política, Dworkin afirma que dos condiciones parecen necesarias: «un voto mayoritario carece de la necesaria legitimidad a menos que, en primer lugar, todos los ciudadanos tengan la independencia moral para participar en la decisión política como agentes morales libres, y al menos, en segundo lugar, que el proceso político sea tal que trate a todos los individuos con igual consideración. Si lo anterior es correcto —continúa Dworkin— entonces las precondiciones de la democracia incluyen algunos derechos (...) tendentes a garantizar esas condiciones»⁶¹⁶, como pueden ser la libertad de conciencia, de religión, y de expresión, por ejemplo⁶¹⁷.

⁶¹⁶ DWORKIN, R., «Constitutionalism and Democracy», cit., p. 5.

⁶¹⁷ Precisamente, es esa pluralidad de respuestas posibles la que lleva a Dworkin a distinguir dos formas de acción colectiva comunitaria: integrada y monolítica. En el primer caso, «las actitudes compartidas de los participantes crean una unidad colectiva de responsabilidad, no así una unidad colectiva de

En realidad, es cierto que la presencia de disposiciones constitucionales restrictivas de posibilidades futuras puede funcionar como un eficaz mecanismo de autogobierno o autoadministración colectiva, de la misma manera que las autorrestricciones individuales pueden ser una estrategia encaminada a asegurar bienes o a evitar males futuros. Pero el carácter autónomo de estas medidas, a nivel colectivo o individual, hace que los criterios justificatorios aplicables difieran de aquellos que en su caso serían aceptables en el caso de restricciones heterónomas o autorrestricciones, como aquellas que se producen cuando los efectos de la rigidez constitucional afectan a generaciones futuras. Si la cuestión de la justificación moral de las reglas mordaza, cuando éstas son autónomas, es importante, mucho más lo es la cuestión de la fundamentación en el caso de que sean heterónomas.

Stephen Holmes señala que las autoimposiciones colectivas son un caso de autopaternalismo⁶¹⁸. Creo que hablar de autopaternalismo presenta algunas dificultades conceptuales, ya que el paternalismo se identifica con las conductas encaminadas a salvaguardar los intereses ajenos y no los propios. Nadie es paternalista consigo mismo, cuando actúa de la manera que considera adecuada para lograr determinados objetivos. Lo que hace es, en todo caso, actuar de manera racional. La racionalidad consigo mismo no debería identificarse con el paternalismo. En todo caso, el problema aquí no es el de las autoimposi-

juicio, que permanece completamente individual»; en el segundo caso, «tanto la unidad de responsabilidad como la unidad de juicio se hacen colectivas. Nuevamente, esta es una cuestión de actitudes compartidas», DWORKIN, R., «Igualdad, democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales», en CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 129.

⁶¹⁸ Vid. HOLMES, S., «El precompromiso y la paradoja de la democracia», cit., p. 257. Desde una posición crítica con la posible identificación entre el caso individual y el caso colectivo, R. GARGARELLA también habla de autopaternalismo en referencia al caso Ulises en «Il ruolo dei giudici di fronte al 'terreno proibito'», cit., p. 67.

ciones sino el de las imposiciones que afectan a generaciones futuras.

Existen diversas clasificaciones de las actuaciones paternalistas. Así, se habla de paternalismo fuerte o blando, directo (puro) o indirecto (impuro), negativo o positivo⁶¹⁹. En todo caso, podemos asumir la definición propuesta por Gerald Dworkin: paternalismo es «la interferencia en la libertad de acción de una persona justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores de la persona coaccionada»⁶²⁰. El paternalismo jurídico, por su parte, señala Ernesto Garzón Valdés, «sostiene que siempre hay una buena razón a favor de una prohibición o de un mandato jurídico, impuesto también en contra de la voluntad del destinatario de esta prohibición o mandato, cuando ello es necesario para evitar un daño (físico, psíquico o económico) de la persona a quien se impone esa medida»⁶²¹. Caracterizado así, el paternalismo ofrece zonas de contacto con el moralismo y con el perfeccionismo. No obstante lo que aquí interesa es observar que las medidas paternalistas suponen: 1) la imposición de un comportamiento; 2) a otra persona; 3) con la intención de asegurar los intereses de esa otra persona.

Pues bien, ¿hasta qué punto las heterorrestricciones constitucionales que afectan a las generaciones venideras podrían ser analizadas como manifestaciones de paternalismo jurídico? ⁶²².

⁶¹⁹ Vid. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., *La disponibilidad de la propia vida en el Derecho penal*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, pp. 15 y ss.

⁶²⁰ DWORKIN, G., «El paternalismo» (trad. de J. Malem), en BETEGÓN, J., DE PÁRAMO, J. R., (coords.), *Derecho y moral. Ensayos analíticos*, Ariel, Barcelona, 1990, p. 148.

⁶²¹ Vid. GARZÓN VALDÉS, E., «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, cit., p. 362.

⁶²² HABERMAS alude a esta posibilidad en *Facticidad y validez*, cit., p. 653. Sobre el carácter paternalista de determinadas restricciones a la democracia, como por ejemplo el *coto vedado*, vid. VIDAL GIL, E., «Paradojas de la

Detengámonos en esta cuestión. La situación que se produce en lo que Elster denomina la «paradoja de la democracia» cumple las tres exigencias a las que se acaba de aludir. En efecto, 1) las cláusulas de intangibilidad constitucional suponen la cristalización de determinados contenidos que se excluyen de la negociación y de los que derivan restricciones (positivas o negativas) del comportamiento; 2) esas cláusulas son aplicables a las generaciones futuras, distintas por tanto de aquella que adoptó la decisión; 3) se pretende con ello asegurar espacios de libertad a estas generaciones y la posibilidad de que tomen decisiones en un marco de estabilidad.

La justificación moral del paternalismo puede entenderse como inversamente proporcional a la competencia predicada del sujeto al que se impone la medida paternalista⁶²³. Al mismo tiempo, la competencia se vincula a la capacidad de enfrentarse racionalmente a las diversas situaciones en las que un sujeto se puede encontrar. La competencia básica es la competencia exigible en las circunstancias normales en las que no se exige competencia relativa o específica, que es la referida a actividades y circunstancias concretas y particulares. El sujeto que carece de competencia básica se encuentra en una situación deficitaria, que la intervención paternalista está llamada a superar. Esa situación se caracteriza por un déficit de competencia básica, que convierte a los sujetos en incompetentes básicos y los posiciona respecto a los de más en condiciones de desigualdad negativa. Garzón Valdés considera que un sujeto carece de competencia básica en las siguientes situaciones: a) cuando no conoce elementos relevantes de las circunstancias en las que tiene que desenvolverse; b) cuando su fuerza de voluntad está tan reducida que no tiene la posibilidad de mate-

democracia», *Anuario de Filosofía del Derecho*, VII, 1990, p. 49; ID., «Justificación de la democracia y límites a la decisión por mayorías», cit.

⁶²³ Vid. GARZÓN VALDÉS, E., «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, cit., a quien sigo en este punto. Vid. también RAMIRO AVILÉS, M. A., «A vueltas con el paternalismo jurídico», *Derechos y Libertades*, n.º 15, junio 2006, pp. 211-256.

realizar sus decisiones; c) cuando tiene alteradas, de manera temporal o permanente, sus facultades mentales; d) cuando actúa bajo compulsión; e) cuando, aceptando la importancia de un bien u objetivo, y no queriendo ponerlo en peligro, no quiere utilizar los medios necesariamente conducente a lograr ese bien, siendo así que el sujeto puede disponer de ellos con facilidad. Así, podemos identificar a a) con la falta de información; a b) con la debilidad de la voluntad o *akrasia*; a c) con la demencia; a d) con el sometimiento a la fuerza; y a e) con la irracionalidad si, como se señaló anteriormente la racionalidad supone la relación de adecuación entre fines deseados y actuaciones emprendidas para alcanzar esos fines.

Pues bien, si la anterior caracterización del paternalismo es correcta, y si lo es también la identificación de las heterorrestricciones constitucionales con las medidas paternalistas, quedaría por resolver la cuestión de la incompetencia básica de los destinatarios de esas medidas —las generaciones futuras—, cuestión esta de la que dependería la justificación de esas restricciones. Dicha justificación es especialmente relevante en democracia, habida cuenta de que «la principal razón que nos permite defender la democracia como la mejor forma de gobierno o la menos mala, radica precisamente en el presupuesto de que el individuo concreto, el individuo como persona moral y racional, es el mejor juez de su propio interés»⁶²⁴. En un sistema democrático y constitucional, tendente a maximizar la autonomía de los individuos y en el cual la competencia del individuo está reconocida como regla general, se produce una inversión de esta regla general cuando ya no se trata de decisiones individuales, sino de decisiones colectivas, considerando que respecto a ciertas materias, la regla del mayor número, que es operativa sólo en relación con lo opinable, no debe admitirse⁶²⁵. Corres-

⁶²⁴ BOBBIO, N., «Democrazia ed Europa», recogido en ID., *Teoria generale della politica*, cit., con el título «Dall'ideologia democratica agli universali procedurali», p. 378.

⁶²⁵ Vid. BOBBIO, N., «La regola di maggioranza: limiti e aporie», cit., p. 400.

ponde al constitucionalismo la carga de la prueba de esa incompetencia, para evitar que se le acuse de incurrir, como han hecho otros críticos del gobierno de la mayoría, en el «desprecio por la masa considerada incapaz de gobernar»⁶²⁶.

Precisamente, la denuncia del desprecio o, si se prefiere, de la falta de confianza en las posibilidades cognitivas y de decisión del sujeto constituye una de las bases de los argumentos que ha desarrollado Jeremy Waldron en su análisis de las implicaciones del constitucionalismo.

Según Waldron, cuando en una Constitución se positivizan de manera reforzada los derechos, se está adoptando de alguna manera una determinada posición respecto a los ciudadanos, que es una combinación de autoprotección y de desconfianza. En el primer caso, el sujeto que propone la inclusión de los derechos en la Constitución es consciente de la importancia de esos derechos y pretende por ello garantizar la formulación correcta de los mismos (que es la suya) en la mayor medida posible. Pero al mismo tiempo está expresando una desconfianza hacia los ciudadanos, ya que mantiene la opinión de las concepciones alternativas a la suya son erróneas o no fundamentadas, y piensa, en definitiva, que lo mejor que puede hacer es proteger su posición respecto a los posibles cambios que en su caso pudiera proponer el legislador. Para Waldron, la desconfianza es contradictoria con el reconocimiento de la autonomía y de la responsabilidad que se supone del sujeto del que se reconocen derechos: «Es imposible (...) pensar en una persona como portadora de derechos y no considerarla como alguien que tiene el tipo de capacidad necesaria para averiguar cuáles son sus derechos»⁶²⁷. En efecto, tras los derechos se esconde una determinada concepción de la persona que lo entiende como un sujeto pensante (*thinking agent*) con capacidad de deliberación moral y con capacidad también para asumir y preocuparse de los intereses ajenos y colectivos que trascienden los propios y

⁶²⁶ BOBBIO, N., «La regola di maggioranza: limiti e aporie», cit., p. 384.

⁶²⁷ WALDRON, J., *Derecho y desacuerdos*, cit., p. 299.

particulares. La «fortificación» de los derechos se correspondería, así, con una «concepción predatoria»⁶²⁸ de la naturaleza humana que, como acabamos de señalar, entra en contradicción con aquella otra que concibe a los sujetos como portadores de derechos: «si nuestra única imagen del hombre es la de un animal egoísta en el que no se puede confiar que se preocupe por los intereses de otros, carecemos de una concepción de una autonomía moral dignificada en la que se puedan basar tales discriminaciones de intereses»⁶²⁹. Lo que quiere aseverar Waldron es que la compatibilidad entre una teoría de los derechos (que implica una determinada concepción del sujeto) y la desconfianza en las capacidades democráticas, es ciertamente difícil: «Las razones que me llevan a concebir al individuo humano como portador de derechos son las mismas que me permiten confiar en él como portador de responsabilidades políticas. Es precisamente porque veo a cada persona como un potencial agente moral, dotado de dignidad y autonomía, por lo que quiero confiar en el pueblo *en masse* con la carga del autogobierno»⁶³⁰.

Waldron estaría denunciando la existencia de un doble rasero a la hora de considerar al individuo. La teoría de los derechos predica su dignidad y su autonomía y nos sitúa ante lo que podríamos considerar una concepción optimista del individuo, como portador de derechos. Pero cuando cambiamos la perspectiva y observamos al individuo como participante, como actor colectivo, la concepción es pesimista. Este 'cambio de opinión' respecto al sujeto no parece justificado. Por otra parte, de lo que se trataría también es de analizar si es posible no tanto el cambio de opinión como el drástico cambio de perspectiva: individuo aislado/sujeto político, ya que los derechos respecto a cuyo ejercicio se desconfía (en el plano social) son los mismos cuya titularidad se predica y se intenta garantizar en el plano individual.

⁶²⁸ WALDRON, J., «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», cit., p. 28.

⁶²⁹ *Ibidem*.

⁶³⁰ *Ibidem*.

No obstante, el planteamiento de Waldron en este punto puede suscitar dudas en relación con el papel que una concepción del juez como tercero imparcial encargado de resolver el conflicto puede, en su caso, tener en su teoría. Respecto a los derechos que tienen los ciudadanos, es evidente que pueden existir conflictos a la hora de identificarlos y de interpretarlos. Si bien en última instancia sabemos que los derechos que tenemos son los que están en la Constitución, en ocasiones se producen desacuerdos en relación con la interpretación, o con el alcance, o con el contenido de la norma que desarrolla los derechos y que puede entrar en contradicción con la Constitución. Y es en ese caso cuando se recurre a la decisión del juez. Ello no debería ser observado necesariamente como un signo de desconfianza hacia el sujeto. Si se recurre al juez, no es porque se asuma que el sujeto de los derechos (el ciudadano) carece de la capacidad para determinar qué derechos tiene, sino porque se ha producido un conflicto, o un desacuerdo, en lo que a esa determinación se refiere (entre ciudadanos, o entre ciudadanos y poderes públicos). Excluir la necesidad de que un tercero imparcial intervenga para resolver ese desacuerdo supone una absoluta confianza en la capacidad del sujeto a la hora de resolver los conflictos en los que interviene y supone al mismo tiempo restringir la operatividad de los mecanismos de heterointegración del conflicto. Waldron asume que las condiciones en las que se van a encontrar los ciudadanos a la hora de resolver el conflicto son de igualdad: «...hay *algo* digno de consideración en la posición que estoy examinando de que los portadores de derechos deberían ser los que decidan qué derechos poseen, si es que hay desacuerdos sobre la cuestión, a la vez que parece haber algo desagradablemente inadecuado e irrespetuoso en la tesis de que las preguntas sobre los derechos son demasiado complejas o demasiado importantes como para dejar que las determinen los portadores de derechos mismos en un plano de igualdad»⁶³¹. Waldron está asumiendo que los con-

⁶³¹ WALDRON, J., *Derecho y desacuerdos*, cit., p. 300.

flictos se van a solucionar en un plano de igualdad, lo cual parece ser contradictorio con la realidad, no sólo de los desacuerdos en relación con los derechos, sino con la mayoría de los desacuerdos o conflictos jurídicos. Ello justificaría la intervención de un tercero imparcial en la resolución del conflicto.

5. ¿TENSIÓN IRRESOLUBLE?

Como posiblemente se pueda desprender de lo expuesto hasta este momento, el análisis de lo que parecerían ser las exigencias, respectivamente contrarias, del constitucionalismo y de la democracia permite diversas aproximaciones.

La cuestión que podríamos plantear en este momento es la de hasta qué punto dichas exigencias son extrañas entre sí, o si, por el contrario, pueden ser analizadas dentro de un discurso que abarcara la democracia y el constitucionalismo como realidades vinculadas. Es decir, cuando hablamos de democracia y de constitucionalismo, ¿estamos hablando de cosas diferentes o, por el contrario, estamos haciendo referencia a elementos de un mismo discurso? La disyuntiva es importante, ya que si optamos por la primera posibilidad, podemos plantear el problema en términos de contradicción, mientras que si preferimos la segunda posibilidad, podríamos presentar un planteamiento de la relación de los dos elementos en términos de tensión. La cuestión que habría que afrontar sería entonces la de dilucidar si esa tensión es resoluble o no.

Pues bien, creo que si recordamos en este momento los conceptos de Estado de Derecho y de Constitución que hemos venido manejando a lo largo de esta investigación, podemos estar en condiciones de intentar abordar las cuestiones que acabamos de plantear en el párrafo anterior. En ambos casos, en el del Estado de Derecho y en el de la Constitución, hemos considerado que la dimensión sustancial es definitiva a la hora de proceder a una identificación de los mismos. Los derechos fundamentales, expresión paradigmática de la concepción moral asumida por los Estados democráticos, permiten dotar

de un contenido distintivo al Estado de Derecho frente al Estado «a secas» o frente a otros tipos de Estado. Hemos señalado también que, por lo que a la recepción de dimensiones sustanciales se refiere, existe una vinculación entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Por otra parte, hemos intentado mostrar los rasgos básicos de la Constitución del Constitucionalismo, subrayando la importancia de las dimensiones sustanciales integradas en ella. Con la puesta en marcha de los mecanismos de garantía constitucional, estas dimensiones adquieren una relevancia jurídica inusitada que no hace sino profundizar en el aludido carácter invasivo y expansivo de la Constitución. Recordemos también que hemos reconocido explícitamente que una concepción de la democracia apoyada únicamente en la regla de las mayorías se mostraría como incompleta, necesitando así ser completada por los derechos, como marco sustantivo en el que actúan las mayorías. Si, al pensar en la democracia, hemos subrayado uno de sus aspectos —que no por el hecho de no ser suficiente carece de relevancia— es porque así hemos podido detectar y mostrar de manera más evidente el conflicto al que asistimos en las democracias constitucionales.

Obsérvese que a través de los conceptos de Estado de Derecho, Constitución y democracia, circula una línea común constituida precisamente por los derechos. El proceso de adopción de decisiones en sede democrática asume como uno de sus elementos al reconocimiento y garantía de los derechos. Es más, dicho proceso no es comprensible en manera alguna sin el correcto funcionamiento de determinados derechos, como por ejemplo la libertad de expresión y de opinión o los derechos de participación. Si lo anterior es cierto, podemos llegar a la conclusión de que el funcionamiento de la democracia implica el ejercicio de derechos. A partir de ahí estamos en condiciones de abordar desde una determinada perspectiva la cuestión de la relación entre soberanía popular y derechos constitucionales⁶³².

⁶³² Puede consultarse al respecto, PALOMBELLA, G., *Costituzione e Sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Dedalo, Bari, 1997; FIORA-

Recordemos, en este punto, que Habermas defiende una conexión interna entre ambos, que consiste en que «en el «sistema de los derechos» se recogen exactamente las condiciones bajo las que pueden a su vez institucionalizarse jurídicamente las formas de comunicación necesarias para una producción de normas políticamente autónoma»⁶³³. Estaríamos en presencia, así, de una «cooriginalidad», de una «presuposición recíproca» entre autonomía privada y autonomía pública que permite entender que «el principio democrático sólo pueda aparecer como núcleo de un *sistema* de derechos»⁶³⁴.

¿De lo anterior puede deducirse entonces que el problema que se ha planteado en esta parte del trabajo es en definitiva ficticio? ¿Estamos, empleando una expresión de Jefferson, ante «el sueño de un teórico»?⁶³⁵. No lo creo. Al principio del libro llamé la atención sobre la necesidad de que la Filosofía del Derecho se ocupe de los problemas que se generan a partir de la práctica de los sistemas jurídicos. De la misma manera que no todos los sistemas jurídicos presentan la misma configuración, tampoco presentan los mismos problemas. La tensión entre derechos y democracia, entre Constitución y soberanía popular, se plantea sólo en aquellos sistemas en los que estos conceptos —y sus exigencias— son tomados en serio.

Estamos ante una tensión interna y consustancial al sistema jurídico-político del constitucionalismo democrático contemporáneo; una «tensión vital»⁶³⁶ o, en palabras de Alexy, «un problema insoslayable y permanente»⁶³⁷. Es la tensión entre dos fuer-

VANTI, M., *Costituzione e popolo sovrano. La costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Il Mulino, Bologna, 1998.

⁶³³ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 169.

⁶³⁴ HABERMAS, J., *Facticidad y validez*, cit., p. 187.

⁶³⁵ Vid. JEFFERSON, Th., «Carta a James Madison», 6 de septiembre de 1789, en ID., *Autobiografía y otros escritos*, cit., p. 522.

⁶³⁶ Vid. BIN, R., *Lo Stato di diritto*, cit., p. 53.

⁶³⁷ ALEXY, R., *Teoría de la argumentación jurídica*, cit., p. 433. De tensión «ineliminable» habla J. AGUILÓ en «Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las concepciones de la Constitución», en CARBONELL,

zas que tenderían a dirigirse a polos puestos. El escenario en el que se desarrollan esas fuerzas es el de la política democrática. La tensión es la que se produce, como hemos visto, entre dos criterios de organización de la convivencia. De un lado, el criterio referido a la regla de las mayorías y, de otro, el de los derechos: la voluntad de las mayorías frente a la razón de los derechos. Mientras que el primer criterio exige amplia operatividad para las decisiones mayoritarias, el segundo procede a una disminución de esa operatividad, a través de la exclusión o salvaguarda de objetivos respecto a la negociación, a la deliberación y, en última instancia, a la decisión; en definitiva, a través de la presentación de «triumfos frente a la mayoría». Desde el momento en que se es consciente de la tensión, se pueden comprender fácilmente los peligros derivados del predominio absoluto de alguna de las dos fuerzas en conflicto. Tanto una hegemonía de la regla de las mayorías, como de las potencialidades restrictivas respecto a aquella por parte de los derechos, desembocaría en una desfiguración del sistema democrático, que se produciría, por ejemplo, allí donde, con la intención de eliminar la posibilidad de «suicidio» del sistema, se estrangulaban los rasgos distintivos del mismo⁶³⁸. El reto que la tensión le plantea al sistema democrático es precisamente el del equilibrio o, en palabras de Elster, el de conseguir «la estrechez óptima de las ataduras»⁶³⁹ a las que se somete a los mecanismos decisorios en democracia. Y dentro del sistema democrático, el reto se le plantea en particular a la Constitución, desde el momento en que suya es la responsabilidad de estabilizar la relación entre continuidad y

M., GARCÍA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*, cit., p. 237. También LA TORRE, M., «Democrazia», en LA TORRE, M., ZANETTI, G., *Seminari di Filosofia del diritto*, Rubbetino, Soveria Mannelli, 2000, pp. 216-217.

⁶³⁸ E. GARZÓN VALDÉS ha estudiado la capacidad autodestructiva de la democracia representativa y del mercado y la posibilidad de establecer límites éticos en ambos casos en «Instituciones suicidas», cit.

⁶³⁹ ELSTER, J., *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, cit., p. 323.

discontinuidad en el marco de la ordenación social⁶⁴⁰. En definitiva, estamos ante el problema del diseño institucional óptimo, que en este caso, necesariamente, debe estar basado en el equilibrio⁶⁴¹. Y ahí, las propuestas y los instrumentos son múltiples. Así, se ha propuesto una Constitución más flexible pero mejor garantizada⁶⁴², una clarificación de los criterios que determinan el «atrinceramiento» de los derechos en la Constitución⁶⁴³, un constitucionalismo «débil», que vincule el diseño institucional adecuado a las circunstancias del contexto⁶⁴⁴, un modelo en el que el control de constitucionalidad sea enervable a través de la mayoría parlamentaria ordinaria que se exige para la aprobación de las leyes⁶⁴⁵ o la imprescindible vinculación al Parlamento del último órgano competente para la atribución de significado a las normas de derechos fundamentales⁶⁴⁶.

En todo caso, creo que la solución que se ofrezca al problema pasa, en todo caso, por una reivindicación de la «dignidad de la legislación»⁶⁴⁷. Me parece que en un contexto democrático es difícil renunciar a la necesidad de «un cuerpo firme de *leyes*, entendidas como vehículos normativos coherentes de reglas generales, lo más precisas que sea posible razonablemente estables, y a las que todos, profesionales liberales, jueces y funcio-

⁶⁴⁰ Vid. GRIMM, D., «Il futuro della costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*, cit., p. 156.

⁶⁴¹ Otras propuestas, como la de R. M. JIMÉNEZ CANO, confían la articulación del modelo a la exclusiva primacía del proceso democrático. Vid. *Democracia con motivos*, Dykinson, Madrid, 2013, en particular, pp. 151 y ss.

⁶⁴² Vid. PRIETO SANCHÍS, L., «Constitución y democracia», cit. p. 173.

⁶⁴³ Vid. LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., pp. 219 y ss.

⁶⁴⁴ Vid. BAYÓN, J. C., «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», cit., pp. 127 y ss.

⁶⁴⁵ Vid. RUIZ MIGUEL, A., «Constitucionalismo y democracia», *Isonomía*, n.º 21, 2004, p. 76.

⁶⁴⁶ ASÍS ROIG, R. DE., «Los derechos y la argumentación judicial», *Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, N.º. 10, 2004, pp. 13 y ss.

⁶⁴⁷ Vid. WALDRON, J., *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, 1999.

narios, deban una especial y acentuada deferencia en el momento de la aplicación del Derecho»⁶⁴⁸. Se está pensando en una legislación que, comprometida con las dimensiones morales asumidas y compartidas por el sistema democrático —y por tanto con la Constitución—, tenga la capacidad de expresar en cada momento el parecer de la soberanía popular contribuyendo así a configurar un Derecho cada vez más autónomo y por tanto más ético. Ello implicaría, entre otras cosas, la desmitificación del momento constituyente —entendido como momento diametralmente opuesto al legislador y liberado de los vicios y pasiones que concurren en éste⁶⁴⁹— y una justa apreciación de las virtudes del legislador democrático. Y, detrás de todo ello, una reivindicación de lo que Waldron considera «el derecho de los derechos», es decir el derecho de participación⁶⁵⁰, detrás del cual existe una determinada visión del individuo como ser digno, autónomo, capaz de autogobernarse y de establecer un diálogo con los demás: es decir, el mismo optimismo moral en el que se apoya una teoría de los derechos⁶⁵¹. Derecho de participación que es más necesario en un marco como el de las sociedades que constituyen el ámbito del constitucionalismo contemporáneo, caracterizadas por pluralidad y el conflicto. Es precisamente en presencia de éste donde, como nos ha recordado Waldron, se exige el desarrollo de una teoría de la autoridad cuya función debe ser la de aportar criterios relativos a quién y a través de qué mecanismos se supera el conflicto, no para reemplazar a la teoría de los derechos, sino para complementarla⁶⁵².

⁶⁴⁸ LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 219.

⁶⁴⁹ Vid. ELSTER, J., «Argumenter et négocier dans deux Assemblées constituantes», *Revue Française de Science Politique*, vol. 44, n.º 2, avril 1994, pp. 187 y ss. También REY PÉREZ, J. L., *La democracia amenazada*, Universidad de Alcalá, 2012, pp. 31 y ss. Y LAPORTA, F. J., *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., p. 223.

⁶⁵⁰ Vid. WALDRON, J., *Derecho y desacuerdos*, cit., pp. 277 y ss.

⁶⁵¹ Vid. WALDRON, J., «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», cit., pp. 37-38.

⁶⁵² Vid. WALDRON, J., *Derecho y desacuerdos*, cit., p. 291.

En definitiva: el mantenimiento de un concepto sustantivo de Estado de Derecho vinculado, como se ha visto, a la noción de democracia y a la de Constitución, permite integrar las exigencias contrarias de ambas. El Estado de Derecho, a través del imperio de la ley, entendido en un sentido amplio —imperio del Derecho— permite dotar a las relaciones sociales de la estabilidad suficiente⁶⁵³, prolongable en el tiempo, indispensable para el desarrollo de los planes de vida de los sujetos en el marco de contextos paramétricos, dotados por tanto de la suficiente certeza. Junto a esto, el Estado de Derecho, a través de su legalidad selectiva, de la que constituyen parte esencial los derechos fundamentales, somete a control la acción del Poder, satisfaciendo así una de las exigencias de las democracias contemporáneas, que son, en definitiva, democracias constitucionales. La que podía parecer aparente contradicción se torna por tanto en tensión irresoluble, en tanto que consustancial a los rasgos del Estado de Derecho. Creo que esto es algo que supo ver en su momento Kelsen en su escrito sobre «Los fundamentos de la democracia» cuando, por una parte, afirmaba la existencia de «un cierto antagonismo» entre el principio democrático (el poder del pueblo es ilimitado, «El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación» [Declaración de 1789], y el principio liberal (limitación del poder democrático); y, por otra, reconocía que la democracia moderna no puede separarse del liberalismo político⁶⁵⁴. El carácter irresoluble de la tensión nos obliga a aspirar a administrarla con prudencia y a explorar nuevas estrategias intermedias entre las cuales la deliberación puede ocupar un papel protagonista. Al fin y al cabo, Kelsen tenía razón, una vez más, cuando afirmaba que «democracia es discusión»⁶⁵⁵.

⁶⁵³ HABERMAS se refiere a la «estabilización de expectativas de comportamiento» en *Facticidad y validez*, cit., p. 211.

⁶⁵⁴ Vid. KELSEN, H., «Los fundamentos de la democracia», cit., pp. 210 y 243.

⁶⁵⁵ KELSEN, H., «Los fundamentos de la democracia», cit., p. 243.

BIBLIOGRAFÍA

- AARNIO. A., *Lo racional como razonable*, trad. de E. Garzón Valdés, revisión de E. Garzón Valdés y R. Zimmerling, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
- AGUILÓ REGLA, J., «Sobre la Constitución del Estado Constitucional», *Doxa*, n.º 24, 2001.
- «Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional», *Doxa*, n.º 26, 2003.
- «Cuatro pares de concepciones opuestas de la Constitución», en AGUILÓ REGLA, J., ATIENZA, J., RUIZ MANERO, J, *Fragmentos para una teoría de la Constitución*.
- «Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las concepciones de la Constitución» en CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*.
- AGUILÓ REGLA, J., ATIENZA, J., RUIZ MANERO, J, *Fragmentos para una teoría de la Constitución*, Iustel, Madrid, 2007.
- ALEXANDER, L. (ed.), *Constitutionalism. Philosophical Foundations*, Cambridge University Press, 1998.
- ALEXY, R., *Teoría de la argumentación jurídica*, trad.de M. Atienza e I. Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.
- *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
- *El concepto y la validez del Derecho*, trad. de J. M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1994.
- «Los principales elementos de mi Filosofía del Derecho», *Doxa*, n.º 32, 2009.

- ALEXI, R., BULYGIN, E., *La pretensión de corrección del derecho. La polémica sobre la relación entre derecho y moral*, trad. e introd. de P. Gaido, Universidad Externado de Colombia, 2001.
- ALEGREM, M., GARGARELLA, R., ROSENKRATZ, C. F., *Homenaje a Carlos S. Nino*, La Ley-Universidad de Buenos Aires, 2008.
- ANDRÉS IBÁÑEZ, P., «Introducción», en ID. (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Trotta, Madrid, 1996.
- ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., «¿Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli» *Derechos y Libertades*, n.º 2, 1993-1994.
- *Poder, Ordenamiento jurídico, derechos*, Dykinson, Madrid, 1997.
- «Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales», *Sistema*, n.º 158, 2000.
- «Positivismo jurídico y sistemas mixtos», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*.
- «Estado de Derecho, crisis de la ley y Estado constitucional», ZAPATERO, V. (ed.), *Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, (2).
- «El Estado constitucional: apuntes para una comprensión de su significado histórico», *Revista de Historiografía*, n.º 9, V, 02/2008.
- «Argumentos para una teoría de los derechos sociales», *Revista de Derecho del Estado*, Universidad Externado de Colombia, n.º 24, julio 2010.
- «Los derechos fundamentales en *Principia Iuris* (o los límites de la teoría del Derecho)», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXIX, 2013.
- ARCOS RAMÍREZ, F., *La seguridad jurídica. Una teoría formal*, Dykinson, Madrid, 2000.
- «Una defensa de la moral interna del Derecho», *Derechos y libertades*, n.º 9, 2000.
- ARNAUD A.-J.-FARIÑAS DULCE, M. J., *Sistemas jurídicos: elementos para un análisis sociológico*, BOE-Universidad Carlos III de Madrid, 1996.
- ARROW, K. J., «Values and Collective Decision-Making», en LASLETT, P., RUCIMAN, W. G., (eds.), *Philosophy, Politics and Society*.
- ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J., «Dejemos atrás el positivismo jurídico», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*.

- BALLESTEROS, J. (ed.), *Derechos humanos*, Tecnos, Madrid, 1992.
- BARATTA, A., «El Estado de Derecho. Historia del concepto y problemática actual», *Sistema*, n.º 17-18, 1977.
- BARBERÀ, A., (ed). *Le basi filosofiche del Constituzionalimo*, Laterza, Roma, 1998.
- BARBERIS, M., «Progetto per la voce 'Costituzione' di una enciclopedia», *Filosofia Politica*, a. V, n.º 2, 1991.
- «Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- «L'eterogeneità del bene. Giuspositivismo, giusnaturalismo e pluralismo etico», *Analisi e diritto*, 2002-2003.
- «I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico», *Analisi e diritto*, 2005.
- *Etica per giuristi*, Laterza, Bari, 2006.
- *Europa del diritto*, il Mulino, Bologna, 2008.
- BARRANCO AVILÉS, M. C., *Derechos y decisiones interpretativas*, Marcial Pons, Madrid, 2004.
- «Los contenidos materiales de las Constituciones y la posibilidad del constitucionalismo positivista», en RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*.
- BARTOLOMEI, F., «Lo 'Stato di diritto' nel rapporto di tensione esistente tra legge e diritto», *Diritto e Società* 1997/4.
- BASCIU, M. (ed.), *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Giuffré editore, Milano, 1996.
- BAYÓN, J. C., «Derechos, democracia, Constitución», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- «Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo», en VVAA., *Constitución y derechos fundamentales*.
- BETEGÓN, J., DE PÁRAMO, J. R., (coords.), *Derecho y moral. Ensayos analíticos*, Ariel, Barcelona, 1990.
- BICKEL, A., *The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar of Politics*, Yale University Press, New Haven, 1962.
- BIN, R., *Lo Stato di diritto*, il Mulino, Bologna, 2004.
- BINGHAM, T., *The Rule of Law*, Penguin Books, London, 2011.
- BLANCO VALDÉS, R., *El valor de la Constitución*, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
- BOBBIO, N., «Algunos argumentos contra el Derecho Natural», en VVAA., *Crítica del Derecho natural*.

- *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, 1965.
- «Governo degli uomini o governo della legge», en ID., *Il futuro della democrazia*
- *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991.
- *Teoría General del Derecho*, trad. de E. Rozo Acuña, Debate, Madrid, 1991.
- «Dal diritto al potere e viceversa», ID., *Diritto e Potere. Saggi su Kelsen.*
- *Diritto e Potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.
- «La regola di maggioranza: limiti e aporie», en ID., *Teoria generale della politica.*
- «Democrazia ed Europa», recogido en ID., *Teoria generale della politica*, con el título «Dall'ideologia democratica agli universali procedurali».
- *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino, 1999.
- BÖCKENFORDE, E. W., «La democrazia como principio constitucional» ID., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia.*
- «Origen y cambio del concepto de estado de Derecho», ID., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia.*
- *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, trad. de R. Agapito Serrano, Trotta, Madrid, 2000.
- BOHMAN, J., REHG, W., (eds.), *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, Massachusetts Institute of Technology, 1997.
- BONGIOVANNI, G., (ed.), *La Filosofia del Diritto Costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*, Clueb, Bologna, 1998.
- «Stato di diritto e giustizia costituzionale. Hans Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica.*
- *Teorie «costituzionalistiche» del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin*, Clueb, Bologna, 2000.
- BOVERO, M., *Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores*, trad. de L. Córdova Vianello, Trotta, Madrid, 2002.
- BRYCE, J., *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962.
- BUNGE, M., *La causalidad*, trad. H. Rodríguez, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1997
- BURKE, E., *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*, trad. de E. Pujals, Rialp, Madrid, 1989.

- CABO, C. de, *Sobre el concepto de ley*, Trotta, Madrid, 2000.
- CALSAMIGLIA, A., «Justicia, eficiencia y optimización de la legislación», en ID., *Racionalidad y eficiencia del Derecho*, Fontamara, México, 1993.
- CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*, Trotta, Madrid, 2003.
- (ed.), *Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos*, Trotta, Madrid, 2007.
- CARBONELL, M., GARCIA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010.
- CARPIZO, J., «El Poder: su naturaleza y su tipología», VVAA, *Constitución y constitucionalismo hoy*.
- CARRÉ DE MALBERG, R., *Teoría General del Estado*, estudio preliminar de H. Fix Zamudio, trad. de J. Lión Depetre, UNAM-Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
- CASALINI, B., «Sovranità popolare, governo della legge e governo dei giudici negli Stati Uniti d'America», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- CASTILLO, M., «La question de l'autolimitation de l'État», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 13, 1988.
- CATANIA, A., «Diritto naturale e diritto positivo nella tradizione occidentale. Costituzione e diritti umani», *Ragion Pratica*, 1998/11.
- CELANO, B., «Diritti, principi e valori nello status costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione», *Analisi e diritto*, 2004.
- «Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto», *Filosofia Politica*, a. XIX, n. 3, dicembre 2005.
- COMANDUCCI, P., *Assaggi di metaetica*, Giappichelli editore, Torino 1992.
- «Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico», trad. de M. Carbonell, en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- «Constitucionalización y neoconstitucionalismo», en COMANDUCCI, P., AHUMADA, M. A., GONZÁLEZ LAGIER, D., *Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo*.
- COMANDUCCI, P., AHUMADA, M. A., GONZÁLEZ LAGIER, D., *Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009.
- COSTA, P., «Lo Stato di diritto: un'introduzione storica», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.

- CRAIG, P. P., «Formal and substantive conceptions of the rule of law», *Diritto Pubblico*, vol. 1, 1995.
- CUENCA GÓMEZ, P., «Acerca del carácter dinámico del sistema jurídico en la teoría de Kelsen y su compatibilidad con el constitucionalismo», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, n.º 15, 2007.
- *El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica*, Dykinson, Madrid, 2008.
- «Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez jurídica», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXV, 2008-2009.
- «La compleja teoría de la validez jurídica de Principia Iuris. Una revisión crítica», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, núm. 26, 2012
- CHEVALLIER, J., *L'État de Droit*, Montchrestien, Paris, 1992.
- DAHL, R. A., *La democracia y sus críticos*, trad. de L. Wolfson, Paidós, Barcelona, 1992.
- DAHRENDORF, R., *Ley y orden*, trad. de L. M. Díez-Picazo, Cívitas, Madrid, 1994.
- DE ASÍS ROIG, R., «Notas sobre Poder y Ordenamiento», *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 36, 1992.
- *Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho*, Dykinson, 1999.
- «De nuevo sobre la relación entre el Derecho y el Poder», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XVII, 2000.
- *Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al Poder*, Dykinson, Madrid, 2000.
- *Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación dualista*, Dykinson, Madrid, 2001.
- «Los derechos y la argumentación judicial», *Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, N.º. 10, 2004.
- DE LUCAS, F. J., «Sobre la justificación de la democracia representativa», *Doxa*, n.º 6, 1989.
- «Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos», en BALLESTEROS, J. (ed.), *Derechos humanos*.
- DÍAZ, E., *Estado de Democrático y Sociedad democrática*, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1973.
- *Sociología y Filosofía del Derecho*, Taurus, Madrid, 1984.
- «Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales», *Sistema*, n.º 125, 1995.

- *Curso de Filosofía del Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 1998.
- «Estado de Derecho y derechos humanos (seguido de diez tesis)», VVAA., *Ética Pública y Estado de Derecho*, Fundación Juan March, Madrid, 2000.
- «Estado de Derecho y legitimidad democrática», DÍAZ, E., COLOMER, J. L., (eds.), *Estado, justicia, derechos*.
- *El derecho y el poder. Realismo crítico y filosofía del derecho*, Dykinson, Madrid, 2013.
- DÍAZ, E.-RUIZ MIGUEL, A., (eds.), *Filosofía Política II: Teoría del Estado*, Trotta-CSIC, Madrid, 1996.
- DÍAZ, E., COLOMER, J. L., (eds.), *Estado, justicia, derechos*, Alianza, Madrid, 2002.
- DICEY, A. V., *Introduction to the study of the Law of the Constitution*, Liberty Fund, Indianapolis, 1982.
- DONNARUMMA, R. M., «Una tematica sempre attuale: lo «Stato di diritto»», *Diritto e Società*, 1994/1.
- DORADO PORRAS, J., *La lucha por la Constitución. Las teorías del 'Fundamental Law' en la Inglaterra del siglo XVII*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.
- *Iusnaturalismo y positivismo jurídico: una revisión de los argumentos en defensa del iuspositivismo*, Dykinson, Madrid, 2005.
- DUPRET, B., «Il 'governo dell legge' nei limiti dell'etica islamica. Il caso egiziano», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- DWORKIN, G., «El paternalismo» (trad. de J.Malem), en BETEGÓN, J., DE PÁRAMO, J. R., (coords.), *Derecho y moral. Ensayos analíticos*.
- DWORKIN, R., *Los derechos en serio*, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona, 1984.
- «Rights as trumps», en WALDRON, J. (ed.), *Theories of Rights*.
- *A Matter of Principle*, Harvard University Press, 1985.
- *A Bill of Rights for Britain*, Chatto Counter Blasts, London, 1990.
- «Constitutionalism and Democracy», *European Journal of Philosophy*, 3/1, 1995.
- *Freedom's Law. The moral reading of the American Constitution*, Harvard University Press, 1996.
- *Law's empire*, Hart Publishing, Oxford, 1998.
- «Igualdad, democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales», en CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*.

- ELSTER, J., *Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad*, trad. de E. Lynch, Península, Barcelona, 1988.
- «Intertemporal Choice and Political Thought», en LOEWENSTEIN, G., ELSTER, J., (eds.), *Choice over time*.
 - «Argumenter et négocier dans deux Assemblées constituantes», *Revue Française de Science Politique*, vol. 44, n.º 2, avril 1994.
 - *Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad* (1984), trad. de J. J. Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
 - *El cemento de la sociedad. Las paradojas del desorden social*, trad. de A. L. Bixio, Gedisa, Barcelona, 1997.
 - «Régimen de mayorías y derechos individuales», en SHUTE, S., HURLEY, S., (eds.) *De los derechos humanos*, trad. de H. Valencia, Trotta, Madrid, 1998.
 - «Introducción», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*.
 - (comp.), *La democracia deliberativa*, trad. de J. M. Lebrón, Gedisa, Barcelona, 2001.
 - *Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones*, trad. de J. Mundó, Gedisa, Barcelona, 2002.
- ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*, estudio introductorio de A. Herrera, trad. de M. Utrilla de Neira, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
- EMERI, CL., «L'Etat de droit dans les systèmes polyarchiques européens», *Revue Française de Droit Constitutionnel*, 9, 1992.
- ENDICOTT, TH. A. O., «The impossibility of the Rule of Law», ID., *Vagueness in Law*, Oxford University Press, 2000.
- «Law is necessarily vague», *Legal Theory*, 7, 2001.
- ESCUADERO ALDAY, R., *Positivismo y moral interna del Derecho*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
- «La moral interna del Derecho como objeto de debate (Respuesta a J. Rodríguez-Toubes y R. García Manrique)», *Derechos y Libertades*, n.º 10, 2001.
 - «Argumentos para la recuperación de la teoría de Lon L. Fuller», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIX, 2002.
- FALLON, R. H., ««The rule of law» as a concept in constitutional discourse», *Columbia Law Review*, vol. 97, n.º 1, 1997.
- FARALLI, C., «Stato», en BARBERÀ, A., (ed). *Le basi filosofiche del Costituzionalismo*.
- FARRELL, M. D., *Hacia un criterio empírico de validez*, Astrea, Buenos Aires, 1972.

- FASSÓ, G., «Stato di diritto e Stado di giustizia», *Atti del VI Congresso Nazionale di Filosofia del Diritto*, vol. I, Milano, 1963
- FERNÁNDEZ GARCÍA, E., «Ética, Derecho y política ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?, ID., *Filosofía Política y Derecho*.
- *Filosofía Política y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 1995.
- «Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho», *Sistema*, n.º 138, 1997.
- «El iusnaturalismo», en GARZÓN VALDÉS, E., LAPORTA, F. J., (eds.), *El Derecho y la Justicia*.
- «El Derecho y otros órdenes normativos», PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R., (eds.), *Curso de Teoría del Derecho*.
- «La polémica Burke-Paine», en PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R. (dirs.), *Historia de los derechos fundamentales*, tomo II: «Siglo XVIII», vol. II: «La filosofía de los derechos humanos».
- FERRAJOLI, L., «Note critiche ed autocritiche intorno alla discussione su *Diritto e ragione*», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*.
- *Derecho y razón*, trad. de P. Andrés Ibáñez y otros, Trotta, Madrid, 1995.
- *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale*, Laterza, Roma, 1997.
- «Democrazia e costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*.
- «Lo Stato di diritto fra passato e futuro», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- «Entrevista a L. Ferrajoli», (G. Pisarello y R. Soriano), *Isonomía*, n.º 9, 1998.
- *Derechos y garantías. La ley del más débil*, trad. de P. Andrés Ibáñez y A. Greppi, Trotta, Madrid, 1999.
- «Garantías», *Jueces para la Democracia*, n.º 38, julio 2000.
- «Derechos fundamentales», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*.
- «Los derechos fundamentales en la teoría del Derecho», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*.
- «Los fundamentos de los derechos fundamentales», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*.
- *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, edic. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 2001.

- *Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia*, Laterza, Bari, 2007.
- FERRERES COMELLA, V., *Justicia constitucional y democracia*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.
- «Una defensa de la rigidez Constitucional», *Doxa*, n.º 23, 2000.
- FIORAVANTI, M., *Stato e costituzione: materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli editore, Torino, 1993.
- *Costituzione e popolo sovrano. La costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Il Mulino, Bologna, 1998.
- *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, trad. de M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2001.
- «Costituzione e stato di diritto», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*.
- «Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni preliminari sulla tradizione europeo-continentale», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*.
- «Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*.
- «Costituzione e politica: bilancio di fine secolo», en ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*.
- *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, II, Giuffrè, Milano, 2001.
- FISHKIN, J., *Democracia y deliberación: nuevas perspectivas para la reforma democrática*, trad. de J. Malem, Ariel, Barcelona, 1995.
- FREEMAN, S., «Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment», *Philosophy and Public Affairs*, 29/4, 2000.
- FULLER, L. L., *La moral del Derecho*, trad. de F. Navarro, Trillas, México, 1967.
- GALIZIA, M., «Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg», *Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno*, 2, 1973.
- GALLIE, W. B., «Essentially Contested Concepts», *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 56, 1955-56.
- GARCÍA AMADO, J. A., «La Filosofía del Derecho de Jürgen Habermas», *Doxa*, n.º 13, 1993.
- *Hans Kelsen y la norma fundamental*, Marcial Pons, Madrid, 1996.

- «Habermas y el Derecho», en GARCÍA AMADO, J. A., (coord.), *El Derecho en la teoría social. Diálogo con catorce propuestas actuales*.
- (coord.), *El Derecho en la teoría social. Diálogo con catorce propuestas actuales*, Dykinson, Madrid, 2001.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Cívitas, Madrid, 1982.
- «Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución», *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 10, 1984.
- *La lengua de los derechos. La formación del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa*, Alianza, Madrid, 1994.
- GARCÍA FIGUEROA, A., «El no positivismo principialista en *Il diritto mite* de Gustavo Zagrebelsky», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996
- *Principios y positivismo jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.
- «La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- GARCÍA MANRIQUE, R., «Acerca de la moralidad intrínseca del Derecho», *Derechos y Libertades*, n.º 10, 2001.
- *El valor de la seguridad jurídica*, Fontamara, México, 2007.
- GARCÍA PASCUAL, C., *Legitimidad democrática y Poder judicial*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1996.
- GARCÍA PELAYO, M., *Las transformaciones del Estado contemporáneo*, Alianza, Madrid, 1982.
- «Estado legal y Estado constitucional de Derecho», *Obras completas*, vol. III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
- GARGARELLA, R., *La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial*, Ariel, Barcelona, 1996.
- «Il ruolo dei giudici di fronte al 'terreno proibito'», *Ragion Pratica*, 1998/10.
- GARZÓN VALDÉS, E., «Representación y democracia», *Doxa*, n.º 6, 1989.
- «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, ID., *Derecho, ética y política*.
- *Derecho, ética y política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
- «Instituciones suicidas», *Isegoría*, n.º 9, 1994.
- «Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho», *Claves de razón práctica*, n.º 101, abril 2000.
- *Consenso, legitimidad y democracia*, Fontamara, México, 2013.

- GARZÓN VALDÉS, E., LAPORTA, F. J., (eds.), *El Derecho y la Justicia*, Trotta-CSIC-BOE, Madrid, 1996.
- GASCÓN ABELLÁN, M., «El imperio de la ley. Motivos para el desencanto», *Jueces para la democracia*, n.º 32, 1998.
- GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli ed., Torino, 1993.
- GIRI, A. K., «I 'governo della legge' e la società indiana. Dal colonialismo al post-colonialismo», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- GONZÁLEZ VICÉN, F., «La filosofía del Derecho como concepto histórico», en ID., *Estudios de Filosofía del Derecho*, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 1979.
- GOYARD-FABRE, S., «L'État du droit et la démocratie selon Kelsen», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 17, 1990.
- GOZZI, G., (ed.), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- «Storia e prospettive del costituzionalismo», en BONGIOVANNI, G., (ed.), *La Filosofia del Diritto Costituzionale e i problemi del liberalismo contemporaneo*.
- «Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- GRIMM, D., «Il futuro della costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*.
- GUASTINI, R., «Note su Stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico», en MONTANARI, B., (ed.), *Stato di diritto e trasformazione della politica*.
- «Derecho dúctil, Derecho incierto», trad. de M. Gascón, *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996-97.
- «La constitución como límite a la actividad legislativa», trad. de A. Greppi, *Derechos y Libertades*, n.º 8, 2000.
- «Implementing the Rule of Law», *Analisi e diritto*, 2001.
- «La «constitucionalización» del Ordenamiento jurídico: el caso italiano», trad. de J. M. Lujambio, en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- «Sobre el concepto de Constitución», en CARBONELL, M. (ed.), *Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos*.
- GUEST, A. G., (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, 1961.

- HABERMAS, J., «¿Cómo es posible la legitimidad por vía de la legalidad?», trad. de M. Giménez Redondo, *Doxa*, n.º 5, 1988.
- «Derecho natural y revolución», en ID., *Teoría y praxis. Estudios de filosofía social*, trad. de S. Más Torres y C. Moya, Tecnos, Madrid, 1990.
- *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*, intr. y trad. de M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998.
- «El vínculo interno entre Estado de Derecho y Democracia», ID., *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*.
- *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*, trad. de J.C. Velasco Arroyo y G. Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999.
- HABERMAS, J., RAWLS, J., *Debate sobre el liberalismo político*, intr. de F. Vallespín, trad. de G. Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1998.
- HART, H.L.A., «Positivism and the Separation of Law and Morals», ID., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1983.
- «El nuevo desafío al positivismo jurídico» (trad. de L. Hierro. F. Laporta y J. R. de Páramo), *Sistema*, 36, 1980.
- *El concepto de Derecho*, trad. de G. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990.
- «Postscript», ID., *The concept of Law*, second edition, ed. by P. A. Bulloch and J. Raz, Clarendon Press, Oxford, 1994.
- HAYEK, F. A. *Los fundamentos de la libertad*, 3ª edic, trad. de J. V. Torrente, Unión Editorial, Madrid, 1978.
- HELLER, H., *Teoría del Estado*, trad. de L. Tobío, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
- «¿Estado de Derecho o dictadura?», ID., *Escritos políticos*, trad. de S. Gómez de Arteche, prólogo y selección de A. López Pina, Alianza, Madrid, 1985.
- HERMIDA DEL LLANO, C., *J. L. L. Aranguren. Estudios sobre su vida, obra y pensamiento*, Dykinson-Universidad Carlos III de Madrid, 1997.
- HIERRO, L., «El imperio de la ley y la crisis de la ley», ID., *Estado de Derecho. Problemas actuales*, Fontamara, México, 1998.
- «Justicia, igualdad y eficiencia», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 2, 1998.
- HOERSTER, N., «En defensa del positivismo jurídico», en ID., *En defensa del positivismo jurídico*, trad. de Jorge M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1992.

- HOLMES, S. «Las reglas mordaza o la política de la omisión», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*.
- «El precompromiso y la paradoja de la democracia», ELSTER, J., SLAGSTAD, R., (eds.), *Constitucionalismo y democracia*.
- *Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy*, The University of Chicago Press, 1995.
- HOMERO, *Odisea*, trad. de L. Segala Estalela, Círculo de Lectores, Barcelona, 1971.
- HONGJU KOH, H., SLYE, R. C., (eds.), *Deliberative Democracy and Human Rights*, Yale University Press, 1999.
- IGLESIAS VILLA, M., *El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento jurídico*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.
- «Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional», *Doxa*, n.º 22, 2000.
- «Es realmente superfluo el Derecho? Justicia política e insularidad del razonamiento jurídico», en ALEGREM, M., GARGARELLA, R., ROSENKRATZ, C. F., *Homenaje a Carlos S. Nino*.
- IHERING, R. v. *El fin en el Derecho*, s. trad., ed. Heliasta, Buenos Aires, 1978.
- JEFFERSON, Th., *Autobiografía y otros escritos*, est. prel. y redición de A. Koch y W. Peden, trad. de A. Escohotado y M. Sáenz de Heredia, Tecnos, Madrid, 1987.
- JELLINEK, G., *Sistema dei Diritti Pubblici Subbiettivi*, trad. italiana de G. Vitagliano, con prefacio de V. E. Orlando, Società Editrice Libreria, Milano, 1912.
- *Teoría General del Estado*, prólogo y traducción de Fernando de los Ríos, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- JIMÉNEZ CANO, R. M., *Democracia con motivos*, Dykinson, Madrid, 2013.
- JORI, M., «La cicala e la formica», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*.
- «Ferrajoli sobre los derechos», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*,
- JOWELL, J., «The rule of law today», JOWELL, J., OLIVER, D., (eds.), *The Changing Constitution*.
- JOWELL, J., OLIVER, D., (eds.), *The Changing Constitution*, third edition, Clarendon Press, Oxford, 1994.
- KANT, «¿Qué es la Ilustración?», ID., *Filosofía de la Historia*, trad. de E. Imaz, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1985.

- KELSEN, H., «La garantie juridictionnelle de la Constitution (la Justice constitutionnelle)», *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l'Etranger*, 1928.
- *Esencia y valor de la democracia*, trad. de la 2ª edic. alemana por R. Luengo Tapia y L. Legaz Lacambra, Labor, Barcelona, 1934.
 - «Justicia y Derecho natural», en VVAA, *Crítica del Derecho natural*.
 - *Teoría General del Estado*, trad. de L. Legaz Lacambra, Editora Nacional, México 1972 (reimpr.).
 - *Teoría Pura del Derecho*, trad. de la segunda edic. en alemán por R. J. Vernengo, UNAM, 1982.
 - La doctrina del Derecho natural ante el tribunal de la ciencia», *¿Qué es justicia?*, ed. y trad. de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1982
 - *Teoría General del Derecho y del Estado*, trad. de E. García Maynez, UNAM, 1983.
 - «Los fundamentos de la democracia», ID., *Escritos sobre la democracia y el socialismo*, selección y presentación de J. Ruiz Manero, Debate, Madrid, 1988.
 - «L'essence de l'État», trad. de P. H. Tavoillot, *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 17, 1990.
 - «La doctrina del Derecho natural y el Positivismo jurídico», trad. de E. Bulygin, *Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho*, Fontamara, México, 1991.
 - *¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?*, trad. de E. Garzón Valdés, Fontamara, México, 1992.
 - *El Estado como integración. Una controversia de principio*, estudio preliminar y traducción de J. A. García Amado, Tecnos, Madrid, 1997.
- KRAWIETZ, W., MACCORMICK, N., VON WRIGHT, G. H., (eds.), *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems*. Festschrift for Robert Summers, Duncker & Humblot, Berlin, 1994.
- LA TORRE, M., «Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso del diritti di libertà», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. XII, n.º1, junio, 1982.
- Derecho y conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde una perspectiva europea», *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, n.º 16, 1993.
 - «Discutiendo de democracia. Representación política y derechos fundamentales», trad. de F. J. Ansuátegui, *Derechos y Libertades*, n.º 3, 1994.

- «Formalism and Anti-Formalism in Modern Law-State Law and Beyond», en KRAWIETZ, W., MACCORMICK, N., VON WRIGHT, G. H., (eds.), *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems. Festschrift for Robert Summers*.
- *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Bari, 1999.
- «Un giurista nel crepuscolo di Weimar. Politica e diritto nell'opera di Hermann Heller», *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, 29, 2000.
- «Democrazia», en LA TORRE, M., ZANETTI, G., *Seminari di Filosofia del diritto*.
- «Legitimacy for a Supranational European Political Order-Derivative, Regulatory or Deliberative?», *Ratio Iuris*, 15/1, 2002, p. 74.
- «Positivismo giuridico», *Enciclopedia del Diritto*, Giuffré, annali VI, 2013.
- LA TORRE, M., ZANETTI, G., *Seminari di Filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000.
- LAPORTA, F. J., «Norma básica, constitución y decisión por mayorías», *Revista de las Cortes Generales*, n.º 1, 1984.
- «Sobre el concepto de derechos humanos», *Doxa*, n.º 4, 1987.
- «Respuesta a Pérez Luño, Atienza y Ruz Manero», *Doxa*, n.º 4, 1987.
- «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», *Doxa*, n.º 15-16, 1994.
- «Materiales para una reflexión sobre racionalidad y crisis de la ley», *Doxa*, n.º 22, 1999.
- «Imperio de la ley y seguridad jurídica», DÍAZ, E., COLOMER, J. L., (eds.), *Estado, justicia, derechos*.
- «El ámbito de la Constitución», *Doxa*, n.º 24, 2001.
- *El imperio de la ley. Una visión actual*, Trotta, Madrid, 2007.
- «Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y Francisco Laporta», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, Iustel, n.º 0, octubre 2008,
- LAQUIÈZE, A., «État de droit e sovranità nazionale in Francia», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- LASLETT, P., RUCIMAN, W. G., (eds.), *Philosophy, Politics and Society*, Third Series, Oxford, 1967.
- LEGAZ LACAMBRA, L., *Filosofía del Derecho*, cuarta edición, Bosch, Barcelona, 1975.

- LLANO ALONSO, F. H., *El formalismo jurídico y la teoría experiencial del Derecho. Un estudio iusfilosófico en clave comparativa*, Tirant, Valencia, 2009.
- LLOREDO ALIX, L. M., *Rudolf Jhering y el paaradigma positivista. Fundamentos ideológicos y filosóficos de su pensamiento*, Dykinson, Madrid, 2012.
- LOEWENSTEIN, G., ELSTER, J., (eds.), *Choice over time*, Russell Sage Foundation, New York, 1992.
- LÓPEZ ARANGUREN, J. L., «La enseñanza de la ética», ID., *Ética de la felicidad y otros lenguajes*.
— *Ética de la felicidad y otros lenguajes*, Tecnos, Madrid, 1989.
— *Ética*, Alianza Universidad, 1994.
- LÓPEZ CALERA, N. M., *Derecho y Poder: ¿La razón de la fuerza o la fuerza de la razón?*, Academia de Jurisprudencia y Legislación, Granada, 1991.
- LUZZATI, C., «Sulla giustificazione della pena e sui conflitti normativi», en GIANFORMAGGIO, L., (ed.), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*.
- MAcCORMICK, N., «Constitucionalismo y democracia», *Anuario de Derechos Humanos*, 5, 1988-89.
— «Retórica y Estado de Derecho», *Isegoría*, n.º 21, 1999.
- MARGIOTTA, C., «Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci», *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, a. XXX, n. 2, dicembre 2000.
- MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades multiculturales*, Tecnos, Madrid, 2001.
- MARSH, N. S., «The Rule of Law as a Supra-National Concept», en GUEST, A. G., (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*.
- MARSHALL, G., «The Rule of Law. Its Meaning, Scope and Problems», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 24, 1993.
- MARTÍ, J. L., *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Marcial Pons, Madrid, 2006.
- MATTEUCCI, N., «Positivismo giuridico e costituzionalismo», *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, anno XVII, n.º 3, 1963.
— «Costituzionalismo», ID., *Lo Stato moderno*, Il Mulino, Bologna, 1993.
— *Organización del Poder y libertad. Historia del Constitucionalismo moderno*, trad. de Fco. Javier Ansuátegui y Roig y M. Martínez Neira Trotta, Madrid, 1998.

- MERRY, S. E., GRIFFITHS, J., TAMANAHA, B. Z., *Pluralismo jurídico*, est. prel. de L. Ariza Higuera y D. Bonilla Maldonado, Siglo del Hombre, Bogotá, 2007.
- MONHAUPT, H., «L'État de Droit en Allemagne. Histoire, notion, fonction», *Cahiers de Philosophie Politique et Juridique*, n.º 24, 1993.
- MONTANARI, B., (ed.), *Stato di diritto e trasformazione della politica*, Giappichelli Ed., Torino, 1992.
- MORESO, J. J., *La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.
- «Diritti e giustizia procedurale imperfetta», *Ragion Pratica*, 1998/10.
- «Sulla portata del vincolo preventivo», *Ragion Pratica*, 1998/10.
- «Algunas consideraciones sobre la interpretación constitucional», *Doxa*, n.º 23, 2000.
- MORESO, J. J., TROPER, M., *Giustizia costituzionale e Stato di diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.
- NINO, C. S., *La validez del Derecho*, Astrea, Buenos Aires, 1985.
- *Introducción al análisis del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1987.
- *Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino*, Emecé, Buenos Aires, 1992.
- *Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica*, Fontamara, México, 1993
- *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1994.
- «A philosophical reconstruction of judicial review», *Cardozo Law Review*, 1993.
- *La constitución de la democracia deliberativa*, trad. de R. P. Saba, Gedisa, Barcelona, 1997.
- OPPENHEIM, F. E., *Conceptos políticos. Una reconstrucción*, trad. de M. D. González Soler, Tecnos, Madrid, 1987.
- PAINE, Th., *Derechos del hombre*, trad., intr., cronología y notas de F. Santos Fontenla, Alianza, Madrid, 1984.
- PALOMBELLA, G., *Costituzione e Sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Dedalo, Bari, 1997.
- *La autorità dei diritti*, Laterza, Bari, 2002.
- PÁRAMO, J. R. DE, «Compromisos, grilletes de arena y nudos corre-dizos», ZAPATERO, V. (ed.), *Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, (1).

- PASSERIN D'ENTREVES, A., *La noción del Estado*, trad. de A. Fernández Galiano, Centro de Estudios Universitarios, s. f.
- *La dottrina del diritto naturale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1962.
- PECES-BARBA, G., «Reflexiones sobre Derecho y Poder», ID., *Libertad, Poder, Socialismo*, Cívitas, Madrid, 1978.
- *Tránsito a la Modernidad y derechos fundamentales*, Mezquita, Madrid, 1982.
- *Introducción a la Filosofía del Derecho*, Debate, Madrid, 1983.
- «Prólogo», en PÁRAMO ARGÜELLES, J. R. de, *H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.
- «Desobediencia civil y objeción de conciencia», *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 5, 1988-89.
- «Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales», ID., *Escritos sobre derechos fundamentales*.
- «La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho», ID., *Derecho y derechos fundamentales*.
- «Seguridad jurídica y solidaridad como valores de la Constitución española», ID., *Derecho y derechos fundamentales*.
- *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
- *El sistema de los derechos fundamentales*, Quadern de Treball, n.º 1, Centre d'Estudis de drets humans-Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.
- *Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de siglo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995.
- «Sobre el valor de la ley y el gobierno de las leyes», *Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, n.º 3, 2000.
- *Escritos sobre derechos fundamentales*, Eudema, Madrid, 1998.
- «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», en ZAGREBELSKY, G., *El Derecho dúctil*.
- «Notas sobre la justicia constitucional desde la Filosofía del Derecho», *Cuadernos de Derecho Público*, 14, 2002.
- *Diez lecciones sobre Ética, Poder y Derecho*, Dykinson, Madrid, 2010.
- PECES-BARBA, G., (con la col. de R. de Asís, C. R. Fernández Liesa y A. Llamas), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, Universidad Carlos III de Madrid, BOE, Madrid, 1995.
- PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R., (eds.), *Curso de Teoría del Derecho*, (2ª edic.), Marcial Pons, Madrid, 2000.

- PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASÍS, R. (dirs.), *Historia de los derechos fundamentales*, tomo II: «Siglo XVIII», vol. II: «La filosofía de los derechos humanos», Dykinson, Madrid, 2001.
- PECES-BARBA G., (y otros), *Textos básicos de derechos humanos*, Aranzadi, Pamplona, 2001.
- PECZENIK, A., «Dimensiones morales del Derecho», trad. de J. A. Pérez Lledó, *Doxa*, n.º 8, 1990.
- «Una concepción de la democracia», ID., *Derecho y razón*.
- *Derecho y razón*, trad. de E. Garzón Valdés, Fontamara, México, 2000.
- PEI, C., «La dottrina confuciana e il 'governo dell'uomo': l'umanesimo cinese originario», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- PEÑA FREIRE, A. M., *La garantía en el Estado constitucional de Derecho*, Trotta, Madrid, 1997.
- PERELMAN, Ch. *De la justicia*, trad. de R. Guerra, UNAM, México, 1964.
- PÉREZ LUÑO, A. E., *La seguridad jurídica*, Ariel, Barcelona, 1991.
- *El desbordamiento de las fuentes del Derecho*, Real Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación, Sevilla, 1993.
- (y otros), *Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica*, Tecnos, Madrid, 1997.
- «Estado constitucional y derechos de la tercera generación», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XVI, 1997.
- *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, 8ª edición, Tecnos, Madrid, 2003.
- *La Filosofía del Derecho en perspectiva histórica*, Universidad de Sevilla, 2009.
- PINO, G., «Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale», *Analisi e diritto*, 1998.
- PINTORE, A., «Democracia sin derechos. En torno al Kelsen democrático», trad. de J. A. Pérez Lledó, *Doxa*, n.º 23, 2000.
- *I diritti della democrazia*, Laterza, Bari, 2003.
- PORCIELLO, A., «Algunas cuestiones metateóricas relativas a la cuestión de la observación del fenómeno jurídico: una breve comparación entre positivismo jurídico metodológico y neoconstitucionalismo», trad. de F. J. Ansuátegui, *Derechos y Libertades*, n.º 22, 2010.
- PORTINARO, P. P., «Dal custode della Costituzione alla Costituzione dei custodi», en GOZZI, G., (ed.), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*.
- «Oltre lo Stato di diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.

- POZZOLO, S., *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2001.
- «Un constitucionalismo ambiguo», en CARBONELL, M. (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
 - «Reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la Constitución», en CARBONELL, M., GARCIA JARAMILLO, L. (eds.), *El canon neoconstitucional*.
- PRIETO SANCHÍS, L., *Estudios sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990.
- «El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? A propósito de «El Derecho dúctil» de Gustavo Zagrebelsky», *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996.
 - *Constitucionalismo y Positivismo*, Fontamara, México, 1997.
 - «Del mito a la decadencia de la Ley. La Ley en el Estado constitucional», ID., *Ley, principios, derechos*, Dykinson, Madrid, 1998.
 - «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en CARBONELL, M. (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
 - «Presupuestos ideológicos y doctrinales de la justicia constitucional» en ID., *Justicia constitucional y derechos fundamentales*.
 - «Constitución y democracia» en ID., *Justicia constitucional y derechos fundamentales*.
 - *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Trotta, Madrid, 2003.
 - «Sobre las relaciones entre el Derecho y la moral: una crítica del constitucionalismo ético», en ID., *El constitucionalismo de los derechos*.
 - «Algunos desafíos al constitucionalismo de los derechos: globalización y multiculturalidad», en ID., *El constitucionalismo de los derechos*.
 - «Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos» en ID., *El constitucionalismo de los derechos*.
 - *El constitucionalismo de los derechos*, Trotta, Madrid, 2013.
- RADBRUCH, G., *Filosofía del Derecho*, est. prel. de J. L. Monereo, Comares, Granada, 1999.
- *Arbitrariedad legal y Derecho suprallegal*, trad. de M. I. Azareto de Vásquez, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962.
- RADIN, M. J., «Reconsidering the Rule of Law», *Boston University Law Review*, vol. 69, n.º 4, 1989.
- RAMIRO AVILÉS, M. A., «A vueltas con el paternalismo jurídico», *Derechos y Libertades*, n.º 15, junio 2006.

- RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), *El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.
- RAWLS, J., *Teoría de la Justicia*, trad. de M. D. González, Fondo de Cultura Económica, México, 1979.
- «Justice as Fairness: Political, not Metaphysical», *Philosophy and Public Affairs*, 14, 1985.
- *El derecho de gentes y «Una revisión de la idea de razón pública»*, trad. de H. Valencia, Paidós, Barcelona, 2001.
- RAZ, J. «El Estado de Derecho y su virtud», ID., *La autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y moral*, trad. y notas de R. Tamayo Salmorán, UNAM, México, 1982.
- *Razón práctica y normas*, trad. de J. Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
- «The Politics of the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 3, n.º 3, 1990.
- RECASÉNS SICHES, L., *Tratado General de Filosofía del Derecho*, Porrúa, México, 1986.
- REDONDO, C., «El carácter práctico de los deberes jurídicos», *Doxa*, n.º 21/II, 1998, pp. 355 y ss.
- REDOR, M.-J., *De l'Etat legal a l'Etat de droit. L'Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française 1879-1914*, Economica-Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1992.
- REY PÉREZ, J. L., *La democracia amenazada*, Universidad de Alcalá, 2012.
- REYNOLDS, N. B., «Comment on Robert Summers on the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 1, n.º 3, 1988.
- «Grounding the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 2, n.º 1, 1989.
- ROBINSON, R., *Definition*, Clarendon Press, Oxford, 1954.
- ROBLES MORCHÓN, G., *Teoría del Derecho (Fundamentos de Teoría comunicacional del Derecho)*, vol. I, Cívitas, Madrid, 1998.
- RODRÍGUEZ PALOP, M. E., «La sinrazón de la razón como estrategia. Razones en favor de la racionalidad de los agentes morales», *Derechos y Libertades*, n.º 27, junio 2012.
- RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J., «La relevancia conceptual y valorativa de la moral interna del Derecho», *Derechos y Libertades*, n.º 10, 2001.
- RODRÍGUEZ URIBES, J. M., *Formalismo ético y constitucionalismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
- ROSENFELD, M., «The rule of law, and the legitimacy of constitutional democracy», *Cardozo Law School, Public Law Research Paper*, n.º 36, march, 2001.

- RUIZ MIGUEL, A., «Problemas de ámbito de la democracia», *Doxa*, n.º 6, 1989.
- «Constitucionalismo y democracia», *Isonomía*, n.º 21, 2004.
- RUIZ RUIZ, R., *Los orígenes del republicanismo clásico. Patrios Politeia y Res Publica*, Dykinson, Madrid, 2006.
- SANTORO, E., «Rule of law e 'libertà degli inglesi'. L'interpretazione di Albert Venn Dicey», *VVAA., Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- SASTRE ARIZA, S., *Ciencia jurídica positivista y neoconstitucionalismo*, McGraw Hill, Madrid, 1999.
- «La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo», en CARBONELL, M., (ed.), *Neoconstitucionalismo(s)*.
- SCALIA, A., «The Rule of Law as a Law of Rules», *The University of Chicago Law Review*, vol. 56, n.º 4, 1989.
- SCARPELLI, U., *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1955.
- *Cos'è il positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.
- *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano, 1985.
- SCHAUER, F., *Playing by the rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- SEARLE, J. R., *Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío*, trad. de L. M. Valdés Villanueva, Círculo de Lectores, Madrid, 2000.
- SOLARI, G., *La formazione storica e filosofica dello Stato Moderno*, (rist.), Giappichelli, Torino, 1962.
- SQUELLA NARDUCCI, A., «Derecho y Estado de Derecho en la obra de Rudolph von Ihering», *Revista de Ciencias Sociales*, Valparaiso, 1976-77.
- STAMMLER, R., *Tratado de Filosofía del Derecho*, trad. de W. Rocés, Editora Nacional, México, 1980.
- SUMMERS, R. S., «The Ideal Socio-Legal Order. Its «Rule of Law» Dimension», *Ratio Iuris*, vol. 1, n.º 2, 1988.
- «On analyzing and characterizing the General Style of a legal system as a formal or as substantive», *Rechtstheorie*, 23, 1992.
- «A formal Theory of the Rule of Law», *Ratio Iuris*, vol. 6, n.º 2, 1993.
- «The Juristic Study of Law's Formal Character», *Ratio Iuris*, vol. 8, n.º 3, 1995.

- «Forma, Imperio de la ley, Imperio del buen Derecho», *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2, 1998.
- «The practical and theoretical importance of the formal character of law», *Rechthstheorie*, 30, 1999.
- *Essays in Legal Theory*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000.
- *La naturaleza formal del Derecho*, trad. de P. Larrañaga, Fontamara, México, 2001.
- SUNSTEIN, C., «Constituciones y democracias: epílogo», en ELSTER J., SLAGSTAD, R. (eds), *Constitucionalismo y democracia*.
- TAMANAH, B. Z., *On the Rule of Law. History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, 2004.
- TAY, A. E.-S., «I valori asiatici e il rule of law», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.
- TOMÁS Y VALIENTE, F., «Constitución», DÍAZ, E.-RUIZ MIGUEL, A., (eds.), *Filosofía Política II: Teoría del Estado*.
- TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., *La disponibilidad de la propia vida en el Derecho penal*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999
- TROPER, M., «Le concept d'État de Droit», *Cahiers de Philosophie Politique*, n.º 24, Université de Caen, 1993.
- *La théorie du droit, le droit, l'État*, Presses Universitaires de France, Paris, 2001.
- «El concepto de constitucionalismo y la moderna teoría del Derecho», en ID, *Por una teoría jurídica del Estado*.
- *Por una teoría jurídica del Estado*, trad. de M. Venegas Grau, Dykinson, Madrid, 2001.
- «I limiti del Rule of Law», en MORESO, J. J., TROPER, M., *Giustizia costituzionale e Stato di diritto*.
- TUORI, K., *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, Ashgate, Surrey, 2010.
- VIDAL GIL, E., «Paradojas de la democracia», *Anuario de Filosofía del Derecho*, VII, 1990.
- «Justificación de la democracia y límites a la decisión por mayorías», *Doxa*, n.º 15-16, 1994.
- VILLA, V., *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli Editore, Torino, 1993.
- VIOLA, F., *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi*, Giappichelli, Torino, 2011.

- VITALE, E., «¿Teoría general del Derecho o fundación de una república óptima? Cinco dudas sobre la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*.
- VOLPE, G., *Il costituzionalismo del Novecento*, Laterza, Bari, 2000.
- VVAA., *Crítica del Derecho natural*, introducción y traducción de Elías Díaz, Taurus, Madrid, 1966.
- VVAA., *Constitución y constitucionalismo hoy*, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2000.
- VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, (P. Costa, D. Zolo, eds.), Feltrinelli, Milano, 2002.
- VVAA., *Constitución y derechos fundamentales*, BETEGÓN, J, LAPORTA, F. J, PRIETO, L, DE PÁRAMO, J. R. (coords.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004.
- WALDRON, J., (ed.), *Theories of Rights*, Oxford University Press, 1984.
- «The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory», *Ratio Iuris*, vol. 2, n.º 1, 1989.
- *The Law (Theory and practice in British Politics)*, Routledge, London, 1990.
- «A Right-Based Critique of Constitutional Rights», *Oxford Journal of Legal Studies*, 13/1, 1993.
- *Derecho y desacuerdos*, trad. de J. L. Martí y Á. Quiroga, est. prel. de R. Gargarella y J. L. Martí, Marcial Pons, Madrid, 2005.
- *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, 1999.
- «Disagreement and Precommitment», en ALEXANDER, L. (ed.), *Constitutionalism. Philosophical Foundations*.
- «Is the Rule of Law an essentially contested concept (in Florida)?», *Law and Philosophy*, 21, 2002.
- ZAGREBELSKY, G., *Società, stato, costituzione*, Giappichelli editore, Torino, 1988.
- *El Derecho dúctil*, trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1995.
- «Storia e costituzione», en ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*.
- *Principi e voti. La Corte costituzionale e la política*, Einaudi, Torino, 2005.
- ZAGREBELSKY, G., PORTINARO, P. P., LUTHER., (eds) *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino 1996.
- ZANETTI, G., *Political Friendship and the Good Life. Two Liberal Arguments against Perfectionism*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.

ZAPATERO, V. (ed.), *Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, (2), Universidad de Alcalá de Henares, 2002.

ZOLO, D., «Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los «derechos fundamentales». A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli», en FERRAJOLI, L., *Los fundamentos de los derechos fundamentales*.

— «Teoria e critica dello Stato di diritto», VVAA., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*.

ÍNDICE DE MATERIAS

- Acción colectiva: 135, 334, 335
 - estadística: 334
 - comunitaria: 334
- Anomia: 134-136
- Arbitrariedad: 104, 121, 138, 148, 152, 154-160, 164, 165, 167, 170, 173, 266
 - diferencia con la injusticia: 156-160
 - relación con la justicia: 158
- Autoobligación (autolimitación): 43, 50, 54-64, 161, 163, 174
- Autopaternalismo: 336
- Autoreferencialidad: 67
- Autorrestricciones: 290, 308, 314, 318, 319, 332, 336
- Certeza del Derecho: 98, 107, 129, 145, 150, 151, 159, 166, 168, 183, 185, 190, 299, 349
- Concepto esencialmente controvertido: 35, 36
- Competencia básica: 338, 339
- Complementariedad entre el Derecho y la moral: 84, 86, 87
- Conductas cooperativas: 131, 132
- Conexión conceptual entre el Derecho y la moral: 16, 54, 70, 72, 76
 - tesis débil: 76
 - tesis fuerte: 76
- Conexión entre el Derecho y la moral: 123-126, 169, 183, 184, 215
 - funcional: 83
 - interpretativa: 91, 92, 94
 - justificatoria: 92, 94
 - práctica: 81
- Constitución:
 - concepto histórico: 239
 - concepto sociológico: 239
 - concepto racional-normativo: 239
 - concepto mínimo: 239
 - indeterminación (de la): 91, 94, 95, 97
 - superfluidad (de la): 92, 94, 95
 - de los antiguos: 234-236
 - medieval: 234-236
 - de los modernos: 234, 235, 237, 238
 - mixta: 235, 237
 - tensión con la democracia: 279, 280, 288, 290
- Constitucionalismo:
 - débil: 226, 347
 - fuerte: 227
 - *lato sensu*: 227
 - *stricto sensu*: 227
 - *strictissimo sensu*: 227

- Constitucionalización del Ordenamiento: 232, 233, 241
Contexto paramétrico: 179, 180, 349
Contexto estratégico: 179, 180
Corrección estructural: 144
Corrección funcional: 120, 144
Coto vedado: 299-305, 322, 337
Crisis de la Ley: 186-190
Cultura de la legalidad: 147
- Debilidad de la voluntad: 311-314, 317, 329, 339
- Decisiones:
— de primer nivel: 302, 303
— de segundo nivel: 302, 303
— de tercer nivel o «metadecisiones»: 302, 303
- Definición:
— explicativa: 36, 37, 199
— léxica: 36, 37, 200
— estipulativa: 36, 37, 199, 200
- Derecho:
— como concepto: 12, 13
— como institución: 12, 13
— como punto de vista sobre la justicia: 74, 75, 79, 207
— materialización del: 18, 29, 43, 242-246, 276
— como sistema de símbolos: 85
— como sistema de acción: 86
— dimensión autoritativa: 218, 219
— relación con la moral: 68-98
- Democracia:
— concepción estadística: 335
— concepción comunitaria: 335
— concepto sustantivo: 29
— tensión con la Constitución: 279, 280, 288, 290
— tensión con los derechos: 343-350
— vinculación con los derechos fundamentales y con el Estado de Derecho: 21, 64, 144
- Derecho natural: 76, 162, 163, 189, 213, 245, 247, 248, 294-299, 305
— proceso de positivación: 43, 61, 68, 195, 208, 209, 214
— proceso de subjetivización: 221, 222
— constitucionalización del: 69, 212, 219
- Derechos fundamentales:
— carácter sustantivo: 191-214
— como límites al Poder: 31, 63, 204, 209, 210, 238, 272, 274
— como mínimo moral común: 220, 222
— definición estipulativa: 199-201
— definición formal: 196-199, 201
— neutralidad axiológica de la definición de: 206, 207
— proceso de universalización: 208, 222
— tensión con la democracia: 343-350
— vinculación con el Estado de Derecho y la democracia: 21, 64, 144
- Derechos patrimoniales: 200-204
- Discreción absoluta (sistema de): 115, 156
- Esfera de lo indecible: 205, 209, 285, 299
- Estado constitucional: 13, 14, 16, 19-21, 29, 40, 69, 100, 110, 114, 117, 124, 186, 190, 192, 194, 203, 212, 215, 216, 220, 223, 224, 228-231, 237, 239-251, 257-259, 261-277, 344.
- Estado de Derecho:
— concepciones finalistas: 123
— concepciones funcionalistas: 123
— concepto amplio: 34, 38, 39, 100, 101, 124-126

- concepto formal: 21, 28, 34, 39, 40, 100, 101, 109-123, 140, 192-195, 262, 270
- concepto material: 110-223
- concepto restringido: 34, 100, 101, 114, 123, 125, 126
- como concepto supranacional: 104
- como institucionalización jurídica de la democracia: 32, 194
- modelo restringido: 123, 125, 126
- modelo estricto: 124, 126
- modelo amplio: 124, 125
- modelo democrático: 124, 126
- modelo liberal: 124
- modelo garantista: 124
- vinculación con los derechos fundamentales y la democracia: 21, 64, 144
- État de Droit*: 34, 99, 101, 274
- État legal*: 34, 274
- Exigencias:
 - cognitivas: 86-89
 - motivacionales: 86-89
 - organizativas: 86-89
- Exoneración moral: 85, 86
- Filosofía del Derecho: 11, 12, 16, 17, 19, 23, 69, 89, 90, 100, 284, 293, 296, 345
- Filosofía política: 17, 225, 237, 241, 284, 327
- Filosofía del Derecho constitucional: 15
- Generaciones (relaciones entre): 290, 315, 317-319, 326-332, 336-339
- Gobierno de las leyes/de los hombres: 38, 104, 113, 162, 163
- Gobierno sub lege/per leges: 115
- Hecho Fundante Básico: 43, 50, 65-68
- Heterorrestricciones: 316-319, 326, 332, 337, 339
- Imperio de la Constitución: 20, 29, 275
- Imperio de la ley: 19, 22, 28, 29, 48, 111, 114-116, 119, 120, 163, 167, 191-194, 225, 262, 265, 273-276, 283-285, 349
 - como principio de moralidad institucional: 168
 - como universo ético: 177, 179, 182
 - concepción formal: 137-142, 145-152, 154, 161
 - concepción material: 167-191
 - concepción instrumental: 167-186
 - déficit del: 164-166
 - valor moral: 167-186
- Imperio del Derecho: 28, 29, 139, 186, 277, 349
- Incompetencia básica: 339, 340
- Infraestatalidad normativa: 45, 260
- Iusnaturalismo: 53, 76, 184, 195, 203, 208, 222, 241, 270, 279, 294, 296-298, 305
 - en sentido débil: 183-185
 - en sentido fuerte: 183-185
 - deontológico: 183
 - ontológico: 183
- Jurisprudencia de conceptos: 245
- Legalismo: 243
- Legitimación: 96, 115, 116, 246, 277
 - externa: 70, 71, 195, 246, 247, 296
 - interna: 70, 71, 208, 246, 247, 296
- Legitimidad: 17, 79, 93, 113-116, 134, 138-140, 194, 245, 248, 261, 262, 273, 286, 298, 335
- Limitación del Poder: 18, 22, 31, 47, 48, 50, 58-64, 71, 106, 107, 109,

- 110, 117, 118, 120, 122, 168, 218,
223-227, 231, 232, 274, 275, 305,
332, 349
- Machtstaat*: 266
- Materialización (del Derecho): 18,
29, 43, 242-246, 276
- Moral:
 - crítica: 72, 76, 81, 82, 89, 300
 - legalizada: 72, 81, 82
 - como contenido: 76-78
 - como estructura: 76, 78
- Moral interna del Derecho: 48, 125,
141, 144, 169, 185
- Objeción contramayoritaria: 287
- Objeción democrática: 287
- Optimismo normativo: 108, 109
- Origen social de las fuentes del Dere-
cho: 122, 229
- Pandectística: 245
- Paradoja de la democracia: 326-342
- Paternalismo: 290, 317, 318, 336-339
- Pesimismo potestativo: 108
- Pluralismo ético: 222
- Pluralismo jurídico: 46
- Poder (relación con el Derecho): 12,
16-18, 44-67, 110, 113, 117, 118,
126, 161, 167-169, 236, 246, 251,
273-276, 306
- Poder constituyente: 66, 67, 219, 295,
296
- Polizeistaat*: 266
- Positivismo: 11, 54, 62, 75, 122,
183, 184, 212, 215, 216, 227, 230,
246, 247, 252-258, 268, 271, 279,
294
 - teórico: 46, 228
 - ideológico: 228, 262, 270
 - metodológico: 72, 184, 228,
229, 231
 - imperativista: 54
 - compatibilidad con el constitu-
cionalismo: 215-223
- Precompromiso: 313-319, 330-332
- Predictibilidad: 129, 145
- Pretensión de corrección: 53
- Principio de diferenciación del Poder:
106-108
- Principio de difusión del Poder: 106-
108
- Principio de legalidad: 19, 34, 108,
114, 117, 118, 120, 139, 203, 255,
263-266, 275, 276
 - en sentido amplio: 115, 125
 - en sentido estricto: 115, 116
 - formal: 118, 192
 - material: 118
- Principio de legalidad selectiva: 48,
124-126, 191-196
- Principio de no dictadura: 301
- Principios de primer orden: 145,
146
- Principios de segundo orden: 145
- Racionalidad: 17, 18, 94, 167, 189,
285, 298, 310, 317, 330, 336, 339
 - formal: 244, 246
 - imperfecta: 310, 329
 - perfecta: 310
 - sustancial: 244, 246
- Razón:
 - tensión con la voluntad: 12, 17,
18, 20-22, 279, 346
- Rechtstaat*: 34, 99, 101, 102
- Regla de las mayorías: 29, 30, 264,
280, 285, 286-292, 296, 307, 320,
333, 344, 346
- Reglas constitucionales:
 - limitadoras: 333
 - posibilitadoras: 333
- Restricciones colectivas: 308-319
- Restricciones constitucionales: 279-
350
- Restricciones individuales: 308-319

Índice de materias

- Rigidez constitucional: 20, 225, 241, 271, 279-293, 326, 336
- Rule of law*: 28, 34-5, 99, 101-105, 110-112, 114, 119-121, 137, 143, 153, 226
- *Rule-book conception*: 112
- *Rights conception*: 112
- Seguridad jurídica: 144, 151-154, 185, 190
- Sentimiento jurídico: 157
- Separación conceptual entre Derecho y moral (tesis de la): 43, 44, 69-80, 122, 216, 220, 270
- Separación de Poderes: 21, 22, 38, 113, 114, 123-125, 181, 225, 226, 275, 297, 306, 308
- Sistemas jurídicos mixtos: 217-219, 256
- Sistema normativo:
- dinámico: 218, 255-257
- estático: 217, 255-257
- Soberanía: 38, 46, 57, 59, 60, 106, 187, 235, 236, 238, 289, 293, 294
- Soberanía popular: 22, 162, 193, 236, 330, 344, 345, 348, 349
- Supraestatalidad normativa: 45, 260
- Teorema fundamental de la Filosofía del Derecho: 89-98
- Teoría del Derecho: 14-16, 69, 127, 200, 209, 227, 248, 251, 254, 279, 293
- Textura abierta del lenguaje: 160-166
- Vaguedad del lenguaje: 91, 97, 160-166, 175
- Validez: 17, 44, 52, 65, 92, 93, 118, 126, 146, 194, 195, 246-249, 254-257, 262, 271
- formal: 71, 187, 247, 249-251, 253, 254
- material: 71, 187, 247, 249-251, 253, 254
- Vigencia: 177, 195, 248-257, 283, 300, 301
- Voluntad:
- tensión con la razón: 12, 17, 18, 20-22, 279, 346

ÍNDICE ONOMÁSTICO

- AARNIO, A.: 165, 351
 AGUILÓ REGLA, J.: 39, 229, 232, 239, 240, 276, 345, 351
 AHUMADA, M. A.: 228, 355
 ALEGREM, M.: 95, 352, 364
 ALEXANDER, L.: 351, 375
 ALEXY, R.: 15, 53, 54, 76, 81, 93, 97, 98, 243, 345, 351, 352, 354
 ALTHUSIUS, J.: 237
 ANDRÉS IBÁÑEZ, P.: 263, 352
 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J.: 35, 36, 60, 65, 187, 196, 256, 258, 352
 AQUINO, T. DE: 237
 ARCOS RAMIREZ, F.: 112, 141, 153, 154, 352
 ARISTÓTELES: 38, 235
 ARNAUD, A.-J.: 46, 352
 ARROW, K. J.: 301, 352
 ATIENZA, M.: 39, 216, 351, 352
 AUSTIN, J.: 294

 BALLESTEROS, J.: 353, 356
 BARATTA, A.: 32, 33, 34, 106, 353
 BARBERÀ, A.: 275, 353, 358
 BARBERIS, M.: 92, 105, 222, 223, 225, 234, 353
 BARRANCO AVILES, M. C.: 18, 25, 215, 353

 BARTOLOMEI, F.: 104, 109, 353
 BASCIU, M.: 46, 353
 BAYÓN, J. C.: 287, 302, 317, 347, 353
 BETEGÓN, J.: 302, 337, 353, 357, 375
 BICKEL, A.: 286, 353
 BIN, R.: 277, 345, 353
 BINGHAM, T.: 103, 104, 353
 BLANCO VALDÉS, R.: 187, 239, 265, 353
 BOBBIO, N.: 46, 47, 64, 67, 83, 115, 122, 228, 255, 285, 291, 297, 299, 320, 339, 340, 353
 BÖCKENFORDE, E. W.: 41, 282, 354
 BODINO, J.: 238
 BOHMAN, J.: 292, 354
 BONGIOVANNI, G.: 53, 58, 103, 225, 354, 362
 BRACON, H.: 237
 BRYCE, J.: 281, 324, 354
 BULYGIN, E.: 53, 162, 352, 365
 BUNGE, M.: 311, 354
 BURKE, E.: 327, 328, 354, 359

 CABO, C. DE.: 233, 355
 CALSAMIGLIA, A.: 136, 162, 180, 355
 CARBONELL, M.: 92, 228, 233, 241, 244, 287, 297, 336, 345, 351, 353, 355, 357, 361, 362, 371, 373
 CARPIZO, J.: 66, 355

- CARRÉ DE MALBERG, R.: 34, 50, 60, 61, 62, 63, 274, 355
CASALINI, B.: 103, 355
CASTILLO, M.: 60, 355
CATANIA, A.: 295, 355
CELANO, B.: 218, 219, 355
CHEVALLIER, J.: 34, 50, 356
CICERÓN, M. T.: 235
CLÍSTENES: 235
COKE, E.: 237
COLOMER, J. L.: 182, 194, 357, 366
COMANDUCCI, P.: 228, 239, 355
COSTA, P.: 41, 103, 104, 110, 355
CRAIG, P. P.: 111, 214, 356
CUENCA GÓMEZ, P.: 25, 256, 257, 356

DAHL, R. A.: 325, 326, 356
DAHRENDORF, R.: 136, 137, 356
DE ASÍS ROIG, R.: 25, 39, 40, 41, 47, 49, 63, 67, 68, 79, 113, 122, 123, 124, 125, 126, 194, 208, 251, 272, 306, 328, 347, 356
DE LUCAS, F. J.: 304, 356
DE PÁRAMO, J. R.: 302, 323, 327, 337, 353, 357, 368, 375
DÍAZ, E.: 20, 21, 22, 29, 31, 33, 64, 66, 67, 122, 138, 139, 162, 182, 193, 194, 238, 272, 273, 356, 357, 366, 374
DICEY, A. V.: 33, 101, 103, 105, 120, 121, 357
DONNARUMMA, R. M.: 57, 357
DORADO PORRAS, J.: 73, 121, 237, 357
DUPRET, B.: 104, 357
DWORKIN, G.: 337, 357
DWORKIN, R.: 15, 36, 53, 112, 160, 231, 333, 334, 335, 336, 337, 357

ELSTER, J.: 131, 132, 133, 179, 281, 292, 293, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 319, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 338, 346, 348, 358, 364, 367, 374
EMERI, CL.: 358

ENDICOTT, TH. A. O.: 161, 163, 164, 165, 166, 358
ESCUDERO ALDAY, R.: 141, 150, 168, 169, 358

FALLON, R. H.: 35, 104, 358
FARALLI, C.: 275, 358
FARIÑAS DULCE, M. J.: 46, 352
FARRELL, M. D.: 65, 358
FASSÓ, G.: 359
FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: 48, 68, 79, 80, 113, 192, 295, 327, 359
FERRAJOLI, L.: 15, 38, 39, 69, 70, 71, 114, 115, 116, 120, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 220, 221, 225, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 270, 271, 289, 296, 299, 359, 364, 375, 376
FERRERES COMELLA, V.: 283, 286, 326, 360
FIORAVANTI, M.: 41, 224, 225, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 344, 360
FISHKIN, J.: 292, 360
FORTESCUE, J.: 237
FREEMAN, S.: 292, 360
FULLER, L. L.: 48, 125, 141, 144, 175, 185, 360

GALIZIA, M.: 60, 360
GALLIE, W. B.: 35, 36, 360
GARCÍA AMADO, J. A.: 87, 256, 265, 360, 361
GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: 104, 187, 193, 242, 361
GARCÍA FIGUEROA, A.: 50, 53, 228, 361
GARCÍA JARAMILLO, L.: 241, 336, 346, 351, 355, 357, 371
GARCÍA MANRIQUE, R.: 141, 151, 361
GARCÍA PASCUAL, C.: 275, 361
GARCÍA PELAYO, M.: 189, 190, 264, 275, 361

- GARGARELLA, R.: 95, 286, 317, 336, 352, 361, 364
 GARZÓN VALDÉS, E.: 109, 295, 299, 300, 301, 302, 304, 322, 323, 337, 338, 346, 361, 362
 GASCÓN ABELLÁN, M.: 137, 139, 186, 187, 190, 265, 362
 GIANFORMAGGIO, L.: 250, 253, 254, 359, 362, 364, 367
 GIRI, A. K.: 104, 362
 GERBER, C. F. V.: 33
 GONZÁLEZ LAGIER, D.: 228, 355
 GONZÁLEZ VICÉN, F.: 202, 362
 GOYARD-FABRE, S.: 51, 362
 GOZZI, G.: 59, 103, 104, 225, 285, 362, 371
 GRAIG, P. P.: 111, 214, 356, 362
 GRIFFITHS, J.: 46, 368
 GRIMM, D.: 347, 362
 GUASTINI, R.: 116, 117, 118, 139, 169, 232, 233, 241, 265, 269, 272, 362
 GUEST, A. G.: 101, 362, 367

 HABERMAS, J.: 17, 69, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 195, 244, 245, 262, 289, 292, 337, 345, 349, 363
 HART, H.L.A.: 19, 56, 72, 73, 88, 122, 127, 141, 165, 166, 167, 169, 231, 253, 363
 HAYEK, F. A.: 41, 363
 HELLER, H.: 47, 152, 363
 HERMIDA DEL LLANO, C.: 77, 363
 HIERRO, L.: 136, 138, 140, 186, 363
 HOERSTER, N.: 253, 364
 HOLMES, S.: 319, 320, 321, 324, 330, 331, 332, 336, 364
 HOMERO: 311, 364
 HONGJU KOH, H.: 292, 364
 HOTMAN, F.: 237
 HURLEY, S.: 307, 358

 IGLESIAS VILLA, M.: 35, 95, 160, 364
 IHERING, R. V.: 12, 54, 55, 56, 156, 157, 364
 JEFFERSON, TH.: 329, 345, 364
 JELLINEK, G.: 58, 59, 66, 364
 JIMÉNEZ CANO, R. M.: 347, 364
 JORI, M.: 201, 253, 364
 JOWELL, J.: 168, 364, 365

 KANT, I.: 33, 39, 58, 88, 167, 327, 364
 KELSEN, H.: 50, 51, 52, 55, 56, 57, 157, 161, 162, 168, 169, 195, 218, 255, 290, 291, 307, 349, 365
 KRAWIETZ, W.: 13, 365, 366

 LA TORRE, M.: 12, 13, 35, 47, 54, 59, 81, 83, 90, 91, 244, 288, 291, 346, 365, 366
 LABAND, P.: 33
 LAPORTA, F. J.: 63, 134, 138, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 190, 273, 274, 281, 288, 295, 302, 304, 317, 347, 348, 359, 362, 366, 375
 LAQUIÈZE, A.: 103, 274, 366
 LASLETT, P.: 301, 352, 366
 LEGAZ LACAMBRA, L.: 74, 75, 152, 153, 154, 158, 366
 LLANO ALONSO, F. H.: 213, 309, 317, 367
 LLOREDO ALIX, L. M.: 54, 367
 LOCKE, J.: 33, 39, 241
 LOEWENSTEIN, G.: 308, 358, 367
 LÓPEZ ARANGUREN, J. L.: 77, 78, 79, 367
 LÓPEZ CALERA, N. M.: 167, 367
 LUTHER, J.: 234, 246, 347, 359, 362, 376
 LUZZATI, C.: 254, 367

 MACCORMICK, N.: 13, 288, 365, 366, 367
 MARGIOTTA, C.: 297, 367
 MARSH, N. S.: 101, 104, 367
 MARSHALL, G.: 111, 367
 MARTÍ, J. L.: 292, 367
 MARTÍNEZ DE PISÓN, J.: 275, 367
 MARX, C.: 239
 MATTEUCCI, N.: 297, 298, 299, 367

- MERRY, S. E.: 46, 368
 MONHAUPT, H.: 103, 105, 106, 368
 MONTANARI, B.: 116, 362, 368
 MONTESQUIEU: 33, 239
 MORESO, J. J.: 33, 231, 288, 318, 320, 368, 374

 NINO, C.: 15, 69, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 131, 133, 134, 135, 136, 226, 227, 253, 294, 295, 296, 368

 OLIVER, D.: 168, 364, 365
 OPPENHEIM, F. E.: 103, 368

 PAINE, TH.: 33, 327, 328, 329, 368
 PALOMBELLA, G.: 344, 368
 PASSERIN D'ENTREVES, A.: 45, 183, 369
 PECES-BARBA, G.: 15, 19, 25, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 65, 67, 68, 79, 102, 112, 113, 114, 122, 151, 152, 191, 194, 202, 269, 272, 286, 306, 324, 327, 359, 369, 370
 PECZENIK, A.: 35, 158, 370
 PEI, C.: 104, 370
 PEÑA FREIRE, A. M.: 248, 249, 275, 370
 PERELMAN, CH.: 158, 370
 PÉREZ LUÑO, A. E.: 37, 38, 41, 45, 144, 150, 153, 202, 223, 243, 255, 259, 261, 262, 370
 PERICLES: 235
 PINO, G.: 228, 370
 PINTORE, A.: 29, 295, 296, 370
 PLATÓN: 38, 39, 235
 POLIBIO: 235
 PORCIELLO, A.: 231, 370
 PORTINARO, P. P.: 104, 234, 246, 285, 347, 359, 362, 370, 376
 POZZOLO, S.: 16, 228, 241, 297, 371
 PRIETO SANCHÍS, L.: 14, 15, 69, 71, 75, 186, 205, 227, 231, 241, 243, 244, 256, 257, 265, 272, 273, 276, 287, 302, 305, 306, 347, 371

 RADBRUCH, G.: 50, 53, 54, 154, 185, 371
 RADIN, M. J.: 371
 RAMIRO AVILÉS, M. A.: 338, 371
 RAMOS PASCUA, J. A.: 215, 216, 223, 256, 352, 353, 372
 RAWLS, J.: 36, 292, 319, 320, 321, 363, 372
 RAZ, J.: 102, 147, 155, 156, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 372
 RECASÉNS SICHES, L.: 157, 158, 159, 372
 REDONDO, C.: 94, 372
 REDOR, M.-J.: 105, 274, 372
 REHG, W.: 292, 354
 REY PÉREZ, J. L.: 348, 372
 REYNOLDS, N. B.: 105, 142, 147, 372
 ROBINSON, R.: 37, 372
 ROBLES MORCHÓN, G.: 56, 372
 RODILLA GONZÁLEZ, M. A.: 215, 216, 223, 256, 352, 353, 372
 RODRÍGUEZ PALOP, M. E.: 311, 372
 RODRÍGUEZ URIBES, J. M.: 229, 372
 RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J.: 141, 372
 ROSENFELD, M.: 35, 101, 372
 ROSENKRATZ, C. F.: 95, 352, 364
 ROUSSEAU, J. J.: 33, 261, 322
 RUCIMAN, W. G.: 301, 352, 366
 RUIZ MANERO, J.: 39, 216, 217, 351, 352
 RUIZ MIGUEL, A.: 238, 302, 303, 347, 357, 373, 374
 RUIZ RUIZ, R.: 235, 373

 SALISBURY, J. DE: 237
 SANTORO, E.: 103, 121, 373
 SASTRE ARIZA, S.: 228, 373
 SCALIA, A.: 151, 373
 SCARPELLI, U.: 37, 373
 SCHAUER, F.: 128, 130, 131, 134, 160, 373
 SEARLE, J. R.: 310, 311, 373
 SHUTE, S.: 307, 358

Índice onomástico

- SLAGSTAD, R.: 293, 306, 319, 330, 358,
364, 374
SLYE, R. C.: 292, 364
SOLARI, G.: 45, 373
SQUELLA NARDUCCI, A.: 54, 373
STAMMLER, R.: 157, 373
SUMMERS, R. S.: 111, 114, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 150, 168, 170, 373
SUNSTEIN, C.: 293, 324, 374

TAMANAHA, B. Z.: 38, 46, 119, 305,
368, 374
TAY, A. E.-S.: 104, 374
TOMÁS Y VALIENTE, F.: 238
TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C.: 337, 374
TROPER, M.: 16, 33, 34, 64, 119, 161,
162, 163, 227, 296, 297, 368,
374
TUORI, K.: 58, 63, 121, 374

VIDAL GIL, E.: 289, 305, 337, 375
VILLA, V.: 35, 95, 375
VIOLA, F.: 111, 154, 171, 375
VITALE, E.: 375
VOLPE, G.: 234, 375
VON WRIGHT, G. H.: 13, 112, 365, 366

WALDRON, J.: 35, 38, 53, 145, 168,
169, 313, 314, 340, 341, 342,
347, 348, 357, 375
WEBER, M.: 88, 244

ZAGREBELSKY, G.: 19, 190, 194, 195,
212, 213, 234, 246, 265, 266,
267, 268, 269, 285, 347, 359,
362, 369, 375, 376
ZANETTI, G.: 82, 346, 366, 376
ZAPATERO, V.: 24, 323, 352, 369, 376
ZOLO, D.: 41, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 200, 201, 271, 375

COLECCIÓN DERECHOS HUMANOS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

LECCIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Peces-Barba Martínez, G.
2005, 368 págs.

PRINCIPIOS DEL DERECHO Y

RAZONAMIENTO JURÍDICO

Rodríguez Calero, J. M.
2005, 160 págs.

LA TEORÍA SOCIAL DE A. GIDDENS.

UNA LECTURA CRÍTICA DESDE LA TEORÍA JURÍDICA

Campione, R.
2005, 236 págs.

DERECHOS FUNDAMENTALES, VALORES Y MULTICULTURALISMO

Ansuátegui, F. J. / López, J. A. / Del Real, A. Ruiz, R. (Editores)
2005, 272 págs.

EL JUEZ Y LA MOTIVACIÓN EN EL DERECHO

De Asís, R.
2005, 168 págs.

HERMENÉUTICA, ARGUMENTACIÓN Y

JUSTICIA EN PAUL RICOEUR

Picontó Novales, T.
2005, 356 págs.

PLURALISMO CULTURAL Y DERECHOS DE LAS MINORÍAS

Pérez de la Fuente, O.
2005, 624 págs.

LA TRADICIÓN REPUBLICANA

Ruiz Ruiz, R.
2006, 446 págs.

LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. MODELOS DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN

Campoy Cervera, I.
2006, 1.052 págs.

METODOLOGÍA JURÍDICA IRREVERENTE

Pedro Haba, E.
2006, 440 págs.

EL FUNDAMENTO DE LOS LÍMITES AL PODER EN LA TEORÍA DEL DERECHO DE LÉON DUGUIT

Ara Pinilla, I.
2006, 448 págs.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y

PROTECCIÓN DE DATOS GENÉTICOS

Álvarez González, Susana
2007, 536 págs.

ESTADO DE DERECHO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Alarcón Requejo, Gílder
2007, 577 págs.

NACIONALISMO E IDENTIDADES COLECTIVAS: LA DISPUTA DE LOS INTELECTUALES (1762-1936)

Del Real Alcalá, J. Alberto
2007, 456 págs.

LA LEY DESMEDIDA. ESTUDIOS DE LEGISLACIÓN, SEGURIDAD Y JURISDICCIÓN

Martínez Roldán, L. / Fernández Suárez, J. A. / Suárez Llanos, L.
2007, 342 págs.

LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE ERNESTO GARZÓN VALDÉS

Álvarez Ortega, Miguel
2008, 488 págs.

JOHN STUART MILL Y LA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI

Josefa Dolores Ruiz Resa (ed.)
2008, 300 págs.

EL SISTEMA JURÍDICO COMO SISTEMA NORMATIVO MIXTO. LA IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS MATERIALES EN LA VALIDEZ JURÍDICA

Patricia Cuenca Gómez
2008, 615 págs.

LA IGUALDAD EN LOS DERECHOS, CLAVE DE LA INTEGRACIÓN

Javier De Lucas Martín y Ángeles Solanes Corrella (coord.)
2008, 542 págs.

LA CONSTRUCCIÓN COHERENTE DEL DERECHO

Mario Ruiz Sanz
2009, 332 págs.

LA IGUALDAD EN EL CONTENIDO Y EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

M.^a Isabel Garrido Gómez
2009, 346 págs.

JOHN RAWLS. SOBRE (DES)IGUALDAD Y JUSTICIA

Silvina Ribotta
2009, 364 págs.

SALUD, JUSTICIA, DERECHOS EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO SOCIAL

Carlos Lema Añón
2009, 296 págs.

¿QUÉ IGUALDAD? EL PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Rosa María Ricoy Casas
2010, 708 págs.

LA DIGNIDAD HUMANA. SUS ORÍGENES EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO

Antonio Pele
2010, 752 págs.

LA NUEVA GENERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN

María Eugenia Rodríguez Palop
2010, 612 págs.

ENTRE LA MORAL, LA POLÍTICA Y EL DERECHO. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y JURÍDICO DE GREGORIO PECES-BARBA

Reynaldo Bustamante Alarcón
2010, 720 págs.

DIEZ LECCIONES SOBRE ÉTICA, PODER Y DERECHO

Gregorio Peces-Barba Martínez
2010, 434 págs.

EL ESTADO EN ORTEGA Y GASSET

Fernando H. Llano Alonso
2010, 224 págs.

THOMAS HOBBS Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: UN ANÁLISIS DESDE LAS PERSPECTIVAS DE CARL SCHMITT, LEO STRAUSS Y NORBERTO BOBBIO

Gregorio Saravia
2010, 600 págs.

FAMILIAS TRANSNACIONALES, SOCIEDADES MULTICULTURALES E INTEGRACIÓN: ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL EN PERSPECTIVA COMPARADA

Encarnación La Spina
2010, 576 págs.

JUECES Y LEYES, ENTRE EL ABSOLUTISMO Y LA CODIFICACIÓN

Alberto Iglesias Garzón
2011, 278 págs.

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS EMERGENTES EN EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Jaume Saura Estapà
2012, 396 págs.

RUDOLF VON JHERING Y EL PARADIGMA POSITIVISTA. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS DE SU PENSAMIENTO JURÍDICO

Luis M. Lloredo Alix
2012, 604 págs.

DEMOCRACIA CON MOTIVOS

Roberto M. Jiménez Cano
2013, 216 págs.

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

José Manuel Rodríguez Uribe
2013, 363 págs.

EL DERECHO Y EL PODER. REALISMO CRÍTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

Elías Díaz
2013, 220 págs.

EL DERECHO A LA VIVIENDA

M.^a José González Ordovás
2013, 240 págs.

SOBRE DISCAPACIDAD Y DERECHOS

Rafael de Asís
2013, 158 págs.

RAZÓN Y VOLUNTAD EN EL ESTADO DE DERECHO. UN ENFOQUE FILOSÓFICO-JURÍDICO

Francisco Javier Ansuátegui Roig
2013, 392 págs.

